PRÉCIS DE FORMATION JURIDIQUE APPROFONDIE

Droit ivoirien · Droit OHADA · Droit comparé

Tome I

Théorie générale et fondements du droit

Notion de droit, fondements, systèmes, sources et droits subjectifs



VERSION 1.1 · ÉTAT DU DROIT AU 4 NOVEMBRE 2026

PRÉCIS DE FORMATION JURIDIQUE APPROFONDIE

Droit ivoirien · Droit OHADA · Droit comparé

Tome I

Théorie générale et fondements du droit

Notion de droit, fondements, systèmes, sources et droits subjectifs

Édition complète en douze chapitres
Niveaux : licence, master, préparation à la recherche

VERSION 1.1 · ÉTAT DU DROIT AU 4 NOVEMBRE 2026

ÉTAT DU DROIT

Le présent tome expose l'état du droit tel qu'il a pu être établi au 4 novembre 2026. Les textes cités sont ceux en vigueur à cette date, sous réserve des modifications intervenues postérieurement ou non encore publiées. Les textes abrogés ou modifiés sont signalés comme tels lorsqu'ils sont cités.

STATUT DES RÉFÉRENCES

Conformément à la charte de fiabilité de la collection, aucune référence n'a été inventée. Les textes et décisions ivoiriens et régionaux cités font l'objet d'une fiche de vérification (annexe) qui précise, pour chacun, s'il a été vérifié sur sa source, recoupé par des sources concordantes ou s'il reste à confirmer ; ces derniers portent la marque V. Les citations entre guillemets reproduisent la lettre des textes ; lorsque la lettre exacte n'a pu être établie, le contenu est paraphrasé.

SIGNALÉTIQUE

DP droit positif · JP solution jurisprudentielle · DOC thèse doctrinale · PP proposition de l'auteur · MOD texte modifié · ABR texte abrogé · V référence à confirmer.

MODE D'ÉLABORATION

Ouvrage élaboré avec l'assistance d'un système d'intelligence artificielle (Claude, Anthropic), sous la direction scientifique de son commanditaire, selon la méthode définie par le document-cadre de la collection. Toute utilisation contentieuse ou académique d'une référence suppose sa confrontation préalable avec la source officielle.

VERSION

Version 1.1 — novembre 2026. Par rapport à la version 1.0 : signalement de la révision de l'AUPSRVE (acte révisé du 17 octobre 2023, en vigueur le 16 février 2024) aux chapitres 1, 6 et 12 et dans la fiche de vérification ; corrections de mise en page. Les corrections et mises à jour ultérieures seront intégrées dans les versions suivantes.

Sommaire

Avant-propos **12**

Introduction générale **14**

1. Le droit, objet de connaissance. 14
2. L'ordre juridique ivoirien : un ordre pluriel en construction 15
3. Méthode et plan du tome 17

PREMIÈRE PARTIE — LE DROIT : NOTION ET FONDEMENTS **19**

CHAPITRE 1 La règle de droit : définition, caractères et fonctions **20**

1. Introduction et problématique 20
2. Fondements historiques et théoriques 21
3. Explication approfondie des concepts 23
4. Analyse des principes et mécanismes juridiques 27
5. Étude des textes applicables 29
6. Analyse de jurisprudences vérifiables 31
7. Présentation des débats doctrinaux. 33
8. Illustrations pratiques 34
9. Cas pratiques corrigés 35
10. Synthèse et connaissances essentielles 37
11. Questions d'évaluation. 38
12. Références bibliographiques 38

CHAPITRE 2 Le droit et les autres systèmes normatifs **40**

1. Introduction et problématique 40
2. Fondements historiques et théoriques 40
3. Explication approfondie des concepts 42
4. Analyse des principes et mécanismes juridiques 45
5. Étude des textes applicables 47
6. Analyse de jurisprudences vérifiables 48
7. Présentation des débats doctrinaux. 50
8. Illustrations pratiques 51
9. Cas pratiques corrigés 51
10. Synthèse et connaissances essentielles 54
11. Questions d'évaluation. 54
12. Références bibliographiques 55

CHAPITRE 3 Les fondements du droit (I) : droit naturel et positivisme juridique **56**

1. Introduction et problématique 56

2. Fondements historiques et théoriques 57
3. Explication approfondie des concepts 60
4. Analyse des principes et mécanismes juridiques 61
5. Étude des textes applicables 63
6. Analyse de jurisprudences vérifiables 64
7. Présentation des débats doctrinaux 66
8. Illustrations pratiques 68
9. Cas pratiques corrigés 68
10. Synthèse et connaissances essentielles 70
11. Questions d'évaluation 71
12. Références bibliographiques 71

CHAPITRE 4 Les fondements du droit (II) : approches sociologiques, réalistes et anthropologiques ; le pluralisme juridique 73

1. Introduction et problématique 73
2. Fondements historiques et théoriques 74
3. Explication approfondie des concepts 77
4. Analyse des principes et mécanismes juridiques 79
5. Étude des textes applicables 81
6. Analyse de jurisprudences vérifiables 82
7. Présentation des débats doctrinaux 84
8. Illustrations pratiques 85
9. Cas pratiques corrigés 86
10. Synthèse et connaissances essentielles 88
11. Questions d'évaluation 88
12. Références bibliographiques 89

DEUXIÈME PARTIE — L'ORDRE JURIDIQUE : SYSTÈMES, DIVISIONS ET SOURCES . 91

CHAPITRE 5 Les systèmes juridiques et la formation du droit ivoirien 92

1. Introduction et problématique 92
2. Fondements historiques et théoriques 93
3. Explication approfondie des concepts 95
4. Analyse des principes et mécanismes juridiques 97
5. Étude des textes applicables 99
6. Analyse de jurisprudences vérifiables 100
7. Présentation des débats doctrinaux 101
8. Illustrations pratiques 102
9. Cas pratiques corrigés 102
10. Synthèse et connaissances essentielles 104
11. Questions d'évaluation 104
12. Références bibliographiques 105

CHAPITRE 6 Les divisions du droit 107
1. Introduction et problématique 107
2. Fondements historiques et théoriques 108
3. Explication approfondie des concepts 109
4. Analyse des principes et mécanismes juridiques 112
5. Étude des textes applicables 114
6. Analyse de jurisprudences vérifiables 115
7. Présentation des débats doctrinaux 116
8. Illustrations pratiques 117
9. Cas pratiques corrigés 118
10. Synthèse et connaissances essentielles 120
11. Questions d'évaluation 120
12. Références bibliographiques 121

CHAPITRE 7 La hiérarchie des normes : Constitution, normes internationales, communautaires et uniformes 122
1. Introduction et problématique 122
2. Fondements historiques et théoriques 123
3. Explication approfondie des concepts 124
4. Analyse des principes et mécanismes juridiques 126
5. Étude des textes applicables 129
6. Analyse de jurisprudences vérifiables 130
7. Présentation des débats doctrinaux 132
8. Illustrations pratiques 134
9. Cas pratiques corrigés 135
10. Synthèse et connaissances essentielles 137
11. Questions d'évaluation 138
12. Références bibliographiques 138

CHAPITRE 8 La loi : élaboration, entrée en vigueur, application dans le temps et dans l'espace 140
1. Introduction et problématique 140
2. Fondements historiques et théoriques 141
3. Explication approfondie des concepts 142
4. Analyse des principes et mécanismes juridiques 144
5. Étude des textes applicables 148
6. Analyse de jurisprudences vérifiables 149
7. Présentation des débats doctrinaux 151
8. Illustrations pratiques 152
9. Cas pratiques corrigés 152
10. Synthèse et connaissances essentielles 154

11. Questions d'évaluation. 155
12. Références bibliographiques 156

CHAPITRE 9 La coutume et les usages. 157
1. Introduction et problématique 157
2. Fondements historiques et théoriques 158
3. Explication approfondie des concepts 159
4. Analyse des principes et mécanismes juridiques 160
5. Étude des textes applicables 162
6. Analyse de jurisprudences vérifiables 163
7. Présentation des débats doctrinaux. 164
8. Illustrations pratiques 165
9. Cas pratiques corrigés 166
10. Synthèse et connaissances essentielles 167
11. Questions d'évaluation. 168
12. Références bibliographiques 169

CHAPITRE 10 La jurisprudence et la doctrine 170
1. Introduction et problématique 170
2. Fondements historiques et théoriques 171
3. Explication approfondie des concepts 172
4. Analyse des principes et mécanismes juridiques 174
5. Étude des textes applicables 176
6. Analyse de jurisprudences vérifiables 177
7. Présentation des débats doctrinaux. 179
8. Illustrations pratiques 181
9. Cas pratiques corrigés 181
10. Synthèse et connaissances essentielles 183
11. Questions d'évaluation. 183
12. Références bibliographiques 184

TROISIÈME PARTIE — LES DROITS SUBJECTIFS ET LEUR RÉALISATION. 187

CHAPITRE 11 Les droits subjectifs et leurs titulaires 188
1. Introduction et problématique 188
2. Fondements historiques et théoriques 189
3. Explication approfondie des concepts 190
4. Analyse des principes et mécanismes juridiques 193
5. Étude des textes applicables 195
6. Analyse de jurisprudences vérifiables 196
7. Présentation des débats doctrinaux. 198
8. Illustrations pratiques 199
9. Cas pratiques corrigés 200

10. Synthèse et connaissances essentielles 201
11. Questions d'évaluation. 202
12. Références bibliographiques 202

CHAPITRE 12 La preuve et la sanction des droits. 204

1. Introduction et problématique 204
2. Fondements historiques et théoriques 205
3. Explication approfondie des concepts 206
4. Analyse des principes et mécanismes juridiques 209
5. Étude des textes applicables 212
6. Analyse de jurisprudences vérifiables 213
7. Présentation des débats doctrinaux. 214
8. Illustrations pratiques 216
9. Cas pratiques corrigés 216
10. Synthèse et connaissances essentielles 218
11. Questions d'évaluation. 219
12. Références bibliographiques 219

Bibliographie générale et spécialisée 221

I. Dictionnaires et instruments de travail 221
II. Introduction au droit et théorie générale 221
III. Philosophie et théorie du droit 222
IV. Sociologie et anthropologie juridiques 223
V. Droit comparé, droits africains et droit colonial. 223
VI. Droit OHADA et droit communautaire. 224
VII. Rapports et études 224
VIII. Revues 225
IX. Sources officielles et bases de données 225

Annexe — Fiche de vérification des références. 226

A. Constitution et textes constitutionnels 226
B. Lois, ordonnances et décrets ivoiriens 227
C. Décisions des juridictions ivoiriennes 229
D. Droit OHADA, communautaire et régional 229

Principales abréviations

al.	alinéa
art.	article
Ass. plén.	Assemblée plénière de la Cour de cassation (France)
AUA	Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage (OHADA)
AUDCG	Acte uniforme relatif au droit commercial général (OHADA)
AUPSRVE	Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution (OHADA)
AUS	Acte uniforme portant organisation des sûretés (OHADA)
AUSCGIE	Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique (OHADA)
Bull. civ.	Bulletin des arrêts des chambres civiles de la Cour de cassation (France)
C. civ.	Code civil, dans sa rédaction applicable en Côte d'Ivoire (la mention « France » désigne le Code civil français en vigueur)
C. pén.	Code pénal
Cass.	Cour de cassation (France, sauf précision contraire)
CCJA	Cour commune de justice et d'arbitrage (OHADA)
CE	Conseil d'État (France, sauf précision contraire)
CEDEAO	Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest
CEDH	Cour européenne des droits de l'homme
ch. mixte	Chambre mixte de la Cour de cassation (France)
Charte africaine	Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (Nairobi, 1981)
CIJ	Cour internationale de justice
CJ CEDEAO	Cour de justice de la Communauté (CEDEAO)
Cons. const.	Conseil constitutionnel (France, sauf précision contraire)
Cons. const. CI	Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire
Const.	Constitution de la République de Côte d'Ivoire du 8 novembre 2016, révisée
Cour ADHP	Cour africaine des droits de l'homme et des peuples

CPCCA	Code de procédure civile, commerciale et administrative (Côte d'Ivoire)
D.	Digeste de Justinien (cité par livre, titre, fragment)
DC	Décision de contrôle *a priori* du Conseil constitutionnel français
JORCI	Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire
OHADA	Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires
Req.	Chambre des requêtes de la Cour de cassation (France, supprimée en 1947)
TC	Tribunal des conflits (France)
UEMOA	Union économique et monétaire ouest-africaine
v°	*verbo* (au mot)

Avant-propos

Ce premier tome de la collection *Précis de formation juridique approfondie* est consacré à la théorie générale et aux fondements du droit. Il traite des questions que toute étude juridique présuppose et que les manuels spécialisés tiennent le plus souvent pour acquises : qu'est-ce qu'une règle de droit ? Qu'est-ce qui la distingue d'une règle morale, religieuse ou coutumière ? Pourquoi obéit-on au droit ? D'où viennent les règles, comment s'ordonnent-elles, comment s'appliquent-elles dans le temps et dans l'espace ? Que signifie « avoir un droit », et comment le faire valoir ?

Ces questions ne sont pas des préliminaires abstraits. Le juriste qui ignore la hiérarchie des normes ne sait pas résoudre un conflit entre une loi ivoirienne et un acte uniforme de l'OHADA ; celui qui ignore les règles d'application de la loi dans le temps ne sait pas quelle loi régit un contrat conclu avant une réforme ; celui qui n'a jamais réfléchi au rapport entre le droit et la coutume ne comprend ni le contentieux foncier rural ni la persistance de pratiques matrimoniales que la loi a longtemps prohibées. La théorie générale est la grammaire du droit : elle ne dispense pas d'apprendre le vocabulaire des matières spéciales, mais elle permet seule d'en construire des phrases correctes.

Un ouvrage ancré dans l'ordre juridique ivoirien. Les introductions au droit en usage dans les facultés francophones sont souvent conçues pour le droit français, et transposées sans adaptation. Le présent tome prend le parti inverse : il part de l'ordre juridique ivoirien — de son histoire, de ses sources, de ses institutions et de ses difficultés propres — et mobilise le droit français et les autres droits comme éléments de comparaison. Il accorde une place particulière aux phénomènes que les manuels européens traitent marginalement : la superposition des ordres juridiques national, communautaire et uniforme ; la survivance et la reconnaissance partielle des coutumes ; la question de l'effectivité du droit étatique.

Une méthode constante. Chacun des douze chapitres suit la méthode définie par le document-cadre de la collection : introduction et problématique, fondements historiques et théoriques, concepts, principes et mécanismes, textes, jurisprudence, débats doctrinaux, illustrations pratiques, cas pratiques corrigés, synthèse, questions d'évaluation et bibliographie. Le lecteur débutant s'attachera d'abord aux définitions, aux mécanismes, aux encadrés « À retenir » et aux synthèses ; le lecteur avancé trouvera dans les rubriques consacrées à la jurisprudence et aux débats doctrinaux de quoi approfondir sa réflexion ; le lecteur qui se destine à la recherche pourra s'exercer sur les sujets de dissertation et les propositions de l'auteur, qu'il est invité à discuter.

Une exigence de fiabilité. Les références citées ont fait l'objet d'une vérification dont le degré est indiqué dans la fiche placée en annexe. Le lecteur est invité à ne jamais se dispenser de consulter les textes eux-mêmes : un précis guide la lecture des sources, il ne les remplace pas.

Comment utiliser ce tome. Les chapitres peuvent être lus dans l'ordre, qui suit une progression logique — de la notion de droit à ses fondements, de ses sources à sa réalisation — ou consultés isolément grâce aux renvois internes. Les cas pratiques gagnent à être résolus par le lecteur avant la lecture du corrigé ; les questions d'évaluation peuvent servir de grille de révision ou de support de travaux dirigés.

Introduction générale

1. Le droit, objet de connaissance

A. Les sens du mot « droit »

Le mot « droit » désigne en français plusieurs réalités que d'autres langues distinguent par des termes différents. Il désigne d'abord l'**ensemble des règles** qui régissent la vie en société et dont le respect est garanti par l'autorité publique : c'est le *droit objectif*, celui que l'on évoque en parlant du « droit ivoirien » ou du « droit des sociétés ». Il désigne ensuite les **prérogatives** que ces règles reconnaissent aux personnes : le droit de propriété, le droit de vote, le droit d'agir en justice ; ce sont les *droits subjectifs*. Il désigne encore la **science** qui étudie ces règles et ces prérogatives, la science du droit ou, selon un usage ancien, la jurisprudence au sens de *juris prudentia*. Il évoque enfin, dans le langage courant, une **idée de justice** : réclamer « son droit », c'est réclamer ce qui est juste. La langue anglaise sépare *law* et *right* ; la langue allemande, au contraire, réunit dans le mot *Recht* le droit objectif et le droit subjectif, comme le français.

Cette polysémie n'est pas un accident. Elle révèle que le droit est à la fois un ensemble de normes, un ensemble de prérogatives, un savoir et une aspiration. Le présent tome les envisage successivement : la règle et le système qu'elle forme (première et deuxième parties), les prérogatives qu'elle confère et leur réalisation (troisième partie), la science qui les étudie et la justice qu'elles prétendent servir (dans tous les chapitres, et particulièrement dans ceux consacrés aux fondements du droit).

B. Théorie générale, philosophie et sociologie du droit

L'étude des notions communes à toutes les branches du droit relève de plusieurs disciplines voisines, qu'il importe de distinguer.

La **théorie générale du droit** cherche à identifier les concepts et les structures communs à tout ordre juridique : norme, validité, ordre juridique, source, droit subjectif, personne, acte juridique. Elle se veut descriptive et analytique ; sa forme la plus exigeante, la « théorie pure du droit » de Hans Kelsen, entend décrire le droit tel qu'il est, sans le juger ni l'expliquer par des facteurs extérieurs[1].

1. H. Kelsen, *Théorie pure du droit*, trad. Ch. Eisenmann, Dalloz, 1962 (traduction de la seconde édition allemande de 1960).

La **philosophie du droit** s'interroge sur le fondement et la finalité du droit : pourquoi obéir à la loi ? Qu'est-ce qu'une loi juste ? Le droit a-t-il un fondement transcendant ou n'est-il que le produit de la volonté humaine ?

La **sociologie du droit** étudie le droit comme fait social : ses causes, ses effets, son effectivité, les représentations qu'en ont ses destinataires. L'**anthropologie juridique** élargit ce regard aux sociétés dans lesquelles la régulation sociale ne passe pas, ou pas seulement, par l'État.

L'**introduction au droit**, enfin, est l'enseignement par lequel les facultés initient les étudiants aux notions fondamentales ; elle emprunte à toutes ces disciplines et y ajoute l'exposé des institutions et des sources du droit positif.

Le présent tome se situe au point de rencontre de ces approches. Il expose les notions de théorie générale indispensables au juriste, mais ne les sépare pas de leurs fondements philosophiques ni de leur réalité sociologique, parce que l'ordre juridique ivoirien ne peut être compris sans ces deux éclairages.

2. L'ordre juridique ivoirien : un ordre pluriel en construction

A. Une histoire en strates

Le droit applicable aujourd'hui en Côte d'Ivoire porte la trace de plusieurs époques, dont chacune a laissé des normes encore en vigueur ou des pratiques encore vivantes.

Les droits précoloniaux. Avant la colonisation, les sociétés établies sur le territoire de l'actuelle Côte d'Ivoire — sociétés akan, krou, mandé, gur et autres — étaient régies par des ordres normatifs coutumiers, oraux, intimement liés aux structures de parenté, aux croyances religieuses et au rapport à la terre. Ces ordres connaissaient des autorités (chefs, conseils d'anciens, sociétés initiatiques), des règles (de mariage, de succession, d'accès à la terre) et des procédures de règlement des conflits, souvent orientées vers la réconciliation plutôt que vers la sanction.

La période coloniale. La Côte d'Ivoire devient colonie française par un décret du 10 mars 1893, puis est intégrée à l'Afrique occidentale française (AOF), créée en 1895. Le droit colonial organise une **dualité de statuts** : les citoyens français relèvent du droit français ; les « sujets » relèvent de leurs coutumes, appliquées par des juridictions dites indigènes, et sont soumis au régime répressif de l'indigénat jusqu'à sa suppression en 1946. La législation coloniale procède essentiellement par décrets ; certains d'entre eux, notamment en matière foncière et domaniale, ont survécu à l'indépendance.

L'État indépendant. Indépendante le 7 août 1960, la Côte d'Ivoire se dote d'une Constitution le 3 novembre 1960. Le choix des premières années est celui de la **modernisation par**

la loi : les lois du 7 octobre 1964 substituent aux coutumes un droit écrit unifié en matière de nom, d'état civil, de mariage, de divorce, de filiation, d'adoption, de successions et de libéralités ; le Code civil hérité demeure applicable pour le reste. Suivent d'autres codifications : Code de procédure civile, commerciale et administrative (1972), Code pénal (1981), Code du travail, réformes foncières.

L'intégration régionale. À partir des années 1990, une part croissante du droit applicable procède d'instances supranationales : le Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, signé à Port-Louis le 17 octobre 1993 et révisé à Québec le 17 octobre 2008, crée l'OHADA, dont la Cour commune de justice et d'arbitrage siège à Abidjan ; le Traité de Dakar du 10 janvier 1994 institue l'UEMOA ; la CEDEAO, créée en 1975, est refondée par le Traité révisé de Cotonou du 24 juillet 1993.

Les refondations constitutionnelles. Après le coup d'État de décembre 1999, une nouvelle Constitution est adoptée par référendum en juillet 2000 et promulguée le 1er août 2000. La décennie de crise politico-militaire (2002-2011) éprouve durement les institutions. La Constitution du 8 novembre 2016, adoptée par référendum le 30 octobre 2016, fonde la IIIe République ; elle est révisée par la loi constitutionnelle n° 2020-348 du 19 mars 2020. Le droit pénal et le droit de la famille sont refondus en 2019.

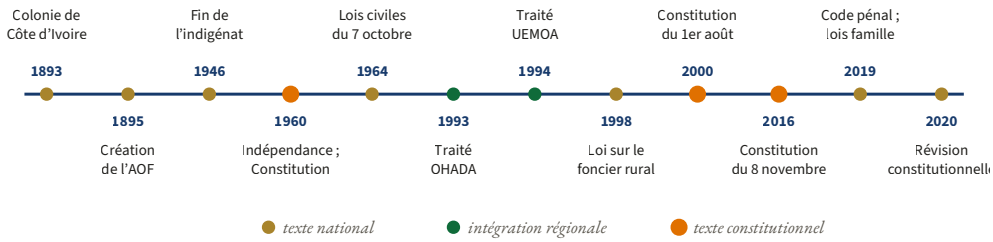


Schéma 1 — Repères chronologiques de la formation du droit ivoirien

B. Trois défis pour la théorie du droit

L'histoire qui vient d'être esquissée fait de l'ordre juridique ivoirien un terrain particulièrement exigeant pour la théorie du droit. Trois défis la traversent, qui forment le fil conducteur du présent tome.

Le **défi de la pluralité**. Le juriste ivoirien doit composer avec des normes d'origines diverses — nationales, communautaires, uniformes, internationales, coutumières — dont l'articulation n'est pas toujours réglée avec clarté. La théorie de la hiérarchie des normes (cha-

pitre 7), la théorie des sources (chapitres 8 à 10) et la théorie du pluralisme juridique (chapitre 4) sont ici des instruments de travail quotidien.

Le **défi de l'effectivité**. Une partie importante de la population règle ses rapports familiaux, fonciers ou commerciaux selon des normes qui ne sont pas celles du droit étatique, ou en marge de celui-ci. L'interdiction de la dot, édictée en 1964 et demeurée largement inappliquée, a été abandonnée par la réforme du mariage de 2019 ; la loi de 1998 sur le domaine foncier rural a dû composer avec des droits coutumiers qu'elle entendait transformer. Ces exemples invitent à ne jamais confondre l'énoncé de la règle et sa réalité sociale (chapitres 1, 4 et 9).

Le **défi de la légitimité**. Les crises constitutionnelles et politiques qu'a connues le pays ont posé avec acuité la question des fondements du droit : qu'est-ce qui rend une Constitution légitime ? Un accord politique peut-il prévaloir sur elle ? Un juge peut-il revenir sur sa propre décision au nom d'une norme supérieure ? Ces questions, qui relèvent de la philosophie du droit (chapitre 3), ont reçu en Côte d'Ivoire des réponses pratiques dont l'analyse est instructive.

3. Méthode et plan du tome

Le tome est divisé en trois parties, qui suivent une progression logique.

La **première partie** est consacrée à la notion de droit et à ses fondements. Elle établit d'abord ce qu'est une règle de droit, par ses caractères et ses fonctions (chapitre 1), et ce qui la distingue des autres règles sociales (chapitre 2) ; elle examine ensuite les grandes réponses apportées à la question du fondement du droit : le droit naturel et le positivisme juridique (chapitre 3), puis les approches sociologiques, réalistes et anthropologiques, qui conduisent à la théorie du pluralisme juridique (chapitre 4).

La **deuxième partie** étudie l'ordre juridique comme système. Elle situe le droit ivoirien parmi les grands systèmes juridiques et retrace sa formation (chapitre 5), présente les divisions du droit (chapitre 6), puis analyse les sources du droit : leur hiérarchie (chapitre 7), la loi (chapitre 8), la coutume et les usages (chapitre 9), la jurisprudence et la doctrine (chapitre 10).

La **troisième partie** est consacrée aux droits subjectifs : leur notion, leurs classifications et leurs titulaires, personnes physiques et morales (chapitre 11), puis leur preuve et leur sanction (chapitre 12).

Chaque chapitre suit la méthode des douze rubriques définie par le document-cadre de la collection. Un sommaire détaillé figure en tête d'ouvrage ; une table des matières complète, une bibliographie générale et la fiche de vérification des références figurent en fin d'ouvrage.

PREMIÈRE PARTIE

Le droit : notion et fondements

CHAPITRE 1

La règle de droit : définition, caractères et fonctions

« Les lois ne sont pas de purs actes de puissance ; ce sont des actes de sagesse, de justice et de raison. »

— Portalis, Discours préliminaire du premier projet de Code civil (1801)

1. Introduction et problématique

Toute société humaine connaît des règles. Les règles de politesse prescrivent de saluer les aînés ; les règles religieuses prescrivent le jeûne ou la prière ; les règles morales prescrivent de dire la vérité ; les règles du jeu prescrivent la manière de déplacer les pièces. Parmi toutes ces règles, certaines sont dites **juridiques**. Elles se reconnaissent intuitivement : on sait que l'obligation de payer l'impôt, l'interdiction du vol ou la règle selon laquelle le mariage est célébré devant l'officier de l'état civil sont des règles de droit, alors que l'obligation de céder sa place à une personne âgée n'en est pas une. Mais l'intuition ne suffit pas à fonder un critère. Qu'est-ce qui fait qu'une règle est juridique ?

La question n'est pas seulement théorique. Elle se pose concrètement lorsqu'un texte officiel contient des énoncés dépourvus de portée prescriptive (« la Nation encourage la culture de la paix »), lorsqu'une autorité publique adopte des recommandations, des lignes directrices ou des chartes dont la force obligatoire est incertaine, lorsqu'une règle coutumière est invoquée devant un juge, ou lorsqu'une règle édictée par l'État n'est pas appliquée dans les faits. Dans chacun de ces cas, il faut savoir si l'on est en présence d'une règle de droit, parce que la réponse commande la possibilité de l'invoquer en justice et d'en obtenir le respect.

Problématique. La définition classique de la règle de droit repose sur la réunion de plusieurs caractères — généralité, abstraction, caractère obligatoire, sanction par l'autorité publique — dont chacun, pris isolément, se révèle insuffisant ou discutable. Le chapitre s'attache donc à une double question : *quels sont les caractères qui permettent d'identifier une règle de droit, et ces caractères suffisent-ils à rendre compte de la diversité des normes juridiques*

contemporaines ? Il montrera que la règle de droit se définit moins par un caractère unique que par son appartenance à un **ordre juridique** organisé, qui en détermine l'élaboration, l'interprétation et la sanction, et qu'elle remplit des fonctions — ordre, sécurité, justice, transformation sociale — qui en éclairent le régime.

2. Fondements historiques et théoriques

A. *Jus* et *directum* : la double origine du mot et de l'idée

Le mot français « droit » vient du latin populaire *directum*, qui évoque la ligne droite, la rectitude, la direction : le droit est ce qui guide la conduite et ce qui est conforme à une mesure. Les juristes romains employaient cependant un autre mot, *jus*, dont dérivent « juridique », « juridiction », « jurisprudence ». Le Digeste de Justinien, compilation de textes de jurisconsultes réalisée au VIe siècle, s'ouvre sur deux définitions restées célèbres. La première, empruntée à Celse et rapportée par Ulpien, définit le droit comme « l'art du bon et de l'équitable » (*jus est ars boni et aequi*)[1]. La seconde énonce les « préceptes du droit » : vivre honnêtement, ne pas nuire à autrui, rendre à chacun le sien (*honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere*)[2].

Ces formules montrent que, pour les Romains, le droit n'était pas séparé de la morale ni de l'idée de justice ; mais elles montrent aussi qu'il était un **art**, c'est-à-dire une technique pratiquée par des spécialistes — les jurisconsultes — dans le cadre de procédures. C'est cette dimension technique et institutionnelle qui deviendra, à l'époque moderne, le cœur de la définition du droit.

B. La règle de droit, commandement de l'État

À partir du XVIe siècle, la formation de l'État moderne centralise la production du droit. Jean Bodin définit la souveraineté comme la puissance de donner et de casser la loi[3] ; Thomas Hobbes affirme que c'est l'autorité, et non la vérité, qui fait la loi[4]. Au XIXe siècle, le juriste anglais John Austin définit le droit comme un **commandement** du souverain, assorti d'une menace de sanction en cas de désobéissance. La codification napoléonienne de 1804, qui sera transportée dans les colonies françaises et dont le Code civil applicable en Côte d'Ivoire est

1. D. 1, 1, 1 pr.
2. D. 1, 1, 10, 1 (Ulpien).
3. J. Bodin, *Les Six Livres de la République*, 1576, livre I, chap. 10.
4. Th. Hobbes, *Léviathan*, 1651, chap. 26 ; la formule latine *auctoritas, non veritas facit legem* figure dans l'édition latine de 1668.

l'héritier, consacre cette conception : la loi, expression de la volonté générale, est la source principale et presque exclusive du droit.

Cette conception étatique de la règle de droit a été vivement discutée au XXe siècle. Le juriste autrichien Hans Kelsen la reformule en écartant l'idée de commandement psychologique : la norme juridique est une **signification objective** (un « devoir-être », *Sollen*) qui tire sa validité d'une norme supérieure, et le droit se caractérise par son caractère **contraignant**, c'est-à-dire par le fait qu'il organise l'usage de la force en réaction aux comportements qu'il interdit[5]. Le philosophe anglais Herbert Hart, de son côté, conteste que le droit puisse se réduire à des ordres appuyés de menaces : une telle conception confond la règle de droit avec l'ordre d'un bandit armé, et ne rend pas compte des règles qui confèrent des pouvoirs (de contracter, de tester, de légiférer) plutôt qu'elles n'imposent des obligations[6]. Ces débats, repris au chapitre 3, ont profondément renouvelé la définition de la règle de droit.

C. Les conceptions africaines de la norme

Les sociétés africaines précoloniales ne connaissaient pas l'État au sens moderne, mais elles n'ignoraient ni les règles ni les procédures de règlement des conflits. Les travaux d'anthropologie juridique ont montré que, dans de nombreuses sociétés d'Afrique de l'Ouest, la norme est pensée comme partie d'un ordre global — social, familial, religieux et cosmique — dont elle ne se détache pas ; que sa violation appelle moins une punition qu'une **réparation** de l'équilibre rompu ; et que le règlement des conflits privilégie la négociation et la réconciliation, dont la palabre est l'institution emblématique[7].

Ces conceptions n'ont pas disparu avec l'indépendance. Elles expliquent que, en Côte d'Ivoire comme dans d'autres États africains, la règle étatique coexiste avec d'autres normativités, et que son autorité ne résulte pas de sa seule édiction. La définition de la règle de droit doit être construite en tenant compte de cette réalité, sans pour autant renoncer à la précision conceptuelle qu'exige le travail juridique.

5. H. Kelsen, *Théorie pure du droit*, préc.
6. H. L. A. Hart, *Le concept de droit*, trad. M. van de Kerchove, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 1976, chap. 2 à 4.
7. Sur ces conceptions, v. N. Rouland, *Anthropologie juridique*, PUF, coll. « Droit fondamental », 1988 ; É. Le Roy, *Le jeu des lois. Une anthropologie « dynamique » du droit*, LGDJ, coll. « Droit et société », 1999 ; M. Alliot, *Le droit et le service public au miroir de l'anthropologie. Textes choisis*, éd. C. Kuyu, Karthala, 2003.

3. Explication approfondie des concepts

A. Droit objectif et droits subjectifs

DÉFINITION — DROIT OBJECTIF

Ensemble des règles de conduite qui, dans une société donnée, régissent les rapports entre les personnes et dont le respect est assuré, au besoin, par la contrainte organisée par l'autorité publique. On parle ainsi du droit ivoirien, du droit OHADA ou du droit du travail.

DÉFINITION — DROIT SUBJECTIF

Prérogative reconnue par le droit objectif à une personne déterminée, qui lui permet d'exiger d'autrui une prestation ou une abstention, ou d'exercer un pouvoir sur une chose, dans son intérêt propre (droit de propriété, droit de créance, droit à l'image).

Les deux notions sont liées : c'est le droit objectif qui crée, délimite et protège les droits subjectifs. L'article 544 du Code civil, qui définit la propriété comme « le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements », est une règle de droit objectif qui confère un droit subjectif. Le présent chapitre est consacré au droit objectif ; les droits subjectifs sont étudiés aux chapitres 11 et 12.

B. La définition de la règle de droit

DÉFINITION — RÈGLE DE DROIT

Règle de conduite dans les rapports sociaux, générale et abstraite, obligatoire, dont le respect est garanti par une sanction organisée par l'autorité publique, et qui appartient à un ordre juridique déterminé.

Cette définition, qui synthétise la tradition doctrinale francophone, appelle l'examen de chacun de ses éléments.

1° Une règle de conduite dans les rapports sociaux

La règle de droit régit les **rapports entre les personnes** ; elle a une dimension sociale. Elle ne s'intéresse pas aux pensées intimes qui ne se traduisent par aucun comportement extérieur : on ne punit pas l'intention criminelle qui n'a donné lieu à aucun commencement d'exécution. Elle ne régit pas non plus les rapports de l'homme avec lui-même ou avec la divinité, qui relèvent de la morale et de la religion. Cette **extériorité** n'empêche pas le droit de tenir

compte des intentions — la bonne ou la mauvaise foi, l'intention de nuire, le dol — mais seulement lorsqu'elles se manifestent dans des actes.

2° Une règle générale et abstraite

La règle de droit est **générale** : elle s'adresse à tous ceux qui se trouvent dans la situation qu'elle vise, et non à une personne nommément désignée. Elle est **abstraite** : elle vise des situations définies par des critères (« tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage… »), et non des faits particuliers. La généralité est une garantie d'**égalité** et d'**impartialité** : parce qu'elle est formulée avant la survenance des cas qu'elle régit et sans considération des personnes, la règle générale protège contre l'arbitraire.

La généralité n'exclut pas que la règle ne concerne en fait qu'un petit nombre de personnes, voire une seule : les règles constitutionnelles relatives au Président de la République sont générales et abstraites, alors même qu'il n'y a, à un moment donné, qu'un seul Président. Elle se distingue en revanche des **décisions individuelles** — un jugement, un décret de nomination, un permis de construire — qui appliquent la règle à une personne déterminée. Dans la théorie de Kelsen, ces décisions sont elles-mêmes des normes, mais des **normes individuelles**, situées au bas de la hiérarchie des normes (chapitre 7). Le contrat, qui « tient lieu de loi » aux parties selon l'ancien article 1134 du Code civil, est également une norme individuelle, dont la force obligatoire est limitée aux contractants.

3° Une règle obligatoire

La règle de droit **oblige** : elle ne se borne pas à conseiller ou à recommander, elle prescrit, interdit ou permet. Ce caractère obligatoire connaît cependant des degrés, qui fondent une distinction essentielle.

Les **règles impératives** (ou d'ordre public) s'imposent aux intéressés, qui ne peuvent y déroger par leurs conventions : l'article 6 du Code civil dispose qu'« on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs ». Les **règles supplétives** (ou dispositives) ne s'appliquent qu'à défaut de volonté contraire des intéressés : elles proposent un régime « par défaut », que les parties peuvent écarter ou aménager. Les règles supplétives sont tout aussi obligatoires que les règles impératives lorsque les parties ne les ont pas écartées : le juge doit les appliquer.

> **À RETENIR**
>
> Une règle supplétive n'est pas une règle facultative. Elle est obligatoire dans le silence des parties ; seule sa mise à l'écart est permise, et encore dans les limites fixées par le droit. La distinction des règles impératives et supplétives commande la validité des clauses contractuelles et statutaires.

Le droit OHADA fournit une illustration précise de cette distinction. L'article 2 de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique (AUSCGIE) pose en principe que ses dispositions sont d'ordre public, sauf dans les cas où il autorise expressément les associés à substituer leurs propres clauses statutaires à celles de l'Acte uniforme ou à compléter celles-ci par leurs dispositions statutaires. L'impérativité est donc la règle et la liberté statutaire l'exception, ce qui commande une méthode d'interprétation : en l'absence d'autorisation expresse, une clause statutaire contraire à l'Acte uniforme est illicite.

4° Une règle sanctionnée par l'autorité publique

Le caractère le plus souvent mis en avant pour distinguer la règle de droit des autres règles sociales est la **sanction organisée**. La violation d'une règle morale expose au remords ou à la réprobation ; la violation d'une règle de droit expose à une réaction prévue, organisée et mise en œuvre par des autorités habilitées, qui peuvent recourir à la contrainte.

Les sanctions juridiques sont diverses :

– les **sanctions répressives** punissent l'auteur de la violation (peines d'emprisonnement, d'amende) ; elles relèvent principalement du droit pénal ;
– les **sanctions réparatrices** obligent à réparer le dommage causé (dommages-intérêts) ;
– les **sanctions restitutives** rétablissent la situation conforme au droit : exécution forcée d'une obligation, nullité d'un acte irrégulier, expulsion d'un occupant sans titre, démolition d'une construction illicite ;
– les **sanctions administratives** et **disciplinaires** frappent les manquements à des réglementations ou à des obligations professionnelles (retrait d'agrément, suspension, radiation).

L'organisation de la sanction suppose des **institutions** : des juges pour constater la violation et prononcer la sanction, des agents d'exécution pour la mettre en œuvre, une force publique pour vaincre la résistance. C'est pourquoi l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution (AUPSRVE, adopté en 1998 et révisé le 17 octobre 2023 MOD) consacre, au profit du créancier muni d'un titre exécutoire, le droit de contraindre son débiteur défaillant et organise le concours de l'État à l'exécution. La sanction juridique est ainsi indissociable de l'existence d'un appareil institutionnel ; on verra cependant (rubrique 7) que cette observation ne suffit pas à faire de la sanction le critère exclusif de la règle de droit.

5° Une règle appartenant à un ordre juridique

Le dernier élément de la définition est souvent omis, alors qu'il est décisif : une règle est juridique parce qu'elle **appartient à un ordre juridique**, c'est-à-dire à un ensemble organisé de normes et d'institutions qui détermine qui peut créer des règles, selon quelles procédures, et qui peut en sanctionner la violation. Une règle édictée par une autorité incompétente, ou selon une procédure irrégulière, n'est pas valide, même si elle est générale, abstraite et assortie d'une sanction. À l'inverse, une règle dépourvue de sanction spécifique peut être juridique si elle est valablement édictée et si son respect peut être demandé à un juge. Cette dimension systémique de la règle de droit, mise en lumière par Kelsen, Hart et Santi Romano, est développée aux chapitres 3, 4 et 7.

C. Les classifications des règles de droit

Les règles de droit peuvent être classées selon plusieurs critères, dont chacun éclaire un aspect de leur régime.

Tableau 1 — Les principales classifications des règles de droit

Critère	Catégories	Intérêt de la distinction
Objet	Règles de conduite (qui prescrivent des comportements) / règles d'organisation (qui instituent des autorités, des procédures, des compétences)	Les secondes, que Hart nomme « règles secondaires », permettent de créer, modifier et appliquer les premières
Force obligatoire	Règles impératives / supplétives / interprétatives	Validité des dérogations conventionnelles
Degré de précision	Règles (précises) / standards (notions à contenu variable : « bon père de famille », « délai raisonnable ») / principes (énoncés généraux d'optimisation)	Marge d'appréciation laissée au juge
Contenu	Règles de fond (substantielles) / règles de forme et de procédure	Application dans le temps (les lois de procédure sont d'application immédiate)
Destinataires	Règles s'adressant aux particuliers / règles s'adressant aux autorités publiques	Invocabilité devant le juge

4. Analyse des principes et mécanismes juridiques

A. La structure logique de la règle : présupposé et effet juridique

Toute règle de droit peut être décomposée en deux éléments. Le **présupposé** (ou hypothèse, ou conditions d'application) décrit la situation de fait à laquelle la règle s'applique. L'**effet juridique** (ou dispositif) énonce la conséquence que le droit attache à cette situation. La règle a donc la forme d'un énoncé conditionnel : *si* telle situation est réalisée, *alors* telle conséquence juridique doit s'ensuivre.

Soit l'article 1382 du Code civil, toujours en vigueur sous ce numéro en Côte d'Ivoire : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. » Le présupposé réunit trois conditions — une faute, un dommage, un lien de causalité entre les deux ; l'effet juridique est l'obligation de réparer.

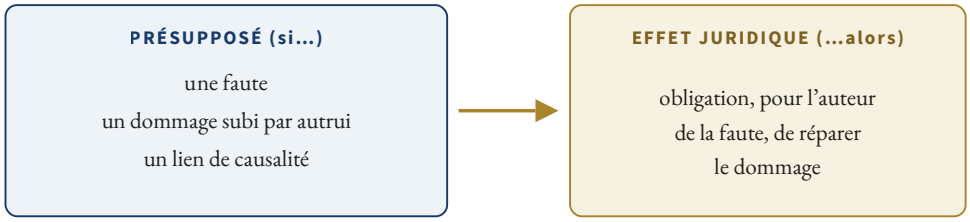


Schéma 1 — La structure de la règle de droit (exemple de l'article 1382 du Code civil)

Cette structure commande le raisonnement juridique, qui prend la forme d'un **syllogisme** : la règle constitue la majeure ; la constatation que les faits de l'espèce réalisent le présupposé constitue la mineure ; l'application de l'effet juridique constitue la conclusion. L'opération décisive est la **qualification**, qui consiste à faire entrer les faits dans les catégories du présupposé (tel comportement est-il une « faute » ?). Le Tome 2 de la collection est consacré à ces opérations ; il suffit ici de souligner que la qualité d'une règle dépend en grande partie de la précision de son présupposé.

B. La force obligatoire et la connaissance de la règle

La règle de droit oblige ses destinataires indépendamment de leur consentement et de leur connaissance effective. L'adage « nul n'est censé ignorer la loi » (*nemo censetur ignorare legem*) exprime cette idée : nul ne peut se soustraire à l'application d'une règle en prétendant l'avoir ignorée. Il ne s'agit pas d'une présomption, au sens où il serait vraisemblable que chacun

connaisse toutes les lois — ce qui est manifestement faux —, mais d'une **nécessité sociale** : si l'ignorance excusait, la règle ne s'appliquerait qu'à ceux qui veulent bien la connaître.

Cette exigence a pour contrepartie une obligation de l'autorité : rendre la règle **accessible**. C'est la fonction de la **publication** des lois et règlements au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire : une règle non publiée n'est pas opposable aux particuliers (chapitre 8). La rigueur de l'adage connaît par ailleurs des tempéraments, dont le plus net figure en droit pénal français : l'article 122-3 du Code pénal français exonère de responsabilité la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte. La question de l'erreur de droit en droit pénal ivoirien est étudiée au Tome 7.

C. Validité, effectivité et efficacité

Trois notions, souvent confondues, doivent être distinguées.

> **DÉFINITION — VALIDITÉ**
>
> Qualité d'une norme qui appartient à un ordre juridique parce qu'elle a été édictée par l'autorité compétente, selon la procédure prescrite, et dans le respect des normes supérieures. Une norme valide est obligatoire.

> **DÉFINITION — EFFECTIVITÉ**
>
> Degré auquel une norme est effectivement respectée par ses destinataires ou appliquée par les autorités chargées de la mettre en œuvre. Notion sociologique, l'effectivité se mesure.

> **DÉFINITION — EFFICACITÉ**
>
> Aptitude d'une norme à atteindre les objectifs que lui assignait son auteur. Une norme effective peut être inefficace, si son application ne produit pas les résultats escomptés.

Le lien entre validité et effectivité est l'un des problèmes centraux de la théorie du droit. Pour Kelsen, une norme isolée peut être valide sans être effective; mais un ordre juridique qui cesse, dans son ensemble, d'être effectif perd sa validité. L'histoire du droit ivoirien de la famille illustre la tension entre ces notions : l'interdiction de la dot, édictée en 1964, est restée valide pendant plus d'un demi-siècle tout en étant largement ineffective, jusqu'à son abandon par la loi n° 2019-570 du 26 juin 2019 relative au mariage[8] V. L'ineffectivité durable d'une

8. Selon les analyses publiées de la réforme, la loi de 2019 a abrogé les dispositions de la loi n° 64-381 du 7 octobre 1964 (art. 20 à 22) qui prohibaient la dot; v. la fiche de vérification en annexe.

règle valide affaiblit l'autorité de l'ensemble du droit et appelle soit un effort de mise en œuvre, soit une révision de la règle.

D. Les fonctions de la règle de droit

La règle de droit remplit plusieurs fonctions, qui expliquent sa raison d'être et éclairent son interprétation.

Une fonction d'ordre et de paix. Le droit substitue au rapport de force un ordre prévisible et un mode pacifique de règlement des conflits. L'interdiction de se faire justice à soi-même et le monopole de la contrainte légitime confié à l'État en sont l'expression.

Une fonction de sécurité juridique. Le droit permet à chacun de prévoir les conséquences de ses actes et de ceux d'autrui, donc de faire des projets, d'investir, de contracter. La sécurité juridique exige des règles accessibles, intelligibles, stables et non rétroactives. Elle est au cœur du projet de l'OHADA, dont le Traité a pour objet l'harmonisation du droit des affaires par l'élaboration de règles communes simples, modernes et adaptées, et par la mise en œuvre de procédures judiciaires appropriées (Traité OHADA, art. 1er).

Une fonction de justice. Le droit prétend attribuer à chacun ce qui lui revient. Aristote distinguait la **justice commutative**, qui régit les échanges et exige l'égalité arithmétique des prestations, et la **justice distributive**, qui répartit les biens et les charges selon le mérite ou le besoin[9]. Le droit des contrats relève principalement de la première, le droit fiscal ou le droit de la protection sociale de la seconde.

Une fonction de transformation sociale. Le droit n'est pas seulement le reflet de la société ; il peut être un instrument de sa transformation. Les lois civiles ivoiriennes de 1964 entendaient moderniser la famille en substituant aux coutumes un modèle unifié ; les réformes de 2013 et de 2019 ont poursuivi l'objectif d'égalité entre les époux. Cette fonction volontariste expose le droit au risque de l'ineffectivité lorsqu'il s'écarte trop des pratiques sociales.

Une fonction expressive. Enfin, le droit exprime les valeurs d'une société et contribue à les façonner. L'inscription dans la Constitution de l'abolition de la peine de mort (Const., art. 3) a une portée symbolique qui excède ses effets techniques.

5. Étude des textes applicables

A. Les dispositions préliminaires du Code civil

Le Code civil applicable en Côte d'Ivoire s'ouvre sur un **titre préliminaire** « De la publication, des effets et de l'application des lois en général », qui énonce plusieurs règles relatives à la

règle de droit elle-même. Ces dispositions, issues de la rédaction de 1804, n'ont pas été remplacées par des lois ivoiriennes et demeurent la référence en la matière, sous réserve des règles constitutionnelles relatives à la promulgation et à la publication.

Tableau 2 — Le titre préliminaire du Code civil

Article	Contenu	Portée
Art. 2	« La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif. »	Principe de non-rétroactivité (chapitre 8)
Art. 3	Lois de police et de sûreté ; loi applicable aux immeubles ; loi applicable à l'état et à la capacité des personnes	Application de la loi dans l'espace (chapitre 8)
Art. 4	Le juge qui refuse de juger sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi peut être poursuivi comme coupable de déni de justice	Obligation de juger ; pouvoir d'interprétation (chapitre 10)
Art. 5	Interdiction aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire	Prohibition des arrêts de règlement (chapitre 10)
Art. 6	Interdiction de déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs	Distinction des règles impératives et supplétives

DROIT COMPARÉ —

En France, l'article 1er du Code civil a été réécrit par l'ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 relative aux modalités et effets de la publication des lois et de certains actes administratifs : les lois entrent désormais en vigueur à la date qu'elles fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication au *Journal officiel*. Cette réforme n'est pas applicable en Côte d'Ivoire, où l'entrée en vigueur des lois obéit aux règles constitutionnelles de promulgation et de publication (chapitre 8).

B. Les dispositions constitutionnelles

La Constitution du 8 novembre 2016 détermine les autorités habilitées à édicter des règles de droit et la répartition de leurs compétences. Son article 101 énumère les matières dans lesquelles « la loi fixe les règles » ou détermine les principes fondamentaux ; les matières qui n'y

9. Aristote, *Éthique à Nicomaque*, livre V.

figurent pas relèvent du pouvoir réglementaire (Const., art. 103 V). Ces dispositions confirment que la qualité de règle de droit dépend de l'autorité qui l'édicte et de la procédure suivie : le critère formel est inséparable de la définition (chapitres 7 et 8).

C. Le droit uniforme OHADA

L'article 10 du Traité OHADA dispose que les actes uniformes « sont directement applicables et obligatoires dans les États Parties nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure ». Cette disposition illustre le caractère obligatoire de règles qui ne sont pas édictées par le législateur national, et dont la force procède d'un traité ratifié par la Côte d'Ivoire. Elle est étudiée au chapitre 7.

6. Analyse de jurisprudences vérifiables

Jurisprudence — Cons. const. (France), déc. n° 2005-512 DC, 21 avril 2005, Loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école

Question. Une disposition législative dépourvue de portée normative est-elle conforme à la Constitution ?

Solution. Le Conseil constitutionnel juge que la loi a pour vocation d'énoncer des règles et doit par suite être revêtue d'une portée normative. Il censure une disposition de la loi déférée qui se bornait à énoncer des objectifs généraux, sans contenu prescriptif.

Portée. La décision consacre, en droit français, une exigence de **normativité** de la loi : le législateur ne peut se contenter de déclarations d'intention. Elle offre un critère utile pour apprécier les « neutrons législatifs » — dispositions qui occupent la place d'une règle sans en avoir la substance. Aucune jurisprudence ivoirienne équivalente n'a été identifiée à la date de rédaction ; la question demeure ouverte devant le Conseil constitutionnel ivoirien.

Jurisprudence — Cons. const. (France), déc. n° 99-421 DC, 16 décembre 1999, Loi portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie législative de certains codes

Solution. Le Conseil constitutionnel reconnaît que l'accessibilité et l'intelligibilité de la loi constituent un **objectif de valeur constitutionnelle**, au motif que l'égalité devant la loi et la garantie des droits ne seraient pas effectives si les citoyens ne disposaient pas d'une connaissance suffisante des normes qui leur sont applicables.

Portée. La décision fait de la qualité de la règle — sa clarté, son accessibilité — une exigence juridique, et non plus seulement une recommandation de bonne législation. Elle justifie les entreprises de codification.

Jurisprudence — CEDH, 26 avril 1979, Sunday Times c. Royaume-Uni

Question. Une restriction à la liberté d'expression fondée sur une règle jurisprudentielle de *common law* (le *contempt of court*) est-elle « prévue par la loi » au sens de la Convention européenne des droits de l'homme ?

Solution. La Cour adopte une conception **matérielle** de la loi, qui inclut le droit non écrit, mais pose deux exigences : la règle doit être suffisamment **accessible**, et énoncée avec assez de **précision** pour permettre au citoyen de régler sa conduite, au besoin en s'entourant de conseils éclairés.

Portée. La décision montre que la qualité de règle de droit ne dépend pas de la forme législative, mais de propriétés substantielles — accessibilité et prévisibilité — qui conditionnent la possibilité d'obéir. Ce raisonnement est transposable à l'interprétation des instruments africains de protection des droits de l'homme, qui subordonnent également certaines restrictions aux libertés à leur prévision par la loi.

Jurisprudence — Cour ADHP, 18 novembre 2016, Actions pour la protection des droits de l'homme (APDH) c. République de Côte d'Ivoire, requête n° 001/2014

Faits et question. Une organisation non gouvernementale ivoirienne contestait la composition de la Commission électorale indépendante (CEI), telle qu'organisée par la loi n° 2014-335 du 18 juin 2014, au regard des engagements internationaux de l'État relatifs à l'indépendance et à l'impartialité de l'organe électoral.

Solution. La Cour africaine juge que l'État a manqué à son obligation de créer un organe électoral indépendant et impartial et lui ordonne de modifier la loi de 2014 pour la rendre conforme aux instruments applicables.

Portée. Pour la théorie de la règle de droit, la décision est instructive à deux titres. D'une part, elle montre qu'une loi nationale valide au regard de l'ordre interne peut être jugée contraire à des normes internationales obligatoires pour l'État. D'autre part, elle illustre une **sanction** d'un type particulier : la condamnation internationale et l'injonction de modifier la loi ne s'exécutent pas par la force, mais par la responsabilité internationale de l'État et la pression qui en résulte. La Côte d'Ivoire a adopté en 2019 une loi portant recomposition de la CEI (loi n° 2019-708 du 5 août 2019), dont la conformité à l'arrêt a été contestée devant la même Cour. Les suites de cette jurisprudence sont étudiées au Tome 3.

7. Présentation des débats doctrinaux

A. La sanction est-elle le critère de la règle de droit ?

DÉBAT DOCTRINAL — SANCTION, CONTRAINTE ET JURIDICITÉ

La thèse de la sanction. Pour une large tradition, que représentent Austin puis, sous une forme renouvelée, Kelsen, le droit se distingue des autres ordres normatifs par son caractère **coercitif** : est juridique la norme dont la violation est la condition d'un acte de contrainte organisé. Cette thèse a le mérite de la netteté et rend compte du rôle central de la force publique dans l'exécution du droit DOC.

Les objections. Elle se heurte cependant à plusieurs objections. Hart observe que de nombreuses règles juridiques ne sont pas assorties de sanctions au sens strict : les règles qui confèrent le pouvoir de contracter, de tester ou de légiférer ne punissent pas ceux qui ne les respectent pas ; elles se bornent à priver d'effet l'acte irrégulier. Il ajoute que la sanction ne peut être le critère de la règle, car c'est une autre règle qui organise la sanction : on est renvoyé à l'infini, sauf à admettre que certaines règles — celles qui obligent les juges à sanctionner — sont juridiques sans être elles-mêmes sanctionnées. Le droit international public, dont les mécanismes de contrainte sont faibles, et les règles constitutionnelles qui s'imposent aux plus hautes autorités, rarement susceptibles d'exécution forcée, sont juridiques sans répondre pleinement au critère de la sanction DOC.

Les thèses alternatives. Jean Carbonnier a proposé de substituer au critère de la sanction celui de la **justiciabilité** : est juridique la règle dont le respect peut faire l'objet d'un jugement, c'est-à-dire d'une décision rendue par un tiers selon une procédure[10]. Hart, de son côté, fait reposer l'identification du droit sur une **règle de reconnaissance**, pratiquée par les officiels de l'ordre juridique, qui détermine les critères de validité des autres règles DOC.

État de la discussion. La doctrine contemporaine tend à considérer que la sanction est un caractère **normal** de la règle de droit, mais non un critère **nécessaire** de chaque règle prise isolément : c'est l'ordre juridique dans son ensemble qui est sanctionné, non chacune de ses règles.

B. Le « droit souple » est-il du droit ?

Les autorités publiques recourent de plus en plus à des instruments qui ne créent pas d'obligations au sens strict : recommandations, lignes directrices, chartes, codes de bonne conduite, référentiels. Le Conseil d'État français, dans son étude annuelle de 2013 consacrée au « droit souple », les définit comme des instruments qui ont pour objet de modifier ou d'orienter les comportements de leurs destinataires en suscitant leur adhésion, qui ne créent pas par eux-

10. J. Carbonnier, *Sociologie juridique*, PUF, coll. « Quadrige ».

mêmes de droits ou d'obligations, mais qui présentent, par leur contenu et leur mode d'élaboration, un degré de formalisation et de structuration qui les apparente aux règles de droit[11].

Deux thèses s'opposent. Pour les uns, le droit souple n'est pas du droit, puisqu'il n'oblige pas ; le qualifier de « droit » entretient une confusion préjudiciable à la sécurité juridique. Pour les autres, la normativité est **graduée** : entre l'obligation stricte et l'absence de toute portée, il existe des degrés de contrainte, et le droit souple produit des effets juridiques réels — il oriente l'interprétation, il fonde des attentes légitimes, il prépare la règle obligatoire. Le Conseil d'État français a d'ailleurs admis que certains actes de droit souple émanant d'autorités de régulation puissent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir lorsqu'ils sont de nature à produire des effets notables, notamment de nature économique, ou ont pour objet d'influer de manière significative sur les comportements de leurs destinataires[12] JP.

PROPOSITION DE L'AUTEUR — UNE CONCEPTION GRADUÉE DE LA NORMATIVITÉ

Il paraît préférable de réserver la qualification de **règle de droit** aux normes obligatoires appartenant à un ordre juridique, tout en reconnaissant que la **juridicité** est une propriété plus large : des instruments non obligatoires peuvent produire des effets de droit (interprétatifs, probatoires, contentieux) et doivent, à ce titre, être étudiés par le juriste. Pour le législateur ivoirien, cette distinction plaide pour l'adoption d'un guide de légistique qui proscrive les dispositions dépourvues de portée normative dans les lois, et qui encadre l'usage des instruments de droit souple par les autorités de régulation PP.

8. Illustrations pratiques

La clause statutaire dérogatoire. Les associés d'une société à responsabilité limitée constituée à Abidjan souhaitent insérer dans les statuts une clause qui aménage une règle de l'AUSCGIE. Le premier réflexe du praticien doit être de rechercher si l'Acte uniforme autorise expressément cette dérogation : à défaut, la règle est impérative en vertu de l'article 2 de l'Acte uniforme, et la clause est réputée non écrite ou expose à la nullité. La distinction des règles impératives et supplétives a ici une portée directement opérationnelle.

Le texte publié et le texte connu. Un nouveau règlement de police administrative est adopté et publié au Journal officiel ; un commerçant poursuivi pour sa violation invoque son ignorance. L'adage « nul n'est censé ignorer la loi » s'oppose à ce moyen de défense dès lors que la publication a été régulièrement faite. La situation serait différente si le texte n'avait pas été publié : il ne serait alors pas opposable.

11. Conseil d'État, *Le droit souple*, Étude annuelle 2013, La Documentation française, 2013.
12. CE, ass., 21 mars 2016, *Société Fairvesta International GmbH et autres* et *Société NC Numericable*.

Les déclarations de principe. Les textes législatifs et réglementaires contiennent parfois des dispositions qui énoncent des objectifs, des valeurs ou des engagements de politique publique (« l'État favorise… », « la Nation encourage… »). Le juriste doit les identifier comme des dispositions **programmatiques** : elles éclairent l'interprétation des autres règles, mais ne confèrent pas, en principe, de droits invocables par les particuliers.

La règle valide mais ineffective. L'observation de la pratique matrimoniale ivoirienne, où la célébration coutumière et religieuse demeure socialement centrale alors que seul le mariage célébré devant l'officier de l'état civil produit des effets juridiques, illustre l'écart possible entre la règle et la pratique. Cet écart a des conséquences concrètes : le « conjoint » uni selon la seule coutume ne bénéficie pas des droits que la loi attache au mariage, notamment en matière successorale.

9. Cas pratiques corrigés

Cas pratique n° 1 — L'ignorance de la règle

Énoncé. M. Koffi exploite un établissement recevant du public à Bouaké. Un décret, publié au Journal officiel trois mois plus tôt, impose aux exploitants de tels établissements d'afficher les tarifs pratiqués, sous peine d'une amende administrative. Contrôlé, M. Koffi soutient qu'il ignorait l'existence du décret, qu'il n'a jamais reçu de notification personnelle et que l'administration aurait dû l'informer. Ses arguments sont-ils fondés ?

CORRIGÉ

Problème de droit. L'ignorance d'une règle de droit régulièrement publiée peut-elle exonérer son destinataire des sanctions attachées à sa violation ?

Règle applicable. La règle de droit oblige ses destinataires indépendamment de leur connaissance effective, dès lors qu'elle a été régulièrement publiée : c'est le sens de l'adage « nul n'est censé ignorer la loi », qui exprime une nécessité sociale et non une présomption de fait. La publication au Journal officiel est la formalité qui rend la règle opposable ; elle dispense l'administration de toute notification individuelle pour les actes réglementaires, qui sont par définition généraux et impersonnels.

Application. Le décret a été publié trois mois avant le contrôle ; il est donc opposable à M. Koffi. Son caractère réglementaire exclut toute exigence de notification personnelle, qui ne vaut que pour les décisions individuelles. L'ignorance alléguée, qui ne résulte d'aucune circonstance exceptionnelle (impossibilité d'accès au texte, information erronée délivrée par l'administration elle-même), est sans incidence.

Conclusion. Les arguments de M. Koffi sont infondés. Il pourrait seulement, à titre subsidiaire, vérifier la régularité du décret lui-même (compétence de son auteur, confor-

mité à la loi) et, le cas échéant, en contester la légalité par voie d'exception à l'occasion du contentieux de la sanction.

Cas pratique n° 2 — Règle impérative ou supplétive ?

Énoncé. Trois associés constituent une société commerciale régie par l'AUSCGIE. Ils souhaitent insérer dans les statuts deux clauses : la première fixe la majorité requise pour certaines décisions à un niveau supérieur à celui prévu par l'Acte uniforme ; la seconde dispense le gérant de toute obligation de rendre compte de sa gestion aux associés. Ils vous demandent si ces clauses sont valables.

CORRIGÉ

Problème de droit. Les associés peuvent-ils, par des clauses statutaires, déroger aux dispositions de l'AUSCGIE ?

Règle applicable. L'article 2 de l'AUSCGIE pose en principe le caractère d'ordre public de ses dispositions, sauf lorsque l'Acte uniforme autorise expressément les associés à substituer leurs propres clauses à ses dispositions ou à les compléter. La validité de chaque clause dépend donc de l'existence d'une autorisation expresse dans la disposition concernée.

Application. Pour la première clause, il convient de vérifier si la disposition de l'Acte uniforme relative à la majorité en cause permet aux statuts de prévoir une majorité plus forte : de nombreuses dispositions relatives aux majorités fixent un seuil minimal en autorisant les statuts à prévoir davantage ; si tel est le cas, la clause est valable. La seconde clause porte atteinte à un droit essentiel des associés — le droit à l'information sur la gestion sociale — que l'Acte uniforme organise de manière impérative ; aucune autorisation expresse ne permettant d'y déroger, elle est illicite.

Conclusion. La première clause est valable sous réserve de l'autorisation expresse de la disposition concernée ; la seconde est illicite. La méthode à retenir est de partir de la présomption d'impérativité et de rechercher, disposition par disposition, l'existence d'une autorisation de dérogation.

Cas pratique n° 3 — Une disposition sans règle

Énoncé. Une loi sectorielle comporte un article ainsi rédigé : « L'État encourage la culture de la paix, du dialogue et de la tolérance dans les établissements d'enseignement. » Une association de parents d'élèves envisage d'assigner l'État pour obtenir qu'il finance des programmes d'éducation à la paix, en se fondant sur cet article. Quelles sont ses chances de succès ?

CORRIGÉ

Problème de droit. Une disposition législative de nature programmatique confère-t-elle aux particuliers un droit invocable en justice ?

Règle applicable. Une disposition ne crée de droits subjectifs que si elle présente un caractère normatif suffisant, c'est-à-dire si elle prescrit un comportement déterminé à un destinataire identifiable et si elle est assez précise pour être appliquée par un juge. Les dispositions qui énoncent des objectifs ou des orientations de politique publique sont dites programmatiques ; elles guident l'action des pouvoirs publics et l'interprétation des autres règles, mais ne confèrent pas de droits subjectifs. En droit comparé, le Conseil constitutionnel français va jusqu'à censurer les dispositions législatives dépourvues de portée normative (déc. n° 2005-512 DC du 21 avril 2005).

Application. L'article invoqué n'impose à l'État aucune prestation déterminée : le verbe « encourager » exprime une orientation, sans fixer d'obligation chiffrée, de moyens ou de résultat. Il ne désigne aucun bénéficiaire d'un droit à une prestation. Il ne peut donc fonder une condamnation de l'État à financer des programmes particuliers.

Conclusion. L'action a peu de chances de prospérer. L'association pourrait en revanche invoquer cet article au soutien de l'interprétation d'autres dispositions plus précises, ou dans une démarche de plaidoyer auprès des pouvoirs publics.

10. Synthèse et connaissances essentielles

SYNTHÈSE — CONNAISSANCES ESSENTIELLES

- Le mot « droit » désigne le **droit objectif** (ensemble des règles) et les **droits subjectifs** (prérogatives individuelles), ainsi que la science qui les étudie.
- La **règle de droit** est une règle de conduite sociale, **générale et abstraite**, **obligatoire**, dont le respect est garanti par une **sanction organisée par l'autorité publique**, et qui **appartient à un ordre juridique**.
- Les règles **impératives** s'imposent aux intéressés ; les règles **supplétives** s'appliquent à défaut de volonté contraire. En droit OHADA des sociétés, l'impérativité est le principe (AUSCGIE, art. 2).
- La règle se compose d'un **présupposé** et d'un **effet juridique** ; son application passe par la **qualification** des faits et le **syllogisme** juridique.
- **Validité**, **effectivité** et **efficacité** sont des notions distinctes ; l'ineffectivité durable d'une règle valide (exemple de la dot) en affaiblit l'autorité.
- La sanction est un caractère normal de la règle de droit, mais son statut de **critère** est discuté (Kelsen, Hart, Carbonnier).
- Le **droit souple** pose la question d'une normativité graduée.

– Le droit remplit des fonctions d'**ordre**, de **sécurité juridique**, de **justice**, de **transformation sociale** et d'**expression** des valeurs.

11. Questions d'évaluation

QUESTIONS D'ÉVALUATION

Questions de cours

1. Distinguez le droit objectif et les droits subjectifs, en donnant un exemple de chacun tiré du droit ivoirien.
2. En quoi la généralité de la règle de droit est-elle une garantie contre l'arbitraire ? Une règle qui ne concerne qu'une seule personne peut-elle être générale ?
3. Qu'est-ce qu'une règle supplétive ? Est-elle facultative ?
4. Présentez les différentes catégories de sanctions juridiques.
5. Distinguez validité, effectivité et efficacité d'une règle de droit.
6. Quel est le sens de l'adage « nul n'est censé ignorer la loi » ? Quelles en sont les limites ?

Questions de réflexion

1. Pourquoi l'article 2 de l'AUSCGIE pose-t-il le principe de l'impérativité de ses dispositions ? Quels en sont les avantages et les inconvénients pour la pratique des affaires ?
2. L'arrêt *APDH c. Côte d'Ivoire* de la Cour africaine montre-t-il que la sanction n'est pas nécessaire à la juridicité d'une règle ?

Sujets de dissertation

1. « La sanction, critère de la règle de droit ? »
2. « Le droit souple est-il du droit ? »
3. « Effectivité et validité de la règle de droit : l'exemple ivoirien. »

Commentaire

1. Commentez l'article 6 du Code civil : « On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs. »

12. Références bibliographiques

Ouvrages généraux

J. Carbonnier, *Droit civil. Introduction*, PUF, coll. « Thémis », dernière éd.

G. Cornu, *Droit civil. Introduction au droit*, Montchrestien, coll. « Domat droit privé », dernière éd.

F. Terré, *Introduction générale au droit*, Dalloz, coll. « Précis », dernière éd.

J. Ghestin et G. Goubeaux, *Traité de droit civil. Introduction générale*, LGDJ, dernière éd.

J.-L. Bergel, *Théorie générale du droit*, Dalloz, coll. « Méthodes du droit », dernière éd.

Ouvrages spéciaux

H. Kelsen, *Théorie pure du droit*, trad. Ch. Eisenmann, Dalloz, 1962.

H. L. A. Hart, *Le concept de droit*, trad. M. van de Kerchove, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 1976.

J. Carbonnier, *Flexible droit. Pour une sociologie du droit sans rigueur*, LGDJ, dernière éd.

J. Carbonnier, *Sociologie juridique*, PUF, coll. « Quadrige ».

P. Amselek, *Méthode phénoménologique et théorie du droit*, LGDJ, 1964.

S. Rials, *Le juge administratif français et la technique du standard*, LGDJ, 1980.

Conseil d'État, *Le droit souple*, Étude annuelle 2013, La Documentation française, 2013.

Droit africain et anthropologie juridique

N. Rouland, *Anthropologie juridique*, PUF, coll. « Droit fondamental », 1988.

É. Le Roy, *Le jeu des lois. Une anthropologie « dynamique » du droit*, LGDJ, 1999.

Sources officielles

Constitution de la République de Côte d'Ivoire du 8 novembre 2016 (loi n° 2016-886), révisée ; Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique (Port-Louis, 17 octobre 1993, révisé à Québec le 17 octobre 2008) ; AUSCGIE (30 janvier 2014) ; décisions du Conseil constitutionnel français (www.conseil-constitutionnel.fr) ; arrêts de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples (www.african-court.org).

CHAPITRE 2

Le droit et les autres systèmes normatifs

1. Introduction et problématique

La règle de droit n'est pas la seule règle qui gouverne les conduites humaines. Dans la vie quotidienne d'un habitant d'Abidjan, de Korhogo ou de Daloa, les prescriptions religieuses, les exigences morales, les usages de politesse, les obligations coutumières envers la famille élargie et les règles professionnelles exercent souvent une influence plus immédiate que les codes et les lois. Le juriste doit donc savoir situer le droit parmi les autres **systèmes normatifs**, pour deux raisons.

La première est **conceptuelle** : identifier le droit suppose de le distinguer de ce qui n'en est pas. Une obligation morale n'est pas une obligation juridique ; un précepte religieux ne s'impose pas, comme tel, au juge de l'État. La seconde est **pratique** : les systèmes normatifs ne vivent pas séparés. Le droit renvoie à la morale lorsqu'il sanctionne les conventions contraires aux bonnes mœurs ; il tient compte de la religion lorsqu'il garantit la liberté de culte ; il intègre les usages lorsqu'il en fait des éléments du contrat ; il se fait l'instrument de l'équité lorsqu'il permet à l'arbitre de statuer en amiable compositeur.

Problématique. *Le droit est-il un ordre normatif autonome, séparable de la morale, de la religion et des mœurs, ou n'est-il qu'une expression particulière, institutionnalisée, de normes sociales plus larges ?* Le chapitre montrera que le droit moderne s'est construit par **distinction** d'avec les autres ordres normatifs — distinction qui est une condition de la liberté de conscience et de la sécurité juridique —, mais que cette distinction n'est pas une **séparation** : le droit organise lui-même les canaux par lesquels il reçoit, filtre et parfois sanctionne les exigences morales, religieuses et sociales.

2. Fondements historiques et théoriques

A. De la confusion à la distinction

Dans la plupart des sociétés anciennes, les normes juridiques, morales et religieuses formaient un ensemble indifférencié. La Rome archaïque distinguait certes le *fas*, ce qui est permis par

les dieux, et le *jus*, ce qui relève de l'ordre humain ; mais le droit était longtemps resté l'affaire des pontifes. Au Moyen Âge, en Europe, le droit canonique de l'Église régissait le mariage, les testaments et de nombreux aspects de la vie sociale. Dans les sociétés africaines précoloniales, comme on l'a vu au chapitre 1, la norme sociale était inséparable de l'ordre religieux et cosmique.

La **distinction** moderne entre le droit et la morale s'est construite progressivement. Au début du XVIIIe siècle, le juriste allemand Christian Thomasius distingue trois ordres : le juste (*justum*), qui vise la paix extérieure et peut faire l'objet d'une contrainte ; l'honnête (*honestum*), qui vise la paix intérieure et relève de la morale ; le convenable (*decorum*), qui relève de la bienséance. À la fin du même siècle, Emmanuel Kant oppose la **légalité**, simple conformité extérieure de l'action à la loi, quel qu'en soit le mobile, et la **moralité**, qui exige que l'action soit accomplie par devoir ; la législation juridique admet des mobiles extérieurs, comme la crainte de la sanction, tandis que la législation morale exige un mobile intérieur[1].

B. La sécularisation du droit

La distinction entre le droit et la religion procède d'un mouvement historique distinct : la **sécularisation** de l'État. En France, elle culmine avec la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État. Dans les colonies, le pouvoir colonial adopta une attitude ambivalente : tout en affirmant la neutralité de l'État, il reconnut, au titre du « statut personnel » des populations colonisées, l'application de coutumes et de règles religieuses, notamment islamiques, en matière familiale et successorale, appliquées par des juridictions spécifiques.

À l'indépendance, la Côte d'Ivoire a fait le choix d'un **État laïque** et d'un droit de la famille unifié, applicable à tous indépendamment de leur religion ou de leur origine. La laïcité de l'État figure parmi les principes que la Constitution soustrait à la révision (Const., art. 178), ce qui lui confère une place éminente dans l'ordre constitutionnel. D'autres États de la région ont fait des choix différents, en ménageant une place au droit musulman en matière familiale ; la comparaison en sera faite plus loin.

C. Le droit, ordre normatif institutionnalisé

La théorie contemporaine du droit explique la spécificité du droit non par son contenu — car le droit et la morale prescrivent souvent les mêmes conduites : ne pas tuer, ne pas voler, tenir ses promesses — mais par sa **forme institutionnelle**. Le droit est un ordre normatif qui comporte des règles sur la production des règles, des organes spécialisés pour les appliquer et une contrainte organisée pour en assurer le respect. La morale, la religion et les mœurs

1. E. Kant, *Métaphysique des mœurs*, 1797, Introduction.

peuvent connaître des autorités et des sanctions ; mais elles n'ont pas, dans l'État moderne, le monopole de la contrainte légitime.

3. Explication approfondie des concepts

A. Le droit et la morale

> **DÉFINITION — MORALE**
>
> Ensemble des règles de conduite qui visent le bien de la personne et le perfectionnement de son comportement, et dont le respect relève principalement de la conscience individuelle et de la réprobation sociale.

1° Les critères de distinction

Tableau 1 — Droit et morale : critères de distinction

Critère	Droit	Morale
Finalité	Ordre social, coexistence pacifique, sécurité	Perfectionnement de la personne, recherche du bien
Objet	Comportements extérieurs ; intentions seulement si elles se manifestent	Comportements et intentions, y compris les pensées
Source	Autorités habilitées (hétéronomie)	Conscience individuelle, tradition, religion (autonomie relative)
Sanction	Organisée, extérieure, prononcée par des autorités, au besoin par la contrainte	Intérieure (remords) ou sociale diffuse (réprobation)
Exigence	Minimum nécessaire à la vie sociale	Idéal de perfection
Forme	Écrite, précise, publiée	Souvent non écrite, générale

Aucun de ces critères n'est absolu. Le droit s'intéresse aux intentions (la bonne foi, la mauvaise foi, l'intention de nuire, l'élément moral de l'infraction) ; la morale peut être formalisée dans des codes de déontologie ; certaines règles juridiques sont dépourvues de contenu moral (les règles de circulation, les délais de procédure). Mais pris ensemble, ces critères permettent de comprendre que le droit et la morale sont **deux ordres distincts dont les domaines se recoupent partiellement**.

2° Les recoupements

Le droit **consacre** de nombreuses règles morales : l'interdiction de tuer, de voler, de tromper, l'obligation de tenir ses engagements. Il renvoie expressément à la morale à travers des **notions-cadres** : les bonnes mœurs (C. civ., art. 6 et 1133), la bonne foi dans l'exécution des conventions (C. civ., art. 1134, al. 3), l'équité dans la détermination des suites du contrat (C. civ., art. 1135), la diligence du « bon père de famille » (C. civ., art. 1137). Le doyen Ripert a montré l'importance de ces infiltrations morales dans le droit des obligations[2].

À l'inverse, le droit peut **tolérer** des comportements que la morale réprouve (le mensonge non dolosif, l'ingratitude hors les cas légaux) et **imposer** des comportements moralement neutres. Il peut même, dans des circonstances historiques extrêmes, prescrire l'injustice : c'est le problème du « droit injuste », examiné au chapitre 3.

B. Le droit et la religion

> **DÉFINITION — NORME RELIGIEUSE**
>
> Règle de conduite qui tire son autorité d'une révélation, d'une tradition sacrée ou d'une institution religieuse, et dont le respect est sanctionné, selon les croyants, par la divinité, et socialement par la communauté des fidèles.

La Côte d'Ivoire est un pays de grande diversité religieuse, où coexistent l'islam, le christianisme sous ses différentes confessions et les religions traditionnelles. Dans un État laïque, la norme religieuse n'a pas d'autorité juridique propre : elle ne s'impose ni au juge ni à l'administration. Mais le droit étatique la prend en compte de plusieurs manières :

- il **garantit la liberté de religion**, qui inclut la liberté de pratiquer et de manifester ses croyances, sous réserve du respect de l'ordre public, comme le prévoit également l'article 8 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples ;
- il **refuse les effets juridiques** des actes purement religieux lorsqu'il a organisé une institution civile concurrente : seul le mariage célébré devant l'officier de l'état civil produit les effets légaux du mariage ;
- il **prend en compte** les convictions religieuses dans certaines situations (aménagements, objection, fêtes légales).

C. Le droit et les mœurs, usages et règles de bienséance

Les **mœurs** désignent les habitudes de comportement d'une société ; les **règles de bienséance** ou de politesse en sont la part prescriptive (saluer, respecter les aînés, honorer l'hospitalité).

Leur sanction est purement sociale. Elles se distinguent des **usages** au sens juridique, qui sont des pratiques auxquelles le droit reconnaît une force obligatoire dans certaines conditions (C. civ., art. 1135 ; usages commerciaux), et de la **coutume**, véritable source de droit lorsqu'elle réunit un élément matériel et un élément psychologique (chapitre 9).

D. Le droit et l'équité

> **DÉFINITION — ÉQUITÉ**
>
> Sentiment de justice appliqué au cas particulier, qui conduit à tempérer la rigueur de la règle générale pour tenir compte des circonstances de l'espèce.

Aristote présentait l'équité (*epieikeia*) comme un correctif de la loi : parce que la loi est générale, elle ne peut prévoir tous les cas, et l'équité la corrige là où sa généralité la rend défaillante[3]. La tradition juridique française se méfie pourtant de l'équité du juge, comme en témoigne l'adage d'Ancien Régime « Dieu nous garde de l'équité des Parlements », qui exprimait la crainte de l'arbitraire des cours souveraines. Le juge étatique doit statuer en droit ; il ne peut écarter une règle au motif qu'elle lui paraîtrait inéquitable. L'équité n'intervient que **par délégation** de la loi : lorsque celle-ci renvoie à l'appréciation du juge (fixation de dommages-intérêts, octroi de délais de grâce, réduction d'une clause pénale dans les systèmes qui l'admettent) ou, en matière d'arbitrage, lorsque les parties ont conféré aux arbitres le pouvoir de statuer en **amiable compositeur**, ce que permet l'Acte uniforme OHADA relatif au droit de l'arbitrage.

E. Le droit et les autres normativités contemporaines

Le droit coexiste enfin avec des normativités d'apparition plus récente :

- les **normes techniques** (normes de qualité, de sécurité, de comptabilité), élaborées par des organismes de normalisation, que le droit rend parfois obligatoires par renvoi ;
- les **règles déontologiques** des professions organisées (médecins, avocats, notaires), qui deviennent juridiques lorsqu'elles sont consacrées par un texte et sanctionnées par une juridiction disciplinaire ;
- le **droit souple** (recommandations, chartes, lignes directrices), étudié au chapitre 1 ;
- les **ordres normatifs transnationaux** non étatiques, comme les usages du commerce international (*lex mercatoria*) ou les règles des fédérations sportives, dont l'articulation avec le droit étatique pose des questions de pluralisme juridique (chapitre 4).

2. G. Ripert, *La règle morale dans les obligations civiles*, LGDJ, 4e éd., 1949.
3. Aristote, *Éthique à Nicomaque*, livre V, chap. 14.

4. Analyse des principes et mécanismes juridiques

Le droit n'ignore pas les autres systèmes normatifs : il organise lui-même les **mécanismes de réception** par lesquels certaines de leurs exigences acquièrent une force juridique, et les **mécanismes de résistance** par lesquels il refuse d'en accueillir d'autres.

A. La réception par les notions-cadres

Les notions de bonne foi, de bonnes mœurs, d'ordre public, d'équité ou de diligence raisonnable sont des **standards** dont le contenu n'est pas fixé par la loi. En y recourant, le législateur délègue au juge le soin d'en préciser le contenu en fonction des valeurs sociales de son temps. Ce mécanisme permet au droit d'évoluer sans réforme législative, mais il confère au juge un pouvoir d'appréciation important, dont l'exercice doit être motivé. Le contenu des bonnes mœurs a ainsi profondément évolué : la jurisprudence française a cessé, depuis le début des années 2000, de juger contraires aux bonnes mœurs les libéralités consenties dans le cadre d'une relation adultère (rubrique 6).

B. L'obligation naturelle, passerelle entre devoir moral et obligation juridique

> **DÉFINITION — OBLIGATION NATURELLE**
>
> Devoir moral ou obligation civile imparfaite (par exemple une dette prescrite) dont l'exécution ne peut être exigée en justice, mais qui, lorsqu'elle a été volontairement exécutée ou promise, produit certains effets juridiques.

L'obligation naturelle illustre de façon remarquable le passage de la morale au droit. Elle n'est pas susceptible d'exécution forcée : le créancier ne peut en demander l'exécution au juge. Mais si le débiteur l'exécute volontairement, il ne peut obtenir la restitution de ce qu'il a payé : l'article 1235, alinéa 2, du Code civil dispose que la répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. Et si le débiteur s'engage à l'exécuter, la jurisprudence française décide que cet engagement unilatéral transforme l'obligation naturelle en obligation civile, dont l'exécution peut alors être exigée (rubrique 6).

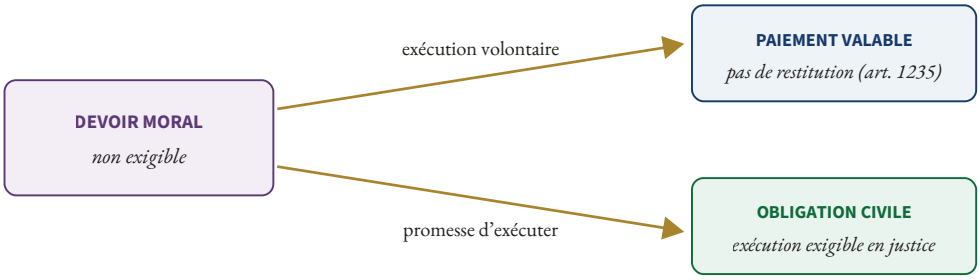


Schéma 1 — L'obligation naturelle : du devoir moral à l'obligation juridique

C. L'ordre public et les bonnes mœurs, limites de la liberté contractuelle

La liberté contractuelle permet aux personnes de créer entre elles des règles ; mais elle trouve sa limite dans l'ordre public et les bonnes mœurs (C. civ., art. 6). Le contrat dont la cause est illicite — c'est-à-dire prohibée par la loi, contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public (C. civ., art. 1133) — est nul. Par ce mécanisme, des exigences morales et sociales deviennent des conditions de validité des actes juridiques.

L'ordre public a lui-même un contenu évolutif. Au-delà de l'**ordre public politique** (protection de l'État, de la famille, des bonnes mœurs), le droit contemporain connaît un **ordre public économique**, de direction ou de protection, qui encadre les contrats pour orienter l'économie ou protéger la partie faible (salarié, consommateur). La jurisprudence administrative française a, par ailleurs, intégré le **respect de la dignité de la personne humaine** parmi les composantes de l'ordre public (rubrique 6).

D. La neutralité de l'État et ses conséquences

La laïcité impose à l'État une double obligation : ne pas s'identifier à une religion et garantir la liberté de toutes. Elle a des conséquences juridiques précises :

- les autorités religieuses n'exercent aucune fonction juridique en tant que telles ; un mariage religieux ne produit pas les effets du mariage civil ;
- les règles religieuses ne peuvent être imposées par l'État à ceux qui n'y adhèrent pas ;
- la liberté de manifester sa religion peut être limitée, dans les conditions prévues par la loi, pour des motifs d'ordre public.

5. Étude des textes applicables

A. Les textes ivoiriens

Tableau 2 — Textes ivoiriens organisant les rapports du droit avec la morale et la religion

Texte	Contenu	Rapport avec les autres systèmes normatifs
Const., art. 178	La laïcité de l'État figure parmi les principes qui ne peuvent faire l'objet d'une révision	Séparation du droit et de la religion
C. civ., art. 6	Interdiction de déroger aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs	Réception de la morale sociale
C. civ., art. 1133	Illicéité de la cause contraire à la loi, aux bonnes mœurs ou à l'ordre public	Nullité des contrats immoraux
C. civ., art. 1134, al. 3	Les conventions doivent être exécutées de bonne foi	Exigence morale de loyauté
C. civ., art. 1135	Les conventions obligent aux suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation	Réception de l'équité et des usages
C. civ., art. 1235, al. 2	Pas de répétition des obligations naturelles volontairement acquittées	Effets juridiques du devoir moral
Loi n° 2019-570 du 26 juin 2019 relative au mariage	Le mariage est l'union d'un homme et d'une femme célébrée devant l'officier de l'état civil	Primauté du mariage civil sur les célébrations religieuses et coutumières

B. Les textes régionaux et africains

La **Charte africaine des droits de l'homme et des peuples** occupe une place originale dans ce débat. D'une part, elle garantit la liberté de conscience et de religion, sous réserve de l'ordre public (art. 8). D'autre part, elle fait de « la promotion et la protection de la morale et des valeurs traditionnelles reconnues par la Communauté » un devoir de l'État (art. 17, al. 3), et impose à l'individu le devoir de veiller à la préservation et au renforcement des valeurs culturelles africaines positives (art. 29). La Charte intègre ainsi explicitement la morale et les valeurs traditionnelles dans le champ du droit, ce qui distingue la conception africaine des droits de l'homme d'une conception strictement individualiste. Cette intégration est cependant encadrée : seules les valeurs « positives » sont protégées, et le Protocole à la Charte relatif aux droits des femmes en Afrique, adopté à Maputo le 11 juillet 2003, impose aux États d'éliminer les pratiques traditionnelles néfastes et de garantir l'égalité dans le mariage.

L'**Acte uniforme OHADA relatif au droit de l'arbitrage** permet aux arbitres de statuer en amiable compositeur lorsque les parties leur ont conféré ce pouvoir : l'équité devient alors le critère de la décision, par la volonté des parties.

DROIT COMPARÉ —

Plusieurs États d'Afrique de l'Ouest ont adopté, pour leur droit de la famille, des solutions qui ménagent une place aux normes religieuses. Le Sénégal s'est doté en 1972 d'un Code de la famille unifié qui organise toutefois des options, notamment entre monogamie et polygamie, et comporte des règles successorales de droit musulman applicables à certaines conditions. Au Mali, l'adoption d'un Code des personnes et de la famille, votée une première fois en 2009, a suscité une forte contestation d'organisations religieuses et a abouti, en 2011, à un texte révisé plus proche des normes religieuses et coutumières. La Côte d'Ivoire a fait, dès 1964, le choix d'un droit civil unifié et laïque, confirmé en 2019.

6. Analyse de jurisprudences vérifiables

Jurisprudence — Cass. 1re civ. (France), 10 octobre 1995, n° 93-20.300, Bull. civ. I, n° 352

Faits. Un joueur, ayant gagné au jeu grâce à une collaboration, s'était engagé à partager ses gains avec la personne qui l'avait aidé, puis avait refusé d'exécuter son engagement.

Question. L'engagement d'exécuter une obligation naturelle est-il juridiquement obligatoire ?

Solution. La Cour de cassation juge que la transformation, improprement qualifiée de novation, d'une obligation naturelle en obligation civile repose sur un **engagement unilatéral** d'exécuter l'obligation naturelle ; l'engagement pris envers la personne qui avait contribué au gain est donc obligatoire.

Portée. L'arrêt clarifie le fondement de la transformation de l'obligation naturelle : non une novation, mais la volonté unilatérale du débiteur qui s'engage à exécuter son devoir moral. Le raisonnement, fondé sur des dispositions du Code civil communes aux droits français et ivoirien dans leur rédaction antérieure à la réforme française de 2016, est transposable en droit ivoirien sous réserve de l'appréciation des juridictions ivoiriennes.

Jurisprudence — CE (France), ass., 27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge

Faits. Un maire avait interdit un spectacle de « lancer de nain », dans lequel une personne de petite taille, consentante et rémunérée, était projetée par des spectateurs.

Question. Le respect de la dignité de la personne humaine peut-il justifier une mesure de police, en l'absence de trouble matériel à l'ordre public et malgré le consentement de l'intéressé ?

Solution. Le Conseil d'État juge que le respect de la dignité de la personne humaine est une **composante de l'ordre public** et que l'autorité de police peut, même en l'absence de circonstances locales particulières, interdire une attraction qui y porte atteinte.

Portée. L'arrêt intègre une exigence morale fondamentale — la dignité — dans une notion juridique — l'ordre public —, en la rendant opposable au consentement même de la personne concernée. Il illustre le mécanisme de réception de la morale par les notions-cadres, et le débat sur la limite entre protection de la dignité et paternalisme.

Jurisprudence — Cass. ass. plén. (France), 29 octobre 2004, n° 03-11.238

Question. Une libéralité consentie à l'occasion d'une relation adultère est-elle nulle comme contraire aux bonnes mœurs ?

Solution. L'Assemblée plénière juge que n'est pas nulle comme ayant une cause contraire aux bonnes mœurs la libéralité consentie à l'occasion d'une relation adultère.

Portée. L'arrêt témoigne de l'évolution du contenu des bonnes mœurs : un comportement que la morale sociale réprouvait hier n'entraîne plus la nullité des actes qui s'y rattachent. Il montre que les notions-cadres sont des instruments d'adaptation du droit à l'évolution des mœurs, ce qui pose la question du rôle du juge dans la détermination de la morale sociale.

Jurisprudence — Cour ADHP, 11 mai 2018, Association pour le progrès et la défense des droits des femmes maliennes (APDF) et Institute for Human Rights and Development in Africa (IHRDA) c. République du Mali, requête n° 046/2016

Faits. Deux organisations contestaient plusieurs dispositions du Code malien des personnes et de la famille de 2011, adopté après la contestation religieuse évoquée plus haut, notamment l'âge minimum du mariage des filles, les conditions du consentement au mariage et les règles successorales renvoyant aux règles religieuses et coutumières.

Solution. La Cour africaine juge que plusieurs de ces dispositions méconnaissent les obligations du Mali au titre du Protocole de Maputo, de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant et de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, et ordonne à l'État de modifier sa législation.

Portée. L'arrêt fixe une limite juridique à la réception des normes religieuses et coutumières par le droit étatique : les engagements internationaux de l'État en matière de droits de l'homme s'imposent au législateur, y compris lorsque celui-ci entend tenir compte des convictions religieuses de la population. Il éclaire, par contraste, le choix ivoirien d'un droit de la famille unifié.

7. Présentation des débats doctrinaux

A. Le droit doit-il imposer la morale ?

DÉBAT DOCTRINAL — LE DÉBAT HART–DEVLIN SUR L'IMPOSITION DE LA MORALE

Le contexte. En 1957, le rapport Wolfenden recommanda, au Royaume-Uni, de dépénaliser l'homosexualité entre adultes consentants, au motif qu'il existe un domaine de moralité privée qui n'est pas l'affaire du droit.

La thèse de Devlin. Le juge Patrick Devlin soutint qu'une société est constituée par une communauté d'idées morales partagées ; que la désagrégation de cette morale commune menace la société elle-même ; et que le droit est donc fondé à sanctionner les comportements qui heurtent profondément la conscience morale collective, même s'ils ne causent pas de dommage à autrui[4] DOC.

La thèse de Hart. Herbert Hart lui opposa, dans la lignée de John Stuart Mill et de son « principe du préjudice »[5], que le droit ne doit intervenir que pour prévenir un dommage à autrui ; que la réprobation majoritaire ne suffit pas à justifier une contrainte ; et que la société survit à l'évolution de ses idées morales[6] DOC.

Prolongements. Le débat demeure actuel en Afrique, où la protection des « valeurs traditionnelles » et de la « morale publique » est fréquemment invoquée pour justifier des incriminations ou des restrictions aux libertés, alors que les instruments régionaux de protection des droits de l'homme exigent que les restrictions soient prévues par la loi, nécessaires et proportionnées. L'article 17, alinéa 3, de la Charte africaine peut être lu dans le sens de Devlin ; les exigences d'égalité et de non-discrimination de la même Charte appellent une lecture restrictive.

B. La laïcité : séparation ou reconnaissance ?

Deux conceptions de la laïcité s'opposent dans la doctrine. Une conception **séparatiste** insiste sur l'étanchéité entre l'État et les religions, et sur la neutralité stricte de l'espace public. Une conception **de reconnaissance** ou de coopération insiste sur la garantie positive de la liberté religieuse et admet des formes de collaboration entre l'État et les confessions, dans le respect de l'égalité. La Côte d'Ivoire, dont la vie sociale fait une large place aux communautés religieuses — sollicitées notamment dans les processus de médiation et de réconciliation —, paraît pratiquer une laïcité de la seconde sorte, tout en maintenant fermement l'unité et la neutralité du droit civil.

4. P. Devlin, *The Enforcement of Morals*, Oxford University Press, 1965.
5. J. S. Mill, *De la liberté* (*On Liberty*), 1859.
6. H. L. A. Hart, *Law, Liberty and Morality*, Oxford University Press, 1963.

PROPOSITION DE L'AUTEUR — UNE LAÏCITÉ DE GARANTIE

La laïcité ivoirienne gagnerait à être comprise comme une **laïcité de garantie** : neutralité du droit et des institutions, qui ne reconnaissent d'effets juridiques qu'aux actes accomplis selon les formes légales; garantie active de la liberté religieuse de tous; refus que le droit étatique sanctionne une norme religieuse comme telle. Cette conception explique que la loi de 2019 ait cessé de prohiber la dot sans pour autant lui conférer d'effet juridique sur la validité du mariage : l'État laisse à la sphère sociale et religieuse ce qui ne relève pas de sa mission, sans abdiquer l'unité du droit civil PP.

8. Illustrations pratiques

Le mariage religieux sans mariage civil. De nombreux couples s'unissent selon les rites religieux ou coutumiers sans célébrer de mariage civil. Juridiquement, ils ne sont pas mariés : ils ne bénéficient ni des droits et devoirs du mariage, ni de la vocation successorale du conjoint survivant, ni du régime matrimonial. Le juriste consulté par une personne qui se croit « mariée » doit lui expliquer cette situation et rechercher les mécanismes de droit commun susceptibles de la protéger (libéralités, preuve d'une contribution à l'acquisition de biens, règles générales des obligations).

La dot après 2019. La pratique de la dot n'est plus prohibée par la loi depuis la réforme de 2019. Elle n'est pas pour autant une condition de validité du mariage civil, qui demeure régi par la loi. Le juriste doit éviter deux erreurs symétriques : croire que la dot serait toujours illicite, ou croire qu'elle conditionnerait désormais la validité du mariage.

L'arbitre amiable compositeur. Dans un contrat commercial, les parties stipulent une clause compromissoire qui confère à l'arbitre le pouvoir de statuer en amiable compositeur. L'arbitre pourra alors écarter l'application stricte d'une règle supplétive dont le résultat lui paraîtrait inéquitable, en motivant sa décision au regard de l'équité, sans pouvoir toutefois méconnaître l'ordre public.

La déontologie professionnelle. Un médecin qui manque à une règle de déontologie consacrée par un code de déontologie adopté par voie réglementaire s'expose à des sanctions disciplinaires prononcées par l'instance ordinale : la règle déontologique est alors devenue une règle juridique.

9. Cas pratiques corrigés

Cas pratique n° 1 — La promesse de l'héritier

Énoncé. M. Yao est décédé en laissant une dette envers son ami M. Bamba, qui lui avait prêté de l'argent sans écrit. L'action en paiement de M. Bamba est aujourd'hui prescrite. Le fils de M. Yao, Kouassi, informé de cette dette, écrit à M. Bamba : « Par respect pour la mémoire de mon père, je m'engage à vous rembourser la somme qu'il vous devait, en dix mensualités. » Après avoir versé deux mensualités, Kouassi cesse ses paiements et demande la restitution des sommes versées. Qu'en pensez-vous ?

CORRIGÉ

Problèmes de droit. (1) Kouassi peut-il obtenir la restitution des sommes versées ? (2) M. Bamba peut-il exiger le paiement du solde ?

Règles applicables. Une dette prescrite subsiste à l'état d'obligation naturelle : son exécution ne peut être exigée en justice, mais l'article 1235, alinéa 2, du Code civil exclut la répétition des obligations naturelles volontairement acquittées. Par ailleurs, selon une jurisprudence française fondée sur les mêmes dispositions (Cass. 1re civ., 10 octobre 1995), l'engagement unilatéral d'exécuter une obligation naturelle la transforme en obligation civile.

Application. (1) Les deux mensualités ont été versées volontairement, en exécution d'un devoir moral reconnu par l'intéressé ; la restitution est exclue. (2) La lettre de Kouassi exprime de manière claire et non équivoque sa volonté de s'engager à payer ; elle constitue un engagement unilatéral qui a transformé l'obligation naturelle en obligation civile. M. Bamba peut donc en demander l'exécution, la lettre constituant un écrit utile à la preuve.

Conclusion. Kouassi ne peut obtenir la restitution des sommes versées et peut être contraint de payer le solde, sous réserve de l'appréciation par le juge ivoirien de la portée de l'engagement et de la reprise par celui-ci du raisonnement de la jurisprudence française.

Cas pratique n° 2 — La « veuve » de l'union religieuse

Énoncé. Mme Diarra a vécu vingt ans avec M. Touré, qu'elle avait épousé selon les rites religieux, sans mariage civil. M. Touré vient de décéder. Ses frères entendent recueillir l'ensemble de ses biens, dont la maison familiale construite pendant la vie commune. Mme Diarra soutient qu'en sa qualité d'épouse, elle a des droits dans la succession. Conseillez-la.

CORRIGÉ

Problème de droit. Une personne unie selon les seuls rites religieux peut-elle revendiquer la qualité de conjoint survivant ?

Règles applicables. En droit ivoirien, le mariage est l'union d'un homme et d'une femme célébrée devant l'officier de l'état civil (loi n° 2019-570 du 26 juin 2019). Seul le mariage civil produit les effets juridiques du mariage, notamment la vocation successorale du conjoint survivant prévue par la loi relative aux successions. Une union religieuse ou coutumière, si respectable soit-elle socialement, ne confère pas la qualité de conjoint.

Application. Mme Diarra ne peut revendiquer la qualité de conjoint survivant. Elle n'est pas pour autant dépourvue de tout recours. Elle peut rechercher : l'existence d'un testament ou d'une libéralité en sa faveur ; la preuve de sa propre contribution au financement de la maison, qui pourrait fonder une demande de remboursement ou la reconnaissance d'un droit de copropriété selon les règles du droit commun ; le cas échéant, l'existence d'un titre de propriété établi à son nom ou aux deux noms.

Conclusion. Mme Diarra n'a pas de vocation successorale légale. Sa protection passe par les mécanismes du droit commun des biens et des obligations, dont la mise en œuvre dépendra des preuves qu'elle pourra réunir. Ce cas illustre l'intérêt pratique de la célébration du mariage civil.

Cas pratique n° 3 — L'arbitre qui juge en équité

Énoncé. Une société ivoirienne et une société sénégalaise ont soumis leur litige à un arbitre selon l'Acte uniforme OHADA relatif au droit de l'arbitrage, sans lui conférer le pouvoir de statuer en amiable compositeur. L'arbitre écarte l'application d'une clause du contrat qu'il juge « inéquitable », en se fondant exclusivement sur l'équité. La partie perdante peut-elle contester la sentence ?

CORRIGÉ

Problème de droit. L'arbitre peut-il statuer en équité sans y avoir été autorisé par les parties ?

Règle applicable. L'arbitre tranche le litige conformément aux règles de droit désignées par les parties ou, à défaut, choisies par lui ; il ne peut statuer en amiable compositeur que si les parties lui ont conféré ce pouvoir. L'arbitre qui statue en équité sans y avoir été autorisé méconnaît sa mission, ce qui constitue un cas d'annulation de la sentence prévu par l'Acte uniforme.

Application. L'arbitre a fondé sa décision exclusivement sur l'équité pour écarter une clause contractuelle, sans habilitation des parties. Il a ainsi statué sans se conformer à sa mission.

Conclusion. La partie perdante peut exercer un recours en annulation contre la sentence, en invoquant le non-respect par l'arbitre de sa mission, devant la juridiction compétente selon l'Acte uniforme.

10. Synthèse et connaissances essentielles

SYNTHÈSE — CONNAISSANCES ESSENTIELLES

- Le droit coexiste avec d'autres **systèmes normatifs** : morale, religion, mœurs et bienséance, équité, normes techniques et déontologiques, ordres non étatiques.
- Le droit se distingue de la **morale** par sa finalité (ordre social), son objet (conduites extérieures), sa source (autorités habilitées) et sa sanction (organisée) ; mais leurs domaines se recoupent.
- Le droit **reçoit** des exigences morales par les notions-cadres (bonnes mœurs, ordre public, bonne foi, équité) et par l'**obligation naturelle**, qui produit des effets juridiques lorsqu'elle est exécutée ou promise.
- Dans un **État laïque** comme la Côte d'Ivoire (Const., art. 178), la norme religieuse n'a pas d'autorité juridique propre ; seul le mariage civil produit les effets du mariage.
- L'**équité** n'est appliquée par le juge que par délégation de la loi ; l'arbitre ne statue en amiable compositeur que si les parties l'y ont autorisé.
- La **Charte africaine** intègre la morale et les valeurs traditionnelles dans les devoirs de l'État (art. 17, al. 3), dans les limites que fixent l'égalité et le Protocole de Maputo.
- Le débat **Hart–Devlin** pose la question de la légitimité de l'imposition de la morale par le droit.

11. Questions d'évaluation

QUESTIONS D'ÉVALUATION

Questions de cours

1. Quels sont les critères de distinction du droit et de la morale ? Sont-ils absolus ?
2. Qu'est-ce qu'une obligation naturelle ? Quels en sont les effets ?
3. Par quels mécanismes le droit reçoit-il des exigences morales ?
4. Quelles sont les conséquences juridiques de la laïcité de l'État ivoirien ?
5. Dans quelles conditions un juge ou un arbitre peut-il statuer en équité ?

Questions de réflexion

1. La réforme ivoirienne de 2019, en cessant de prohiber la dot, a-t-elle fait reculer le droit au profit de la coutume ?
2. Comment concilier l'article 17, alinéa 3, de la Charte africaine et le principe d'égalité ?

Sujets de dissertation

1. « Droit et morale en droit ivoirien. »
2. « Le droit doit-il imposer la morale ? »
3. « La laïcité, principe d'organisation du droit ivoirien. »

Commentaire

1. Commentez l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples du 11 mai 2018, *APDF et IHRDA c. Mali*.

12. Références bibliographiques

Ouvrages généraux

J. Carbonnier, *Droit civil. Introduction*, PUF, coll. « Thémis », dernière éd.

F. Terré, *Introduction générale au droit*, Dalloz, coll. « Précis », dernière éd.

Ouvrages spéciaux

G. Ripert, *La règle morale dans les obligations civiles*, LGDJ, 4e éd., 1949.

E. Kant, *Métaphysique des mœurs*, 1797 (trad. A. Renaut, GF-Flammarion).

H. L. A. Hart, *Law, Liberty and Morality*, Oxford University Press, 1963.

P. Devlin, *The Enforcement of Morals*, Oxford University Press, 1965.

J. S. Mill, *De la liberté*, 1859 (trad. fr., Gallimard, coll. « Folio essais »).

Conseil d'État, *Le droit souple*, Étude annuelle 2013, La Documentation française, 2013.

Droit africain

K. Mbaye, *Les droits de l'homme en Afrique*, Pedone, 2e éd., 2002.

K. Mbaye (dir.), *Le droit de la famille en Afrique noire et à Madagascar*, Maisonneuve et Larose, 1968.

Sources officielles

Constitution du 8 novembre 2016 ; loi n° 2019-570 du 26 juin 2019 relative au mariage ; Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (1981) ; Protocole à la Charte africaine relatif aux droits des femmes en Afrique (Maputo, 11 juillet 2003) ; Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage (23 novembre 2017).

CHAPITRE 3

Les fondements du droit (I) : droit naturel et positivisme juridique

« Est quidem vera lex recta ratio, naturae congruens... »

— Cicéron, De re publica, III, 22

1. Introduction et problématique

Pourquoi obéit-on au droit ? La question paraît naïve ; elle est en réalité l'une des plus anciennes et des plus difficiles de la pensée juridique. On peut obéir par crainte de la sanction, par habitude, par intérêt, par adhésion aux valeurs que la règle exprime. Mais la question du **fondement** du droit est plus précise : elle demande ce qui confère à une règle sa force obligatoire et sa légitimité, ce qui la rend *due* et non seulement *imposée*.

Deux grandes réponses se sont affrontées dans l'histoire de la pensée. Selon le **jusnaturalisme** (ou doctrine du droit naturel), il existe, au-dessus des règles posées par les hommes, un droit supérieur, fondé sur la nature, la raison ou la volonté divine, qui fournit le critère de la justice des lois et peut, dans les cas extrêmes, les priver de leur caractère de droit. Selon le **positivisme juridique**, le droit est l'ensemble des règles effectivement posées par les autorités habilitées d'une société ; son existence et sa validité ne dépendent pas de sa conformité à une morale ou à une justice supérieure, même si l'on peut et doit le juger moralement.

La question n'est pas d'école. Elle se pose chaque fois qu'un juge est confronté à une loi qu'il estime injuste, chaque fois qu'une société sortant d'un régime autoritaire ou d'un conflit doit juger les actes accomplis sous l'empire de règles iniques, chaque fois qu'un ordre constitutionnel est rompu et qu'il faut déterminer le fondement du nouvel ordre. L'histoire constitutionnelle récente de la Côte d'Ivoire en offre des illustrations saisissantes.

Problématique. *Le fondement du droit réside-t-il dans une norme de justice supérieure aux volontés humaines, ou dans la seule volonté des autorités que l'ordre juridique habilite ?* Le chapitre montrera que l'opposition, nette dans ses principes, s'est atténuée dans les ordres juridiques contemporains : le positivisme fournit la **méthode** d'identification du droit valide,

tandis que les exigences du droit naturel ont été en grande partie **incorporées** dans le droit positif lui-même, sous la forme de droits fondamentaux garantis par des constitutions et des traités, et contrôlés par des juges.

2. Fondements historiques et théoriques

A. Le jusnaturalisme classique

Antigone. Le premier témoignage littéraire du conflit entre loi positive et droit supérieur se trouve dans l'*Antigone* de Sophocle (Ve siècle av. J.-C.). Le roi Créon interdit qu'on donne une sépulture à Polynice, mort en combattant sa cité ; sa sœur Antigone brave l'interdiction au nom des lois non écrites et immuables des dieux, qu'aucun décret humain ne saurait abolir. La tragédie pose, dès l'origine, l'alternative entre l'obéissance à la loi de la cité et la fidélité à une justice supérieure.

Aristote. Le philosophe distingue, au sein du juste politique, le **juste naturel**, qui a partout la même force et ne dépend pas de l'opinion, et le **juste légal**, qui à l'origine peut être indifféremment ainsi ou autrement, mais qui, une fois établi, s'impose[1]. Pour Aristote, le droit naturel n'est pas un code de règles immuables, mais la juste proportion que le juriste découvre dans l'observation de la nature des choses et des rapports sociaux.

Les stoïciens et Cicéron. Les stoïciens fondent le droit naturel sur la raison universelle qui gouverne le monde et que partagent tous les hommes. Cicéron en donne une formule célèbre : la vraie loi est la droite raison, conforme à la nature, répandue en tous, constante et éternelle ; elle ne peut être abrogée ni par le Sénat ni par le peuple[2].

La pensée chrétienne. Saint Augustin affirme qu'une loi qui n'est pas juste ne paraît pas être une loi, formule que la tradition a résumée dans l'adage *lex iniusta non est lex*. Thomas d'Aquin construit, au XIIIe siècle, une hiérarchie des lois : la **loi éternelle**, plan divin qui gouverne l'univers ; la **loi naturelle**, participation de la créature raisonnable à la loi éternelle ; la **loi humaine**, qui dérive de la loi naturelle par conclusion ou par détermination ; la **loi divine** révélée. Il définit la loi comme une ordonnance de la raison en vue du bien commun, promulguée par celui qui a la charge de la communauté, et enseigne qu'une loi humaine contraire à la loi naturelle n'est plus une loi, mais une corruption de la loi[3].

1. Aristote, *Éthique à Nicomaque*, livre V, chap. 7.
2. Cicéron, *De re publica*, III, 22.
3. Thomas d'Aquin, *Somme théologique*, Ia-IIae, q. 90 à 97.

B. L'École moderne du droit naturel

Aux XVIIe et XVIIIe siècles, l'**École du droit de la nature et des gens** sécularise le droit naturel en le fondant sur la seule raison humaine. Hugo Grotius, dans son traité *Du droit de la guerre et de la paix* (1625), soutient que le droit naturel conserverait sa validité même si l'on admettait — ce qui ne se peut sans crime, précise-t-il — que Dieu n'existe pas. Samuel Pufendorf, John Locke et Jean-Jacques Rousseau développent, à partir de l'hypothèse d'un état de nature, la théorie des **droits naturels** de l'individu (vie, liberté, propriété) et du **contrat social** par lequel les hommes instituent un pouvoir politique chargé de les garantir.

Cette pensée a eu une influence décisive sur le droit positif. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 proclame les « droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme » et affirme que le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme (art. 2). Le Code civil de 1804 lui-même s'inscrit dans cette tradition : Portalis voit dans les lois positives la mise en œuvre de principes de justice et de raison.

C. Le positivisme juridique

Le positivisme juridique naît, au XIXe siècle, d'une réaction contre l'idée d'un droit supérieur dont le contenu, toujours discuté, paraissait offrir une arme à l'arbitraire des juges et un prétexte à la désobéissance.

Hobbes et Bentham. Thomas Hobbes, dès le XVIIe siècle, avait affirmé que c'est l'autorité, et non la vérité, qui fait la loi. Jeremy Bentham, réformateur utilitariste, qualifie les droits naturels de « non-sens monté sur des échasses » et entend distinguer rigoureusement le droit tel qu'il est (objet d'une science descriptive) et le droit tel qu'il devrait être (objet d'une science de la législation fondée sur le principe d'utilité). John Austin, son disciple, définit le droit comme un ensemble de commandements du souverain assortis de sanctions.

L'École de l'exégèse. En France, les commentateurs du Code civil, au XIXe siècle, pratiquent un **positivisme légaliste** : le droit est dans la loi, et l'interprète doit rechercher la volonté du législateur. Une formule attribuée au juriste Bugnet résume cet état d'esprit : il ne connaîtrait pas le droit civil, il n'enseignerait que le Code Napoléon.

Kelsen. Hans Kelsen donne au positivisme sa forme la plus rigoureuse. Sa **théorie pure du droit** entend décrire le droit en le purifiant de tout élément étranger : morale, politique, sociologie. Le droit est un ordre de normes ; une norme est valide si elle a été produite conformément à une norme supérieure ; la chaîne de validité remonte jusqu'à la Constitution historiquement première, dont la validité repose sur une **norme fondamentale** (*Grundnorm*) supposée par la pensée juridique, qui prescrit d'obéir à cette Constitution. Le contenu des

normes est indifférent à leur validité : selon Kelsen, tout contenu quelconque peut être du droit.

Hart. Herbert Hart renouvelle le positivisme en le libérant de la théorie du commandement. Un système juridique est l'union de **règles primaires**, qui imposent des obligations, et de **règles secondaires**, qui permettent d'identifier, de modifier et d'appliquer les règles primaires. La plus importante des règles secondaires est la **règle de reconnaissance**, qui fixe les critères de validité des autres règles et dont l'existence est un fait social : la pratique concordante des officiels (juges, administrateurs) qui l'acceptent d'un **point de vue interne**, comme un standard de conduite.

D. Le renouveau du droit naturel après 1945

Les crimes commis sous l'empire de législations criminelles, en particulier sous le régime national-socialiste, ont provoqué un renouveau des doctrines du droit naturel. En 1946, le juriste allemand Gustav Radbruch, longtemps positiviste, formule une thèse restée célèbre sous le nom de **formule de Radbruch** : la loi positive l'emporte en principe, même lorsqu'elle est injuste et inopportune, sauf lorsque sa contradiction avec la justice atteint un degré si insupportable que la loi doit céder devant la justice ; et là où l'égalité, noyau de la justice, est délibérément niée, la loi n'est pas seulement du « droit injuste » : elle n'a aucune nature juridique[4].

Le procès de Nuremberg, la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 et l'adoption de constitutions fondées sur la dignité humaine traduisent ce retour à l'idée qu'il existe des exigences de justice que nul législateur ne peut méconnaître. Lon Fuller soutient, de son côté, que le droit possède une « moralité interne » : une législation qui méconnaît massivement certaines exigences — généralité, publicité, non-rétroactivité, clarté, cohérence, possibilité d'exécution, stabilité, concordance entre les règles et l'action des autorités — cesse d'être un système juridique[5]. Michel Villey, enfin, invite à revenir au droit naturel classique d'Aristote, conçu comme recherche du juste partage des biens, contre les droits subjectifs abstraits de la modernité[6].

4. G. Radbruch, « Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht » (« Injustice légale et droit supralégal »), 1946.
5. L. L. Fuller, *The Morality of Law*, Yale University Press, 1964.
6. M. Villey, *Le droit et les droits de l'homme*, PUF, 1983 ; *Philosophie du droit*, Dalloz.

3. Explication approfondie des concepts

A. Le droit naturel

> **DÉFINITION — DROIT NATUREL**
>
> Ensemble de principes de justice supposés antérieurs et supérieurs au droit posé par les autorités humaines, fondés selon les doctrines sur la nature des choses, la nature humaine, la raison ou la volonté divine, et constituant le critère de la légitimité du droit positif.

Le terme recouvre des doctrines très différentes, qu'il faut se garder de confondre :

- le **droit naturel cosmologique** des Anciens, découvert dans l'ordre de la nature et des choses ;
- le **droit naturel théologique**, fondé sur la volonté ou la sagesse divine ;
- le **droit naturel rationaliste** des modernes, déduit de la raison humaine et centré sur les droits de l'individu ;
- le **droit naturel à contenu variable**, selon la formule de Rudolf Stammler, qui admet que l'idéal de justice demeure tandis que son contenu concret varie avec les époques et les sociétés.

B. Le positivisme juridique

> **DÉFINITION — POSITIVISME JURIDIQUE**
>
> Doctrine selon laquelle le droit est constitué exclusivement des règles posées (*positum*) par les autorités habilitées d'une société et identifiables par des critères tenant à leur source, sans que leur existence ou leur validité dépende de leur conformité à une morale ou à une justice supérieure.

Le philosophe italien Norberto Bobbio a montré que le terme recouvre trois choses distinctes[7] :

1. une **approche** (ou méthode) : étudier le droit tel qu'il est, en le distinguant du droit tel qu'il devrait être ;
2. une **théorie** : le droit est un ensemble de normes posées par l'État, dotées de la contrainte, et organisées en système complet et cohérent ;

7. N. Bobbio, *Giusnaturalismo e positivismo giuridico*, Milan, Edizioni di Comunità, 1965 ; v. aussi N. Bobbio, *Essais de théorie du droit*, trad. M. Guéret et Ch. Agostini, Bruylant-LGDJ, 1998.

3. une **idéologie** : le droit positif, parce qu'il est posé, doit être obéi.

Cette distinction est capitale : on peut adopter le positivisme comme méthode sans adhérer au positivisme comme idéologie. La plupart des positivistes contemporains — Kelsen, Hart — rejettent expressément l'idée qu'il y aurait une obligation morale d'obéir à toute loi valide. Leur thèse est seulement que la validité juridique et la valeur morale sont deux questions distinctes, et que confondre les deux obscurcit à la fois l'analyse du droit et sa critique.

C. Validité, légitimité et justice

Tableau 1 — Validité, légitimité, justice, effectivité

Notion	Question posée	Critère	Discipline
Validité	La norme appartient-elle à l'ordre juridique ?	Conformité aux normes de production (compétence, procédure, hiérarchie)	Théorie du droit, droit positif
Légitimité	La norme ou l'autorité qui l'édicte est-elle acceptée comme fondée à commander ?	Adhésion des destinataires, conformité à des principes de légitimation (démocratie, tradition)	Science politique, sociologie
Justice	La norme est-elle juste ?	Conformité à un idéal (égalité, dignité, utilité, équité)	Philosophie du droit, morale
Effectivité	La norme est-elle appliquée ?	Observation des comportements	Sociologie du droit

Les deux grandes doctrines s'opposent principalement sur le rapport entre validité et justice : pour le jusnaturaliste strict, une norme gravement injuste n'est pas valide ; pour le positiviste, elle peut être valide et injuste.

4. Analyse des principes et mécanismes juridiques

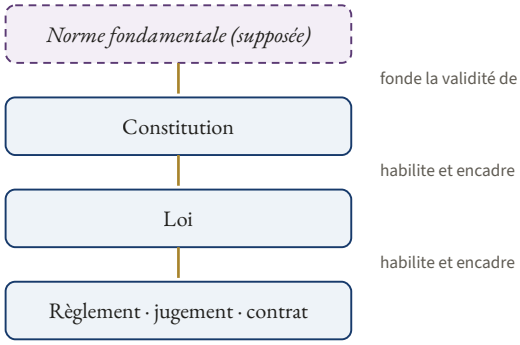
A. Le mécanisme positiviste d'identification du droit valide

Dans une perspective positiviste, l'identification d'une règle de droit valide obéit à une méthode précise, que pratique quotidiennement tout juriste, quelle que soit sa philosophie :

1. identifier l'**auteur** de la règle et vérifier sa **compétence** (le Parlement est-il compétent dans cette matière en vertu de l'article 101 de la Constitution ?) ;
2. vérifier le respect de la **procédure** d'édiction (vote, promulgation, publication) ;
3. vérifier la **conformité aux normes supérieures** (Constitution, traités, actes uniformes) ;

4. vérifier que la règle est **en vigueur** (non abrogée, entrée en vigueur).

Cette méthode renvoie de norme en norme jusqu'à la Constitution. Au-delà, la question du fondement de la Constitution elle-même ne peut plus recevoir de réponse juridique interne : Kelsen la résout par l'hypothèse de la norme fondamentale, Hart par le constat de la règle de reconnaissance effectivement pratiquée.



Chaque norme est valide parce qu'elle a été produite conformément à la norme supérieure.

Schéma 1 — La chaîne de validité selon la théorie pure du droit

B. La « positivation » des exigences du droit naturel

Le trait le plus remarquable du droit contemporain est que les exigences traditionnellement rattachées au droit naturel ont été en grande partie **incorporées dans le droit positif** :

- les **déclarations de droits** et les **titres constitutionnels** consacrés aux droits et libertés (Titre Ier de la Constitution ivoirienne de 2016) transforment des droits « naturels » en droits constitutionnels ;
- le **contrôle de constitutionnalité** permet de sanctionner la loi qui méconnaîtrait ces droits : en Côte d'Ivoire, tout plaideur peut soulever l'exception d'inconstitutionnalité d'une loi devant toute juridiction, qui sursoit alors à statuer pour permettre la saisine du Conseil constitutionnel (Const., art. 135) ;
- les **conventions internationales** de protection des droits de l'homme, ratifiées par l'État, s'imposent à la loi (Const., art. 123 V) et sont garanties par des juridictions régionales ;
- le **droit international** connaît des normes impératives (*jus cogens*), auxquelles aucune dérogation n'est permise, et la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969 déclare nul tout traité qui, au moment de sa conclusion, est en conflit avec une telle norme (art. 53) ;

– les **limites matérielles à la révision constitutionnelle** soustraient certains principes à la volonté même du pouvoir constituant dérivé : en Côte d'Ivoire, la forme républicaine et la laïcité de l'État (Const., art. 178).

Ce mouvement modifie les termes du débat. Lorsque le juge écarte une loi contraire à la dignité humaine, il ne le fait plus au nom d'un droit naturel extérieur au système, mais en application de normes positives supérieures. Le conflit entre droit naturel et droit positif se transforme en **conflit de normes à l'intérieur du droit positif**, réglé par les mécanismes de la hiérarchie des normes (chapitre 7).

C. Le droit de résistance à l'oppression

La tradition jusnaturaliste a conduit certains textes à consacrer un **droit de résistance à l'oppression**. La Déclaration de 1789 le range parmi les droits naturels et imprescriptibles (art. 2). La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples reconnaît aux peuples colonisés ou opprimés le droit de se libérer de leur état de domination en recourant à tous moyens reconnus par la communauté internationale (art. 20, al. 2). La positivation d'un tel droit est paradoxale, puisqu'elle prétend organiser juridiquement la contestation de l'ordre juridique lui-même ; elle a surtout une portée de légitimation et de principe.

5. Étude des textes applicables

Tableau 2 — La positivation des exigences du droit naturel

Texte	Disposition	Lecture au regard du débat
Const., art. 3	« Le droit à la vie est inviolable. Nul n'a le droit d'ôter la vie à autrui. La peine de mort est abolie. »	Positivation d'un droit fondamental de tradition jusnaturaliste
Const., art. 7	Principe de légalité des délits et des peines	Exigence de la « moralité interne » du droit (Fuller)
Const., art. 123 V	Autorité supérieure des traités régulièrement ratifiés sur les lois, sous réserve de réciprocité	Réception des droits de l'homme d'origine internationale
Const., art. 135	Exception d'inconstitutionnalité soulevée par tout plaideur	Mécanisme juridictionnel de contrôle de la loi au regard des droits constitutionnels
Const., art. 178	La forme républicaine et la laïcité ne peuvent faire l'objet d'une révision	Limites matérielles au pouvoir de révision
Charte africaine, art. 20, al. 2	Droit des peuples opprimés de se libérer de la domination	Droit de résistance positivé

Texte	Disposition	Lecture au regard du débat
Convention de Vienne (1969), art. 53	Nullité des traités contraires au *jus cogens*	Normes impératives du droit international
Statut de la CIJ, art. 38, § 1, c)	Principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées	Source « supra-positive » intégrée au droit international positif

ÉTAT DU DROIT — POINT DE VIGILANCE

La numérotation de l'article de la Constitution de 2016 relatif à l'autorité des traités (art. 123) a été établie par recoupement de sources concordantes ; la disposition correspondante de la Constitution de 2000 était l'article 87. La lettre de l'article doit être vérifiée au Journal officiel avant toute citation contentieuse (v. la fiche de vérification).

6. Analyse de jurisprudences vérifiables

Jurisprudence — Cons. const. CI, décision n° CI-2011-EP-036/04-05/CC/SG du 4 mai 2011, proclamation de M. Alassane Ouattara en qualité de Président de la République

Contexte. À l'issue du second tour de l'élection présidentielle du 28 novembre 2010, la Commission électorale indépendante avait annoncé des résultats provisoires donnant la victoire à M. Alassane Ouattara ; le Conseil constitutionnel avait, le 3 décembre 2010, proclamé des résultats définitifs donnant la victoire à M. Laurent Gbagbo. La crise post-électorale qui s'ensuivit conduisit l'Union africaine, par l'intermédiaire de son Conseil de paix et de sécurité, à reconnaître l'élection de M. Ouattara et à adopter des décisions destinées à résoudre la crise.

Décision. Le 4 mai 2011, le Conseil constitutionnel rend une nouvelle décision par laquelle il fait siennes les décisions de l'Union africaine, considérées comme obligatoires pour l'État ivoirien, et proclame M. Alassane Ouattara Président de la République.

Intérêt pour la théorie du fondement du droit. La décision soulève des questions majeures. D'un point de vue strictement positiviste interne, les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours et s'imposent à tous ; la remise en cause d'une décision antérieure du même Conseil paraît difficilement conciliable avec l'autorité qui s'attache à ses décisions. La décision s'explique en revanche si l'on admet que l'ordre juridique ivoirien est intégré dans un ordre juridique international et africain dont les normes, acceptées par l'État, l'emportent sur les décisions internes ; elle s'inscrit alors dans un raisonnement de hiérarchie des normes, et non dans un appel à une justice extra-juridique. Elle illustre enfin le rôle de l'**effectivité** dans la reconstitution d'un ordre juridique après une rupture : la doctrine y a vu une décision singulière, tant dans sa forme que dans son fond[8].

Jurisprudence — Cour constitutionnelle fédérale allemande, 24 octobre 1996 (affaire dite des « gardes du Mur ») ; CEDH, gr. ch., 22 mars 2001, Streletz, Kessler et Krenz c. Allemagne

Faits. Après la réunification allemande, d'anciens dirigeants et des gardes-frontières de la République démocratique allemande furent poursuivis pour la mort de personnes abattues en tentant de franchir la frontière. Ils invoquaient le droit de la RDA, qui justifiait selon eux l'usage des armes.

Solution. Les juridictions allemandes, approuvées par la Cour constitutionnelle fédérale, écartèrent cette justification en jugeant que des règles autorisant l'usage d'armes à feu pour empêcher le franchissement de la frontière, au mépris le plus grave du droit à la vie, ne pouvaient être invoquées, en se référant notamment à la formule de Radbruch. Saisie par d'anciens dirigeants, la Cour européenne des droits de l'homme jugea que les condamnations ne violaient pas le principe de légalité des délits et des peines (art. 7 de la Convention), dès lors que la pratique étatique invoquée méconnaissait les principes mêmes du droit de la RDA et les obligations internationales relatives au droit à la vie.

Portée. Ces décisions montrent la persistance de la question du « droit injuste » dans les transitions politiques, et la manière dont les juges contemporains la traitent : en combinant l'argument jusnaturaliste (Radbruch) et le recours à des normes positives supérieures (droits fondamentaux, droit international).

Jurisprudence — Cour d'appel de New York, Riggs v. Palmer, 115 N.Y. 506 (1889)

Faits. Un petit-fils, institué légataire par son grand-père, avait empoisonné celui-ci pour hériter plus rapidement. La loi sur les testaments, prise à la lettre, ne prévoyait aucune exclusion du légataire meurtrier.

8. V. notamment les analyses publiées dans la revue en ligne *Afrilex* consacrées à cette décision.

Solution. La cour refuse au meurtrier le bénéfice du testament, en se fondant sur le principe selon lequel nul ne peut tirer profit de sa propre faute.

Portée. Ronald Dworkin a fait de cette décision l'un des arguments centraux de sa critique du positivisme de Hart : le droit ne se compose pas seulement de règles identifiables par leur source, mais aussi de **principes**, dont l'autorité tient à leur valeur morale et à leur insertion dans l'histoire institutionnelle d'une communauté[9]. Les droits de tradition civiliste connaissent des solutions comparables à travers l'indignité successorale et l'adage *nemo auditur propriam turpitudinem allegans*.

Jurisprudence — Cons. const. (France), déc. n° 71-44 DC, 16 juillet 1971, Liberté d'association

Solution. Le Conseil constitutionnel censure une loi qui soumettait la constitution des associations à un contrôle préalable, en se fondant sur les « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et réaffirmés solennellement par le préambule de la Constitution », au nombre desquels figure la liberté d'association.

Portée. La décision intègre le Préambule de la Constitution de 1958, et à travers lui la Déclaration de 1789 et le Préambule de 1946, dans les normes de référence du contrôle de constitutionnalité. Elle constitue un exemple paradigmatique de **positivation juridictionnelle** des droits naturels : des droits proclamés comme naturels deviennent des normes constitutionnelles sanctionnées par un juge.

7. Présentation des débats doctrinaux

A. Le débat Hart–Fuller

DÉBAT DOCTRINAL — FAUT-IL JUGER LES ACTES ACCOMPLIS SOUS L'EMPIRE D'UNE LOI INIQUE ?

L'affaire. En 1958, Hart et Fuller s'opposent dans la *Harvard Law Review* à propos d'une affaire jugée en Allemagne après la guerre : une femme avait dénoncé son mari aux autorités nazies pour des propos hostiles au régime, en vue de se débarrasser de lui ; condamné en application de la législation de l'époque, le mari avait été envoyé au front. Après la guerre, l'épouse fut poursuivie pour privation illégale de liberté.

La position de Hart. Pour Hart, la législation nazie était du droit, si odieuse fût-elle ; prétendre le contraire revient à brouiller l'analyse. S'il fallait punir la dénonciatrice, la voie honnête était d'adopter ouvertement une loi rétroactive, en assumant le sacrifice d'un principe

9. R. Dworkin, *Prendre les droits au sérieux*, PUF, coll. « Léviathan », 1995.

(la non-rétroactivité) au profit d'un autre (la justice). La séparation du droit et de la morale, loin d'affaiblir la critique morale du droit, la rend possible : c'est parce qu'on reconnaît une loi comme valide qu'on peut la dénoncer comme injuste et lui désobéir en connaissance de cause DOC.

La position de Fuller. Pour Fuller, un régime qui pratique les lois secrètes, la rétroactivité systématique et l'interprétation arbitraire méconnaît la « moralité interne » du droit à un point tel qu'il cesse de produire un véritable ordre juridique ; refuser la qualité de droit aux normes nazies n'est pas une confusion, mais la reconnaissance de ce que le droit implique une certaine forme de respect des personnes DOC.

Enjeux actuels. Le débat éclaire les problèmes de justice transitionnelle que connaissent les sociétés sortant de conflits ou de régimes autoritaires, en Afrique comme ailleurs : poursuite des crimes commis sous couvert de règles officielles, amnisties, commissions vérité et réconciliation.

B. Le positivisme et ses critiques contemporaines

La critique de Dworkin a conduit le positivisme à se diviser. Le **positivisme inclusif** admet que la règle de reconnaissance d'un système peut incorporer des critères moraux — par exemple lorsque la Constitution subordonne la validité des lois au respect de la dignité ou de l'égalité. Le **positivisme exclusif**, défendu notamment par Joseph Raz, maintient que l'identification du droit ne doit dépendre que de faits sociaux, les standards moraux mentionnés par la Constitution étant des directives adressées aux juges plutôt que des éléments du droit déjà existant. Le **réalisme** juridique, enfin, déplace la question vers l'activité des juges, qui fixent par leurs interprétations le sens des normes (chapitre 4).

C. L'universalité des droits de l'homme en question

Le renouveau du droit naturel sous la forme des droits de l'homme a suscité, en Afrique, un débat spécifique : ces droits sont-ils universels, ou expriment-ils une conception occidentale de la personne, individualiste et abstraite ? Kéba Mbaye a défendu une conception africaine des droits de l'homme qui en affirme l'universalité tout en intégrant les droits des peuples, les devoirs de l'individu envers la famille et la communauté, et le droit au développement[10]. La Charte africaine de 1981 traduit cette synthèse, en consacrant à la fois des droits individuels, des droits des peuples et des devoirs.

PROPOSITION DE L'AUTEUR — UN POSITIVISME MÉTHODOLOGIQUE OUVERT

Pour le juriste ivoirien, il paraît fécond d'adopter un **positivisme méthodologique** — identifier rigoureusement le droit valide par ses sources, sans le confondre avec ce qu'il devrait

être — tout en reconnaissant que la Constitution de 2016 et les engagements internationaux de l'État ont positivé les principales exigences de justice : dignité, égalité, droit à la vie, garanties du procès. La plupart des conflits que la tradition posait en termes de droit naturel contre droit positif peuvent ainsi être traités comme des conflits de normes, devant les juges compétents. Reste un résidu irréductible — les situations de rupture de l'ordre constitutionnel —, dans lequel la question du fondement du droit redevient une question de légitimité politique, que le juriste doit savoir identifier comme telle PP.

8. Illustrations pratiques

Le juge face à une loi qu'il estime injuste. Un juge ivoirien ne peut refuser d'appliquer une loi au motif qu'elle lui paraît injuste : il commettrait un déni de justice (C. civ., art. 4) et méconnaîtrait la séparation des pouvoirs. Mais si la loi lui paraît contraire à la Constitution, la voie est ouverte : il appartient au plaideur de soulever l'exception d'inconstitutionnalité, et la juridiction doit surseoir à statuer pour permettre la saisine du Conseil constitutionnel (Const., art. 135). Le grief de « justice » est ainsi canalisé vers une procédure positive.

La loi d'amnistie. Après les crises politiques, le législateur ou le gouvernement habilité adopte parfois des mesures d'amnistie, effaçant le caractère délictueux de certains faits. Le positiviste constate leur validité si elles ont été régulièrement adoptées ; le jusnaturaliste interroge leur compatibilité avec le droit des victimes à la justice. Le droit positif contemporain intègre en partie cette seconde exigence : le droit international tend à refuser l'amnistie des crimes internationaux les plus graves, et une amnistie nationale ne fait pas obstacle, en principe, à la compétence de la Cour pénale internationale, dont la complémentarité suppose des poursuites nationales effectives.

Le code de l'indigénat. Le régime de l'indigénat, en vigueur dans les colonies françaises d'Afrique jusqu'en 1946, permettait à l'administration d'infliger des sanctions sans jugement aux « sujets » pour des infractions spéciales. Il était, au regard de l'ordre juridique colonial, du droit valide. Son étude montre que la validité formelle d'un système ne garantit ni sa justice ni sa légitimité, et que la mémoire de ce régime explique la valeur attachée, dans les constitutions africaines, aux garanties du procès et à l'égalité devant la loi.

9. Cas pratiques corrigés

Cas pratique n° 1 — Le juge et la loi contestée

10. K. Mbaye, *Les droits de l'homme en Afrique*, Pedone, 2e éd., 2002.

Énoncé. Saisi d'une poursuite fondée sur une loi qui réprime pénalement, en termes très vagues, « tout comportement de nature à porter atteinte à la cohésion sociale », un tribunal correctionnel estime ce texte injuste et dangereux pour les libertés. Le président envisage de relaxer le prévenu en écartant la loi « au nom des principes supérieurs du droit ». Que lui conseillez-vous ?

CORRIGÉ

Problème de droit. Un juge ordinaire peut-il écarter l'application d'une loi qu'il estime contraire à des principes supérieurs ?

Règles applicables. Le juge est tenu de juger en application de la loi ; il ne peut refuser de le faire sous prétexte de son insuffisance (C. civ., art. 4). Le contrôle de la conformité des lois à la Constitution relève du Conseil constitutionnel ; tout plaideur peut soulever l'exception d'inconstitutionnalité devant toute juridiction, qui sursoit alors à statuer et impartit au plaideur un délai pour saisir le Conseil (Const., art. 135). Par ailleurs, le principe de légalité des délits et des peines (Const., art. 7) exige que les incriminations soient définies avec une précision suffisante.

Application. Le président ne peut écarter la loi de sa propre autorité au nom de « principes supérieurs » non identifiés. En revanche, le grief tiré de l'imprécision de l'incrimination peut être articulé en termes de droit positif : contrariété au principe de légalité. Il appartient à la défense de soulever l'exception d'inconstitutionnalité ; le tribunal devra alors surseoir à statuer. Le tribunal peut également, dans l'exercice de son office d'interprétation, retenir une interprétation stricte de la loi pénale, conformément aux principes du droit pénal.

Conclusion. La voie juridique n'est pas l'éviction de la loi par le juge, mais sa contestation devant le juge constitutionnel par la voie de l'exception, et, en attendant, son interprétation stricte.

Cas pratique n° 2 — L'ordre du supérieur

Énoncé. Lors de troubles graves, un officier ordonne à ses hommes de tirer sur une foule désarmée. Poursuivi plusieurs années plus tard, un soldat qui a exécuté l'ordre invoque l'obéissance due à son supérieur et les règlements militaires alors en vigueur. Analysez ce moyen de défense au regard des deux grandes doctrines du fondement du droit et du droit positif applicable.

CORRIGÉ

Problème de droit. L'ordre d'un supérieur, fondé sur une réglementation en vigueur, peut-il justifier un acte gravement attentatoire au droit à la vie ?

Analyse doctrinale. Pour un positivisme idéologique, l'ordre conforme à la réglementation justifierait l'acte. Pour la doctrine du droit naturel, et selon la formule de Radbruch, une règle qui autorise à tuer des personnes désarmées est si gravement contraire à la justice qu'elle ne peut justifier l'acte. Le positivisme méthodologique contemporain parvient au même résultat par une autre voie : en recherchant si la réglementation invoquée était conforme aux normes supérieures du système — Constitution, droit international.

Droit positif. Le droit à la vie est garanti par la Constitution (art. 3). Le droit pénal international refuse de faire de l'ordre hiérarchique une cause d'exonération lorsque l'ordre est manifestement illégal ; le Statut de Rome de la Cour pénale internationale pose que l'ordre de commettre un génocide ou un crime contre l'humanité est manifestement illégal. Les conditions précises de l'exonération pour commandement de l'autorité légitime en droit pénal ivoirien sont étudiées au Tome 7.

Conclusion. Le moyen de défense est voué à l'échec si l'ordre était manifestement illégal, ce qui est le cas d'un ordre de tirer sur une foule désarmée. Les affaires dites des « gardes du Mur » en offrent une illustration comparée.

10. Synthèse et connaissances essentielles

SYNTHÈSE — CONNAISSANCES ESSENTIELLES

- Le **jusnaturalisme** fonde le droit sur une justice supérieure (nature, raison, Dieu) ; dans sa forme stricte, une loi gravement injuste n'est pas du droit (*lex iniusta non est lex*).
- Le **positivisme juridique** identifie le droit par ses sources ; la validité d'une norme est indépendante de sa valeur morale. Il faut distinguer le positivisme comme **méthode**, comme **théorie** et comme **idéologie** (Bobbio).
- Pour **Kelsen**, la validité procède d'une chaîne de normes qui remonte à une **norme fondamentale** supposée ; pour **Hart**, d'une **règle de reconnaissance** pratiquée par les officiels.
- Après 1945, la **formule de Radbruch** et la « moralité interne du droit » de **Fuller** ont renouvelé la critique du positivisme ; **Dworkin** y a ajouté le rôle des **principes**.
- Le droit contemporain a **positivé** les exigences du droit naturel : droits constitutionnels, contrôle de constitutionnalité (Const., art. 135), primauté des traités (Const., art. 123), *jus cogens*, limites à la révision (Const., art. 178).
- La décision du Conseil constitutionnel ivoirien du **4 mai 2011** illustre la tension entre autorité des décisions internes, normes internationales et effectivité dans la reconstitution d'un ordre juridique.

11. Questions d'évaluation

QUESTIONS D'ÉVALUATION

Questions de cours

1. Présentez les principales formes historiques du droit naturel.
2. Quelles sont les trois significations du positivisme juridique selon Bobbio ?
3. Qu'est-ce que la norme fondamentale chez Kelsen ? Qu'est-ce que la règle de reconnaissance chez Hart ?
4. Énoncez la formule de Radbruch.
5. Par quels mécanismes le droit positif ivoirien intègre-t-il des exigences de justice supérieures ?

Questions de réflexion

1. Un positiviste est-il nécessairement favorable à l'obéissance inconditionnelle aux lois ?
2. La décision du Conseil constitutionnel ivoirien du 4 mai 2011 relève-t-elle d'un raisonnement positiviste ou jusnaturaliste ?

Sujets de dissertation

1. « *Lex iniusta non est lex* ? »
2. « Le positivisme juridique est-il dépassé ? »
3. « La positivation du droit naturel. »

Commentaire

1. Commentez la formule de Radbruch.

12. Références bibliographiques

Textes classiques

Aristote, *Éthique à Nicomaque*, livre V.

Cicéron, *De re publica* (*La République*).

Thomas d'Aquin, *Somme théologique*, Ia-IIae, q. 90 à 97 (Traité de la loi).

H. Grotius, *Le droit de la guerre et de la paix* (1625), trad. P. Pradier-Fodéré, PUF, coll. « Léviathan ».

J. Locke, *Deuxième traité du gouvernement civil* (1690).

Théorie et philosophie du droit

H. Kelsen, *Théorie pure du droit*, trad. Ch. Eisenmann, Dalloz, 1962.

H. L. A. Hart, *Le concept de droit*, trad. M. van de Kerchove, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 1976.

L. L. Fuller, *The Morality of Law*, Yale University Press, 1964.

R. Dworkin, *Prendre les droits au sérieux*, PUF, coll. « Léviathan », 1995.

N. Bobbio, *Essais de théorie du droit*, trad. M. Guéret et Ch. Agostini, Bruylant-LGDJ, 1998.

M. Villey, *Le droit et les droits de l'homme*, PUF, 1983.

M. Villey, *La formation de la pensée juridique moderne*, PUF, coll. « Léviathan ».

M. Troper, *La philosophie du droit*, PUF, coll. « Que sais-je ? ».

Perspectives africaines

K. Mbaye, *Les droits de l'homme en Afrique*, Pedone, 2e éd., 2002.

Sources officielles

Constitution du 8 novembre 2016 ; Charte africaine des droits de l'homme et des peuples ; Convention de Vienne sur le droit des traités (1969) ; décisions du Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire (www.conseil-constitutionnel.ci).

CHAPITRE 4

Les fondements du droit (II) : approches sociologiques, réalistes et anthropologiques ; le pluralisme juridique

« The life of the law has not been logic: it has been experience. »

— O. W. Holmes, The Common Law (1881)

1. Introduction et problématique

Le droit naturel et le positivisme juridique, étudiés au chapitre précédent, s'interrogent sur ce qui rend une règle **obligatoire** et **juste**. Ils laissent dans l'ombre une autre série de questions, que le juriste ne peut éluder : d'où viennent réellement les règles ? Sont-elles appliquées ? Comment sont-elles reçues par ceux auxquels elles s'adressent ? L'État est-il le seul producteur de droit, ou existe-t-il, dans la société, d'autres ordres normatifs qui méritent ce nom ?

Ces questions sont au cœur des approches **sociologiques**, **réalistes** et **anthropologiques** du droit. Elles ont en commun de considérer le droit non seulement comme un ensemble de normes, mais comme un **phénomène social** observable, produit par des acteurs — législateurs, juges, administrations, groupes sociaux — et inscrit dans des rapports de pouvoir, des intérêts et des cultures.

En Côte d'Ivoire, ces approches ne sont pas un luxe académique. Une part importante des rapports fonciers, familiaux et commerciaux se noue selon des normes qui ne sont pas celles des codes ; des autorités coutumières et religieuses règlent quotidiennement des différends ; l'économie informelle échappe largement au droit des affaires. Le juriste qui ne connaîtrait que les textes se tromperait sur la réalité du droit qu'il prétend appliquer.

Problématique. *Le droit se réduit-il aux règles posées par l'État, ou faut-il, pour le comprendre, l'observer comme un phénomène social pluriel, produit aussi par les juges, les groupes et les communautés ?* Le chapitre montrera que les approches sociologiques et réalistes ont profondément enrichi la compréhension du droit en révélant son épaisseur sociale et le rôle créa-

teur de ses interprètes, et que la théorie du **pluralisme juridique** offre un cadre indispensable à l'analyse de l'ordre juridique ivoirien — à condition de ne pas confondre la description de la pluralité des normes avec la négation de la spécificité du droit étatique.

2. Fondements historiques et théoriques

A. L'École historique allemande

Au début du XIXe siècle, alors que la France vient de se doter du Code civil, le juriste allemand Anton Thibaut plaide pour l'adoption d'un code civil commun à l'Allemagne. Friedrich Carl von Savigny lui répond en 1814 par un manifeste, *De la vocation de notre temps pour la législation et la science du droit*. Pour Savigny, le droit n'est pas le produit arbitraire d'un législateur : comme la langue, il naît de la conscience commune du peuple, de son « esprit » (*Volksgeist*), et se développe organiquement à travers la coutume, puis la science des juristes. Codifier prématurément, c'est figer et trahir ce développement.

L'École historique a durablement influencé la pensée juridique : elle a imposé l'idée que le droit est un **produit de l'histoire et de la culture**, et non une construction rationnelle intemporelle. Ses arguments ont été repris, en Afrique, dans les débats sur l'opportunité de codifier le droit de la famille contre les coutumes.

B. De la jurisprudence des concepts à la jurisprudence des intérêts

Rudolf von Jhering, d'abord adepte d'une science juridique conceptuelle, s'en détache pour affirmer que le **but** est le créateur de tout le droit : chaque règle naît d'un besoin social et protège des intérêts[1]. Il ouvre la voie à la « jurisprudence des intérêts » (Philipp Heck), qui invite le juge à interpréter les règles en fonction des intérêts qu'elles arbitrent, et à la définition du droit subjectif comme intérêt juridiquement protégé (chapitre 11).

C. Les fondateurs de la sociologie

Émile Durkheim voit dans le droit l'indice visible de la solidarité sociale[2]. Dans les sociétés à **solidarité mécanique**, fondées sur la similitude des individus, domine le **droit répressif**, qui punit les atteintes à la conscience collective ; dans les sociétés à **solidarité organique**, fondées sur la division du travail et la complémentarité des fonctions, domine le **droit restitutif**, qui rétablit les rapports troublés (droit civil, commercial, administratif).

1. R. von Jhering, *Der Zweck im Recht* (*Le but dans le droit*), 1877-1883 ; *Der Kampf ums Recht* (*La lutte pour le droit*), 1872.
2. É. Durkheim, *De la division du travail social*, Alcan, 1893.

Max Weber analyse le droit comme un ordre garanti par un appareil de contrainte et étudie sa rationalisation. Il distingue trois types de domination légitime : **traditionnelle** (fondée sur le caractère sacré des coutumes), **charismatique** (fondée sur les qualités exceptionnelles d'un chef) et **légale-rationnelle** (fondée sur des règles impersonnelles et une administration bureaucratique)[3]. Cette typologie éclaire la coexistence, dans les États africains, de légitimités concurrentes : celle de l'État légal-rationnel, celle des autorités coutumières, celle de leaders charismatiques.

Eugen Ehrlich forge la notion de **droit vivant** (*lebendes Recht*) : le droit qui gouverne effectivement la vie sociale, tel qu'il s'observe dans les contrats, les usages, les statuts des associations, et qui ne coïncide pas avec le droit des codes. Selon lui, le centre de gravité du développement du droit ne se trouve ni dans la législation, ni dans la science juridique, ni dans la jurisprudence, mais dans la société elle-même[4].

D. Les juristes sociologues français

Léon Duguit rejette la souveraineté de l'État et les droits subjectifs comme des notions métaphysiques ; il fonde le droit sur le fait de la **solidarité sociale** et définit l'État par ses fonctions, notamment le **service public**. **Maurice Hauriou** élabore la théorie de l'**institution** : un groupe organisé autour d'une idée d'œuvre, doté d'un pouvoir et de procédures, produit son propre droit. **François Gény**, dans sa *Méthode d'interprétation et sources en droit privé positif* (1899), dénonce le fétichisme de la loi et propose, au-delà des sources formelles, la **libre recherche scientifique** du droit, attentive aux données réelles, historiques, rationnelles et idéales de la vie sociale. **Georges Gurvitch** développe la notion de **droit social**, droit d'intégration produit spontanément par les groupes.

Jean Carbonnier, enfin, fait de la sociologie juridique une discipline à part entière[5]. Il forge des notions devenues classiques — l'**hypothèse du non-droit** (le droit n'occupe pas tout l'espace des relations humaines, et il se retire parfois volontairement de certains domaines), l'**internormativité** (les échanges entre le droit et les autres systèmes normatifs) — et met ces analyses au service d'une œuvre de législateur : les grandes réformes françaises du droit de la famille, entre 1964 et 1975, ont été préparées par des enquêtes sociologiques.

E. Les réalismes juridiques

Le réalisme américain. Oliver Wendell Holmes affirme que la vie du droit n'a pas été la logique, mais l'expérience, et définit le droit, du point de vue de celui qui doit s'y conformer,

3. M. Weber, *Économie et société*, trad. fr., Plon, 1971 (éd. originale posthume, 1922).
4. E. Ehrlich, *Grundlegung der Soziologie des Rechts*, 1913.
5. J. Carbonnier, *Sociologie juridique*, PUF, coll. « Quadrige » ; *Flexible droit*, LGDJ.

comme la prédiction de ce que les tribunaux feront en fait[6]. Les réalistes américains de l'entre-deux-guerres (Karl Llewellyn, Jerome Frank) insistent sur le rôle des facteurs psychologiques, sociaux et idéologiques dans la décision judiciaire et sur l'écart entre le « droit dans les livres » et le « droit en action »[7].

Le réalisme scandinave. Axel Hägerström, Karl Olivecrona et Alf Ross dénoncent les notions juridiques (droit subjectif, obligation) comme des entités métaphysiques et ramènent le droit à des faits psychologiques et sociaux : le sentiment d'être lié, les comportements des juges.

La théorie réaliste de l'interprétation. En France, Michel Troper soutient que l'interprétation d'un texte n'est pas un acte de connaissance, mais un **acte de volonté** : le texte n'a pas de sens objectif avant son interprétation, et c'est l'interprète authentique — celui dont l'interprétation s'impose, comme une cour suprême — qui crée la norme en fixant ce sens[8].

F. L'anthropologie juridique

L'anthropologie juridique est née de l'étude des sociétés sans État. Bronislaw Malinowski montre, à partir de l'observation des îles Trobriand, que l'obéissance aux règles repose moins sur la sanction que sur la **réciprocité** des obligations[9]. Max Gluckman, étudiant les tribunaux des Barotse (Lozi) d'Afrique australe, met en évidence des raisonnements judiciaires comparables à ceux des juges occidentaux, organisés autour de la figure de l'« homme raisonnable »[10].

En France, Michel Alliot fonde en 1964 le Laboratoire d'anthropologie juridique de Paris, dont les travaux, poursuivis par Étienne Le Roy et Norbert Rouland, ont porté principalement sur l'Afrique. Ils ont mis en évidence les **logiques** propres aux droits africains — primauté des groupes, pensée de la complémentarité des différences, recherche de la réconciliation — et les **résistances** que les sociétés africaines ont opposées au droit importé.

6. O. W. Holmes, « The Path of the Law », *Harvard Law Review*, vol. 10, 1897, p. 457.
7. R. Pound, « Law in Books and Law in Action », *American Law Review*, vol. 44, 1910, p. 12.
8. M. Troper, *Pour une théorie juridique de l'État*, PUF, coll. « Léviathan », 1994 ; *La philosophie du droit*, PUF, coll. « Que sais-je ? ».
9. B. Malinowski, *Crime and Custom in Savage Society*, Londres, Kegan Paul, 1926.
10. M. Gluckman, *The Judicial Process among the Barotse of Northern Rhodesia*, Manchester University Press, 1955.

3. Explication approfondie des concepts

A. Les notions de la sociologie du droit

DÉFINITION — SOCIOLOGIE DU DROIT

Branche de la sociologie, ou de la science juridique selon les auteurs, qui étudie les phénomènes juridiques comme des faits sociaux : leurs causes, leurs effets, leur effectivité, les représentations et les comportements qu'ils suscitent.

DÉFINITION — INTERNORMATIVITÉ

Ensemble des rapports et des échanges entre le droit et les autres systèmes normatifs (morale, religion, coutumes, usages, normes techniques) : passage d'une norme d'un ordre à un autre, concurrence, complémentarité (J. Carbonnier).

DÉFINITION — NON-DROIT

Absence de droit dans un certain nombre de rapports humains où le droit aurait eu vocation théorique à être présent; retrait du droit, volontaire ou spontané, au profit d'autres modes de régulation (J. Carbonnier). Le non-droit n'est pas l'anti-droit : il ne désigne pas la violation du droit, mais son absence.

B. L'acculturation juridique

DÉFINITION — ACCULTURATION JURIDIQUE

Processus par lequel un système juridique se transforme au contact d'un autre, par emprunt, imposition ou imitation de règles, d'institutions ou de modes de raisonnement.

L'histoire juridique de l'Afrique francophone est, dans une large mesure, une histoire d'acculturation : imposition du droit colonial, réception volontaire du modèle français après les indépendances, harmonisation par l'OHADA. L'acculturation n'est jamais une simple substitution : le droit reçu est réinterprété, sélectivement appliqué, combiné avec les normes antérieures. Le chapitre 5 examine ce processus à propos de la formation du droit ivoirien.

C. Le pluralisme juridique

> **DÉFINITION — PLURALISME JURIDIQUE**
>
> Coexistence, dans un même espace social, de plusieurs ordres juridiques ou systèmes de normes applicables aux mêmes situations.

La notion recouvre deux réalités que John Griffiths a distinguées dans un article devenu classique[11] :

- le **pluralisme juridique faible** (ou étatique) : l'État lui-même reconnaît et organise l'application de plusieurs corps de règles à différentes catégories de personnes ou de situations — ainsi du régime colonial de dualité des statuts, ou de la reconnaissance actuelle des droits coutumiers par la loi foncière ivoirienne ;
- le **pluralisme juridique fort** (ou sociologique) : coexistent, indépendamment de toute reconnaissance par l'État, des ordres normatifs produits par des groupes sociaux (communautés villageoises, confréries, associations professionnelles, marchés), que l'observateur qualifie de juridiques.

Griffiths qualifie de **centralisme juridique** l'idéologie selon laquelle le droit est et doit être le droit de l'État, uniforme pour tous, exclusif des autres normes et administré par un ensemble unique d'institutions. Sally Falk Moore a proposé, de son côté, la notion de **champ social semi-autonome** : un espace social (une profession, un marché, un village) qui produit ses propres règles et en assure le respect, mais demeure exposé aux règles et aux pressions du monde extérieur, notamment de l'État[12].

D. Tableau comparatif des approches

Tableau 1 — Les approches non positivistes du droit

Approche	Objet privilégié	Thèse centrale	Auteurs représentatifs	Apport	Limite
École historique	Coutume, droit populaire	Le droit naît de l'esprit du peuple	Savigny	Historicité du droit	Idéalisation du passé ; conservatisme
Sociologie classique	Droit et solidarité, rationalisation	Le droit est un fait social	Durkheim, Weber, Ehrlich	Liens entre droit et structure sociale	Faible attention à la technique juridique

11. J. Griffiths, « What is Legal Pluralism? », *Journal of Legal Pluralism*, n° 24, 1986, p. 1.
12. S. F. Moore, « Law and Social Change: The Semi-Autonomous Social Field as an Appropriate Subject of Study », *Law & Society Review*, vol. 7, n° 4, 1973.

Approche	Objet privilégié	Thèse centrale	Auteurs représentatifs	Apport	Limite
Juristes sociologues	Sources réelles du droit	Le droit procède des besoins sociaux	Duguit, Hauriou, Gény, Carbonnier	Méthode d'interprétation et de législation	Risque de confusion entre fait et norme
Réalismes	Décision du juge	Le droit est ce que font les juges	Holmes, Llewellyn, Ross, Troper	Rôle créateur de l'interprète	Difficulté à rendre compte du caractère obligatoire des règles
Anthropologie juridique	Sociétés sans État, droits africains	Le droit existe hors de l'État	Malinowski, Gluckman, Alliot, Le Roy	Relativisation du modèle occidental	Extension parfois excessive de la notion de droit
Pluralisme juridique	Coexistence des ordres	Plusieurs ordres juridiques coexistent	Romano, Griffiths, Moore, Vanderlinden	Cadre d'analyse des sociétés plurales	Risque de dissoudre la notion de droit

4. Analyse des principes et mécanismes juridiques

A. Mesurer l'effectivité du droit

La sociologie du droit a développé des méthodes pour mesurer l'écart entre le droit des textes et le droit vécu : enquêtes de connaissance et d'opinion sur le droit, analyse statistique du contentieux, études de cas, observation des pratiques. Ces méthodes permettent de répondre à des questions que la seule lecture des textes laisse sans réponse : la loi sur le mariage est-elle connue ? Les couples célèbrent-ils le mariage civil ? Les certificats fonciers prévus par la loi de 1998 sont-ils délivrés en nombre suffisant ? Les créanciers recourent-ils aux procédures OHADA de recouvrement ?

L'ineffectivité d'une règle peut avoir plusieurs causes : ignorance de la règle, coût de son application (formalités, frais, éloignement des administrations), inadaptation aux pratiques sociales, concurrence d'une norme jugée plus légitime, faiblesse des institutions chargées de l'appliquer. Le diagnostic de la cause commande le remède : information, simplification, adaptation de la règle ou renforcement des institutions.

B. Les mécanismes de l'internormativité

Les rapports entre le droit étatique et les autres ordres normatifs empruntent plusieurs voies, dont l'identification est utile au juriste.

Tableau 2 — Les mécanismes de l'internormativité

Mécanisme	Description	Illustration ivoirienne
Réception par renvoi	Le droit étatique renvoie à une norme non étatique et lui confère effet	Reconnaissance des « droits coutumiers conformes aux traditions » par la loi de 1998 sur le domaine foncier rural
Conversion	Le droit étatique transforme une norme coutumière en norme étatique	Constatation des droits coutumiers par le certificat foncier, puis immatriculation
Délégation	Le droit étatique confie à des autorités non étatiques une fonction encadrée	Rôle des rois et chefs traditionnels dans la conciliation des litiges
Prohibition	Le droit étatique interdit une pratique sociale	Interdiction de la dot (1964-2019) ; interdiction de la bigamie
Retrait	Le droit étatique cesse de régir un domaine	Abandon de la prohibition de la dot par la loi de 2019
Formalisation	Le droit étatique crée un statut pour intégrer une pratique informelle	Statut de l'entreprenant créé par l'AUDCG de 2010

C. Le « choix du forum »

Les travaux d'anthropologie juridique ont montré que, dans les sociétés plurales, les justiciables ne subissent pas passivement la pluralité des normes : ils **choisissent** l'instance à laquelle ils soumettent leur différend — chef de village, autorité religieuse, association, police, tribunal — en fonction de leurs intérêts, de leurs ressources et de la solution qu'ils espèrent[13]. Ce phénomène est observable en Côte d'Ivoire, notamment en matière foncière, où un même conflit peut être porté successivement devant le chef de village, le sous-préfet et le juge. Il explique la multiplication des procédures et la fragilité des solutions, chacune pouvant être remise en cause devant une autre instance.

D. Le pluralisme organisé par le droit étatique ivoirien

Le droit ivoirien contemporain pratique un **pluralisme faible et encadré**. Il a écarté les coutumes en matière de personnes et de famille, au profit d'un droit civil unifié. Il les reconnaît, en revanche, dans le domaine foncier rural, mais dans une perspective de **conversion** : les droits coutumiers sont constatés par un certificat foncier délivré à l'issue d'une enquête officielle, puis ont vocation à être transformés en droit de propriété par l'immatriculation. Il

13. K. von Benda-Beckmann, « Forum Shopping and Shopping Forums: Dispute Processing in a Minangkabau Village in West Sumatra », *Journal of Legal Pluralism*, n° 19, 1981.

confère enfin aux autorités traditionnelles un statut et une fonction de médiation, sans leur reconnaître de pouvoir juridictionnel.



Loi n° 98-750 du 23 décembre 1998, modifiée : de la reconnaissance à la conversion des droits coutumiers

Schéma 1 — Le pluralisme encadré du domaine foncier rural ivoirien

5. Étude des textes applicables

A. La loi relative au domaine foncier rural

La loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural, modifiée par les lois n° 2004-412 du 14 août 2004, n° 2013-655 du 13 septembre 2013 et n° 2019-868 du 14 octobre 2019, est le texte ivoirien qui organise le plus nettement la rencontre entre le droit étatique et les normes coutumières.

- Son **article 3** définit le domaine foncier rural coutumier comme l'ensemble des terres sur lesquelles s'exercent des droits coutumiers conformes aux traditions et des droits coutumiers cédés à des tiers : la loi reconnaît ainsi l'existence de droits nés hors d'elle.
- Son **article 4**, dans sa rédaction issue de la loi de 2019, pose que la propriété d'une terre du domaine foncier rural résulte de son immatriculation au registre foncier et que, dans le domaine coutumier, les droits coutumiers sont constatés par le certificat foncier.
- La loi de 2019 a inséré un **article 17 bis**, selon lequel les terres du domaine coutumier qui ne sont pas couvertes par un certificat foncier ne peuvent plus faire l'objet de cession à compter de son entrée en vigueur, d'autres opérations étant renvoyées à un décret.
- Le **décret n° 2019-266 du 27 mars 2019** précise les modalités d'établissement, de publication et de gestion du certificat foncier, ainsi que l'immatriculation des biens du domaine coutumier.

Ces dispositions traduisent une stratégie de **conversion progressive** : la coutume est reconnue comme source de droits, mais sa vocation est de céder la place au titre écrit.

B. Le statut des autorités traditionnelles

La loi n° 2014-428 du 14 juillet 2014 portant statut des Rois et Chefs traditionnels a institué la Chambre nationale des Rois et Chefs traditionnels. La Constitution de 2016 a conféré à cette institution un statut constitutionnel : elle regroupe tous les rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire (Const., art. 175), sa composition, ses organes et son fonctionnement étant renvoyés à une loi organique (Const., art. 176). Les autorités traditionnelles sont associées à la préservation de la paix sociale et au règlement amiable des différends, sans pouvoir juridictionnel.

C. Le statut de l'entreprenant

L'Acte uniforme relatif au droit commercial général révisé le 15 décembre 2010 a créé le statut de l'**entreprenant** (AUDCG, art. 30 et s. V) : entrepreneur individuel qui, sur simple déclaration, exerce une activité professionnelle civile, commerciale, artisanale ou agricole, et bénéficie d'obligations allégées. Ce statut est une réponse juridique à une donnée sociologique — le poids du secteur informel — et une tentative de formalisation progressive de l'activité économique.

D. La Charte africaine

La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples reconnaît la valeur des traditions et des cultures africaines (art. 17, al. 3 ; art. 29) tout en garantissant les droits individuels, ce qui fournit un cadre normatif au pluralisme : les normes communautaires sont reconnues, mais dans les limites des droits fondamentaux.

6. Analyse de jurisprudences vérifiables

Jurisprudence — CJ CEDEAO, 27 octobre 2008, Hadijatou Mani Koraou c. République du Niger, arrêt n° ECW/CCJ/JUD/06/08

Faits. Hadijatou Mani avait été vendue, alors qu'elle était enfant, à un homme qui l'avait prise comme « wahaya », pratique qualifiée de cinquième épouse, ou épouse servile, en marge des quatre épouses admises par la coutume religieuse locale. Elle fut maintenue pendant plusieurs années dans une situation de servitude. Après son affranchissement, des procédures devant les juridictions nigériennes, y compris coutumières, aboutirent notamment à sa condamnation pour bigamie lorsqu'elle se maria avec un autre homme.

Question. L'État du Niger engageait-il sa responsabilité internationale à raison d'une pratique d'esclavage fondée sur une coutume, et de l'attitude de ses juridictions ?

Solution. La Cour de justice de la CEDEAO juge que la requérante a été victime d'esclavage, que l'État est responsable de n'avoir pas protégé ses droits, notamment en raison de la

tolérance et de l'inaction de ses autorités, y compris judiciaires, et le condamne à lui verser une indemnité.

Portée. L'arrêt est une illustration majeure des limites du pluralisme juridique : la reconnaissance de normes coutumières par l'État ne peut aller jusqu'à couvrir des pratiques contraires aux droits fondamentaux. Il montre aussi que la responsabilité de l'État peut être engagée lorsqu'il laisse ses juridictions, fussent-elles coutumières, donner effet à de telles pratiques.

Jurisprudence — Cour ADHP, 26 mai 2017, Commission africaine des droits de l'homme et des peuples c. République du Kenya (affaire des Ogiek), requête n° 006/2012

Faits. La communauté des Ogiek, peuple de chasseurs-cueilleurs vivant dans la forêt de Mau, contestait des mesures d'expulsion décidées par les autorités kényanes au nom de la protection de la forêt.

Solution. La Cour africaine reconnaît la qualité de peuple autochtone aux Ogiek et juge que le Kenya a violé plusieurs droits garantis par la Charte, notamment le droit de propriété sur leurs terres ancestrales, en méconnaissant le lien entre la communauté et ses terres.

Portée. L'arrêt consacre, dans le droit régional africain des droits de l'homme, la protection de droits fonciers d'origine **communautaire et coutumière**, opposables à l'État. Il intéresse directement les pays qui, comme la Côte d'Ivoire, organisent la conversion des droits coutumiers : la reconnaissance juridique de ces droits n'est pas seulement une politique de développement, elle peut être une exigence des droits de l'homme.

Jurisprudence — Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, communication n° 155/96, Social and Economic Rights Action Center (SERAC) et Center for Economic and Social Rights c. Nigeria (2001)

Faits. La communication dénonçait les atteintes portées au peuple ogoni du delta du Niger par l'exploitation pétrolière menée par une entreprise publique en consortium avec une société multinationale : pollution, destruction des ressources, répression.

Solution. La Commission constate la violation de plusieurs droits garantis par la Charte, dont le droit des peuples à disposer librement de leurs richesses et ressources naturelles et le droit à un environnement satisfaisant, et affirme l'obligation des États de protéger les communautés contre les atteintes commises par des acteurs privés.

Portée. La décision montre comment le droit africain des droits de l'homme saisit des réalités collectives et communautaires que le droit civil classique, centré sur l'individu, peine à appréhender.

7. Présentation des débats doctrinaux

A. La controverse Kelsen–Ehrlich

DÉBAT DOCTRINAL — LA SOCIOLOGIE DU DROIT EST-ELLE UNE SCIENCE JURIDIQUE ?

Ehrlich. Le juriste autrichien soutient que la véritable science du droit est la sociologie du droit, puisque le droit vivant se trouve dans la société et non dans les textes DOC.

Kelsen. Kelsen lui oppose, dans une polémique restée célèbre (1915-1917), qu'une science des faits sociaux, qui décrit ce qui *est*, ne peut rendre compte des normes, qui disent ce qui *doit être*; confondre les deux plans revient à perdre l'objet même de la science juridique DOC.

État de la discussion. La plupart des auteurs admettent aujourd'hui la complémentarité des deux approches : la science juridique dogmatique identifie et systématise les normes valides; la sociologie du droit en étudie les causes, l'application et les effets. Le juriste complet doit maîtriser la première et savoir mobiliser la seconde.

B. Le pluralisme juridique : concept éclairant ou confusion ?

La théorie du pluralisme juridique fort a été vivement critiquée. Brian Tamanaha a soutenu que, si l'on qualifie de « droit » tout ordre normatif doté de mécanismes de contrôle social, on ne parvient plus à distinguer le droit des autres formes de régulation — la famille, l'entreprise, le club de football produiraient du « droit » — et que la notion perd son utilité analytique[14]. Les défenseurs du pluralisme répondent que la définition étatique du droit n'est elle-même qu'une convention, historiquement située, et qu'elle conduit à méconnaître des ordres normatifs qui remplissent, pour leurs membres, les fonctions du droit.

Une position médiane, adoptée par de nombreux juristes africanistes, distingue le **pluralisme normatif** — fait sociologique incontestable — et le **pluralisme juridique** au sens strict, qui suppose que les ordres en présence soient organisés, dotés d'autorités et de procédures, et reconnus comme obligatoires par leurs membres.

C. Codifier contre la coutume ? Le débat africain

Le choix ivoirien de 1964 — substituer aux coutumes un droit de la famille unifié et inspiré du modèle occidental — a été défendu comme une condition de la construction nationale, de l'égalité des citoyens et du développement. Il a été critiqué, dans la lignée de l'École historique

14. B. Z. Tamanaha, « The Folly of the "Social Scientific" Concept of Legal Pluralism », *Journal of Law and Society*, vol. 20, 1993.

et de l'anthropologie juridique, comme une greffe imposée d'en haut, dont l'ineffectivité était prévisible. Michel Alliot a analysé les **résistances traditionnelles au droit moderne** dans les États d'Afrique francophone, montrant que les populations continuaient à vivre selon leurs normes en contournant le droit officiel. La réforme de 2019, qui a abandonné la prohibition de la dot tout en maintenant l'unité du droit civil, peut être lue comme un ajustement pragmatique.

PROPOSITION DE L'AUTEUR — POUR UN PLURALISME ORDONNÉ

L'expérience ivoirienne invite à dépasser l'alternative entre centralisme juridique et pluralisme fort. Un **pluralisme ordonné** consisterait à maintenir le droit étatique comme droit de référence, garant de l'égalité et des droits fondamentaux, tout en organisant explicitement les passerelles avec les normativités sociales : reconnaissance des droits coutumiers sous condition de constatation contradictoire, homologation judiciaire des accords de conciliation conclus devant les autorités traditionnelles, information juridique adaptée. Les droits fondamentaux — en particulier l'égalité entre hommes et femmes et la protection de l'enfant — constitueraient la limite infranchissable de cette reconnaissance, comme l'a rappelé la jurisprudence de la Cour de justice de la CEDEAO PP.

8. Illustrations pratiques

Le planteur et le « petit papier ». Dans de nombreuses régions forestières, des terres coutumières ont été cédées à des exploitants, souvent originaires d'autres régions ou d'autres pays, selon des arrangements coutumiers — relations dites de « tutorat » entre le détenteur coutumier et l'exploitant — constatés, le cas échéant, par de simples écrits sous seing privé. Au décès des parties, leurs héritiers contestent la nature de l'arrangement : vente définitive pour les uns, droit d'usage moyennant contreparties pour les autres. La loi de 1998 et sa réforme de 2019 tentent de prévenir ces conflits par la certification et par l'interdiction des cessions de terres non certifiées. Le juriste consulté doit à la fois connaître les règles légales et comprendre les logiques coutumières que les parties invoquent.

Le conflit porté devant plusieurs instances. Un différend de limites entre deux familles est d'abord soumis au chef de village, puis au chef de canton, puis au sous-préfet, avant d'être porté devant le tribunal. Chaque instance applique ses propres normes et ses propres procédures. Le juge devra déterminer la valeur juridique des actes intervenus devant les autres instances (procès-verbal de conciliation, accord signé) : ils n'ont pas l'autorité d'un jugement, mais peuvent constituer des éléments de preuve ou des contrats.

L'entreprenant. Une commerçante du marché d'Adjamé exerce depuis des années sans immatriculation. Le statut d'entreprenant lui offre une voie d'entrée simplifiée dans la légali-

té, moyennant une déclaration. La faible utilisation de ce statut, lorsqu'elle est constatée, invite à s'interroger sur les causes sociologiques de l'informalité, qui ne tiennent pas seulement au coût des formalités.

9. Cas pratiques corrigés

Cas pratique n° 1 — La vente d'une terre coutumière non certifiée

Énoncé. En 2023, M. Gnangbo, détenteur coutumier d'une parcelle de terre rurale qui n'a jamais fait l'objet d'un certificat foncier, la « vend » à Mme Koné par un écrit signé devant le chef du village, moyennant un prix. Les frères de M. Gnangbo contestent la vente. Mme Koné vous consulte.

CORRIGÉ

Problème de droit. Une terre du domaine foncier rural coutumier non couverte par un certificat foncier peut-elle faire l'objet d'une cession valable ?

Règles applicables. Selon la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-868 du 14 octobre 2019, la propriété d'une terre du domaine foncier rural résulte de son immatriculation, les droits coutumiers étant constatés par le certificat foncier (art. 4) ; les terres coutumières non couvertes par un certificat foncier ne peuvent plus faire l'objet de cession depuis l'entrée en vigueur de la loi de 2019 (art. 17 bis). En droit commun des obligations, la convention qui porte sur une opération interdite par la loi est entachée d'illicéité (C. civ., art. 1133).

Application. La cession est intervenue en 2023, après l'entrée en vigueur de la loi de 2019, et porte sur une terre non certifiée. Elle se heurte à l'interdiction légale ; sa validité est donc sérieusement compromise et les frères de M. Gnangbo, ou tout intéressé, pourraient en contester l'efficacité. La signature de l'acte devant le chef de village ne lui confère aucune validité au regard du droit étatique.

Conclusion. Mme Koné ne peut se prévaloir d'un droit de propriété. Il lui est conseillé de rechercher, avec M. Gnangbo, l'établissement préalable d'un certificat foncier au nom de celui-ci, puis la conclusion d'un acte conforme aux exigences légales ; à défaut, elle pourra demander la restitution du prix versé. Les modalités exactes de sanction de la violation de l'article 17 bis et les opérations autorisées par décret doivent être vérifiées dans les textes d'application.

Cas pratique n° 2 — Faut-il reconnaître le mariage coutumier ?

Énoncé. Une étude sociologique révèle que, dans plusieurs régions, une majorité de couples ne s'unissent que selon la coutume. Un parlementaire propose une loi reconnaissant au

mariage coutumier les mêmes effets que le mariage civil. Le ministre vous demande une note sur la pertinence de cette proposition au regard des théories étudiées.

CORRIGÉ

Problème. Le constat de l'ineffectivité d'une règle justifie-t-il la reconnaissance juridique de la pratique concurrente ?

Éléments d'analyse. (1) *Apport sociologique* : l'écart entre la règle (seul le mariage civil produit effet) et la pratique est un fait ; ses causes doivent être identifiées (coût et éloignement de l'état civil, attachement aux formes coutumières, méconnaissance de la loi). (2) *Internormativité* : plusieurs voies sont possibles — reconnaissance pure et simple, conversion (enregistrement du mariage coutumier à l'état civil), facilitation de la célébration civile, ou maintien de la règle avec un effort d'information. (3) *Limites juridiques* : toute reconnaissance doit respecter les exigences constitutionnelles et internationales — consentement libre des époux, âge minimum, égalité des époux, prohibition de la polygamie en droit ivoirien ; le Protocole de Maputo et la jurisprudence de la Cour africaine (*APDF et IHRDA c. Mali*, 2018) en rappellent la portée. (4) *Sécurité juridique* : la preuve d'un mariage coutumier est incertaine, ce qui plaide pour un mécanisme d'enregistrement.

Conclusion. Plutôt qu'une assimilation pure et simple, une solution de **conversion** — enregistrement à l'état civil des unions coutumières respectant les conditions de fond du mariage civil — concilierait la prise en compte de la pratique et les exigences de l'ordre juridique. La note devrait recommander une étude d'impact préalable.

Cas pratique n° 3 — La décision du chef de village

Énoncé. Saisi d'un litige entre deux villageois au sujet de dégâts causés par des bœufs dans un champ, le chef de village décide que le propriétaire des animaux versera une somme d'argent et offrira un mouton. Le propriétaire refuse d'exécuter cette « décision ». La victime peut-elle en obtenir l'exécution forcée ?

CORRIGÉ

Problème de droit. La décision d'un chef traditionnel a-t-elle force exécutoire ?

Règles applicables. Les rois et chefs traditionnels disposent d'un statut légal (loi n° 2014-428 du 14 juillet 2014) et constitutionnel (Const., art. 175-176) ; ils participent au règlement amiable des différends, mais ne sont pas investis du pouvoir juridictionnel, qui appartient aux juridictions de l'État. Seuls les titres exécutoires énumérés par la loi — décisions de justice, actes notariés revêtus de la formule exécutoire, etc. — permettent l'exécution forcée (AUPSRVE).

Application. La « décision » du chef n'est pas un jugement et n'est pas un titre exécutoire. Si les deux parties y ont consenti, elle peut constituer un accord de conciliation ayant la valeur d'un contrat, dont l'exécution pourra être demandée au juge ; elle pourra en tout cas servir d'élément de preuve des faits et de l'évaluation du dommage.

Conclusion. La victime ne peut faire exécuter directement la décision du chef. Elle doit saisir la juridiction compétente, sur le fondement de la responsabilité du gardien des animaux (C. civ., art. 1385) ou de l'accord de conciliation s'il est établi.

10. Synthèse et connaissances essentielles

SYNTHÈSE — CONNAISSANCES ESSENTIELLES

- Les approches **sociologiques**, **réalistes** et **anthropologiques** étudient le droit comme un phénomène social : origine, application, effets.
- **Savigny** voit dans le droit le produit de l'esprit du peuple ; **Jhering**, l'instrument de la protection des intérêts ; **Durkheim**, l'indice de la solidarité sociale ; **Weber** distingue les dominations traditionnelle, charismatique et légale-rationnelle ; **Ehrlich** découvre le « droit vivant ».
- **Carbonnier** forge les notions de **non-droit** et d'**internormativité** ; **Gény** prône la libre recherche scientifique.
- Les **réalistes** (Holmes, Ross, Troper) mettent l'accent sur le rôle créateur des juges et des interprètes.
- Le **pluralisme juridique** désigne la coexistence de plusieurs ordres juridiques ; on distingue pluralisme **faible** (organisé par l'État) et **fort** (sociologique) (Griffiths).
- Le droit ivoirien pratique un **pluralisme encadré** : unification du droit de la famille, reconnaissance et conversion des droits coutumiers fonciers (loi de 1998 modifiée), statut des autorités traditionnelles sans pouvoir juridictionnel.
- Les **droits fondamentaux** limitent la reconnaissance des normes coutumières (*Koraou c. Niger*, 2008) ; ils peuvent aussi exiger la protection des droits fonciers communautaires (*Ogiek*, 2017).

11. Questions d'évaluation

QUESTIONS D'ÉVALUATION

Questions de cours

1. Exposez la thèse de Savigny et ses implications pour la codification.

2. Qu'est-ce que le « droit vivant » selon Ehrlich ?
3. Définissez le non-droit et l'internormativité.
4. Distinguez le pluralisme juridique faible et le pluralisme juridique fort.
5. Comment la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 organise-t-elle les rapports entre le droit étatique et les droits coutumiers ?

Questions de réflexion

1. La typologie wébérienne des dominations légitimes permet-elle d'éclairer la place des chefferies traditionnelles dans l'État ivoirien ?
2. La théorie réaliste de l'interprétation est-elle compatible avec l'existence de règles de droit obligatoires ?

Sujets de dissertation

1. « Le pluralisme juridique en Côte d'Ivoire. »
2. « L'effectivité du droit. »
3. « Le juge crée-t-il le droit ? Le point de vue réaliste. »

Commentaire

1. Commentez l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO du 27 octobre 2008, *Hadijatou Mani Koraou c. Niger*.

12. Références bibliographiques

Sociologie du droit

J. Carbonnier, *Sociologie juridique*, PUF, coll. « Quadrige ».

J. Carbonnier, *Flexible droit. Pour une sociologie du droit sans rigueur*, LGDJ, dernière éd.

H. Lévy-Bruhl, *Sociologie du droit*, PUF, coll. « Que sais-je ? », 1961.

É. Durkheim, *De la division du travail social*, Alcan, 1893.

M. Weber, *Économie et société*, trad. fr., Plon, 1971.

G. Gurvitch, *L'idée du droit social*, Sirey, 1932.

P. Bourdieu, « La force du droit. Éléments pour une sociologie du champ juridique », *Actes de la recherche en sciences sociales*, n° 64, 1986.

Réalismes

O. W. Holmes, « The Path of the Law », *Harvard Law Review*, vol. 10, 1897.

M. Troper, *Pour une théorie juridique de l'État*, PUF, coll. « Léviathan », 1994.

Anthropologie juridique et pluralisme

N. Rouland, *Anthropologie juridique*, PUF, coll. « Droit fondamental », 1988.

É. Le Roy, *Le jeu des lois. Une anthropologie « dynamique » du droit*, LGDJ, 1999.

M. Alliot, *Le droit et le service public au miroir de l'anthropologie. Textes choisis*, éd. C. Kuyu, Karthala, 2003.

J. Vanderlinden, *Les systèmes juridiques africains*, PUF, coll. « Que sais-je ? », 1983.

S. Romano, *L'ordre juridique*, trad. L. François et P. Gothot, Dalloz, 1975.

J. Griffiths, « What is Legal Pluralism? », *Journal of Legal Pluralism*, n° 24, 1986.

S. F. Moore, « Law and Social Change: The Semi-Autonomous Social Field as an Appropriate Subject of Study », *Law & Society Review*, vol. 7, 1973.

B. Z. Tamanaha, « The Folly of the "Social Scientific" Concept of Legal Pluralism », *Journal of Law and Society*, vol. 20, 1993.

Sources officielles

Loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural, modifiée ; décret n° 2019-266 du 27 mars 2019 ; loi n° 2014-428 du 14 juillet 2014 portant statut des Rois et Chefs traditionnels ; AUDCG (15 décembre 2010) ; arrêts de la Cour de justice de la CEDEAO et de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples.

DEUXIÈME PARTIE

L’ordre juridique : systèmes, divisions et sources

CHAPITRE 5

Les systèmes juridiques et la formation du droit ivoirien

1. Introduction et problématique

Il existe dans le monde près de deux cents États, et presque autant de droits nationaux, auxquels s'ajoutent des ordres juridiques régionaux, religieux et coutumiers. Le **droit comparé** s'efforce de mettre de l'ordre dans cette diversité en regroupant les droits en **familles** ou **systèmes** qui partagent des traits communs : histoire, sources, méthodes de raisonnement, organisation judiciaire, conception du rôle du droit dans la société.

Situer le droit ivoirien dans cette classification n'est pas un exercice d'érudition. C'est une condition de sa bonne compréhension et de sa bonne application. Le juriste qui sait que le droit ivoirien appartient, pour l'essentiel, à la tradition romano-germanique sait que la loi y est la source principale, que les codes y sont l'instrument privilégié de l'expression du droit, et que la jurisprudence y joue un rôle d'interprétation plutôt que de création ouverte. Mais il doit savoir aussi que ce droit porte la marque d'autres strates — coutumières, coloniales, communautaires — qui en font un système **composite**.

Problématique. *Le droit ivoirien est-il un simple prolongement de la famille romano-germanique, ou un système mixte original, issu de la superposition de strates africaines, coloniales, nationales et régionales ?* Le chapitre montrera que le droit ivoirien appartient à la tradition civiliste par ses sources, ses méthodes et ses institutions, mais qu'il s'en distingue par trois traits : la persistance encadrée de normes coutumières, la survivance de textes coloniaux et d'un Code civil figé à l'époque de l'indépendance, et la part croissante d'un droit d'origine supranationale.

2. Fondements historiques et théoriques

A. La naissance du droit comparé et la notion de famille de droits

Le droit comparé moderne prend son essor au Congrès international de droit comparé réuni à Paris en 1900, auquel Raymond Saleilles et Édouard Lambert prirent une part décisive ; s'y exprima l'ambition, formulée notamment par Saleilles, de dégager un « droit commun de l'humanité civilisée ». La classification des droits en **familles** s'est imposée au XXe siècle, notamment grâce à René David, dont l'ouvrage *Les grands systèmes de droit contemporains* distingue la famille romano-germanique, la famille de la *common law*, la famille des droits socialistes (aujourd'hui largement historique) et un ensemble d'« autres conceptions de l'ordre social et du droit » : droits musulman, hindou, de l'Extrême-Orient, de l'Afrique et de Madagascar[1].

D'autres classifications ont été proposées. Konrad Zweigert et Hein Kötz regroupent les droits selon leur **style**, déterminé par leur formation historique, leur mode de pensée caractéristique, leurs institutions distinctives, leurs sources et leur idéologie[2]. Ugo Mattei propose une typologie fondée sur la source dominante de la régulation sociale : règle du droit professionnel (droits occidentaux), règle du droit politique (droits où la politique prime sur le droit), règle du droit traditionnel (droits où dominent la religion ou la tradition), en soulignant que tout système combine ces trois modèles dans des proportions variables[3].

B. Les grandes traditions juridiques

La famille romano-germanique s'est formée en Europe continentale à partir du droit romain redécouvert dans les universités médiévales (le *jus commune*), enrichi par le droit canonique, les coutumes et l'École du droit naturel, et consacré par les grandes **codifications** des XIXe et XXe siècles (Code civil français de 1804, Code civil allemand de 1900). Elle se caractérise par la primauté de la loi écrite, l'organisation du droit en codes, la distinction du droit public et du droit privé, et le rôle éminent de la doctrine universitaire.

La famille de la *common law* s'est formée en Angleterre à partir de l'activité des cours royales de justice depuis le XIIe siècle. Le droit y est d'abord jurisprudentiel : la règle se dégage des précédents, que les juges sont tenus de suivre (*stare decisis*) ; l'*equity*, développée par la juridiction du Chancelier, a complété et corrigé la *common law*. Le raisonnement procède du cas au cas, par analogie et distinction.

1. R. David et C. Jauffret-Spinosi, *Les grands systèmes de droit contemporains*, Dalloz, coll. « Précis », dernière éd.
2. K. Zweigert et H. Kötz, *Introduction to Comparative Law*, trad. T. Weir, Oxford, Clarendon Press, 3e éd., 1998.
3. U. Mattei, « Three Patterns of Law: Taxonomy and Change in the World's Legal Systems », *American Journal of Comparative Law*, vol. 45, 1997, p. 5.

Le droit musulman (*charia*) est un droit révélé, fondé sur le Coran, la Sunna (tradition du Prophète), le consensus des savants (*ijma*) et le raisonnement par analogie (*qiyas*), élaboré par des écoles juridiques. L'école malékite est historiquement prédominante en Afrique de l'Ouest. Dans les États contemporains, le droit musulman est le plus souvent appliqué en matière de statut personnel, de famille et de successions, dans des proportions variables selon les États.

Les droits africains traditionnels sont des droits coutumiers, oraux, liés aux structures de parenté et à l'organisation religieuse, dont l'anthropologie juridique a montré la logique propre (chapitre 4).

C. La formation historique du droit ivoirien

1° La période coloniale (1893-1960)

La Côte d'Ivoire devient colonie française par décret du 10 mars 1893 ; elle est intégrée à l'Afrique occidentale française (AOF), fédération créée en 1895 et dotée d'un gouvernement général installé à Dakar. Le droit colonial obéit à des principes propres.

- **Le régime des décrets.** Le sénatus-consulte du 3 mai 1854 avait posé que les colonies autres que la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion seraient régies par décrets du chef de l'État. Les lois métropolitaines ne s'appliquaient aux colonies d'Afrique que si elles y avaient été expressément étendues, et toute norme devait faire l'objet d'une **promulgation locale** par le gouverneur pour y être exécutoire.
- **La dualité des statuts.** Les citoyens français relevaient du droit français et des juridictions françaises ; les « sujets » relevaient de leurs coutumes, appliquées par des juridictions indigènes organisées par une série de décrets (notamment en 1903 et en 1931), et du régime de l'**indigénat**, qui permettait à l'administration d'infliger des sanctions sans jugement.
- **La rédaction des coutumes.** L'administration coloniale entreprit de recueillir et de rédiger les coutumes, notamment dans les *Coutumiers juridiques de l'Afrique occidentale française* publiés en 1939 ; cette rédaction contribua à figer des normes par nature évolutives.
- **La législation foncière.** Les décrets fonciers de l'AOF — décret du 24 juillet 1906 introduisant l'immatriculation, décret du 26 juillet 1932 portant réorganisation du régime de la propriété foncière, décret du 15 novembre 1935 relatif aux terres domaniales, décret du 20 mai 1955 portant réorganisation foncière et domaniale — ont posé les bases du droit foncier moderne, dont certaines survivent.
- **Les réformes de l'après-guerre.** L'année 1946 marque une rupture : suppression de l'indigénat et de la justice indigène en matière pénale, attribution de la citoyenneté aux ressortissants des territoires d'outre-mer par la loi du 7 mai 1946, dite loi Lamine Guèye, maintien toutefois du statut personnel coutumier pour ceux qui n'y avaient pas renoncé.

La loi-cadre du 23 juin 1956, dite loi Defferre, instaure une large autonomie interne des territoires ; la Constitution française de 1958 crée la Communauté, au sein de laquelle la Côte d'Ivoire devient une République autonome, avant d'accéder à l'indépendance.

2° La construction du droit national (1960-1990)

Indépendante le 7 août 1960, la Côte d'Ivoire se dote d'une Constitution le 3 novembre 1960. Le principe de **continuité législative** maintient en vigueur la législation antérieure, sauf abrogation et sous réserve de sa conformité à la Constitution. Le législateur ivoirien engage alors une politique de **codification nationale** : lois civiles du 7 octobre 1964, qui substituent aux coutumes un droit de la famille unifié ; Code de procédure civile, commerciale et administrative (1972) ; Code pénal (1981) ; codes successifs du travail. La conception dominante est celle d'un droit instrument de modernisation et d'unité nationale.

3° L'ère de l'intégration régionale et des refondations (depuis 1990)

À partir des années 1990, une part croissante du droit procède d'instances supranationales : OHADA (1993), UEMOA (1994), CEDEAO refondée (1993), auxquelles s'ajoutent la Conférence interafricaine des marchés d'assurances (CIMA), l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) et la Conférence interafricaine de la prévoyance sociale (CIPRES). Sur le plan interne, trois constitutions se succèdent ou s'enchaînent (1960, 2000, 2016), et les années 2010 voient une vague de refontes : Code du travail (2015), Code de procédure pénale (2018), Code pénal et lois sur la famille (2019).

3. Explication approfondie des concepts

DÉFINITION — SYSTÈME JURIDIQUE

Ensemble organisé de règles, d'institutions, de méthodes et de représentations propre à une société donnée. On parle du système juridique ivoirien ou du système juridique français.

DÉFINITION — FAMILLE DE DROITS

Groupe de systèmes juridiques qui présentent des traits communs suffisamment marqués (origine historique, sources, méthodes, institutions) pour être étudiés ensemble (famille romano-germanique, famille de *common law*).

DÉFINITION — SYSTÈME MIXTE

Système juridique qui combine de manière durable des éléments empruntés à plusieurs traditions juridiques (par exemple droit civil et *common law*, ou droit d'origine européenne et droit coutumier ou religieux).

DÉFINITION — RÉCEPTION (OU TRANSFERT) JURIDIQUE

Adoption par un système juridique de règles, d'institutions ou de techniques élaborées dans un autre système, par voie d'imposition, d'imitation volontaire ou d'harmonisation.

Tableau 1 — Les grandes traditions juridiques (traits dominants)

Trait	Romano-germanique	*Common law*	Droit musulman	Droits africains traditionnels
Source principale	Loi, codes	Précédents judiciaires, lois	Coran, Sunna, *ijma*, *qiyas*	Coutume orale
Rôle du juge	Interprète et applique la loi	Crée le droit par le précédent	Applique un droit révélé interprété par les savants	Concilie et rétablit l'équilibre
Rôle de la doctrine	Éminent (systématisation)	Secondaire, croissant	Central (écoles juridiques)	Rôle des anciens et des détenteurs de la tradition
Mode de raisonnement	Déductif, à partir de règles générales	Inductif, du cas au cas	Déductif et analogique	Casuistique, orienté vers la conciliation
Distinction public / privé	Fondamentale	Moins marquée	Étrangère à la tradition	Étrangère à la tradition
Exemple	France, Allemagne, Côte d'Ivoire (dominante)	Angleterre, États-Unis, Ghana, Nigeria	Statut personnel dans de nombreux États	Foncier rural, chefferie (reconnaissance encadrée)

DROIT COMPARÉ —

Le Cameroun, État membre de l'OHADA, offre l'exemple d'un système **bijuridique** : les régions anglophones relèvent historiquement de la *common law*, le reste du territoire de la tradition civiliste. Cette situation explique que l'OHADA ait dû se préoccuper de la traduction de ses actes uniformes en anglais : le Traité révisé à Québec en 2008 fait du français, de l'anglais, de l'espagnol et du portugais les langues de travail de l'Organisation. Le Ghana voisin, ancienne colonie britannique, appartient à la famille de la *common law* : la frontière qui le sépare de la Côte d'Ivoire est aussi une frontière entre deux traditions juridiques, ce qui n'a pas empêché le règlement de leur différend relatif à la délimitation maritime, sur le fon-

dement du droit international, par un arrêt d'une Chambre spéciale du Tribunal international du droit de la mer du 23 septembre 2017.

4. Analyse des principes et mécanismes juridiques

A. Les modes de réception du droit

Le droit ivoirien est le produit de plusieurs modes de réception successifs, dont chacun a laissé une trace distincte.

Tableau 2 — Les modes de réception dans la formation du droit ivoirien

Mode	Période	Caractère	Exemple	Trace actuelle
Imposition	1893-1960	Unilatéral, sélectif	Décrets coloniaux, extension du Code civil	Décrets fonciers et domaniaux non abrogés ; Code civil hérité
Réception volontaire	1960-1990	Choix souverain d'un modèle	Lois civiles de 1964, codes nationaux	Architecture des codes ivoiriens
Harmonisation	depuis 1993	Élaboration commune entre États	Actes uniformes OHADA	Droit des affaires uniforme
Intégration	depuis 1994	Délégation de compétences à une Union	Règlements et directives de l'UEMOA	Droit de la concurrence, droit bancaire, finances publiques

B. La continuité du droit et ses conséquences

Lorsqu'un État accède à l'indépendance, il ne peut créer d'un coup un droit entièrement nouveau. Le **principe de continuité législative** maintient donc en vigueur le droit antérieur, sous réserve des textes nouveaux et de sa compatibilité avec la Constitution. Ce principe a des conséquences pratiques considérables, qu'il faut maîtriser.

1. **Le Code civil « figé ».** Le Code civil applicable en Côte d'Ivoire est le Code civil français tel qu'il était en vigueur dans la colonie au moment de l'indépendance, pour toutes ses parties qui n'ont pas été remplacées par des lois ivoiriennes. Les réformes françaises postérieures n'y ont pas été intégrées. Le droit ivoirien des obligations repose ainsi sur les articles 1101 et suivants dans leur rédaction ancienne, alors que la France les a réécrits en 2016.
2. **Les textes coloniaux survivants.** Des décrets coloniaux continuent de régir certaines matières, dans la mesure où ils n'ont pas été abrogés : ainsi, en matière d'immatriculation foncière, le décret du 26 juillet 1932, plusieurs fois modifié, est longtemps demeuré la référence.

3. **La méthode de vérification.** Pour déterminer si un texte antérieur à l'indépendance est applicable, le juriste doit vérifier successivement : (a) que le texte avait été rendu applicable dans la colonie (extension et promulgation locale) ; (b) qu'il n'a pas été abrogé, expressément ou tacitement, par un texte ivoirien ou par un texte communautaire ou uniforme ; (c) qu'il n'est pas contraire à la Constitution en vigueur ; (d) quelle était sa rédaction à la date de l'indépendance, ou à la date de sa dernière modification par le législateur ivoirien.

> **À RETENIR**
>
> Le droit ivoirien n'est pas le droit français. Les textes français postérieurs à 1960 ne s'appliquent pas en Côte d'Ivoire, sauf reprise par le législateur ivoirien. La jurisprudence et la doctrine françaises postérieures peuvent éclairer l'interprétation de textes communs dans leur rédaction ancienne, mais elles n'ont qu'une autorité de persuasion.

C. La mixité du système ivoirien

Le système ivoirien combine aujourd'hui :

– une **base civiliste**, d'origine française : primauté de la loi, codes, distinction du droit public et du droit privé, organisation juridictionnelle et formation des juristes ;
– des **éléments coutumiers reconnus** dans des domaines délimités, principalement le foncier rural et le statut des autorités traditionnelles ;
– un **droit supranational** important, élaboré dans des enceintes où siègent des États de traditions diverses, et interprété par des juridictions régionales (CCJA, Cour de justice de l'UEMOA, Cour de justice de la CEDEAO) ;
– l'influence d'**instruments internationaux** de protection des droits de l'homme, dont l'interprétation relève de juridictions et d'organes régionaux et universels.

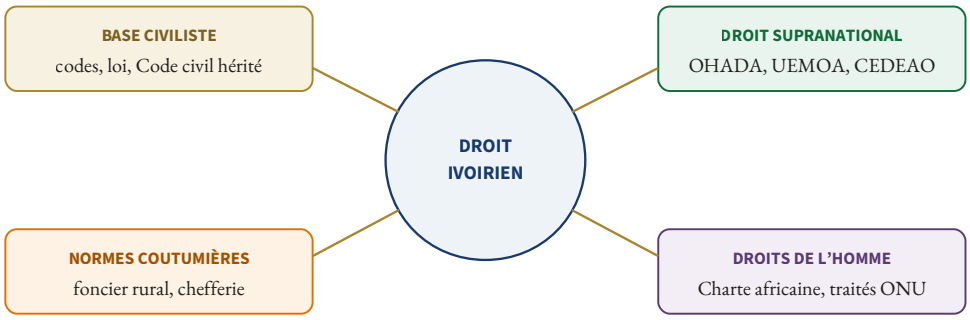


Schéma 1 — Les composantes du système juridique ivoirien

5. Étude des textes applicables

Textes coloniaux de référence. Décret du 10 mars 1893 (création de la colonie) ; décrets d'organisation de la justice en AOF ; décret du 26 juillet 1932 portant réorganisation du régime de la propriété foncière en AOF ; décret du 15 novembre 1935 ; décret du 20 mai 1955. Ces textes doivent toujours être consultés dans leur version applicable en Côte d'Ivoire, compte tenu des modifications intervenues après l'indépendance.

Textes constitutionnels. La Constitution du 8 novembre 2016 comporte, comme ses devancières, des dispositions transitoires qui assurent la continuité de la législation en vigueur dans la mesure où elle n'est pas contraire à la Constitution V. Le principe de cette continuité, constant depuis 1960, explique l'empilement des strates normatives.

Traités d'intégration. Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique (Port-Louis, 17 octobre 1993 ; révisé à Québec le 17 octobre 2008) ; Traité de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (Dakar, 10 janvier 1994 ; modifié le 29 janvier 2003) ; Traité révisé de la CEDEAO (Cotonou, 24 juillet 1993). Ces traités instituent des ordres juridiques dont les normes s'intègrent à l'ordre interne selon des règles propres, étudiées au chapitre 7.

Tableau 3 — Les strates normatives par matière

Matière	Textes hérités (antérieurs à 1960)	Textes ivoiriens	Textes supranationaux
Personnes et famille	— (remplacés)	Lois de 1964 ; lois de 2018 (état civil) et de 2019 (mariage, filiation, successions)	Charte africaine ; Protocole de Maputo
Obligations et contrats	Code civil (rédaction ancienne)	Lois spéciales	AUDCG (vente commerciale) ; AUS (sûretés)
Foncier	Décrets de 1932, 1935, 1955 (dans la mesure où ils subsistent)	Loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 modifiée	—
Droit des affaires	Code de commerce (largement remplacé)	Textes nationaux résiduels	Actes uniformes OHADA
Procédure civile	—	CPCCA (loi n° 72-833 du 21 décembre 1972)	AUPSRVE, AUA
Droit pénal	—	Code pénal (2019) ; CPP (2018)	Incriminations des actes uniformes

6. Analyse de jurisprudences vérifiables

Jurisprudence — TC (France), 22 janvier 1921, Société commerciale de l'Ouest africain (affaire du « bac d'Eloka »)

Faits. La colonie de la Côte d'Ivoire exploitait un bac assurant, moyennant rémunération, la traversée de la lagune Ébrié à Eloka. À la suite d'un accident, la Société commerciale de l'Ouest africain, dont des biens avaient été perdus, agit en responsabilité contre la colonie devant les tribunaux judiciaires.

Question. Le litige relevait-il des juridictions judiciaires ou des juridictions administratives ?

Solution. Le Tribunal des conflits juge que la colonie, en exploitant le bac, exerçait une activité dans les mêmes conditions qu'un industriel ordinaire, et que le litige relevait des juridictions judiciaires.

Portée. L'arrêt est à l'origine de la notion de **service public industriel et commercial**, soumis pour l'essentiel au droit privé, que le droit administratif français a ensuite développée. Il est significatif qu'une notion cardinale du droit administratif français soit née d'un litige ivoirien : le droit colonial n'était pas seulement un droit appliqué aux colonies, il était aussi un lieu de formation du droit métropolitain. La notion est étudiée au Tome 4.

Jurisprudence — CCJA, avis n° 001/2001/EP du 30 avril 2001, rendu à la demande de la République de Côte d'Ivoire

Contexte. La Côte d'Ivoire, qui préparait un avant-projet de loi relatif à certaines matières traitées par les actes uniformes, a sollicité l'avis de la Cour commune de justice et d'arbitrage sur la portée de l'article 10 du Traité OHADA.

Avis. La Cour estime que l'article 10 contient une règle de **supranationalité**, et que l'effet abrogatoire qu'il emporte concerne, sauf dérogations prévues par les actes uniformes eux-mêmes, les dispositions de droit interne ayant le même objet que les actes uniformes et contraires à ceux-ci, qu'elles soient antérieures ou postérieures ; elle précise que cet effet peut porter sur un article, une partie d'article ou un alinéa.

Portée. L'avis fixe la méthode d'articulation entre le droit uniforme et le droit national (chapitre 7). Il montre aussi que la formation du droit ivoirien contemporain se joue en partie hors du territoire national, dans des enceintes régionales dont l'une — la CCJA — siège à Abidjan.

7. Présentation des débats doctrinaux

A. La classification en familles est-elle encore pertinente ?

La classification des droits en familles a été critiquée pour son **européocentrisme** : elle construit les catégories à partir des droits occidentaux et range les droits africains dans une catégorie résiduelle (« autres conceptions »), comme s'ils ne pouvaient être pensés qu'en écart à la norme européenne. Elle a été critiquée aussi pour son **staticité** : elle classe des droits nationaux, alors que les droits contemporains sont traversés par des influences multiples, et que la circulation des modèles (par exemple l'influence croissante de la *common law* dans le droit des affaires) brouille les frontières. Ses défenseurs y voient néanmoins un instrument pédagogique et heuristique irremplaçable, à condition de le manier avec souplesse.

B. Mimétisme juridique et greffes institutionnelles

DÉBAT DOCTRINAL — LES TRANSPLANTATIONS JURIDIQUES SONT-ELLES POSSIBLES ?

La thèse de Watson. Alan Watson a soutenu que l'histoire du droit est, pour l'essentiel, une histoire d'emprunts, et que les règles circulent aisément d'un système à l'autre, souvent sans lien étroit avec les besoins de la société réceptrice[4] DOC.

La thèse de Legrand. Pierre Legrand lui a opposé que les « transplantations » sont impossibles au sens strict : une règle tire son sens de la culture juridique dans laquelle elle s'insère, de sorte que la règle transplantée devient, dans le système récepteur, une autre règle[5] DOC.

Le débat africain. La doctrine africaniste a largement discuté le « mimétisme » des droits et des constitutions des États africains francophones, inspirés du modèle français[6]. Les uns y voient la cause de l'ineffectivité de nombreuses règles ; les autres soulignent que l'emprunt a été souvent un choix délibéré, et que le droit reçu a été réapproprié, adapté et parfois renouvelé — le droit OHADA, élaboré par des États africains et qui a introduit des solutions originales, en fournit l'exemple.

C. L'OHADA : greffe ou appropriation ?

Le droit OHADA est souvent présenté comme une réception du droit français des affaires. L'analyse est trop sommaire : les actes uniformes ont été élaborés dans des enceintes afri-

4. A. Watson, *Legal Transplants. An Approach to Comparative Law*, Scottish Academic Press, 1974.
5. P. Legrand, « The Impossibility of "Legal Transplants" », *Maastricht Journal of European and Comparative Law*, vol. 4, 1997, p. 111.
6. Y. Mény (dir.), *Les politiques du mimétisme institutionnel. La greffe et le rejet*, L'Harmattan, 1993 ; J. du Bois de Gaudusson, « Le mimétisme postcolonial, et après ? », *Pouvoirs*, n° 129, 2009.

caines, avec des apports de traditions diverses, et comportent des institutions originales — statut de l'entreprenant, procédures de recouvrement simplifiées, organisation communautaire de la cassation. La question de leur **effectivité**, notamment dans le secteur informel, demeure en revanche entière.

PROPOSITION DE L'AUTEUR — CLARIFIER LE DROIT APPLICABLE

L'une des faiblesses du système ivoirien tient à l'**opacité** du droit applicable : un Code civil figé dans sa rédaction de 1960, des textes coloniaux dont la survie doit être vérifiée au cas par cas, des actes uniformes qui abrogent partiellement le droit national. Une **consolidation officielle** des textes en vigueur — publication d'un Code civil ivoirien consolidé indiquant, article par article, les dispositions en vigueur, abrogées ou remplacées, et d'un recueil des textes coloniaux maintenus — renforcerait la sécurité juridique et faciliterait l'accès au droit. Une recodification du droit des obligations, inspirée des travaux d'harmonisation régionale, pourrait ensuite être envisagée PP.

8. Illustrations pratiques

L'étudiant qui cite le mauvais Code. Dans une copie sur la responsabilité civile, un étudiant ivoirien cite l'article 1240 du Code civil. Il commet une erreur : cet article est issu de la réforme française de 2016 ; la disposition applicable en Côte d'Ivoire est l'ancien article 1382, dont le texte est identique en substance mais dont la numérotation diffère. L'erreur, bénigne en apparence, révèle une confusion plus grave entre le droit ivoirien et le droit français.

Le contrat conclu à Abidjan. Pour apprécier la validité d'un contrat conclu à Abidjan en 2026, le juriste appliquera le Code civil dans sa rédaction applicable en Côte d'Ivoire (conditions de l'article 1108 ancien : consentement, capacité, objet, cause) et non les nouvelles conditions du droit français (consentement, capacité, contenu licite et certain). Il vérifiera aussi si un acte uniforme régit l'opération (vente commerciale, sûretés).

Le pourvoi mal orienté. Une partie qui entend contester une décision d'appel rendue dans un litige relatif à un acte uniforme doit savoir que la cassation en relève de la CCJA et non de la Cour de cassation ivoirienne. L'appartenance d'une règle à l'ordre juridique OHADA commande la juridiction de cassation compétente (chapitre 10).

9. Cas pratiques corrigés

Cas pratique n° 1 — Quel Code civil ?

Énoncé. Un cabinet d'avocats d'Abidjan doit rédiger une consultation sur la nullité d'un contrat de prestation de services conclu entre deux particuliers. Un jeune collaborateur propose de fonder l'analyse sur les articles 1128 et 1162 du Code civil dans leur rédaction issue de l'ordonnance française du 10 février 2016. Que pensez-vous de cette proposition ?

CORRIGÉ

Problème de droit. Les dispositions du Code civil français issues de réformes postérieures à l'indépendance sont-elles applicables en Côte d'Ivoire ?

Règles applicables. En vertu du principe de continuité législative, le Code civil applicable en Côte d'Ivoire est celui qui était en vigueur dans la colonie au moment de l'indépendance, pour ses parties qui n'ont pas été remplacées par des lois ivoiriennes. Les réformes françaises postérieures, dont l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ne s'appliquent pas en Côte d'Ivoire.

Application. Le contrat de prestation de services entre particuliers relève du droit commun des obligations, qui n'a pas fait l'objet d'une réforme ivoirienne générale. Les conditions de validité sont donc celles de l'article 1108 ancien du Code civil (consentement, capacité, objet certain, cause licite), complétées par les articles 1109 et suivants dans leur rédaction ancienne. Les articles 1128 et 1162 dans leur rédaction de 2016 ne sont pas applicables ; la jurisprudence française antérieure à 2016, rendue sur des textes identiques, peut être citée à titre d'autorité de persuasion.

Conclusion. La proposition doit être écartée. La consultation doit être fondée sur le Code civil dans sa rédaction applicable en Côte d'Ivoire, en vérifiant au préalable qu'aucune loi ivoirienne spéciale ni aucun acte uniforme ne régit l'opération.

Cas pratique n° 2 — Le décret colonial invoqué

Énoncé. Dans un litige relatif à une parcelle rurale, une partie invoque un décret colonial de l'AOF relatif aux terres « vacantes et sans maître » pour soutenir que la parcelle appartient à l'État. Comment déterminer si ce texte est applicable ?

CORRIGÉ

Problème de droit. Un texte colonial antérieur à l'indépendance demeure-t-il applicable en Côte d'Ivoire ?

Méthode. Il convient de vérifier successivement : (a) que le texte avait été rendu applicable en Côte d'Ivoire et y avait été promulgué ; (b) qu'il n'a pas été abrogé, expressément ou tacitement ; (c) qu'il est compatible avec la Constitution ; (d) quelle en est la rédaction en vigueur.

Application. La matière du domaine foncier rural est aujourd'hui régie par la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998, modifiée, qui organise un régime complet de ce

domaine, y compris le sort des terres sans maître et la constatation des droits coutumiers. Les dispositions coloniales qui organisaient différemment les mêmes questions doivent être regardées comme abrogées dans la mesure où elles sont incompatibles avec la loi nouvelle (abrogation tacite), à supposer même qu'elles n'aient pas été expressément abrogées. Il appartient au juriste de vérifier les dispositions abrogatoires de la loi de 1998 et de ses textes modificatifs.

Conclusion. Le litige doit être tranché au regard de la loi de 1998 modifiée ; le décret colonial n'est utile qu'à titre historique ou, le cas échéant, pour apprécier des situations constituées sous son empire (chapitre 8 : application de la loi dans le temps).

10. Synthèse et connaissances essentielles

SYNTHÈSE — CONNAISSANCES ESSENTIELLES

- Le **droit comparé** regroupe les droits en **familles** : romano-germanique, *common law*, droits religieux et traditionnels ; ces classifications sont utiles mais discutées (européocentrisme, staticité).
- Le **droit ivoirien** appartient pour l'essentiel à la **tradition romano-germanique** (primauté de la loi, codes, distinction public/privé).
- Sa formation a connu trois périodes : **coloniale** (régime des décrets, dualité des statuts, indigénat jusqu'en 1946), **nationale** (continuité législative, codifications, lois civiles de 1964), **d'intégration régionale** (OHADA, UEMOA, CEDEAO).
- Le **principe de continuité législative** explique que le Code civil applicable soit celui de l'époque de l'indépendance et que certains textes coloniaux survivent ; les réformes françaises postérieures à 1960 ne s'appliquent pas.
- Le système ivoirien est un **système mixte à dominante civiliste**, qui intègre des normes coutumières reconnues, un droit supranational et des instruments de droits de l'homme.
- L'arrêt du **bac d'Eloka** (TC, 1921), né d'un litige ivoirien, et l'**avis CCJA du 30 avril 2001**, rendu à la demande de la Côte d'Ivoire, jalonnent cette histoire.

11. Questions d'évaluation

QUESTIONS D'ÉVALUATION

Questions de cours

1. Quelles sont les principales familles de droits selon René David ?
2. Qu'est-ce que le régime des décrets dans les colonies françaises ?

3. Quelles réformes l'année 1946 a-t-elle apportées au droit colonial ?
4. Expliquez le principe de continuité législative et ses conséquences.
5. Pourquoi le droit ivoirien peut-il être qualifié de système mixte ?

Questions de réflexion

1. Le droit OHADA est-il une transplantation du droit français ?
2. Quelle autorité attribuer, en Côte d'Ivoire, à la jurisprudence française postérieure à 1960 ?

Sujets de dissertation

1. « Le droit ivoirien, droit civiliste ? »
2. « Le mimétisme juridique en Afrique francophone. »
3. « Continuité et rupture dans la formation du droit ivoirien. »

Commentaire

1. Commentez l'arrêt du Tribunal des conflits du 22 janvier 1921, *Société commerciale de l'Ouest africain*.

12. Références bibliographiques

Droit comparé

R. David et C. Jauffret-Spinosi, *Les grands systèmes de droit contemporains*, Dalloz, coll. « Précis », dernière éd.

K. Zweigert et H. Kötz, *Introduction to Comparative Law*, trad. T. Weir, Oxford, Clarendon Press, 3e éd., 1998.

U. Mattei, « Three Patterns of Law: Taxonomy and Change in the World's Legal Systems », *American Journal of Comparative Law*, vol. 45, 1997.

A. Watson, *Legal Transplants. An Approach to Comparative Law*, Scottish Academic Press, 1974.

P. Legrand, « The Impossibility of "Legal Transplants" », *Maastricht Journal of European and Comparative Law*, vol. 4, 1997.

Droits africains et droit colonial

J. Vanderlinden, *Les systèmes juridiques africains*, PUF, coll. « Que sais-je ? », 1983.

Y. Mény (dir.), *Les politiques du mimétisme institutionnel. La greffe et le rejet*, L'Harmattan, 1993.

J. du Bois de Gaudusson, « Le mimétisme postcolonial, et après ? », *Pouvoirs*, n° 129, 2009.

Coutumiers juridiques de l'Afrique occidentale française, Larose, 1939.

OHADA

J. Issa-Sayegh et J. Lohoues-Oble, *OHADA. Harmonisation du droit des affaires*, Bruylant, 2002.

Sources officielles

Traité OHADA (1993, révisé en 2008); Traité de l'UEMOA (1994, modifié en 2003); Traité révisé de la CEDEAO (1993); avis de la CCJA n° 001/2001/EP du 30 avril 2001.

CHAPITRE 6

Les divisions du droit

1. Introduction et problématique

Le droit n'est pas un bloc indifférencié. Pour l'enseigner, l'étudier, l'appliquer, on le divise en **branches** : droit constitutionnel, droit administratif, droit civil, droit commercial, droit pénal, droit du travail, droit international, et bien d'autres. Ces divisions ne sont pas de simples commodités académiques. Elles commandent, dans une large mesure, le **régime juridique** applicable à une situation : les règles de fond, la juridiction compétente, la procédure, les modes d'exécution des décisions. Savoir qu'un litige relève du droit administratif plutôt que du droit civil, c'est savoir quel juge saisir, quelles règles invoquer et quelles voies d'exécution employer.

La plus ancienne et la plus importante de ces divisions oppose le **droit public** et le **droit privé**. Héritée du droit romain, consacrée par l'organisation juridictionnelle française, elle a été reçue en Côte d'Ivoire. Elle est pourtant contestée : la frontière entre les deux droits est mouvante, des branches entières (droit pénal, droit du travail, droit de l'environnement) participent des deux, et la montée en puissance des droits communautaire et uniforme brouille les catégories traditionnelles.

Problématique. *La distinction du droit public et du droit privé conserve-t-elle une valeur explicative et opératoire dans un droit marqué par l'interpénétration des branches et la superposition des ordres juridiques ?* Le chapitre montrera que la summa divisio demeure un instrument indispensable de **qualification** — parce qu'elle commande des régimes et des compétences —, mais qu'elle doit être maniée comme une distinction de régimes plutôt que comme une séparation de mondes, et complétée par d'autres divisions : droit interne et international, droit national, communautaire et uniforme, droit commun et droit spécial, droit substantiel et droit processuel.

2. Fondements historiques et théoriques

A. L'origine romaine de la distinction

La distinction remonte à un texte célèbre d'Ulpien, placé en tête du Digeste : le droit public est celui qui concerne l'état de la chose romaine, le droit privé celui qui concerne l'utilité des particuliers[1]. Le critère est celui de l'**intérêt** : intérêt de la collectivité politique d'un côté, intérêt des individus de l'autre. Pour les Romains, la distinction n'avait pas la portée institutionnelle qu'elle a prise à l'époque moderne : l'essentiel de la science juridique romaine portait sur le droit privé.

B. La construction moderne : séparation de l'État et de la société civile

La distinction prend sa signification moderne avec la formation de l'État et de la société civile comme sphères distinctes. En France, la Révolution interdit aux tribunaux judiciaires de connaître des actes de l'administration : la loi des 16-24 août 1790 prohibe aux juges de troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs. Cette prohibition a conduit à l'émergence d'une **juridiction administrative** spécialisée, puis d'un **droit administratif** autonome, que le Tribunal des conflits a consacré en jugeant, dans l'arrêt *Blanco* de 1873, que la responsabilité de l'État à raison des dommages causés par ses services publics ne peut être régie par les principes établis dans le Code civil pour les rapports entre particuliers.

La summa divisio est ainsi devenue, en droit français, à la fois une **distinction de règles** (droit administratif contre droit civil) et une **distinction de juges** (juridictions administratives contre juridictions judiciaires). Les deux aspects se renforcent mutuellement : c'est parce qu'il existe un juge administratif qu'un droit administratif autonome a pu se développer.

C. Les contestations doctrinales

La distinction a été contestée dès la fin du XIXe siècle. Léon Duguit rejette la souveraineté de l'État et les prérogatives de puissance publique comme fondement du droit public, au profit de la notion de service public et de la solidarité sociale. Hans Kelsen dénonce le caractère **idéologique** de la distinction : pour la théorie pure, tout droit est création de normes par des organes habilités, et l'opposition entre « puissance » publique et « autonomie » privée masque le fait que le contrat comme la loi sont des actes de production normative. René Savatier décrit, au milieu du XXe siècle, la **publicisation du droit privé**, envahi par l'ordre public économique et l'intervention étatique[2] ; à l'inverse, la doctrine contemporaine observe

1. D. 1, 1, 1, 2 : *Publicum jus est quod ad statum rei Romanae spectat, privatum quod ad singulorum utilitatem.*
2. R. Savatier, *Du droit civil au droit public, à travers les personnes, les biens et la responsabilité civile*, LGDJ, 1945.

une **privatisation du droit public**, avec le recours croissant à des formes et à des techniques de droit privé pour gérer les activités publiques.

D. La réception en Côte d'Ivoire

La Côte d'Ivoire a reçu la distinction du droit public et du droit privé et l'essentiel des notions du droit administratif français. Elle ne l'a cependant pas reçue avec l'organisation juridictionnelle française. Le système ivoirien a longtemps été décrit comme un système d'**unité de juridiction**, ou de dualité seulement partielle : les juridictions de droit commun connaissaient en première instance d'une part importante du contentieux administratif, la chambre administrative de la Cour suprême statuant sur les recours pour excès de pouvoir et en cassation. La Constitution de 2016 a institué une **Cour de cassation** pour l'ordre judiciaire, un **Conseil d'État** pour l'ordre administratif et une **Cour des comptes**, dont l'organisation a été précisée par des lois organiques de 2020. L'organisation précise du contentieux administratif, en évolution, est étudiée au Tome 4.

ÉTAT DU DROIT — POINT DE VIGILANCE

La répartition des compétences entre juridictions de droit commun et Conseil d'État, ainsi que la mise en place éventuelle de juridictions administratives de premier degré, doivent être vérifiées au regard de la loi organique n° 2020-968 relative au Conseil d'État et des textes d'organisation judiciaire en vigueur. Le présent chapitre se borne à en exposer la logique générale.

3. Explication approfondie des concepts

A. Les critères de la distinction du droit public et du droit privé

DÉFINITION — DROIT PUBLIC

Ensemble des règles qui régissent l'organisation de l'État et des autres personnes publiques, ainsi que leurs rapports entre elles et avec les particuliers lorsqu'elles agissent en vertu de prérogatives de puissance publique ou pour la satisfaction de l'intérêt général.

DÉFINITION — DROIT PRIVÉ

Ensemble des règles qui régissent les rapports entre particuliers (personnes physiques et personnes morales de droit privé), ainsi que les rapports entre ceux-ci et les personnes publiques lorsque ces dernières agissent dans les mêmes conditions que des particuliers.

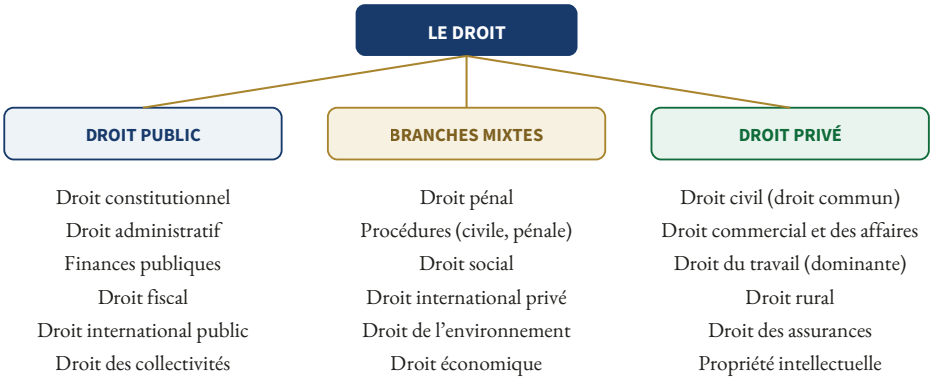
Plusieurs critères ont été proposés pour fonder la distinction ; aucun n'est suffisant à lui seul.

Tableau 1 — Les critères de la distinction du droit public et du droit privé

Critère	Énoncé	Mérite	Limite
Intérêt protégé	Droit public : intérêt général ; droit privé : intérêts particuliers	Critère historique (Ulpien)	Le droit privé protège aussi l'intérêt général (ordre public) ; le droit public protège des intérêts individuels (libertés)
Qualité des sujets	Droit public : rapports impliquant une personne publique	Simple à mettre en œuvre	Les personnes publiques agissent souvent selon le droit privé (bac d'Eloka) ; des personnes privées gèrent des services publics
Nature des rapports	Droit public : rapports inégalitaires (prérogatives de puissance publique) ; droit privé : rapports d'égalité	Rend compte des techniques propres au droit public (décision unilatérale, expropriation)	Le droit privé connaît des rapports inégalitaires (travail, famille)
Finalité et techniques	Droit public : contrainte et intérêt général ; droit privé : autonomie de la volonté	Rend compte des esprits différents des deux droits	Interpénétration croissante des techniques

En pratique, la qualification combine ces critères : une situation relève du droit public lorsqu'elle met en cause une personne publique (ou une personne privée chargée d'une mission de service public) agissant au moyen de prérogatives de puissance publique ou pour l'exécution d'une mission d'intérêt général selon des modalités dérogatoires au droit commun.

B. Les branches du droit



Classement indicatif : les rattachements des branches mixtes sont discutés

Schéma 1 — Les principales branches du droit

Le **droit civil** occupe une place particulière : il est le **droit commun** du droit privé, auquel on revient chaque fois qu'une branche spéciale est silencieuse. Le **droit pénal** est généralement présenté comme une branche mixte : il protège l'ordre public (droit public) mais sanctionne des atteintes aux personnes et aux biens et s'applique par des juridictions judiciaires (droit privé). Le **droit international privé** règle des situations privées (mariage, contrat, succession) présentant un élément d'extranéité, mais par des règles de conflit qui touchent à la souveraineté des États.

C. Les autres divisions du droit

Droit interne et droit international. Le droit interne est celui de l'État ; le droit international public régit les rapports entre États et organisations internationales ; le droit international privé règle les situations privées internationales.

Droit national, droit communautaire et droit uniforme. Cette division, essentielle en Afrique de l'Ouest, distingue trois origines du droit applicable en Côte d'Ivoire.

> **DÉFINITION — DROIT COMMUNAUTAIRE**
>
> Droit produit par les institutions d'une organisation d'intégration (UEMOA, CEDEAO) en vertu des compétences que lui ont transférées les États membres. Il comprend notamment des **règlements**, directement applicables, et des **directives**, qui lient les États quant au résultat à atteindre et doivent être transposées.

DÉFINITION — DROIT UNIFORME

Droit dont le texte est identique dans tous les États qui y sont parties, élaboré en commun et destiné à se substituer aux droits nationaux dans les matières qu'il régit. Les actes uniformes de l'OHADA en sont l'exemple : ils sont directement applicables et obligatoires dans les États Parties (Traité OHADA, art. 10).

Droit commun et droit spécial. Le droit commun s'applique à toutes les situations qui ne font pas l'objet de règles particulières ; le droit spécial régit une catégorie déterminée de situations. Leur articulation obéit à deux adages : *specialia generalibus derogant* (la règle spéciale déroge à la règle générale) et *generalia specialibus non derogant* (la règle générale postérieure ne déroge pas, en principe, à la règle spéciale antérieure).

Droit substantiel et droit processuel. Le droit substantiel (ou matériel) détermine les droits et obligations ; le droit processuel organise leur mise en œuvre devant les juridictions. La distinction commande notamment l'application des lois dans le temps, les lois de procédure étant d'application immédiate (chapitre 8).

4. Analyse des principes et mécanismes juridiques

A. Les conséquences de la qualification

La qualification d'une situation comme relevant du droit public ou du droit privé emporte des conséquences précises.

Tableau 2 — Les conséquences de la qualification

Question	Situation de droit privé	Situation de droit public
Règles de fond	Code civil, droit commercial, droit du travail	Droit administratif (règles jurisprudentielles et textuelles propres)
Juge compétent	Juridictions de l'ordre judiciaire (cassation : Cour de cassation ; CCJA pour les actes uniformes)	Juridictions statuant en matière administrative (Conseil d'État au sommet)
Responsabilité	Responsabilité civile (C. civ., art. 1382 et s.)	Responsabilité administrative (faute de service, risque)
Contrats	Liberté contractuelle, égalité des parties	Contrats administratifs : prérogatives de l'administration (modification, résiliation pour motif d'intérêt général)
Exécution forcée	Voies d'exécution de droit commun (AUPSRVE)	Immunité d'exécution des personnes publiques (AUPSRVE, art. 30, révisé en 2023)
Biens	Propriété privée, aliénable et saisissable	Domaine public inaliénable et insaisissable

B. La méthode de qualification

Face à une situation concrète, le juriste procède par étapes :

1. **Identifier les personnes en cause** : une personne publique est-elle partie ? Une personne privée est-elle investie d'une mission de service public ?
2. **Identifier la nature de l'activité** : s'agit-il d'une activité de service public administratif, d'une activité industrielle ou commerciale exercée dans les conditions d'une entreprise privée, d'une activité de gestion du domaine privé ?
3. **Rechercher les éléments de puissance publique** : la personne publique a-t-elle usé de prérogatives exorbitantes du droit commun (décision unilatérale, clauses exorbitantes dans un contrat) ?
4. **Vérifier les attributions légales** : un texte attribue-t-il expressément le litige à un ordre de juridiction ou soumet-il l'activité à un régime déterminé ?

C. L'articulation du droit commun et du droit spécial

La règle spéciale l'emporte sur la règle générale dans son domaine ; le droit commun s'applique pour tout ce que le droit spécial ne règle pas. Cette articulation est constante dans l'espace OHADA. Ainsi, la vente commerciale entre commerçants est régie par le Livre VIII de l'AUDCG, qui constitue un droit spécial ; le Code civil n'intervient qu'à titre supplétif, pour les questions que l'Acte uniforme ne règle pas. De même, les sociétés commerciales sont régies par l'AUSCGIE, les dispositions du Code civil relatives au contrat de société ne jouant qu'un rôle résiduel.

> **À RETENIR**
>
> Pour résoudre un conflit apparent entre deux règles, il faut successivement : (1) vérifier leur rang hiérarchique (chapitre 7) ; (2) à rang égal, appliquer la règle spéciale de préférence à la règle générale ; (3) à degré de spécialité égal, appliquer la règle postérieure (chapitre 8). Le droit uniforme OHADA obéit en outre à la règle propre de l'article 10 du Traité.

D. L'interpénétration du droit public et du droit privé

La publicisation du droit privé. Le droit privé est de plus en plus pénétré de règles impératives d'inspiration publique : ordre public économique, réglementation des prix, protection des consommateurs, droit du travail, droit de la concurrence. Le droit communautaire de la concurrence de l'UEMOA, mis en œuvre par la Commission de l'Union, soumet les entreprises privées à des règles d'origine supranationale dont la violation est sanctionnée par une autorité publique.

La privatisation du droit public. À l'inverse, les personnes publiques recourent largement aux formes du droit privé. L'AUSCGIE s'applique à toute société commerciale, y compris celles dans lesquelles un État ou une personne morale de droit public est associé (art. 1er) : les sociétés à capitaux publics constituées sous forme de sociétés anonymes relèvent donc, pour leur organisation, du droit uniforme des sociétés. Les services publics industriels et commerciaux sont soumis pour l'essentiel au droit privé, depuis l'arrêt du bac d'Eloka. Les partenariats public-privé contractualisent la réalisation d'équipements publics.

5. Étude des textes applicables

Tableau 3 — Textes intéressant les divisions du droit

Texte	Contenu	Rapport avec les divisions du droit
Constitution de 2016	Institution de la Cour de cassation, du Conseil d'État et de la Cour des comptes	Consécration constitutionnelle d'ordres juridictionnels distincts
Lois organiques n° 2020-967 et n° 2020-968	Attributions, composition, organisation et fonctionnement de la Cour de cassation et du Conseil d'État	Répartition des compétences juridictionnelles
CPCCA (loi n° 72-833 du 21 décembre 1972)	Procédure civile, commerciale **et administrative**	Code de procédure unique pour plusieurs contentieux, trait du système ivoirien
Traité OHADA, art. 10 et 14	Applicabilité directe des actes uniformes ; compétence de la CCJA en cassation	Spécificité du droit uniforme et de sa juridiction
Traité UEMOA	Règlements directement applicables ; directives à transposer ; primauté	Spécificité du droit communautaire
AUSCGIE, art. 1er	Application aux sociétés à participation publique	Privatisation des formes d'action publique
AUPSRVE, art. 30 (rédaction de 1998, remplacée par l'acte révisé de 2023 MOD)	Inapplicabilité de l'exécution forcée aux personnes bénéficiant d'une immunité d'exécution ; compensation de certaines dettes publiques ; nouvel art. 30-1 V	Conséquence de la qualification publique

L'article 30 de l'AUPSRVE, dans sa rédaction de 1998, mérite une attention particulière. Son premier alinéa disposait que l'exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d'une immunité d'exécution. Son second alinéa tempérait ce principe en permettant, à certaines conditions, la compensation des dettes certaines,

liquides et exigibles des personnes morales de droit public ou des entreprises publiques avec les dettes également certaines, liquides et exigibles dont quiconque serait tenu envers elles. Le texte n'indiquait pas lui-même quelles personnes bénéficient de l'immunité : la réponse dépendait du droit applicable à chaque entité, ce qui a nourri un contentieux important.

ÉTAT DU DROIT — UN TEXTE RÉVISÉ : L'ARTICLE 30 DU NOUVEL AUPSRVE

L'AUPSRVE du 10 avril 1998 a été remplacé par un acte révisé, adopté par le Conseil des ministres de l'OHADA le 17 octobre 2023, publié au Journal officiel de l'OHADA le 15 novembre 2023 et entré en vigueur le 16 février 2024 ; l'ancien texte continue de régir les mesures engagées avant cette date MOD. Selon les premiers commentaires, le nouvel article 30 clarifie le champ de l'immunité d'exécution : il exclut l'exécution forcée à l'égard des personnes morales de droit public et ne paraît plus en faire bénéficier les entreprises publiques ; un article 30-1 organise en outre une procédure d'inscription d'office des dettes des personnes publiques DOC. La lettre exacte de ces dispositions doit être vérifiée sur le Journal officiel de l'OHADA V.

6. Analyse de jurisprudences vérifiables

Jurisprudence — TC (France), 8 février 1873, Blanco

Faits. Une enfant, Agnès Blanco, avait été renversée et blessée par un wagonnet d'une manufacture de tabacs exploitée en régie par l'État. Son père agit en responsabilité contre l'État devant les tribunaux judiciaires.

Solution. Le Tribunal des conflits juge que la responsabilité qui peut incomber à l'État pour les dommages causés aux particuliers par le fait des personnes qu'il emploie dans le service public ne peut être régie par les principes établis dans le Code civil pour les rapports de particulier à particulier ; que cette responsabilité n'est ni générale ni absolue et a ses règles spéciales ; et que l'autorité administrative est seule compétente pour l'apprécier.

Portée. L'arrêt lie la compétence du juge administratif à l'application de règles de fond spéciales : il est l'acte fondateur de l'autonomie du droit administratif français, modèle historique du droit administratif ivoirien.

Jurisprudence — Cons. const. (France), déc. n° 86-224 DC, 23 janvier 1987, Conseil de la concurrence

Solution. Le Conseil constitutionnel reconnaît valeur constitutionnelle, au titre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, au principe selon lequel relève en dernier ressort de la compétence de la juridiction administrative l'annulation ou la réformation des décisions prises, dans l'exercice des prérogatives de puissance publique, par les

autorités administratives ; il admet cependant que le législateur puisse, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, unifier les règles de compétence au profit de l'ordre juridictionnel principalement intéressé.

Portée. La décision montre que, en France, la dualité de juridictions n'est pas seulement une donnée historique mais une exigence constitutionnelle partielle. La comparaison souligne la liberté plus grande dont dispose le constituant ivoirien dans l'organisation du contentieux administratif.

Jurisprudence — CCJA, arrêt n° 043/2005 du 7 juillet 2005, Aziablévi Yovo et autres c. Société Togo Télécom

Faits. Des créanciers avaient pratiqué une saisie contre une société de télécommunications présentée comme une entreprise publique de droit togolais. Celle-ci invoquait l'immunité d'exécution de l'article 30 de l'AUPSRVE.

Solution. La CCJA juge, en substance, que l'article 30 de l'AUPSRVE pose le principe de l'immunité d'exécution au profit des personnes morales de droit public et des entreprises publiques visées par ce texte, et que la société en cause, entreprise publique au regard du droit national applicable, pouvait s'en prévaloir.

Portée. La décision a été vivement discutée par la doctrine, qui lui a reproché d'étendre une immunité de puissance publique à des entités exerçant une activité économique sous une forme commerciale, au détriment de la sécurité de leurs créanciers et de l'égalité de concurrence. Elle illustre la difficulté de tracer la frontière entre droit public et droit privé dans le cas des entreprises à capitaux publics, et l'enjeu concret de la qualification. La jurisprudence ultérieure de la CCJA sur la notion d'entreprise publique doit être consultée pour mesurer l'évolution de la question. Surtout, la solution a été rendue sous l'empire de l'article 30 de l'acte de 1998 : la révision de 2023, qui redéfinit le champ de l'immunité, en remet en cause la portée pour les mesures engagées depuis le 16 février 2024 MOD V.

7. Présentation des débats doctrinaux

A. La summa divisio est-elle dépassée ?

DÉBAT DOCTRINAL — DISTINCTION DE RÉGIMES OU SÉPARATION DE MONDES ?

La thèse de la crise. Pour de nombreux auteurs, la distinction du droit public et du droit privé est en crise : interpénétration des techniques, multiplication des branches mixtes, apparition de « droits-carrefours » (droit de l'environnement, droit de la santé, droit du numérique, droit économique) qui ne se laissent pas ranger dans l'une ou l'autre catégorie. Gérard Farjat a ainsi défendu l'autonomie d'un **droit économique**, défini par son objet —

l'organisation de l'économie — plutôt que par la nature publique ou privée de ses règles[3] DOC.

La thèse du maintien. D'autres soulignent que la distinction demeure **opératoire** : tant qu'il existe des personnes publiques dotées de prérogatives spéciales, des biens publics soumis à un régime propre et des juges spécialisés, il faut savoir qualifier DOC.

Synthèse. La distinction gagne à être conçue comme une **distinction de régimes juridiques** — un ensemble de règles qui s'appliquent lorsque certaines conditions sont réunies — plutôt que comme une séparation de deux mondes étanches. Elle est moins un principe de classification des branches du droit qu'un instrument de qualification des situations.

B. Droit uniforme et droit communautaire : une distinction utile

La doctrine africaine a souligné la différence de nature entre le droit uniforme de l'OHADA et le droit communautaire de l'UEMOA ou de la CEDEAO. Le premier procède d'une **technique d'unification** : un texte identique, adopté par le Conseil des ministres de l'OHADA, se substitue aux droits nationaux dans les matières qu'il régit, sans autre institution que celles nécessaires à son élaboration et à son interprétation uniforme. Le second procède d'une **intégration** : les États ont transféré à une Union des compétences dans des domaines déterminés, que ses institutions exercent par des actes de nature diverse (règlements, directives, décisions), sous le contrôle d'une Cour de justice. Les deux ordres peuvent se recouper — ainsi en matière de droit bancaire, de comptabilité ou de concurrence —, ce qui pose des questions de coordination étudiées au Tome 10.

PROPOSITION DE L'AUTEUR — UNE ORGANISATION LISIBLE DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

La création d'un Conseil d'État par la Constitution de 2016 ouvre une réflexion sur l'achèvement du système. Une **spécialisation progressive** — chambres administratives au sein des tribunaux de première instance et des cours d'appel, formées au droit administratif et placées sous le contrôle du Conseil d'État — permettrait de concilier la proximité de la justice, l'unité de la jurisprudence administrative et la maîtrise des coûts, sans reproduire nécessairement la dualité organique française PP.

8. Illustrations pratiques

L'accident causé par un véhicule administratif. Le véhicule d'un ministère heurte un taxi à Abidjan. La victime doit déterminer contre qui agir, devant quel juge et sur quel fondement.

3. G. Farjat, *Droit économique*, PUF, coll. « Thémis », 1971.

L'implication d'une personne publique dans le cadre d'un service public oriente vers le régime de la responsabilité administrative ; mais la nature du contentieux (accident de la circulation) et les règles de compétence ivoiriennes doivent être vérifiées avec soin, de même que l'éventuelle intervention de l'assureur selon le Code CIMA.

Le contrat de collecte des ordures. Une commune confie à une société privée la collecte des ordures ménagères. Le contrat associe le cocontractant à l'exécution d'un service public ; il comporte des clauses qui confèrent à la commune des pouvoirs de contrôle et de sanction. Sa qualification de contrat administratif emporte l'application de règles spéciales : pouvoir de modification unilatérale, droit à l'équilibre financier, compétence du juge administratif.

La saisie contre une société à capitaux publics. Un fournisseur titulaire d'un jugement de condamnation veut saisir les comptes bancaires d'une société détenue majoritairement par l'État et constituée sous forme de société anonyme. La question de l'immunité d'exécution, et donc de la qualification publique ou privée de la débitrice, devient décisive.

9. Cas pratiques corrigés

Cas pratique n° 1 — La société d'État débitrice

Énoncé. La société Batir-CI a obtenu un jugement définitif condamnant la société S., société anonyme dont l'État de Côte d'Ivoire détient la totalité du capital, à lui payer le prix de travaux. S. refuse de payer et invoque son immunité d'exécution lorsque Batir-CI fait pratiquer une saisie-attribution sur ses comptes bancaires. Analysez la situation.

CORRIGÉ

Problème de droit. Une société anonyme à capitaux publics bénéficie-t-elle de l'immunité d'exécution prévue par l'article 30 de l'AUPSRVE ?

Droit applicable dans le temps. L'AUPSRVE de 1998 a été remplacé par un acte révisé entré en vigueur le 16 février 2024 ; l'ancien texte continue de régir les mesures engagées avant cette date. Il faut donc d'abord dater la saisie-attribution MOD.

Règles applicables. *Sous l'acte de 1998*, l'article 30 excluait l'exécution forcée et les mesures conservatoires à l'égard des personnes qui bénéficient d'une immunité d'exécution, tout en organisant un mécanisme de compensation pour les dettes de certaines personnes publiques et entreprises publiques ; la CCJA a admis, dans l'arrêt n° 043/2005 du 7 juillet 2005, qu'une entreprise publique au regard du droit national pouvait se prévaloir de l'immunité, solution discutée par la doctrine. *Sous l'acte révisé de 2023*, le nouvel article 30, selon les premiers commentaires, exclut l'exécution forcée à l'égard des personnes morales de droit public et ne paraît plus en faire bénéficier les

entreprises publiques V. Dans les deux cas, l'AUSCGIE s'applique aux sociétés commerciales dans lesquelles un État est associé (art. 1er).

Application. Deux thèses s'affrontent. Selon la première, inspirée de l'arrêt de 2005, si S. est qualifiée d'entreprise publique par le droit ivoirien qui la régit, elle peut invoquer l'immunité, et Batir-CI devra rechercher le paiement par d'autres voies (compensation, démarches auprès de l'autorité de tutelle, exécution budgétaire). Selon la seconde, une société anonyme soumise au droit uniforme des sociétés, qui exerce une activité économique dans les conditions du marché, ne devrait pas bénéficier d'une immunité réservée à la puissance publique, sauf texte exprès. Il faut donc examiner le statut légal de S., la nature de son activité et l'état de la jurisprudence de la CCJA. Sous l'empire de l'acte révisé, S., société anonyme et donc personne morale de droit privé, ne paraît plus pouvoir invoquer l'immunité, sous réserve de la lettre exacte du nouveau texte V.

Conclusion. L'issue dépend de la date de la saisie (acte de 1998 ou acte révisé de 2023), de la qualification de S. et, sous l'ancien texte, de la jurisprudence de la CCJA. Le conseil de Batir-CI doit sécuriser au préalable la qualification (textes statutaires et législatifs) et envisager, à titre subsidiaire, les mécanismes prévus par le texte applicable (compensation de l'article 30, alinéa 2, de l'acte de 1998 ; articles 30 et 30-1 de l'acte révisé V).

Cas pratique n° 2 — Vente commerciale : quel texte ?

Énoncé. Un grossiste d'Abidjan vend à un commerçant de Bouaké un lot de marchandises. Un litige survient sur le délai dans lequel l'acheteur devait dénoncer les défauts de conformité. Le Code civil et l'AUDCG contiennent-ils des règles concurrentes ? Lesquelles appliquer ?

CORRIGÉ

Problème de droit. Comment articuler les règles du Code civil relatives à la vente et celles de l'AUDCG relatives à la vente commerciale ?

Règles applicables. La vente de marchandises entre commerçants relève du Livre VIII de l'AUDCG (art. 234 et s.), qui constitue un droit spécial et, en vertu de l'article 10 du Traité OHADA, s'impose nonobstant toute disposition contraire de droit interne. En vertu de l'adage *specialia generalibus derogant*, la règle spéciale l'emporte dans son domaine ; le droit commun (Code civil) ne s'applique qu'à titre supplétif, pour les questions non réglées par l'Acte uniforme.

Application. Les deux parties sont commerçantes et la vente porte sur des marchandises : l'opération entre dans le champ du Livre VIII de l'AUDCG. Les règles de l'Acte uniforme relatives à la dénonciation des défauts de conformité et à ses délais doivent

donc être appliquées de préférence à celles du Code civil, dont l'application est exclue sur les points réglés par l'Acte uniforme.

Conclusion. Le litige doit être tranché selon l'AUDCG ; le Code civil n'interviendra, le cas échéant, que pour les questions que l'Acte uniforme ne traite pas.

10. Synthèse et connaissances essentielles

SYNTHÈSE — CONNAISSANCES ESSENTIELLES

- La **summa divisio** oppose le **droit public** (organisation et action des personnes publiques dotées de prérogatives) et le **droit privé** (rapports entre particuliers). Elle remonte à **Ulpien** et a pris sa portée moderne avec la séparation des autorités administratives et judiciaires et l'arrêt **Blanco** (1873).
- Aucun critère (intérêt, sujets, nature des rapports, finalité) n'est suffisant seul ; la qualification les combine.
- La qualification commande les **règles de fond**, le **juge compétent**, le régime de **responsabilité**, des **contrats**, des **biens** et de l'**exécution forcée** (AUPSRVE, art. 30, révisé en 2023).
- La Côte d'Ivoire a reçu la distinction mais avec une **organisation juridictionnelle propre** ; la Constitution de 2016 a institué la Cour de cassation, le Conseil d'État et la Cour des comptes.
- Les autres divisions : droit **interne / international** ; droit **national / communautaire / uniforme** ; droit **commun / spécial** (*specialia generalibus derogant*) ; droit **substantiel / processuel**.
- L'**interpénétration** (publicisation du droit privé, privatisation du droit public) invite à concevoir la summa divisio comme une **distinction de régimes**.

11. Questions d'évaluation

QUESTIONS D'ÉVALUATION

Questions de cours

1. Présentez les critères de distinction du droit public et du droit privé.
2. Quelles sont les conséquences pratiques de la qualification d'une situation de droit public ?
3. Distinguez droit communautaire et droit uniforme.
4. Expliquez les adages *specialia generalibus derogant* et *generalia specialibus non derogant*.

5. Pourquoi le droit pénal est-il présenté comme une branche mixte ?

Questions de réflexion

1. L'arrêt du bac d'Eloka marque-t-il le début de la privatisation du droit public ?
2. L'immunité d'exécution des entreprises publiques est-elle compatible avec les objectifs de l'OHADA ?

Sujets de dissertation

1. « La summa divisio droit public – droit privé en droit ivoirien. »
2. « Droit commun et droit spécial. »
3. « Droit uniforme et droit communautaire en Afrique de l'Ouest. »

Commentaire

1. Commentez l'article 30 de l'AUPSRVE, en comparant sa rédaction de 1998 et celle de l'acte révisé de 2023.

12. Références bibliographiques

Ouvrages généraux

F. Terré, *Introduction générale au droit*, Dalloz, coll. « Précis », dernière éd.

J.-L. Bergel, *Théorie générale du droit*, Dalloz, coll. « Méthodes du droit », dernière éd.

R. Chapus, *Droit administratif général*, Montchrestien, t. 1, dernière éd.

M. Long, P. Weil, G. Braibant, P. Delvolvé et B. Genevois, *Les grands arrêts de la jurisprudence administrative*, Dalloz, dernière éd.

Ouvrages spéciaux

R. Savatier, *Du droit civil au droit public*, LGDJ, 1945.

G. Farjat, *Droit économique*, PUF, coll. « Thémis », 1971.

Droit OHADA et communautaire

J. Issa-Sayegh et J. Lohoues-Oble, *OHADA. Harmonisation du droit des affaires*, Bruylant, 2002.

OHADA. Traité et actes uniformes commentés et annotés, Juriscope, dernière éd.

Sources officielles

Constitution du 8 novembre 2016 ; lois organiques n° 2020-967 et n° 2020-968 ; loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 (CPCCA) ; Traité OHADA ; AUSCGIE ; AUPSRVE (1998) et acte révisé du 17 octobre 2023 ; Traité de l'UEMOA.

CHAPITRE 7

La hiérarchie des normes : Constitution, normes internationales, communautaires et uniformes

1. Introduction et problématique

Un ordre juridique comporte une multitude de normes : Constitution, traités, lois, règlements, décisions individuelles, contrats, jugements. Ces normes ne sont pas juxtaposées ; elles sont **ordonnées**. Une loi doit respecter la Constitution ; un décret doit respecter la loi ; un arrêté ministériel doit respecter le décret ; un contrat doit respecter l'ordre public. Cette organisation verticale, que la doctrine désigne par l'image de la **pyramide des normes**, assure la cohérence de l'ordre juridique et soumet chaque autorité au respect des normes supérieures : elle est au fondement de l'**État de droit**.

En Côte d'Ivoire, l'exercice est rendu particulièrement complexe par la pluralité des sources. Au droit national (Constitution, lois organiques, lois, ordonnances, décrets, arrêtés) s'ajoutent les traités internationaux, le droit communautaire de l'UEMOA et de la CEDEAO, et le droit uniforme de l'OHADA, dont les actes s'appliquent « nonobstant toute disposition contraire de droit interne ». Plusieurs juridictions — Conseil constitutionnel, Cour de cassation, Conseil d'État, CCJA, Cour de justice de l'UEMOA, Cour de justice de la CEDEAO, Cour africaine des droits de l'homme et des peuples — veillent chacune au respect d'une partie de cet édifice.

Problématique. *Comment s'ordonnent, dans l'ordre juridique ivoirien, des normes d'origine nationale, internationale, communautaire et uniforme, et par quels mécanismes le respect de cette hiérarchie est-il garanti ?* Le chapitre montrera que la hiérarchie des normes ivoirienne repose sur la suprématie de la Constitution dans l'ordre interne, sur la supériorité des traités sur les lois et sur la primauté des droits communautaire et uniforme sur le droit national ; mais que l'existence de plusieurs juridictions suprêmes, chacune gardienne d'un ordre, transforme la pyramide en un ensemble plus complexe, dont l'articulation repose sur des règles de conflit et sur le dialogue des juges.

2. Fondements historiques et théoriques

A. La théorie de la pyramide des normes

La représentation hiérarchique de l'ordre juridique a été élaborée par l'École de Vienne, notamment par Adolf Merkl (théorie de la « construction par degrés », *Stufenbau*) et Hans Kelsen. L'ordre juridique est un système **dynamique** : chaque norme est créée selon les conditions fixées par une norme supérieure, qui détermine l'autorité compétente, la procédure à suivre et, éventuellement, le contenu de la norme inférieure. La Constitution habilite le législateur ; la loi habilite le pouvoir réglementaire ; le règlement encadre les décisions individuelles. La validité de chaque norme se mesure à sa conformité à la norme supérieure.

B. L'État de droit

La hiérarchie des normes est l'armature de l'**État de droit**, c'est-à-dire d'un État dans lequel les autorités publiques sont elles-mêmes soumises au droit et dont les actes peuvent être contrôlés par des juges. Carré de Malberg a distingué l'**État légal**, où l'administration est soumise à la loi mais où le législateur est souverain, et l'**État de droit** au sens plein, où le législateur lui-même est soumis à la Constitution sous le contrôle d'un juge[1].

C. L'essor de la justice constitutionnelle

Le contrôle juridictionnel de la constitutionnalité des lois est né aux États-Unis, où la Cour suprême, dans l'arrêt *Marbury v. Madison* (1803), s'est reconnu le pouvoir d'écarter une loi contraire à la Constitution : c'est le modèle **diffus**, dans lequel tout juge peut écarter la loi inconstitutionnelle à l'occasion d'un litige. Kelsen a conçu, pour la Constitution autrichienne de 1920, le modèle **concentré**, dans lequel une juridiction spécialisée, la Cour constitutionnelle, a le monopole du contrôle. Le modèle concentré a été adopté par la plupart des États d'Europe continentale après 1945, puis, à partir des années 1990, par la plupart des États africains francophones, qui ont institué des cours ou conseils constitutionnels.

En Côte d'Ivoire, le Conseil constitutionnel a été mis en place à la suite de la révision constitutionnelle du 16 août 1994 et a commencé à fonctionner en 1995 ; la Constitution de 1960 prévoyait déjà une institution de cette nature, restée longtemps inactive, et le contentieux de l'élection présidentielle relevait jusqu'alors de la Cour suprême. Le Conseil a été maintenu par la Constitution de 2000, organisé par la loi organique n° 2001-303 du 5 juin 2001, puis reconduit par la Constitution du 8 novembre 2016. Il est à la fois juge de la constitutionnalité des lois, juge électoral et régulateur du fonctionnement des institutions.

1. R. Carré de Malberg, *Contribution à la théorie générale de l'État*, Sirey, 2 vol., 1920-1922.

D. L'internationalisation de la hiérarchie des normes

La seconde moitié du XXe siècle a vu se multiplier les normes d'origine internationale et supranationale. La construction européenne a donné naissance à un ordre juridique communautaire dont la Cour de justice des Communautés a affirmé la **primauté** sur les droits nationaux (arrêt *Costa c. ENEL* du 15 juillet 1964). En Afrique de l'Ouest, l'UEMOA et l'OHADA ont repris et adapté cette logique, avec des traits propres. La hiérarchie des normes n'est plus seulement interne : elle est devenue le lieu de l'articulation entre plusieurs ordres juridiques.

3. Explication approfondie des concepts

DÉFINITION — HIÉRARCHIE DES NORMES

Principe d'organisation de l'ordre juridique selon lequel chaque norme doit être conforme aux normes qui lui sont supérieures, la norme inférieure contraire à la norme supérieure étant susceptible d'être annulée, écartée ou privée d'effet par le juge compétent.

DÉFINITION — BLOC DE CONSTITUTIONNALITÉ

Ensemble des normes de valeur constitutionnelle auxquelles les lois doivent être conformes : texte de la Constitution, préambule lorsqu'il fait partie intégrante de la Constitution, et principes de valeur constitutionnelle dégagés par le juge constitutionnel.

DÉFINITION — PRIMAUTÉ

Règle selon laquelle, en cas de conflit, la norme d'un ordre juridique supérieur (international, communautaire, uniforme) l'emporte sur la norme nationale contraire, quel que soit le rang de cette dernière dans l'ordre interne et qu'elle soit antérieure ou postérieure.

DÉFINITION — APPLICABILITÉ DIRECTE

Aptitude d'une norme d'origine externe à s'appliquer dans l'ordre interne sans mesure nationale de réception ou de transposition, et, le cas échéant, à créer des droits et obligations que les particuliers peuvent invoquer devant les juges nationaux (effet direct).

DÉFINITION — SUPRANATIONALITÉ

Qualité d'un ordre juridique dont les normes s'imposent aux États membres et pénètrent directement leur ordre interne, en vertu d'un transfert de compétences consenti par traité, sous le contrôle d'une juridiction commune.

Il faut en outre distinguer trois formes de contrôle, selon la norme de référence :

Tableau 1 — Les formes de contrôle du respect de la hiérarchie des normes

Contrôle	Norme de référence	Norme contrôlée	Juge compétent en Côte d'Ivoire
De constitutionnalité	Constitution	Lois, engagements internationaux, règlements des assemblées	Conseil constitutionnel
De conventionnalité	Traités régulièrement ratifiés	Lois et actes administratifs	Question ouverte en droit ivoirien (v. rubrique 7)
De légalité	Lois (et normes supérieures)	Actes administratifs	Juge administratif (Conseil d'État au sommet) ; juge judiciaire par voie d'exception dans certains cas
De conformité au droit uniforme	Actes uniformes OHADA	Dispositions nationales ayant le même objet	Juges nationaux du fond ; CCJA en cassation et par avis
De conformité au droit communautaire	Traité et actes de l'UEMOA	Droit national	Juges nationaux ; Cour de justice de l'UEMOA

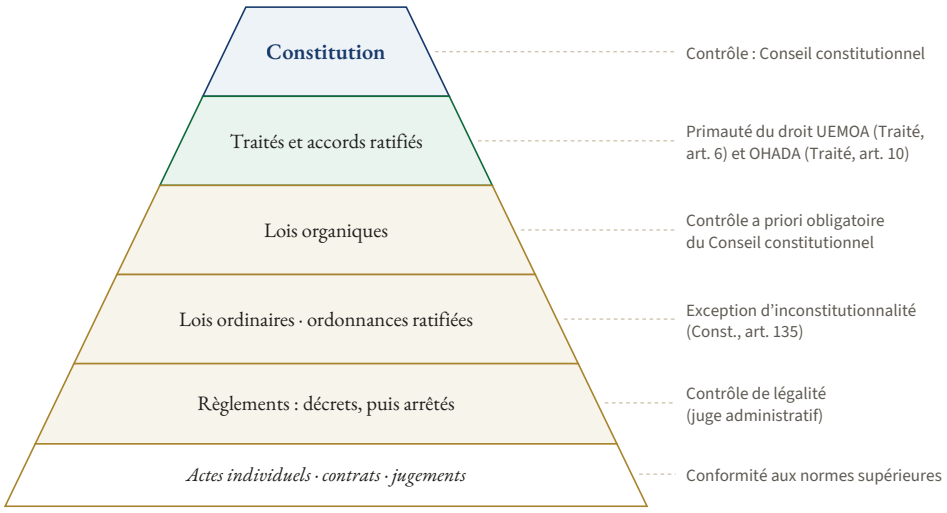


Schéma 1 — La hiérarchie des normes dans l'ordre juridique ivoirien (représentation simplifiée)

Ce schéma doit être lu avec prudence. Il décrit la hiérarchie **dans l'ordre interne**, telle que la commande la Constitution. Du point de vue des ordres juridiques communautaire et uniforme, ce sont leurs propres normes qui prévalent sur toute norme nationale, y compris constitutionnelle, ce qui révèle la coexistence de plusieurs points de vue sur la même hiérarchie (rubrique 7).

4. Analyse des principes et mécanismes juridiques

A. La suprématie de la Constitution et son contrôle

La Constitution est la norme suprême de l'ordre interne : elle fonde la compétence de toutes les autorités et s'impose à toutes. Sa suprématie est garantie par le **Conseil constitutionnel**, selon plusieurs voies.

Le contrôle *a priori*. Avant leur promulgation, certaines lois sont soumises au Conseil : le contrôle est obligatoire pour les lois organiques et facultatif pour les lois ordinaires, sur saisine des autorités habilitées par la Constitution. Le Conseil peut également être saisi des engagements internationaux : si le Conseil constitutionnel a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de le ratifier ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution (Const., art. 122).

Le contrôle *a posteriori* par voie d'exception. La Constitution ouvre à tout plaideur la faculté de soulever l'exception d'inconstitutionnalité d'une loi devant toute juridiction (Const., art. 135). La juridiction saisie sursoit à statuer et impartit au plaideur un délai de quinze jours pour saisir le Conseil constitutionnel ; à l'expiration de ce délai, si le requérant ne rapporte pas la preuve de la saisine, la juridiction poursuit l'instance. Le Conseil constitutionnel a précisé que seul le **plaideur**, c'est-à-dire la partie à une instance juridictionnelle en cours, peut se prévaloir de cette procédure.

L'autorité des décisions. Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours ; elles s'imposent aux pouvoirs publics, à toute autorité administrative, juridictionnelle et militaire et à toute personne physique ou morale (Const., art. 137, al. 4, et 138). Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application.

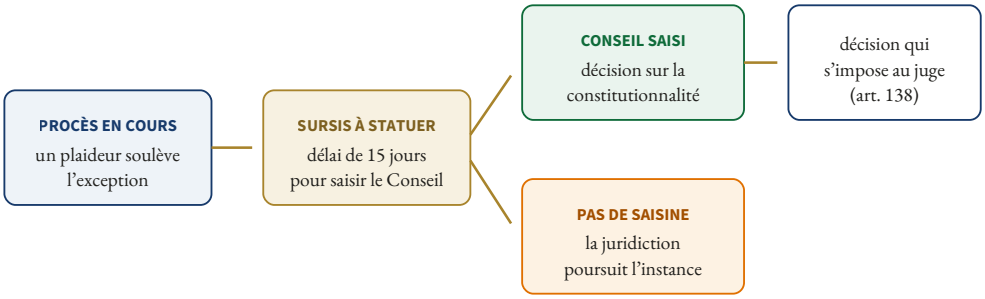


Schéma 2 — L'exception d'inconstitutionnalité (Const., art. 135)

B. Les engagements internationaux

La ratification. Le Président de la République négocie et ratifie les traités ; certains traités — notamment les traités de paix, les traités relatifs aux organisations internationales et ceux qui modifient les lois internes — ne peuvent être ratifiés qu'en vertu d'une loi V. La procédure de ratification est donc un premier filtre de compatibilité entre l'engagement international et l'ordre interne.

Le rang des traités. Les traités ou accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque traité ou accord, de son application par l'autre partie (Const., art. 123 V). Trois conditions conditionnent donc la supériorité : une ratification régulière, une publication, et la réciprocité. La condition de **réciprocité** n'a pas de sens pour les traités qui créent des obligations objectives au profit des personnes, comme les traités de protection des droits de l'homme : ces engagements s'imposent à chaque État partie indépendamment de leur exécution par les autres, comme l'a jugé le Conseil constitutionnel français à propos du Statut de la Cour pénale internationale (déc. n° 98-408 DC du 22 janvier 1999).

La Constitution au-dessus des traités dans l'ordre interne. La procédure de l'article 122 montre que, dans l'ordre interne, la Constitution prévaut sur les traités : un traité contraire à la Constitution ne peut être ratifié qu'après révision de celle-ci. Mais dans l'ordre international, un État ne peut invoquer son droit interne, fût-il constitutionnel, pour justifier l'inexécution d'un traité (Convention de Vienne sur le droit des traités, art. 27).

C. Le droit communautaire de l'UEMOA

Le Traité de l'UEMOA organise un ordre juridique d'intégration dont les actes sont dotés de la **primauté** : les actes arrêtés par les organes de l'Union pour la réalisation des objectifs du Traité, conformément à ses règles et procédures, sont appliqués dans chaque État membre nonobstant toute législation nationale contraire, antérieure ou postérieure (Traité UEMOA,

art. 6). Les **règlements** ont une portée générale, sont obligatoires dans tous leurs éléments et directement applicables dans tout État membre ; les **directives** lient les États quant aux résultats à atteindre (art. 43). La Cour de justice de l'UEMOA veille au respect du droit communautaire et en assure l'interprétation uniforme, notamment par la voie du recours préjudiciel ouvert aux juridictions nationales.

D. Le droit uniforme de l'OHADA

L'article 10 du Traité. Les actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les États Parties, nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure. Cette disposition produit un double effet : un **effet abrogatoire** à l'égard des dispositions nationales antérieures contraires, et un **effet d'interdiction** à l'égard des dispositions nationales postérieures contraires.

La méthode de l'avis de 2001. Saisie par la Côte d'Ivoire, la CCJA a précisé, dans son avis n° 001/2001/EP du 30 avril 2001, que l'article 10 contient une règle de supranationalité, et que l'effet abrogatoire concerne, sauf dérogations prévues par les actes uniformes eux-mêmes, les dispositions de droit interne **ayant le même objet** que les actes uniformes et **contraires** à ceux-ci ; cet effet peut porter sur un article, une partie d'article ou un alinéa. Il en résulte une méthode en deux temps : identifier si la disposition nationale a le même objet qu'une disposition uniforme ; si oui, rechercher si elle lui est contraire. Les dispositions nationales qui ne sont pas contraires, ou qui portent sur des questions non réglées, subsistent.

Les renvois au droit national. Les actes uniformes renvoient parfois expressément au droit national, qu'il s'agisse de préciser une règle ou de fixer des sanctions. Ainsi, les actes uniformes peuvent comporter des incriminations pénales, mais les États Parties s'engagent à déterminer les sanctions pénales encourues (Traité OHADA, art. 5) : le droit pénal des affaires OHADA résulte de la combinaison d'incriminations uniformes et de sanctions nationales.

La CCJA, juge de cassation. La CCJA se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d'appel des États Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l'application des actes uniformes, à l'exception des décisions appliquant des sanctions pénales ; lorsqu'elle casse, elle évoque et statue sur le fond (Traité OHADA, art. 14). Elle garantit ainsi l'interprétation uniforme du droit OHADA et se substitue, dans ce domaine, aux juridictions nationales de cassation.

E. La loi, l'ordonnance et le règlement

Lois organiques et lois ordinaires. Les lois organiques, qui précisent l'organisation et le fonctionnement des institutions dans les cas prévus par la Constitution, sont adoptées selon

une procédure renforcée et soumises au contrôle obligatoire du Conseil constitutionnel ; elles s'imposent aux lois ordinaires.

Le domaine de la loi et le domaine du règlement. La Constitution énumère les matières dans lesquelles la loi fixe les règles ou détermine les principes fondamentaux (Const., art. 101) ; les autres matières relèvent du pouvoir réglementaire (Const., art. 103 V). Le règlement est donc tantôt **d'application** (il précise les modalités d'exécution d'une loi), tantôt **autonome** (il intervient dans les matières non réservées à la loi).

Les ordonnances. Le Président de la République peut être habilité par le Parlement à prendre, par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui relèvent normalement du domaine de la loi V. Avant leur ratification, les ordonnances ont une valeur réglementaire ; leur ratification leur confère valeur législative.

La hiérarchie des actes réglementaires. Les décrets du Président de la République l'emportent sur les arrêtés ministériels, qui l'emportent sur les arrêtés des autorités déconcentrées et décentralisées, sous réserve des compétences propres de chacune. Tous sont soumis au **principe de légalité** et peuvent être contestés devant le juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, ou écartés par la voie de l'exception d'illégalité.

L'écran législatif. Lorsqu'un acte réglementaire a été pris en application d'une loi dont il se borne à tirer les conséquences, le juge administratif, qui n'est pas juge de la constitutionnalité des lois, ne peut en apprécier la conformité à la Constitution sans juger la loi elle-même : la loi fait « écran » (CE, sect., 6 novembre 1936, *Arrighi*). En Côte d'Ivoire, la voie de l'exception d'inconstitutionnalité permet de surmonter cet écran.

5. Étude des textes applicables

Tableau 2 — Les textes de la hiérarchie des normes et leur statut de vérification

Texte	Objet	Statut de la référence
Const., art. 101	Domaine de la loi	Vérifié
Const., art. 103	Domaine du règlement	À confirmer V
Const., art. 122	Engagement international comportant une clause contraire à la Constitution	Recoupé
Const., art. 123	Autorité supérieure des traités sur les lois, sous réserve de réciprocité	Recoupé V
Const., art. 135	Exception d'inconstitutionnalité	Vérifié (jurisprudence du Conseil constitutionnel)
Const., art. 137, al. 4, et 138	Autorité des décisions du Conseil constitutionnel	Vérifié (jurisprudence du Conseil constitutionnel)

Texte	Objet	Statut de la référence
Const., art. 178	Limites de la révision constitutionnelle	Vérifié (décisions du Conseil constitutionnel de 2020)
Loi organique n° 2001-303 du 5 juin 2001	Organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel	Recoupé ; version en vigueur à vérifier
Traité OHADA, art. 5, 10 et 14	Incriminations et sanctions ; applicabilité directe ; compétence de la CCJA	Vérifié (texte du Traité)
Traité UEMOA, art. 6 et 43	Primauté ; règlements et directives	Vérifié (texte du Traité)
Convention de Vienne (1969), art. 27	Le droit interne ne justifie pas l'inexécution d'un traité	Vérifié

ÉTAT DU DROIT — POINT DE VIGILANCE

La numérotation des articles de la Constitution de 2016 relatifs aux traités, au domaine réglementaire et aux ordonnances n'a pu être confrontée directement au Journal officiel lors de la rédaction. Elle a été établie par recoupement (décisions du Conseil constitutionnel, travaux universitaires, correspondance avec la Constitution de 2000, dont les articles 84 à 88 traitaient des traités). Le lecteur vérifiera la lettre exacte de ces dispositions avant toute citation.

6. Analyse de jurisprudences vérifiables

Jurisprudence — CCJA, avis n° 001/2001/EP du 30 avril 2001 (demande de la République de Côte d'Ivoire)

Question. Quelle est la portée abrogatoire de l'article 10 du Traité OHADA à l'égard du droit interne ?

Réponse. La Cour énonce que l'article 10 contient une règle de supranationalité ; que l'effet abrogatoire qu'il emporte concerne, sauf dérogations prévues par les actes uniformes, toute disposition de droit interne ayant le même objet que les dispositions des actes uniformes et contraire à celles-ci, qu'elle soit antérieure ou postérieure ; et que cet effet peut s'appliquer à un article, à une partie d'article ou à un alinéa.

Portée. L'avis est la pierre angulaire de l'articulation entre droit uniforme et droit national. Il rejette une conception maximaliste qui aurait abrogé en bloc toute législation nationale intervenant dans les matières harmonisées, au profit d'une approche **disposition par disposition**, fondée sur le double critère de l'identité d'objet et de la contrariété. Il laisse subsister le droit national compatible et oblige le juriste à un travail de comparaison minutieux.

Jurisprudence — Conseil constitutionnel du Sénégal, décision n° 3/C/93 du 16 décembre 1993

Question. Le Traité OHADA, qui confie à une juridiction commune la cassation des décisions nationales dans les matières harmonisées et rend les actes uniformes directement applicables, est-il compatible avec la Constitution sénégalaise et la souveraineté nationale ?

Solution. Le Conseil constitutionnel sénégalais juge le Traité conforme à la Constitution, en considérant en substance que les engagements qu'il comporte réalisent une limitation de souveraineté, et non un transfert prohibé de celle-ci, et qu'ils s'inscrivent dans la perspective de l'unité africaine que la Constitution autorise à poursuivre.

Portée. La décision, rendue au moment de la signature du Traité, a fourni un modèle de raisonnement aux autres États parties pour concilier supranationalité et souveraineté constitutionnelle. La Constitution ivoirienne autorise également la conclusion d'accords comportant abandon partiel de souveraineté en vue de réaliser l'unité africaine V.

Jurisprudence — Cour constitutionnelle du Bénin, décision DCC 06-074 du 8 juillet 2006

Faits. L'Assemblée nationale béninoise avait adopté une révision constitutionnelle prorogeant la durée du mandat des députés en cours.

Solution. La Cour constitutionnelle déclare la révision contraire à la Constitution, en jugeant notamment que le **consensus national**, principe à valeur constitutionnelle issu de la Conférence nationale de 1990, s'impose à toute révision de la Constitution.

Portée. La décision est souvent citée comme l'affirmation, par un juge constitutionnel africain, de limites matérielles à la révision qui ne figurent pas expressément dans le texte constitutionnel. Elle nourrit le débat sur la **supraconstitutionnalité** (rubrique 7).

Jurisprudence — Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire, décision du 19 mars 2020 relative à la loi constitutionnelle portant révision de la Constitution (n° CI-2020-002)

Contexte. Saisi dans le cadre de la procédure de révision constitutionnelle engagée en 2020, le Conseil constitutionnel a examiné la conformité de la révision aux limites posées par la Constitution elle-même.

Solution. Le Conseil constate que la révision a été engagée alors qu'aucune atteinte à l'intégrité du territoire n'était en cours et qu'elle ne remet en cause ni la forme républicaine du Gouvernement ni le principe de laïcité de l'État, conformément à l'article 178 de la Constitution.

Portée. La décision montre que les limites à la révision posées par l'article 178 sont des **normes de référence effectives** du contrôle exercé par le Conseil constitutionnel ivoirien : la

Constitution hiérarchise ses propres dispositions, certaines échappant au pouvoir de révision.

Jurisprudence — Cass. ch. mixte (France), 24 mai 1975, Société des cafés Jacques Vabre ; CE (France), ass., 20 octobre 1989, Nicolo

Solutions. Après le refus du Conseil constitutionnel français de contrôler la conformité des lois aux traités (déc. n° 74-54 DC du 15 janvier 1975, *Interruption volontaire de grossesse*), la Cour de cassation, en 1975, puis le Conseil d'État, en 1989, ont accepté d'écarter l'application d'une loi, même postérieure, contraire à un traité, en se fondant sur l'article 55 de la Constitution française.

Portée. Ces arrêts ont confié aux **juges ordinaires** le contrôle de conventionnalité des lois. Ils offrent un modèle comparatif pour le droit ivoirien, dont la Constitution comporte une disposition analogue à l'article 55 français et dans lequel la question du juge du contrôle de conventionnalité demeure discutée.

Jurisprudence — CE (France), ass., 30 octobre 1998, Sarran, Levacher et autres ; Cass. ass. plén. (France), 2 juin 2000, Fraisse

Solution. Le Conseil d'État, puis la Cour de cassation, jugent que la suprématie conférée aux engagements internationaux sur les lois ne s'applique pas, dans l'ordre interne, aux dispositions de nature constitutionnelle.

Portée. Ces décisions affirment la suprématie de la Constitution dans l'ordre interne, y compris face aux traités. Leur logique est transposable au droit ivoirien, où la procédure de l'article 122 de la Constitution confirme la primauté de la Constitution sur les engagements internationaux au moment de leur ratification.

7. Présentation des débats doctrinaux

A. Pyramide ou réseau ?

DÉBAT DOCTRINAL — LA HIÉRARCHIE DES NORMES À L'ÉPREUVE DE LA PLURALITÉ DES ORDRES

Le constat. François Ost et Michel van de Kerchove ont soutenu que le modèle pyramidal ne rend plus compte des ordres juridiques contemporains, traversés par des normes d'origines multiples, dans lesquels coexistent plusieurs juridictions suprêmes dont aucune n'a le dernier mot sur toutes les questions, et dans lesquels la régulation procède autant de la négociation que du commandement. Ils proposent le modèle du **réseau**[2] DOC.

L'illustration ouest-africaine. L'ordre juridique ivoirien en offre une illustration nette : le Conseil constitutionnel est juge de la Constitution ; la CCJA est juge suprême du droit OHADA, y compris face aux juridictions nationales ; la Cour de justice de l'UEMOA est gardienne du droit communautaire ; la Cour de justice de la CEDEAO et la Cour africaine contrôlent le respect des droits de l'homme par l'État. Chacune affirme la primauté de l'ordre dont elle est gardienne.

Les réponses. La cohérence de l'ensemble repose alors moins sur une hiérarchie unique que sur des **règles de conflit**, sur la **déférence** réciproque et sur le **dialogue des juges**. La pyramide demeure pertinente à l'intérieur de chaque ordre ; le réseau décrit les rapports entre les ordres.

B. La supraconstitutionnalité

Existe-t-il des normes supérieures à la Constitution, qui s'imposeraient même au pouvoir constituant ? La doctrine est partagée. Pour Georges Vedel, la notion de supraconstitutionnalité est dépourvue de sens juridique : le pouvoir constituant est souverain, et une limite à la révision peut toujours être levée par une révision préalable de la disposition qui la pose[3]. Pour d'autres, les clauses d'intangibilité (forme républicaine, laïcité) et les principes fondamentaux dégagés par certains juges constitutionnels (consensus national au Bénin) traduisent une hiérarchie interne à la Constitution, voire l'existence de principes supérieurs. Le Conseil constitutionnel français s'est déclaré incompétent pour contrôler les lois constitutionnelles (déc. n° 2003-469 DC du 26 mars 2003) ; le Conseil constitutionnel ivoirien vérifie, en revanche, le respect des limites de l'article 178 lors des révisions.

C. Le droit OHADA peut-il primer la Constitution ?

Du point de vue de l'ordre juridique OHADA, les actes uniformes s'imposent « nonobstant toute disposition contraire de droit interne », sans distinction selon le rang de cette disposition. Du point de vue de l'ordre interne, en revanche, le Traité OHADA tire sa force de sa ratification, autorisée par la Constitution, et il est inférieur à celle-ci. Le conflit n'est pas théorique : il peut surgir lorsqu'une garantie constitutionnelle (accès au juge, droit de propriété)

2. F. Ost et M. van de Kerchove, *De la pyramide au réseau ? Pour une théorie dialectique du droit*, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 2002.
3. G. Vedel, « Souveraineté et supraconstitutionnalité », *Pouvoirs*, n° 67, 1993.

paraît affectée par une règle uniforme. La doctrine y voit le signe de la coexistence de **deux points de vue légitimes** sur la hiérarchie des normes, dont la conciliation repose sur la prudence des juges et, le cas échéant, sur la révision des textes.

D. Qui contrôle la conventionnalité des lois en Côte d'Ivoire ?

La Constitution ivoirienne confère aux traités une autorité supérieure à celle des lois, mais ne désigne pas expressément le juge chargé d'en assurer le respect. Deux thèses sont concevables. Selon la première, le Conseil constitutionnel, gardien de la Constitution — y compris de la disposition qui pose la supériorité des traités —, serait compétent ; mais il ne connaît des lois que par les voies limitées de sa saisine. Selon la seconde, conforme au modèle français, tout juge, saisi d'un litige, doit faire prévaloir le traité sur la loi contraire, puisque c'est la Constitution elle-même qui le commande.

PROPOSITION DE L'AUTEUR — RECONNAÎTRE LE CONTRÔLE DE CONVENTIONNALITÉ AUX JUGES ORDINAIRES

La seconde thèse paraît préférable. L'article qui confère aux traités une autorité supérieure à celle des lois s'adresse à toutes les autorités chargées d'appliquer le droit, et donc à tous les juges ; le juge saisi d'un litige qui écarte une loi contraire à un traité ne juge pas la loi, il résout un conflit de normes en appliquant la Constitution. Cette solution est d'ailleurs déjà pratiquée, par la force des choses, en droit OHADA : les juges nationaux écartent quotidiennement les dispositions nationales contraires aux actes uniformes. Elle garantirait l'effectivité des engagements internationaux de l'État, notamment en matière de droits de l'homme, et préviendrait des condamnations par les juridictions régionales PP.

8. Illustrations pratiques

Le décret contraire à la loi. Un décret ajoute aux conditions d'exercice d'une profession une exigence que la loi ne prévoit pas. Un professionnel peut en demander l'annulation par la voie du recours pour excès de pouvoir, dans les délais et après le recours administratif préalable éventuellement exigé, ou en contester la légalité par voie d'exception à l'occasion d'un litige où ce décret lui est opposé.

La loi nationale et l'acte uniforme. Une disposition nationale antérieure régissait les délais de prescription en matière commerciale de manière différente de l'AUDCG. En vertu de l'article 10 du Traité et de l'avis de 2001, la disposition nationale, ayant le même objet et étant contraire, est abrogée ; le juge applique l'Acte uniforme.

L'exception d'inconstitutionnalité dans un procès pénal. Un prévenu estime que la loi d'incrimination méconnaît le principe de légalité des délits et des peines. Son avocat soulève

l'exception devant le tribunal, qui sursoit à statuer et lui impartit quinze jours pour saisir le Conseil constitutionnel. L'avocat doit agir sans délai et produire la preuve de la saisine.

La circulaire impérative. Un ministère diffuse une circulaire qui impose aux usagers une pièce justificative non prévue par les textes. Une circulaire ne peut créer d'obligations nouvelles ; si elle le fait, elle excède la compétence de son auteur et peut être contestée. En droit comparé, le Conseil d'État français admet le recours contre les dispositions impératives à caractère général des circulaires (CE, sect., 18 décembre 2002, *Mme Duvignères*).

9. Cas pratiques corrigés

Cas pratique n° 1 — Loi nationale et Acte uniforme

Énoncé. La société X, bailleresse d'un local commercial à Abidjan, invoque contre son locataire une disposition d'une loi ivoirienne antérieure à l'Acte uniforme relatif au droit commercial général, qui lui permet de résilier le bail dans des conditions plus favorables que celles prévues par l'Acte uniforme. Le locataire soutient que seul l'Acte uniforme est applicable. Qui a raison ?

CORRIGÉ

Problème de droit. Une disposition nationale antérieure, relative au bail à usage professionnel et plus favorable au bailleur, demeure-t-elle applicable après l'entrée en vigueur de l'AUDCG ?

Règles applicables. En vertu de l'article 10 du Traité OHADA, les actes uniformes sont directement applicables et obligatoires nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure. Selon l'avis de la CCJA n° 001/2001/EP du 30 avril 2001, l'effet abrogatoire concerne les dispositions de droit interne ayant le même objet que les actes uniformes et contraires à ceux-ci, cet effet pouvant porter sur un article ou une partie d'article.

Application. La disposition nationale invoquée porte sur la résiliation du bail commercial : elle a le même objet que les dispositions de l'AUDCG relatives au bail à usage professionnel. Elle prévoit des conditions de résiliation différentes et plus favorables au bailleur : elle est contraire à l'Acte uniforme. Elle est donc abrogée par l'effet de l'article 10.

Conclusion. Le locataire a raison : seules les règles de l'AUDCG relatives à la résiliation du bail à usage professionnel sont applicables. Le bailleur ne pourrait invoquer une disposition nationale que sur une question non réglée par l'Acte uniforme et non contraire à celui-ci.

Cas pratique n° 2 — L'exception d'inconstitutionnalité

Énoncé. Poursuivi devant le tribunal correctionnel, M. Ouattara soutient que la loi qui fonde les poursuites porte atteinte à la liberté d'expression garantie par la Constitution. (1) Comment doit-il procéder ? (2) Quelles sont les conséquences pour le procès ? (3) Que se passe-t-il si son avocat oublie de saisir le Conseil constitutionnel ? (4) Un ancien prévenu, définitivement jugé, peut-il emprunter la même voie ?

CORRIGÉ

Règles applicables. Tout plaideur peut soulever l'exception d'inconstitutionnalité d'une loi devant toute juridiction ; la juridiction saisie sursoit à statuer et impartit au plaideur un délai de quinze jours pour saisir le Conseil constitutionnel ; à l'expiration de ce délai, à défaut de preuve de la saisine, la juridiction statue (Const., art. 135 ; loi organique relative au Conseil constitutionnel). Les décisions du Conseil s'imposent à toutes les juridictions (Const., art. 138). Le Conseil constitutionnel réserve la qualité de plaideur aux parties à une instance en cours.

Application. (1) M. Ouattara doit soulever l'exception devant le tribunal, en visant précisément la disposition législative contestée et la norme constitutionnelle méconnue. (2) Le tribunal doit surseoir à statuer et lui impartir un délai de quinze jours ; si le Conseil déclare la disposition inconstitutionnelle, elle ne pourra plus être appliquée et les poursuites fondées sur elle perdront leur base légale. (3) Faute de preuve de la saisine dans le délai, le tribunal reprend l'instance et statue en appliquant la loi ; l'omission de l'avocat pourrait engager sa responsabilité professionnelle. (4) Un ancien prévenu définitivement jugé n'est plus partie à une instance en cours : il n'a plus la qualité de plaideur et ne peut emprunter cette voie.

Conclusion. L'exception d'inconstitutionnalité est une arme procédurale efficace mais exigeante, qui suppose une instance en cours et une diligence stricte dans le délai de quinze jours.

Cas pratique n° 3 — Le règlement contraire à un traité

Énoncé. Un arrêté interministériel impose aux ressortissants des États membres de la CEDEAO des conditions de séjour et d'établissement plus restrictives que celles qu'impose le droit communautaire de la libre circulation. Un commerçant ressortissant d'un État membre, à qui l'arrêté est opposé, vous consulte.

CORRIGÉ

Problème de droit. Un acte réglementaire contraire à un engagement communautaire régulièrement ratifié peut-il être écarté ou annulé ?

Règles applicables. Les traités régulièrement ratifiés ont une autorité supérieure à celle des lois (Const., art. 123 V) et, *a fortiori*, à celle des règlements. Le principe de légalité soumet les actes administratifs à l'ensemble des normes qui leur sont supérieures, y compris les engagements internationaux. Le juge administratif contrôle la légalité des actes réglementaires.

Application. Le contrôle de la conformité d'un **règlement** à un traité ne soulève pas la difficulté du contrôle de conventionnalité des lois : le juge administratif, juge de la légalité des actes administratifs, peut annuler un arrêté contraire à un engagement international, sous réserve que cet engagement soit applicable et invocable, et que la condition de réciprocité ne soit pas en cause. Le commerçant peut former un recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté, dans les délais et selon la procédure applicables (recours administratif préalable le cas échéant), ou invoquer son illégalité par voie d'exception. Il peut également, en cas d'échec des voies internes, envisager de saisir la Cour de justice de la CEDEAO, compétente pour connaître des violations des droits de l'homme par les États membres.

Conclusion. L'arrêté est exposé à l'annulation ; le commerçant dispose de voies internes et, à titre subsidiaire, régionales.

10. Synthèse et connaissances essentielles

SYNTHÈSE — CONNAISSANCES ESSENTIELLES

- La **hiérarchie des normes** (Merkl, Kelsen) ordonne l'ordre juridique : chaque norme doit être conforme aux normes supérieures ; elle est l'armature de l'**État de droit**.
- Dans l'ordre interne ivoirien : **Constitution** › **traités** régulièrement ratifiés (Const., art. 123 V, sous réserve de réciprocité) › **lois organiques** › **lois** et ordonnances ratifiées › **règlements** › actes individuels.
- La suprématie de la Constitution est garantie par le **Conseil constitutionnel** : contrôle *a priori* (obligatoire pour les lois organiques), contrôle des engagements internationaux (art. 122), **exception d'inconstitutionnalité** ouverte à tout plaideur avec délai de **quinze jours** (art. 135) ; ses décisions s'imposent à tous (art. 137 et 138).
- Le droit de l'**UEMOA** prime le droit national (Traité, art. 6) ; ses règlements sont directement applicables, ses directives doivent être transposées (art. 43).
- Les actes uniformes **OHADA** sont directement applicables nonobstant toute disposition interne contraire (art. 10) ; selon l'**avis CCJA du 30 avril 2001**, l'effet abrogatoire frappe les dispositions nationales **ayant le même objet et contraires**, disposition par disposition.

– La pluralité des juridictions suprêmes conduit à penser l'ordre juridique comme un **réseau** d'ordres articulés plutôt que comme une pyramide unique.

11. Questions d'évaluation

QUESTIONS D'ÉVALUATION

Questions de cours

1. Exposez la théorie de la pyramide des normes et son lien avec l'État de droit.
2. Quelles sont les conditions de la supériorité des traités sur les lois en droit ivoirien ?
3. Décrivez la procédure de l'exception d'inconstitutionnalité.
4. Quelle est la portée de l'article 10 du Traité OHADA selon l'avis de la CCJA du 30 avril 2001 ?
5. Distinguez règlement et directive dans le droit de l'UEMOA.
6. Qu'est-ce que la théorie de l'écran législatif ?

Questions de réflexion

1. Le droit OHADA est-il supérieur à la Constitution ivoirienne ?
2. Quel juge doit contrôler la conformité des lois aux traités en Côte d'Ivoire ?

Sujets de dissertation

1. « De la pyramide au réseau : la hiérarchie des normes en droit ivoirien. »
2. « La supranationalité dans l'espace OHADA. »
3. « La supraconstitutionnalité existe-t-elle ? »

Commentaire

1. Commentez l'avis de la CCJA n° 001/2001/EP du 30 avril 2001.

12. Références bibliographiques

Théorie générale

H. Kelsen, *Théorie pure du droit*, trad. Ch. Eisenmann, Dalloz, 1962.

R. Carré de Malberg, *Contribution à la théorie générale de l'État*, Sirey, 1920-1922.

F. Ost et M. van de Kerchove, *De la pyramide au réseau ? Pour une théorie dialectique du droit*, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 2002.

G. Vedel, « Souveraineté et supraconstitutionnalité », *Pouvoirs*, n° 67, 1993.

Droit constitutionnel et justice constitutionnelle

F. Hamon et M. Troper, *Droit constitutionnel*, LGDJ, dernière éd.

L. Favoreu et al., *Droit constitutionnel*, Dalloz, coll. « Précis », dernière éd.

G. Conac (dir.), *Les Cours suprêmes en Afrique*, Economica.

Droit OHADA et communautaire

J. Issa-Sayegh et J. Lohoues-Oble, *OHADA. Harmonisation du droit des affaires*, Bruylant, 2002.

P.-G. Pougoué (dir.), *Encyclopédie du droit OHADA*, Lamy, 2011.

Sources officielles

Constitution du 8 novembre 2016 ; loi organique n° 2001-303 du 5 juin 2001 ; décisions du Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire ; Traité OHADA ; avis CCJA n° 001/2001/EP ; Traité de l'UEMOA ; Convention de Vienne sur le droit des traités (1969).

CHAPITRE 8

La loi : élaboration, entrée en vigueur, application dans le temps et dans l'espace

« L'office des lois est de régler l'avenir ; le passé n'est plus en leur pouvoir. »

— Portalis, Discours préliminaire du premier projet de Code civil (1801)

1. Introduction et problématique

Dans les systèmes de tradition civiliste, la **loi** est la source principale du droit. Elle est l'acte par lequel la collectivité politique, à travers ses représentants, fixe les règles générales qui s'imposent à tous. Mais une loi n'existe pas de toute éternité : elle **naît** au terme d'une procédure, **entre en vigueur** à une date déterminée, **s'applique** pendant une certaine durée et dans un certain espace, puis **disparaît** par abrogation. Chacune de ces étapes soulève des questions juridiques précises, dont la méconnaissance conduit à des erreurs graves : appliquer une loi non encore en vigueur, appliquer une loi abrogée, appliquer la loi nouvelle à un contrat conclu sous l'empire de l'ancienne, appliquer la loi ivoirienne à une situation régie par une loi étrangère.

La difficulté majeure tient au **temps**. Les lois changent ; les situations juridiques durent. Un contrat conclu en 2018 produit ses effets en 2026 ; une succession ouverte avant une réforme est liquidée après ; une infraction commise sous l'empire du Code pénal de 1981 est jugée après l'entrée en vigueur du Code de 2019. Quelle loi appliquer ? La réponse doit concilier deux exigences contradictoires : le **progrès du droit**, qui commande d'appliquer au plus vite la loi nouvelle, réputée meilleure, et la **sécurité juridique**, qui commande de ne pas déjouer les prévisions de ceux qui ont agi sous l'empire de la loi ancienne.

Problématique. *Comment la loi s'insère-t-elle dans le temps et dans l'espace sans porter atteinte à la sécurité juridique ?* Le chapitre étudie d'abord le cycle de vie de la loi — élaboration, promulgation, publication, entrée en vigueur, abrogation —, puis les règles qui gouvernent son application dans le temps (non-rétroactivité, effet immédiat, survie de la loi ancienne) et dans l'espace (territorialité, personnalité, conflits de lois).

2. Fondements historiques et théoriques

A. La loi, expression de la volonté générale

La conception moderne de la loi doit beaucoup à Rousseau, pour qui la loi, acte de la volonté générale, est nécessairement générale et ne peut être injuste envers quiconque, puisque nul n'est injuste envers lui-même. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en a fait un principe : « La loi est l'expression de la volonté générale » (art. 6). Le **légicentrisme** qui en est résulté — la loi, œuvre du Parlement représentant la Nation, est souveraine et ne connaît pas de limites juridiques — a dominé le droit français pendant plus d'un siècle et demi.

B. Le déclin du légicentrisme

Le XXe siècle a vu ce modèle s'éroder. La Constitution française de 1958 a **délimité le domaine de la loi** (art. 34) et confié le reste au pouvoir réglementaire autonome (art. 37), dans une logique de rationalisation du parlementarisme. Le contrôle de constitutionnalité a soumis la loi au respect de la Constitution ; la primauté des traités et du droit communautaire l'a soumise à des normes supranationales. La plupart des constitutions africaines francophones ont repris ce modèle : la Constitution ivoirienne de 2016 énumère les matières réservées à la loi (art. 101) et confie les autres au règlement.

C. La question du temps : de Portalis à Roubier

Les rédacteurs du Code civil ont posé le principe de non-rétroactivité dans l'article 2, qui figure toujours dans le Code applicable en Côte d'Ivoire : « La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif. » Portalis en donnait la justification : l'homme, qui ne peut prévoir que l'avenir, ne doit pas être jugé selon des règles qu'il ne pouvait connaître.

Le principe laissait entière la question des situations en cours. La doctrine classique du XIXe siècle l'a résolue par la théorie des **droits acquis** : la loi nouvelle ne peut porter atteinte aux droits acquis sous l'empire de la loi ancienne, mais elle peut affecter les simples expectatives. Paul Roubier a proposé, au milieu du XXe siècle, une construction plus rigoureuse, fondée sur la distinction des effets passés et des effets futurs des situations juridiques, qui s'est imposée en doctrine et a largement inspiré la jurisprudence[1].

D. La question de l'espace : territorialité et personnalité

Dans l'espace, deux principes s'opposent depuis le Moyen Âge : la **territorialité**, selon laquelle la loi d'un État s'applique à tous ceux qui se trouvent sur son territoire, et la **person-**

nalité, selon laquelle la loi suit la personne où qu'elle se trouve. Les juristes médiévaux, à partir des conflits entre les statuts des villes italiennes, ont élaboré la théorie des **statuts** ; Savigny, au XIXe siècle, a proposé de rattacher chaque rapport de droit au « siège » qui lui est propre, fondant la méthode moderne des **règles de conflit de lois** qui structure le droit international privé.

3. Explication approfondie des concepts

A. Les sens du mot « loi »

DÉFINITION — LOI AU SENS FORMEL

Acte adopté par le Parlement selon la procédure législative prévue par la Constitution, quel que soit son contenu.

DÉFINITION — LOI AU SENS MATÉRIEL

Toute règle de droit générale et abstraite, quelle que soit l'autorité qui l'édicte (loi, ordonnance, décret réglementaire, acte uniforme). C'est en ce sens que l'adage « nul n'est censé ignorer la loi » vise toutes les règles.

Au sein des lois au sens formel, on distingue :

- les **lois constitutionnelles**, qui révisent la Constitution ;
- les **lois organiques**, qui précisent l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics dans les cas prévus par la Constitution ;
- les **lois ordinaires**, parmi lesquelles les **lois de finances**, qui déterminent les ressources et les charges de l'État, et les **lois d'habilitation**, qui autorisent le Président de la République à prendre des ordonnances ;
- les **lois référendaires**, adoptées directement par le peuple.

1. P. Roubier, *Le droit transitoire (Conflits des lois dans le temps)*, Dalloz et Sirey, 2e éd., 1960.

B. Les actes du cycle de vie de la loi

DÉFINITION — PROMULGATION

Acte par lequel le Président de la République atteste l'existence de la loi régulièrement adoptée et en ordonne l'exécution. La promulgation intervient dans un délai fixé par la Constitution ; elle n'est pas un acte de législation, mais un acte d'exécution qui rend la loi exécutoire.

DÉFINITION — PUBLICATION

Formalité qui porte la loi à la connaissance du public par son insertion au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. Elle rend la loi opposable aux personnes : une loi non publiée ne peut leur être appliquée.

DÉFINITION — ABROGATION

Suppression pour l'avenir d'une règle de droit par une autorité compétente. Elle est **expresse** lorsque le texte nouveau la prononce, **tacite** lorsqu'elle résulte de l'incompatibilité entre la règle nouvelle et la règle ancienne.

C. Les notions du droit transitoire

DÉFINITION — RÉTROACTIVITÉ

Application d'une loi nouvelle à des faits ou à des effets juridiques entièrement accomplis avant son entrée en vigueur, ou remise en cause de la validité d'actes valablement accomplis sous l'empire de la loi ancienne.

DÉFINITION — EFFET IMMÉDIAT

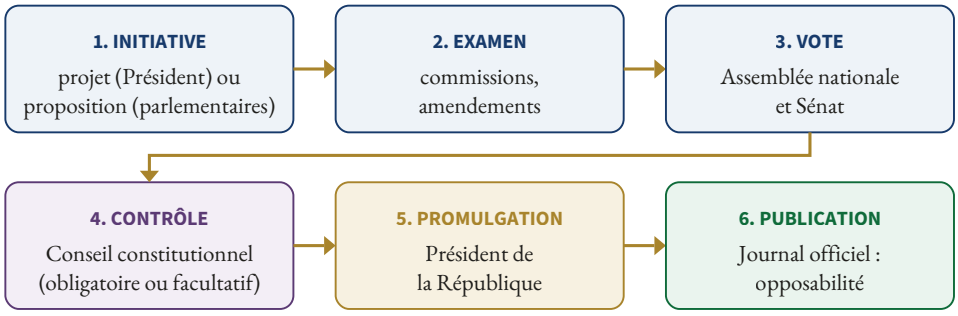
Application de la loi nouvelle, dès son entrée en vigueur, aux situations juridiques en cours, pour leurs effets futurs.

DÉFINITION — SURVIE DE LA LOI ANCIENNE

Maintien de l'application de la loi ancienne, après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, à certaines situations constituées sous son empire, principalement les contrats en cours.

4. Analyse des principes et mécanismes juridiques

A. L'élaboration de la loi



Les modalités précises (navette, délais, procédures d'urgence) sont étudiées au Tome 3

Schéma 1 — Les étapes de l'élaboration de la loi

Depuis la Constitution de 2016, le Parlement ivoirien est **bicaméral** : il comprend l'Assemblée nationale et le Sénat. L'initiative des lois appartient au Président de la République (projets de loi) et aux parlementaires (propositions de loi). Le texte adopté peut, avant sa promulgation, être déféré au Conseil constitutionnel par les autorités que la Constitution habilite — Président de la République, président de l'Assemblée nationale ou du Sénat, une fraction des députés ou des sénateurs, groupes parlementaires — (Const., art. 113 V); ce contrôle est obligatoire pour les lois organiques. La loi est ensuite promulguée par le Président de la République, puis publiée au Journal officiel. Les lois ivoiriennes se terminent traditionnellement par la formule selon laquelle la loi « sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire et exécutée comme loi de l'État ».

B. L'entrée en vigueur

La loi entre en vigueur, en principe, à la suite de sa promulgation et de sa publication, à la date qu'elle fixe elle-même ou, à défaut, selon les règles générales applicables. Plusieurs situations doivent être distinguées :

- **la loi fixe sa date d'entrée en vigueur** : cette date s'impose, y compris lorsqu'elle est différée pour laisser aux intéressés le temps de s'adapter ;
- **la loi renvoie à des textes d'application** : les dispositions dont l'application est subordonnée à l'intervention de décrets n'entrent en vigueur qu'à la date de ces décrets ; les autres dispositions s'appliquent sans attendre ;
- **la loi est muette** : elle entre en vigueur selon les règles générales, après sa publication.

Le droit uniforme OHADA obéit à des règles propres : selon l'article 9 du Traité, les actes uniformes entrent en vigueur quatre-vingt-dix jours après leur adoption, sauf modalités particulières ; ils sont opposables trente jours francs après leur publication au Journal officiel de l'OHADA ; ils sont également publiés au Journal officiel des États Parties, cette formalité étant sans incidence sur leur entrée en vigueur. Les actes uniformes prévoient souvent eux-mêmes des modalités particulières : l'AUDCG révisé, adopté le 15 décembre 2010 et publié au Journal officiel de l'OHADA le 15 février 2011, est ainsi entré en vigueur le 15 mai 2011, quatre-vingt-dix jours après sa publication.

C. La disparition de la loi

L'abrogation expresse résulte d'une disposition de la loi nouvelle. Elle peut être nominative (« la loi n° ... est abrogée ») ou générale (« sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires »), cette dernière formule obligeant l'interprète à identifier lui-même les dispositions incompatibles. Ainsi, le Code pénal de 2019 a expressément abrogé le Code pénal de 1981.

L'abrogation tacite résulte de l'incompatibilité entre la loi nouvelle et la loi ancienne. Elle n'est que partielle si l'incompatibilité est partielle, et se heurte à l'adage *generalia specialibus non derogant* : une loi générale nouvelle n'abroge pas, en principe, une loi spéciale ancienne.

La désuétude — le non-usage prolongé d'une loi — n'emporte pas, en principe, son abrogation dans les systèmes de tradition civiliste : une loi tombée dans l'oubli demeure en vigueur tant qu'elle n'a pas été abrogée. Ce principe protège la sécurité juridique, mais il peut conduire à l'application surprenante de textes oubliés.

Les autres causes de disparition : l'arrivée du terme d'une loi temporaire ; la déclaration d'inconstitutionnalité par le Conseil constitutionnel ; l'abrogation par l'effet d'une norme supérieure, comme l'article 10 du Traité OHADA à l'égard des dispositions nationales contraires aux actes uniformes (chapitre 7).

D. L'application de la loi dans le temps

1° Le principe de non-rétroactivité

La loi nouvelle ne peut remettre en cause les situations juridiques définitivement constituées, ni les effets déjà produits, sous l'empire de la loi ancienne (C. civ., art. 2). En matière civile, ce principe a, dans la tradition française reçue en Côte d'Ivoire, une valeur **législative** : il s'impose au juge, mais le législateur peut y déroger en prévoyant expressément l'application rétroactive d'une loi, sous réserve des exigences constitutionnelles et conventionnelles de sécurité juridique et de procès équitable. En matière pénale, la non-rétroactivité de la loi plus sévère est une exigence de **valeur constitutionnelle**, corollaire du principe de légalité des

délits et des peines (Const., art. 7) et des engagements internationaux de l'État (Charte africaine, art. 7, § 2 ; Pacte international relatif aux droits civils et politiques, art. 15).

2° Le principe de l'effet immédiat

La loi nouvelle s'applique immédiatement aux situations juridiques **en cours** pour leurs **effets futurs**. Ainsi, une loi nouvelle relative aux effets du mariage s'applique, dès son entrée en vigueur, aux couples mariés avant elle, pour l'avenir. Cet effet immédiat n'est pas une rétroactivité : la loi ne revient pas sur le passé, elle régit l'avenir de situations nées dans le passé.

3° La survie de la loi ancienne en matière contractuelle

Les contrats échappent en principe à l'effet immédiat : ils demeurent soumis, même pour leurs effets futurs, à la loi en vigueur au jour de leur conclusion. Cette exception se justifie par la nature du contrat, acte de prévision par lequel les parties organisent leurs rapports en fonction du droit applicable au moment où elles s'engagent ; lui appliquer une loi qu'elles ne pouvaient connaître bouleverserait l'équilibre qu'elles ont voulu. La survie de la loi ancienne cède toutefois devant une volonté contraire du législateur et, selon la jurisprudence de tradition française, devant des lois d'ordre public particulièrement impérieuses.

DROIT COMPARÉ —

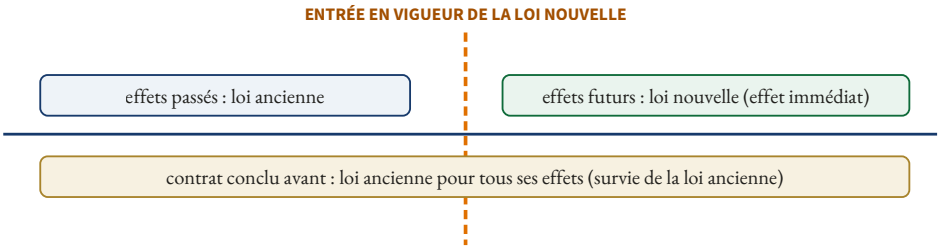
La réforme française du droit des contrats illustre ces principes. L'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 a prévu son entrée en vigueur au 1er octobre 2016, en précisant que les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne (art. 9). La loi de ratification n° 2018-287 du 20 avril 2018 a précisé que cette survie de la loi ancienne vaut y compris pour les effets légaux des contrats et pour les dispositions d'ordre public. Le législateur français a ainsi consacré expressément la survie de la loi ancienne en matière contractuelle.

4° Les exceptions

Tableau 1 — Les exceptions au principe de non-rétroactivité et à l'effet immédiat

Catégorie	Règle	Fondement
Loi expressément rétroactive (matière civile)	Applicable au passé si le législateur l'a voulu, dans les limites de la sécurité juridique et du procès équitable	Valeur législative de l'art. 2 C. civ.
Loi de validation	Validation d'actes dont la légalité est contestée ; admise seulement pour d'impérieux motifs d'intérêt général	Jurisprudence européenne (CEDH, *Zielinski et Pradal*, 1999)

Catégorie	Règle	Fondement
Loi interprétative	Fait corps avec la loi interprétée et s'applique donc depuis l'entrée en vigueur de celle-ci, à condition d'être véritablement interprétative	Nature déclarative de l'interprétation
Loi pénale plus douce	S'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non encore définitivement jugés (rétroactivité *in mitius*)	Pacte international relatif aux droits civils et politiques, art. 15 ; jurisprudence constitutionnelle française
Lois de procédure et de compétence	D'application immédiate aux instances en cours, sans remettre en cause les actes valablement accomplis	Nature des règles de procédure



Synthèse de la théorie de Roubier, sous réserve des exceptions du tableau 1

Schéma 2 — Les conflits de lois dans le temps

E. L'application de la loi dans l'espace

1° Territorialité et personnalité

En principe, la loi ivoirienne s'applique sur le territoire ivoirien (**territorialité**) ; certaines lois suivent cependant les personnes, notamment les lois relatives à l'état et à la capacité (**personnalité**). L'article 3 du Code civil, rédigé pour la France et hérité par la Côte d'Ivoire, énonce trois règles qui ont été lues par la doctrine comme des règles de conflit de portée générale : les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire ; les immeubles sont régis par la loi du lieu de leur situation ; les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les nationaux, même résidant à l'étranger.

La loi pénale obéit principalement au principe de **territorialité** : elle s'applique aux infractions commises sur le territoire, quelle que soit la nationalité de leur auteur, avec des extensions (compétence personnelle active et passive, compétence réelle, compétence universelle) étudiées au Tome 7.

2° Les conflits de lois en droit international privé

Lorsqu'une situation privée présente des liens avec plusieurs États — un mariage entre un Ivoirien et une Ghanéenne, un contrat entre une société ivoirienne et une société française, une succession comprenant des biens situés dans plusieurs pays —, il faut déterminer la loi applicable. La méthode classique consiste à **qualifier** la question (statut personnel, contrat, responsabilité, succession…), puis à appliquer la **règle de conflit** correspondante, qui désigne la loi applicable au moyen d'un **critère de rattachement** (nationalité, domicile, lieu de situation du bien, lieu de conclusion de l'acte, volonté des parties). Trois correctifs tempèrent le jeu des règles de conflit :

– l'**exception d'ordre public international**, qui permet d'écarter la loi étrangère normalement compétente lorsque son application heurterait les valeurs fondamentales du for ;
– la **fraude à la loi**, qui permet d'écarter le rattachement artificiellement créé pour échapper à la loi normalement applicable ;
– les **lois de police**, dont l'application s'impose quelle que soit la loi désignée par la règle de conflit, en raison de leur importance pour l'organisation politique, sociale ou économique de l'État.

3° L'espace du droit uniforme

Le droit uniforme OHADA réduit les conflits de lois entre États parties dans les matières harmonisées, puisque la même règle s'y applique. Il ne les supprime pas entièrement : les matières non harmonisées et les rapports avec des États tiers continuent de relever des règles de conflit. Le champ territorial des actes uniformes est en outre défini par chacun d'eux : ainsi, l'AUSCGIE s'applique aux sociétés commerciales dont le siège social est situé sur le territoire de l'un des États parties (art. 1er).

5. Étude des textes applicables

Tableau 2 — Textes relatifs à la vie et à l'application de la loi

Texte	Disposition	Observation
Const., art. 101	Domaine de la loi	Vérifié
Const., art. 113	Saisine du Conseil constitutionnel avant promulgation	Recoupé V
Const., art. 7	Légalité des délits et des peines	Recoupé (jurisprudence du Conseil constitutionnel)
C. civ., art. 2	Non-rétroactivité	Rédaction de 1804, applicable en Côte d'Ivoire

Texte	Disposition	Observation
C. civ., art. 3	Lois de police, statut réel immobilier, statut personnel	Rédaction de 1804, lue comme posant des règles de conflit
Traité OHADA, art. 9	Entrée en vigueur et opposabilité des actes uniformes	Rédaction issue de la révision de 2008
Loi n° 2019-574 du 26 juin 2019	Code pénal ; abrogation du Code pénal de 1981	Dispositions transitoires à consulter
Charte africaine, art. 7, § 2	Non-rétroactivité de la loi pénale	
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, art. 15	Non-rétroactivité ; application de la peine plus légère	

ÉTAT DU DROIT — POINT DE VIGILANCE

Le délai constitutionnel de promulgation des lois, les règles générales d'entrée en vigueur des lois et règlements en l'absence de date fixée par le texte, ainsi que les dispositions transitoires des grandes réformes de 2018 et 2019 (Code de procédure pénale, Code pénal, lois sur la famille) doivent être vérifiés sur les textes officiels. Le présent chapitre en expose les principes ; les régimes transitoires propres à chaque réforme sont étudiés dans les tomes correspondants.

6. Analyse de jurisprudences vérifiables

Jurisprudence — Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire, décision n° 2023-001 du 11 mai 2023

Contexte. Saisi par la voie de l'exception d'inconstitutionnalité, le Conseil constitutionnel a eu à examiner un grief relatif à l'application dans le temps de la loi pénale, dans le contexte du remplacement du Code pénal de 1981 par celui de 2019.

Apports. La décision rappelle que l'article 7 de la Constitution consacre le principe selon lequel nul ne peut être puni hors des cas prévus par la loi, et relève que le Code pénal de 2019 a abrogé le Code de 1981.

Intérêt. La décision témoigne de l'usage de l'exception d'inconstitutionnalité pour contester l'application de la loi pénale dans le temps. Le lecteur se reportera au texte intégral, publié par le Conseil constitutionnel, pour la solution retenue et sa motivation précise V.

Jurisprudence — Cons. const. (France), déc. n° 80-127 DC des 19 et 20 janvier 1981, Sécurité et liberté

Solution. Le Conseil constitutionnel juge que le fait de ne pas appliquer aux infractions commises sous l'empire de la loi ancienne la loi pénale nouvelle plus douce revient à permettre au juge de prononcer des peines qui, selon l'appréciation même du législateur, ne sont plus nécessaires ; il rattache ainsi la rétroactivité de la loi pénale plus douce au principe de nécessité des peines (art. 8 de la Déclaration de 1789).

Portée. La rétroactivité *in mitius* acquiert valeur constitutionnelle en droit français. Le raisonnement — la loi nouvelle plus douce exprime le jugement actuel du législateur sur la nécessité de la peine — éclaire la règle dans tous les systèmes qui la consacrent, dont le droit international des droits de l'homme.

Jurisprudence — CEDH, gr. ch., 28 octobre 1999, Zielinski et Pradal et Gonzalez et autres c. France

Faits. Le législateur français était intervenu, en cours d'instance, pour valider rétroactivement des actes dont la régularité était contestée devant les juridictions, privant les requérants du bénéfice d'une jurisprudence favorable.

Solution. La Cour juge que le principe de la prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent, sauf pour d'**impérieux motifs d'intérêt général**, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice dans le but d'influer sur le dénouement judiciaire d'un litige.

Portée. La décision encadre les lois rétroactives de validation. Elle illustre la protection supra-législative de la sécurité juridique, que les juridictions africaines des droits de l'homme sont susceptibles de mobiliser sur le fondement du droit au procès équitable (Charte africaine, art. 7).

Jurisprudence — CEDH, gr. ch., 17 septembre 2009, Scoppola c. Italie (n° 2)

Solution. Revenant sur sa jurisprudence antérieure, la Cour juge que l'article 7 de la Convention européenne garantit non seulement la non-rétroactivité des lois pénales plus sévères, mais aussi, implicitement, la rétroactivité de la loi pénale plus douce.

Portée. La rétroactivité *in mitius* devient un droit garanti par la Convention. La solution rejoint l'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, auquel la Côte d'Ivoire est partie.

Jurisprudence — Cass. civ. (France), 18 mars 1878, Princesse de Bauffremont

Faits. Une princesse française, séparée de corps de son mari, s'était fait naturaliser dans un État allemand qui admettait le divorce, alors interdit en France, puis avait divorcé et s'était remariée.

Solution. La Cour de cassation juge le divorce et le remariage inopposables en France, la naturalisation ayant été obtenue dans le seul but d'échapper à la loi française.

Portée. L'arrêt est l'acte fondateur de la théorie de la **fraude à la loi** en droit international privé : la manipulation volontaire du critère de rattachement (ici, la nationalité) pour échapper à la loi normalement applicable est sanctionnée par l'inopposabilité.

7. Présentation des débats doctrinaux

A. Droits acquis ou théorie de Roubier ?

DÉBAT DOCTRINAL — COMMENT RÉSOUDRE LES CONFLITS DE LOIS DANS LE TEMPS ?

La théorie des droits acquis. La doctrine classique distingue les **droits acquis**, que la loi nouvelle doit respecter, et les **simples expectatives**, qu'elle peut librement affecter. La théorie a le mérite de l'intuition, mais elle peine à définir le droit acquis sans pétition de principe : un droit est « acquis » parce qu'on décide de le protéger DOC.

La théorie de Roubier. Roubier substitue à la notion de droit acquis celle de **situation juridique**, et distingue sa constitution, ses effets et son extinction. La loi nouvelle ne peut régir ni la constitution ni l'extinction déjà accomplies, ni les effets déjà produits (non-rétroactivité) ; elle régit les effets futurs des situations en cours (effet immédiat) ; les situations contractuelles, fruit de la volonté des parties, demeurent soumises à la loi ancienne (survie) DOC.

Prolongements. La doctrine contemporaine souligne que la théorie de Roubier, si elle fournit une grille d'analyse rigoureuse, ne dispense pas d'une **pesée des intérêts** : le législateur et le juge mettent en balance l'intérêt de l'application immédiate de la loi nouvelle et la protection des attentes légitimes. La jurisprudence européenne sur la sécurité juridique et les « espérances légitimes » relève de cette logique de proportionnalité.

B. L'inflation législative et la qualité de la loi

L'abondance des textes, leur instabilité et leur complexité menacent l'accessibilité du droit et, partant, le principe même selon lequel nul n'est censé l'ignorer. Le Conseil d'État français l'a dénoncé dans un rapport resté célèbre, en observant que, lorsque le droit bavarde, le citoyen ne lui prête plus qu'une oreille distraite[2]. En Côte d'Ivoire, la difficulté se double d'un problème d'**accès matériel** aux textes : diffusion limitée du Journal officiel, absence de consolida-

2. Conseil d'État, *Rapport public 1991. De la sécurité juridique*, La Documentation française, 1991 ; v. aussi *Rapport public 2006. Sécurité juridique et complexité du droit*.

tion officielle du Code civil, coexistence de textes nationaux, coloniaux, communautaires et uniformes.

PROPOSITION DE L'AUTEUR — UN ACCÈS LIBRE ET CONSOLIDÉ AUX TEXTES

Le principe « nul n'est censé ignorer la loi » n'est légitime que si la loi est réellement accessible. Il serait souhaitable que la Côte d'Ivoire organise la publication électronique gratuite et officielle du Journal officiel, assortie de **versions consolidées** des codes et des principales lois, indiquant pour chaque article sa rédaction en vigueur, son historique et ses modifications. Une telle publication, dont la valeur juridique devrait être précisée par la loi, renforcerait la sécurité juridique et l'égalité des citoyens devant le droit PP.

8. Illustrations pratiques

La succession ouverte avant la réforme de 2019. La dévolution successorale est régie par la loi en vigueur au jour du décès, qui fixe définitivement la qualité d'héritier et la part de chacun. Une succession ouverte avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2019-573 relative aux successions demeure régie par la loi de 1964, même si le partage intervient après la réforme.

L'infraction commise sous l'empire du Code de 1981. Une personne poursuivie après l'entrée en vigueur du Code pénal de 2019 pour des faits commis en 2018 bénéficie de la loi nouvelle si celle-ci est plus douce (suppression de l'incrimination, peine moins sévère) ; si la loi nouvelle est plus sévère, la loi ancienne demeure applicable.

Le contrat de bail en cours. Un bail conclu avant l'entrée en vigueur d'une loi nouvelle demeure en principe régi par la loi en vigueur au jour de sa conclusion, sauf disposition transitoire contraire ou loi d'ordre public impérieux. Le juriste doit donc systématiquement rechercher les dispositions transitoires du texte nouveau.

Le contrat international. Une société ivoirienne conclut un contrat de fourniture avec une société ghanéenne. Les parties ont intérêt à désigner expressément la loi applicable et la juridiction ou l'institution arbitrale compétente, afin d'éviter les incertitudes des règles de conflit.

9. Cas pratiques corrigés

Cas pratique n° 1 — La loi pénale nouvelle

Énoncé. M. Kouamé a commis en 2018 des faits qualifiés de délit par le Code pénal de 1981, punis d'une peine d'emprisonnement. Il est jugé en 2021, après l'entrée en vigueur du Code

pénal de 2019. Quelle loi le tribunal doit-il appliquer (1) si le Code de 2019 prévoit une peine plus légère ; (2) s'il prévoit une peine plus lourde ; (3) s'il a supprimé l'incrimination ?

CORRIGÉ

Problème de droit. Quelle loi pénale appliquer à des faits commis avant l'entrée en vigueur d'une loi nouvelle et jugés après ?

Règles applicables. La loi pénale plus sévère ne rétroagit pas (Const., art. 7 ; Charte africaine, art. 7, § 2) ; la loi pénale plus douce s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés (Pacte international relatif aux droits civils et politiques, art. 15). Les dispositions transitoires du Code de 2019 doivent en outre être consultées.

Application. (1) Si la peine nouvelle est plus légère, elle s'applique à M. Kouamé, dont l'affaire n'est pas définitivement jugée. (2) Si elle est plus lourde, le tribunal applique la peine prévue par le Code de 1981, en vigueur au moment des faits. (3) Si l'incrimination a été supprimée, les faits ne sont plus punissables : M. Kouamé doit être relaxé.

Conclusion. Le tribunal applique toujours la loi la plus favorable au prévenu, sous réserve des dispositions transitoires spéciales et de l'autorité de la chose jugée.

Cas pratique n° 2 — La succession et la réforme

Énoncé. M. Aka est décédé quelques semaines avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2019-573 du 26 juin 2019 relative aux successions. Sa veuve soutient que le partage, qui intervient en 2022, doit être effectué selon la loi nouvelle, plus favorable au conjoint survivant. Les enfants s'y opposent. Qui a raison ?

CORRIGÉ

Problème de droit. La loi successorale applicable est-elle celle du jour du décès ou celle du jour du partage ?

Règles applicables. La loi nouvelle ne rétroagit pas (C. civ., art. 2). La transmission successorale s'opère au jour du décès, qui fixe la qualité d'héritier et la vocation de chacun : la situation juridique est alors constituée. Seules des dispositions transitoires expresses pourraient y déroger.

Application. Le décès est antérieur à l'entrée en vigueur de la loi de 2019 ; la dévolution s'est opérée sous l'empire de la loi ancienne. Appliquer la loi nouvelle reviendrait à modifier rétroactivement les droits nés au jour du décès. Les règles de procédure du partage, en revanche, peuvent relever de la loi nouvelle si elle les modifie.

Conclusion. Les enfants ont raison quant à la détermination des droits successoraux, sous réserve de dispositions transitoires contraires de la loi de 2019, qu'il convient de vérifier.

Cas pratique n° 3 — Le mariage célébré à l'étranger

Énoncé. Mlle Traoré, de nationalité ivoirienne, a épousé à Accra un ressortissant ghanéen, selon les formes locales. Le couple s'installe à Abidjan. Le mariage est-il valable en Côte d'Ivoire ?

CORRIGÉ

Problème de droit. Quelle loi régit la validité d'un mariage célébré à l'étranger entre une Ivoirienne et un étranger ?

Règles applicables. Selon les principes classiques du droit international privé hérités de la tradition française, la **forme** du mariage relève de la loi du lieu de célébration (*locus regit actum*) ; les **conditions de fond** (âge, consentement, absence de mariage antérieur non dissous) relèvent de la loi nationale de chacun des époux ; l'ordre public international peut faire obstacle à la reconnaissance d'un mariage contraire aux valeurs fondamentales du for. Les règles ivoiriennes relatives à la transcription des actes de l'état civil étrangers doivent être respectées.

Application. La forme est valable si les formalités ghanéennes ont été respectées. Au fond, Mlle Traoré doit satisfaire aux conditions de la loi ivoirienne (âge, consentement, absence de mariage antérieur), et son époux à celles de la loi ghanéenne. Si l'époux était déjà marié, le mariage se heurterait, du côté de l'épouse ivoirienne, à la prohibition de la bigamie posée par sa loi nationale.

Conclusion. Le mariage est valable en Côte d'Ivoire si ces conditions sont remplies ; sa transcription sur les registres de l'état civil ivoirien facilitera la preuve. Le droit international privé de la famille est approfondi au Tome 10.

10. Synthèse et connaissances essentielles

SYNTHÈSE — CONNAISSANCES ESSENTIELLES

- La loi au **sens formel** est l'acte adopté par le Parlement ; au **sens matériel**, toute règle générale et abstraite.
- Le cycle de la loi : initiative, examen, vote (Assemblée nationale et Sénat), contrôle éventuel du Conseil constitutionnel, **promulgation** (qui rend la loi exécutoire), **publication** au Journal officiel (qui la rend opposable), **entrée en vigueur**.

– Les actes uniformes OHADA entrent en vigueur **90 jours après leur adoption** et sont opposables **30 jours francs après leur publication** au JO de l'OHADA (Traité, art. 9).
– L'**abrogation** est expresse ou tacite ; la **désuétude** n'abroge pas la loi.
– Dans le temps : **non-rétroactivité** (C. civ., art. 2 ; valeur constitutionnelle en matière pénale), **effet immédiat** pour les effets futurs des situations en cours, **survie de la loi ancienne** pour les contrats (théorie de Roubier).
– Exceptions : lois expressément rétroactives, de validation (impérieux motifs d'intérêt général), interprétatives, **pénales plus douces**, de procédure.
– Dans l'espace : **territorialité** et **personnalité** ; règles de conflit (qualification, rattachement), tempérées par l'**ordre public international**, la **fraude à la loi** (*Bauffremont*) et les **lois de police**.

11. Questions d'évaluation

QUESTIONS D'ÉVALUATION

Questions de cours

1. Distinguez promulgation et publication de la loi.
2. Comment entrent en vigueur les actes uniformes de l'OHADA ?
3. La désuétude abroge-t-elle la loi ?
4. Exposez la théorie de Roubier.
5. Pourquoi les contrats échappent-ils à l'effet immédiat de la loi nouvelle ?
6. Qu'est-ce que la rétroactivité *in mitius* ? Quel en est le fondement ?

Questions de réflexion

1. Le principe « nul n'est censé ignorer la loi » est-il légitime lorsque l'accès aux textes est difficile ?
2. Les lois de validation sont-elles compatibles avec la séparation des pouvoirs ?

Sujets de dissertation

1. « La non-rétroactivité des lois. »
2. « Le temps et la loi. »
3. « La publication des lois, condition de l'État de droit. »

Commentaire

1. Commentez l'article 2 du Code civil : « La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif. »

12. Références bibliographiques

Ouvrages généraux

F. Terré, *Introduction générale au droit*, Dalloz, coll. « Précis », dernière éd.

J. Ghestin et G. Goubeaux, *Traité de droit civil. Introduction générale*, LGDJ, dernière éd.

Ouvrages spéciaux

P. Roubier, *Le droit transitoire (Conflits des lois dans le temps)*, Dalloz et Sirey, 2e éd., 1960.

F. Ost, *Le temps du droit*, Odile Jacob, 1999.

Conseil d'État, *Rapport public 1991. De la sécurité juridique*, La Documentation française, 1991.

Conseil d'État, *Rapport public 2006. Sécurité juridique et complexité du droit*, La Documentation française, 2006.

Droit international privé

Manuels de droit international privé de tradition française (B. Audit, P. Mayer et V. Heuzé, Y. Loussouarn et P. Bourel), dernières éditions.

Sources officielles

Constitution du 8 novembre 2016 ; Code civil (art. 2 et 3) ; Traité OHADA (art. 9) ; loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal ; loi n° 2019-573 du 26 juin 2019 relative aux successions ; Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; Charte africaine des droits de l'homme et des peuples.

CHAPITRE 9

La coutume et les usages

1. Introduction et problématique

La coutume est la plus ancienne des sources du droit. Avant que les États n'écrivent des lois, les sociétés humaines vivaient selon des règles nées de la répétition de pratiques que leurs membres tenaient pour obligatoires. Dans la tradition juridique française, la coutume a longtemps rivalisé avec le droit écrit : la France de l'Ancien Régime était divisée entre pays de droit écrit, au Sud, et pays de coutumes, au Nord, et la rédaction officielle des coutumes, au XVIe siècle, a préparé l'unification du droit réalisée par le Code civil. Depuis 1804, la place de la coutume dans les droits de tradition civiliste s'est considérablement réduite, au profit de la loi.

En Côte d'Ivoire, la question se pose en des termes très différents. La coutume n'y est pas un souvenir historique : elle est une réalité vivante qui règle une part importante de la vie sociale — accès à la terre, mariage, successions de fait, règlement des différends au village. L'État ivoirien a choisi, dès 1964, de l'écarter en matière de personnes et de famille ; il l'a reconnue, en 1998, en matière foncière rurale ; il a doté les autorités coutumières d'un statut en 2014 et d'une institution constitutionnelle en 2016. Dans le monde des affaires, les **usages** — commerciaux, professionnels, internationaux — jouent par ailleurs un rôle considérable, que le droit uniforme OHADA reconnaît.

Problématique. *Quelle place un ordre juridique fondé sur la primauté de la loi écrite peut-il faire à des normes nées spontanément de la pratique sociale ?* Le chapitre montrera que la coutume conserve une fonction de source du droit, mais une fonction **subordonnée et encadrée** : elle tire désormais sa force, dans l'ordre étatique, de la reconnaissance que la loi lui accorde, et elle trouve sa limite dans les normes supérieures, en particulier les droits fondamentaux. Les usages commerciaux, de leur côté, connaissent un regain d'importance dans l'économie mondialisée.

2. Fondements historiques et théoriques

A. La coutume dans l'histoire du droit

Le droit romain connaissait la coutume (*mos maiorum*, *consuetudo*), à laquelle certains textes du Digeste reconnaissent une autorité comparable à celle de la loi, fondée sur le consentement tacite du peuple. Au Moyen Âge, en Europe, la coutume est la source principale du droit dans la plus grande partie des territoires. En France, l'ordonnance de Montils-lès-Tours de 1454 prescrit la rédaction officielle des coutumes, entreprise menée principalement au XVIe siècle ; la Coutume de Paris, rédigée en 1510 puis réformée en 1580, servira de modèle. La loi du 30 ventôse an XII (21 mars 1804), qui promulgue le Code civil, abroge les coutumes générales ou locales dans les matières qui font l'objet du Code.

B. L'École historique et la valorisation de la coutume

Au XIXe siècle, l'École historique allemande renverse la perspective : pour Savigny, la coutume est la manifestation la plus authentique du droit, expression directe de la conscience juridique du peuple, tandis que la loi n'en est qu'une formulation seconde (chapitre 4). Cette valorisation théorique n'a pas empêché le recul pratique de la coutume dans les États européens, mais elle a nourri la réflexion des anthropologues et des juristes africanistes.

C. La coutume en Afrique : de la reconnaissance coloniale à la reconnaissance encadrée

L'administration coloniale française a maintenu les coutumes au profit des « sujets », dans le cadre de la dualité des statuts, sous réserve de leur conformité aux « principes de la civilisation française ». Elle a entrepris de les connaître et de les rédiger — les *Coutumiers juridiques de l'Afrique occidentale française* sont publiés en 1939 —, au risque de les figer. Elle a aussi modifié certaines règles coutumières par voie de décrets, notamment en matière de mariage (décret Mandel du 15 juin 1939, fixant un âge minimal et exigeant le consentement des futurs époux ; décret Jacquinot du 14 septembre 1951, relatif notamment au consentement et à la dot).

À l'indépendance, la Côte d'Ivoire a fait le choix, avec les lois du 7 octobre 1964, de substituer aux coutumes un droit de la famille unifié, applicable à tous les Ivoiriens. Les coutumes ont cessé d'être une source de droit étatique en ces matières. Elles ont conservé, en revanche, une place dans le domaine foncier, où l'État a longtemps toléré, puis reconnu, les droits coutumiers.

3. Explication approfondie des concepts

A. La notion de coutume

DÉFINITION — COUTUME

Règle de droit née de la répétition d'une pratique, généralement suivie pendant une durée suffisante, et considérée par ceux qui l'observent comme juridiquement obligatoire.

La doctrine classique décompose la coutume en deux éléments :

– un **élément matériel** (*corpus*) : un usage, c'est-à-dire une pratique **répétée**, **ancienne**, **constante** et **générale** dans le milieu considéré ;
– un **élément psychologique** (*animus* ou *opinio juris sive necessitatis*) : la conviction, chez ceux qui suivent la pratique, qu'ils y sont tenus juridiquement, et non par simple habitude, politesse ou commodité.

C'est l'élément psychologique qui distingue la coutume du simple usage social : on salue ses voisins par habitude et par politesse, non parce qu'on s'y croit juridiquement obligé.

B. Coutume et usages

Tableau 1 — Coutume et usages

Notion	Définition	Force	Exemples
Usage social	Pratique habituelle sans conviction d'obligation juridique	Aucune force juridique propre	Politesse, cérémonial
Usage conventionnel	Pratique professionnelle à laquelle les parties sont censées s'être référées	Force par la volonté présumée des parties ; doit être prouvé ; peut être écarté	Usages d'une place commerciale, d'une profession
Usage de droit (ou coutume commerciale)	Pratique ayant acquis la force d'une règle de droit dans un milieu donné	Force de règle supplétive, s'impose au juge	Solidarité présumée entre codébiteurs commerciaux en droit français
Coutume	Règle née de la pratique et de la conviction d'obligation	Source de droit dans les limites admises par l'ordre juridique	Droits coutumiers fonciers reconnus par la loi de 1998

C. Les rapports de la coutume et de la loi

La doctrine distingue trois situations :

– la coutume **selon la loi** (*secundum legem*) : la loi elle-même renvoie à la coutume ou aux usages, qui en complètent ou en précisent le contenu (ainsi, l'article 1135 du Code civil prévoit que les conventions obligent à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation ; la loi de 1998 renvoie aux « droits coutumiers conformes aux traditions ») ;
– la coutume **à côté de la loi** (*praeter legem*) : la coutume comble une lacune de la loi, dans un domaine qu'elle ne règle pas ;
– la coutume **contre la loi** (*contra legem*) : la coutume contredit une loi. En principe, elle est sans effet dans un système qui reconnaît la primauté de la loi ; une coutume ne peut abroger une loi, et la désuétude n'emporte pas abrogation.

D. La coutume en droit international

En droit international public, la coutume demeure une source majeure. L'article 38 du Statut de la Cour internationale de justice vise « la coutume internationale comme preuve d'une pratique générale acceptée comme étant le droit ». On y retrouve les deux éléments classiques : une pratique générale des États et l'*opinio juris*. La coutume internationale peut être universelle, régionale ou même bilatérale.

4. Analyse des principes et mécanismes juridiques

A. La preuve de la coutume

La loi n'a pas à être prouvée : le juge est censé la connaître (*jura novit curia*). La coutume, en revanche, pose une question de preuve, puisqu'elle n'est pas écrite. Plusieurs règles se combinent :

– le juge peut connaître lui-même la coutume et l'appliquer d'office lorsqu'elle a la valeur d'une règle de droit ;
– à défaut, la partie qui l'invoque doit en établir l'existence et le contenu, par tous moyens : témoignages, attestations d'autorités coutumières, recueils, expertises, enquêtes ;
– en matière commerciale, l'existence des usages peut être établie par des **parères**, attestations délivrées par des organismes professionnels ou consulaires (chambres de commerce, organisations professionnelles).

La loi ivoirienne relative au domaine foncier rural organise un mode de preuve spécifique des droits coutumiers : l'**enquête officielle**, menée contradictoirement avec les populations, les

autorités coutumières et les voisins, dont les résultats sont validés par les instances villageoises compétentes et qui débouche sur la délivrance du certificat foncier.

B. La reconnaissance de la coutume par la loi foncière ivoirienne

La loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural, modifiée en 2004, 2013 et 2019, organise la rencontre entre le droit étatique et les normes coutumières selon un mécanisme en trois temps.

1. **La reconnaissance.** La loi reconnaît l'existence d'un domaine foncier rural coutumier, constitué par l'ensemble des terres sur lesquelles s'exercent des droits coutumiers conformes aux traditions et des droits coutumiers cédés à des tiers (art. 3).
2. **La constatation.** Les droits coutumiers sont constatés, au terme d'une enquête officielle, par un **certificat foncier**, titre délivré par l'administration (art. 4, dans sa rédaction issue de la loi de 2019 ; décret n° 2019-266 du 27 mars 2019).
3. **La conversion.** Le titulaire du certificat foncier a vocation à faire immatriculer la terre, l'immatriculation conférant le droit de propriété ; seuls l'État, les collectivités publiques et les personnes physiques ivoiriennes sont admis à être propriétaires de terres du domaine foncier rural, les autres titulaires de droits pouvant bénéficier de baux. La réforme de 2019 a en outre interdit les cessions de terres coutumières non couvertes par un certificat foncier (art. 17 bis).

Ce mécanisme traduit une conception de la coutume comme **source transitoire** : elle fonde des droits que la loi reconnaît, mais qu'elle a vocation à transformer en droits écrits du droit commun.

C. Les usages dans le droit des affaires

Les usages jouent un rôle important dans les relations commerciales, caractérisées par la rapidité, la répétition et la spécialisation des opérations.

Les usages conventionnels s'imposent aux parties parce qu'elles sont présumées s'y être référées en contractant dans un milieu où ils sont connus. Ils peuvent être écartés par une stipulation contraire et doivent être prouvés par celui qui les invoque.

Le droit uniforme de la vente. Le Livre VIII de l'AUDCG, consacré à la vente commerciale, s'inspire largement de la Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (Vienne, 11 avril 1980). Cette Convention dispose que les parties sont liées par les usages auxquels elles ont consenti et par les habitudes qui se sont établies entre elles, et qu'elles sont réputées, sauf convention contraire, s'être tacitement référées à tout usage dont elles avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance et qui, dans le com-

merce international, est largement connu et régulièrement observé (art. 9). L'AUDCG fait une place comparable aux usages et aux pratiques établies entre les parties V.

Les usages codifiés. Certains usages du commerce international ont été codifiés par des organismes privés, comme les **Incoterms** de la Chambre de commerce internationale, qui définissent la répartition des frais et des risques dans les ventes internationales. Ces règles n'ont pas de force obligatoire propre : elles s'appliquent parce que les parties s'y réfèrent dans leur contrat.

L'arbitrage. L'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage permet aux arbitres de tenir compte, le cas échéant, des usages du commerce international.

D. Les limites de la coutume

La coutume est subordonnée, dans l'ordre étatique, aux normes écrites supérieures :

- elle ne peut prévaloir contre une loi impérative (pas de coutume *contra legem*) ;
- elle ne peut méconnaître la Constitution et les engagements internationaux de l'État, en particulier les droits fondamentaux ;
- la loi foncière ne reconnaît que les droits coutumiers « conformes aux traditions », et les fait constater selon une procédure contradictoire.

5. Étude des textes applicables

Tableau 2 — Textes relatifs à la coutume et aux usages

Texte	Disposition	Place de la coutume ou des usages
Lois du 7 octobre 1964	Unification du droit des personnes et de la famille	Exclusion des coutumes en ces matières
Loi n° 2019-570 du 26 juin 2019	Mariage ; abrogation de la prohibition de la dot	Retrait de la loi d'un domaine laissé à la pratique sociale, sans effet sur la validité du mariage civil
Loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 modifiée	Domaine foncier rural coutumier (art. 3) ; certificat foncier (art. 4) ; interdiction des cessions de terres non certifiées (art. 17 bis)	Reconnaissance, constatation, conversion
Loi n° 2014-428 du 14 juillet 2014	Statut des Rois et Chefs traditionnels	Statut légal des autorités coutumières
Const., art. 175 et 176	Chambre nationale des Rois et Chefs traditionnels	Consécration constitutionnelle de la chefferie

Texte	Disposition	Place de la coutume ou des usages
C. civ., art. 1135	Suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation	Renvoi aux usages
AUDCG, Livre VIII (art. 234 et s.)	Vente commerciale	Place des usages et pratiques établies
Statut de la CIJ, art. 38	Coutume internationale	Source du droit international

6. Analyse de jurisprudences vérifiables

Jurisprudence — CIJ, 20 février 1969, Plateau continental de la mer du Nord (République fédérale d'Allemagne c. Danemark ; République fédérale d'Allemagne c. Pays-Bas)

Question. La règle de l'équidistance pour la délimitation du plateau continental, prévue par la Convention de Genève de 1958 que la République fédérale d'Allemagne n'avait pas ratifiée, s'imposait-elle à elle comme règle coutumière ?

Solution. La Cour répond par la négative. Elle précise les conditions de formation d'une coutume : une pratique des États, y compris des États particulièrement intéressés, fréquente et pratiquement uniforme, et une conviction que cette pratique est rendue obligatoire par l'existence d'une règle de droit (*opinio juris*). Elle admet qu'une règle conventionnelle puisse devenir coutumière, mais estime que les conditions n'étaient pas réunies en l'espèce.

Portée. L'arrêt est la référence classique sur les éléments constitutifs de la coutume, transposables, *mutatis mutandis*, à l'analyse de la coutume dans les ordres internes.

Jurisprudence — CJ CEDEAO, 27 octobre 2008, Hadijatou Mani Koraou c. République du Niger

Rappel. La Cour de justice de la CEDEAO a jugé l'État du Niger responsable de la servitude subie par une jeune femme au titre d'une pratique coutumière (la « wahaya »), en raison de l'inaction et de la tolérance de ses autorités, y compris judiciaires (chapitre 4).

Portée pour la théorie de la coutume. L'arrêt démontre qu'une coutume, même ancienne et socialement observée, ne peut, dans un ordre juridique soumis aux droits fondamentaux, fonder une situation contraire à la dignité humaine. La condition de « conformité » de la coutume aux normes supérieures n'est pas une simple formule : sa méconnaissance engage la responsabilité internationale de l'État.

Jurisprudence — Cour ADHP, 11 mai 2018, APDF et IHRDA c. République du Mali

Rappel. La Cour africaine a jugé que plusieurs dispositions du Code malien des personnes et de la famille, renvoyant notamment aux règles coutumières et religieuses en matière successorale, méconnaissaient les engagements de l'État en faveur de l'égalité entre hommes et femmes et des droits de l'enfant (chapitre 2).

Portée. Lorsque la loi elle-même renvoie à la coutume (coutume *secundum legem*), c'est la loi de renvoi qui engage la responsabilité de l'État si la coutume consacrée est discriminatoire. Le renvoi à la coutume n'est donc pas une technique neutre : il doit être assorti de garanties.

Jurisprudence — Cass. req. (France), 20 octobre 1920

Question. La solidarité entre codébiteurs, qui ne se présume pas en droit civil (C. civ., art. 1202), peut-elle être présumée en matière commerciale ?

Solution. La Cour de cassation admet que la solidarité se présume entre codébiteurs tenus d'une dette commerciale, en vertu d'un usage constant.

Portée. L'arrêt est l'exemple classique, en droit français, d'un **usage de droit** dérogeant à une disposition supplétive du Code civil : la règle commerciale d'origine coutumière s'impose au juge comme une véritable règle de droit. Il illustre la vitalité des usages dans un domaine où la rapidité et la sécurité du crédit justifient des règles propres.

7. Présentation des débats doctrinaux

A. Le fondement de la force obligatoire de la coutume

DÉBAT DOCTRINAL — POURQUOI LA COUTUME OBLIGE-T-ELLE ?

La thèse de la délégation. Pour les positivistes légalistes, la coutume n'oblige que parce que la loi le permet, expressément ou tacitement : elle est une source **déléguée**. Dans un État de droit écrit, elle n'a d'autorité que dans la mesure où le législateur lui en reconnaît une DOC.

La thèse de l'autonomie. Pour l'École historique et une partie de la doctrine contemporaine, la coutume est une source **autonome**, qui tire sa force de la conviction juridique du groupe, et que le juge constate plutôt qu'il ne la crée. Le droit international en fournit la preuve : la coutume y oblige les États sans délégation d'une autorité supérieure DOC.

La thèse judiciaire. D'autres auteurs, dans une perspective réaliste, soutiennent que la coutume ne devient droit qu'au moment où un juge la consacre : c'est la jurisprudence qui confère à la pratique sa juridicité DOC.

Application au droit ivoirien. Dans l'ordre étatique ivoirien, la thèse de la délégation rend le mieux compte du droit positif : les droits coutumiers fonciers produisent des effets parce

que la loi de 1998 les reconnaît et dans les conditions qu'elle fixe. Mais la thèse de l'autonomie décrit mieux la réalité sociologique des villages, où la coutume est observée indépendamment de toute reconnaissance étatique.

B. Faut-il rédiger ou codifier les coutumes ?

La rédaction des coutumes présente des avantages évidents : accessibilité, sécurité, uniformité. Mais elle a des inconvénients que l'expérience coloniale a révélés : elle fige des normes par nature évolutives, sélectionne une version parmi d'autres, et confie souvent à des interlocuteurs particuliers (chefs, anciens, notables masculins) le pouvoir de dire la coutume au détriment d'autres membres du groupe, en particulier les femmes et les cadets. La politique foncière ivoirienne contemporaine a préféré, à la rédaction générale des coutumes, la **constatation individuelle** des droits coutumiers par certification.

C. La conversion des droits coutumiers : sécurisation ou dépossession ?

La stratégie de la loi de 1998 — reconnaître les droits coutumiers pour mieux les convertir en propriété privée immatriculée — fait l'objet d'un débat. Ses partisans y voient le moyen de sécuriser les droits, de prévenir les conflits et de faciliter l'accès au crédit. Ses critiques soulignent les coûts et la lenteur de la certification, le risque d'appropriation par les plus puissants des droits collectifs ou familiaux, la fragilisation des exploitants non nationaux et des droits secondaires (droits d'usage, droits des femmes), et la difficulté de traduire dans les catégories du Code civil des rapports fonciers complexes.

PROPOSITION DE L'AUTEUR — RECONNAÎTRE LA PLURALITÉ DES DROITS SUR LA TERRE

La conversion des droits coutumiers gagnerait à mieux prendre en compte la **pluralité des droits** qui s'exercent sur une même terre : droit du lignage, droits d'usage des membres de la famille, droits des exploitants installés au titre du « tutorat », droits des femmes. Le certificat foncier pourrait mentionner systématiquement ces droits secondaires, et la procédure d'enquête devrait garantir la participation effective des femmes et des exploitants non autochtones. La sécurisation foncière ne serait alors pas seulement celle du titulaire principal, mais celle de l'ensemble des personnes dont les moyens d'existence dépendent de la terre PP.

8. Illustrations pratiques

La délimitation des terroirs villageois. Deux villages se disputent les limites de leurs territoires respectifs, que chacun établit par des récits d'installation et des témoignages. La loi de

1998 et ses textes d'application organisent la délimitation des territoires des villages, préalable à la certification des parcelles. Le juriste doit articuler preuves coutumières (témoignages, autorités traditionnelles) et procédure administrative.

La dot et le mariage civil. La pratique de la dot, désormais non prohibée par la loi, relève des usages sociaux et familiaux. Elle ne conditionne pas la validité du mariage civil ; les litiges relatifs à sa restitution éventuelle relèvent du droit commun des obligations, sous réserve de l'appréciation des juridictions.

L'usage commercial invoqué devant le juge. Un grossiste soutient qu'un usage de la place d'Abidjan impose à l'acheteur de dénoncer les défauts dans un délai de quelques jours. Il devra prouver cet usage — par exemple par un parère d'une organisation professionnelle — et établir que l'acheteur, professionnel du même secteur, en avait connaissance. Le juge vérifiera en outre que l'usage n'est pas contraire aux règles impératives de l'AUDCG.

Les Incoterms dans un contrat d'importation. Une société ivoirienne importe du matériel d'Europe selon un Incoterm indiquant que le transfert des risques intervient au port de chargement. La référence contractuelle à cette règle codifiée de la Chambre de commerce internationale règle la question des risques pendant le transport, que le droit applicable aurait sinon résolue de manière moins prévisible.

9. Cas pratiques corrigés

Cas pratique n° 1 — Le certificat foncier contesté

Énoncé. M. Gbêhi a obtenu un certificat foncier sur une parcelle qu'il exploite depuis trente ans, à l'issue d'une enquête officielle. Sa sœur, Mme Gbêhi, soutient que la terre est un bien du lignage, sur lequel elle a, selon la coutume, des droits d'usage que l'enquête a ignorés. Elle demande l'annulation du certificat. Quelles questions juridiques se posent ?

CORRIGÉ

Problèmes de droit. (1) La coutume invoquée par Mme Gbêhi peut-elle être prise en compte ? (2) Le certificat foncier peut-il être remis en cause ?

Règles applicables. La loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 modifiée reconnaît les droits coutumiers conformes aux traditions (art. 3) et organise leur constatation par le certificat foncier au terme d'une enquête officielle contradictoire (art. 4 ; décret n° 2019-266 du 27 mars 2019). Les modalités et délais de contestation du certificat foncier sont fixés par les textes d'application. Les droits fondamentaux, notamment l'égalité entre hommes et femmes, s'imposent à l'interprétation de la coutume.

Application. (1) Les droits coutumiers de Mme Gbêhi, s'ils sont établis (témoignages, attestations des autorités coutumières, pratique effective), entrent dans la catégorie des

droits que la loi reconnaît ; une interprétation de la coutume qui exclurait les femmes de tout droit sur les terres familiales se heurterait au principe d'égalité. (2) La contestation du certificat doit emprunter les voies prévues par les textes (recours administratif, action en justice), dans les délais prescrits ; il faudra démontrer que l'enquête a été irrégulière ou incomplète, faute d'avoir recueilli les droits de la requérante.

Conclusion. Mme Gbêhi peut agir, mais doit vérifier sans délai les voies et délais de contestation applicables et réunir des preuves de ses droits coutumiers. Le litige illustre l'intérêt de mentionner les droits secondaires dans les certificats fonciers.

Cas pratique n° 2 — L'usage commercial et la clause contraire

Énoncé. Deux commerçants concluent une vente de marchandises. Le contrat prévoit que les réclamations relatives à la qualité devront être formulées dans un délai de trente jours. Le vendeur invoque un usage de la profession qui imposerait une réclamation dans les huit jours et refuse d'examiner une réclamation formulée le vingtième jour. A-t-il raison ?

CORRIGÉ

Problème de droit. Un usage conventionnel peut-il prévaloir sur une stipulation contractuelle contraire ?

Règles applicables. Les usages conventionnels s'appliquent en raison de la volonté présumée des parties ; ils cèdent devant une volonté contraire exprimée dans le contrat. La Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises, dont s'inspire l'AUDCG, réserve d'ailleurs la convention contraire des parties. Les règles impératives de l'AUDCG demeurent applicables.

Application. Les parties ont expressément fixé un délai de trente jours ; cette stipulation exprime une volonté contraire à l'usage invoqué. L'usage, à le supposer établi, ne peut prévaloir. La réclamation formulée le vingtième jour est donc recevable au regard du contrat, sous réserve du respect des règles impératives de l'AUDCG.

Conclusion. Le vendeur a tort. Ce cas illustre la hiérarchie entre la stipulation expresse et l'usage conventionnel.

10. Synthèse et connaissances essentielles

SYNTHÈSE — CONNAISSANCES ESSENTIELLES

– La **coutume** réunit un élément matériel (pratique répétée, ancienne, constante, générale) et un élément psychologique (*opinio juris*) ; l'usage social n'a pas ce second élément.

– On distingue la coutume **secundum legem** (sur renvoi de la loi), **praeter legem** (comblant une lacune) et **contra legem** (en principe sans effet).
– Les **usages conventionnels** s'appliquent par la volonté présumée des parties et cèdent devant une stipulation contraire ; les **usages de droit** ont la force de règles supplétives.
– En Côte d'Ivoire, les coutumes ont été **écartées en matière familiale** (1964) et **reconnues en matière foncière rurale** (loi n° 98-750) selon un mécanisme de **reconnaissance, constatation (certificat foncier) et conversion (immatriculation)** ; les cessions de terres non certifiées sont interdites depuis 2019.
– Les autorités coutumières ont un **statut légal** (loi n° 2014-428) et une **institution constitutionnelle** (Const., art. 175-176), sans pouvoir juridictionnel.
– La coutume est **subordonnée aux droits fondamentaux** (*Koraou*, 2008 ; *APDF et IHRDA*, 2018).
– En droit international, la coutume est une source majeure (Statut de la CIJ, art. 38 ; *Plateau continental de la mer du Nord*, 1969).

11. Questions d'évaluation

QUESTIONS D'ÉVALUATION

Questions de cours

1. Quels sont les éléments constitutifs de la coutume ?
2. Distinguez usage conventionnel et usage de droit.
3. Une coutume peut-elle abroger une loi ?
4. Comment la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 organise-t-elle la reconnaissance des droits coutumiers ?
5. Comment prouve-t-on une coutume ou un usage ?

Questions de réflexion

1. La coutume est-elle, en droit ivoirien, une source autonome ou déléguée ?
2. La conversion des droits coutumiers en propriété privée est-elle un facteur de sécurité ou de conflit ?

Sujets de dissertation

1. « La coutume, source du droit ivoirien ? »
2. « Les usages dans le droit des affaires OHADA. »
3. « Coutume et droits fondamentaux en Afrique de l'Ouest. »

Commentaire

1. Commentez l'article 3 de la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural.

12. Références bibliographiques

Ouvrages généraux

F. Terré, *Introduction générale au droit*, Dalloz, coll. « Précis », dernière éd.

P. Deumier, *Introduction générale au droit*, LGDJ, coll. « Manuel », dernière éd.

P. Jestaz, *Les sources du droit*, Dalloz, coll. « Connaissance du droit », dernière éd.

Coutume et droits africains

Coutumiers juridiques de l'Afrique occidentale française, Larose, 1939.

K. Mbaye (dir.), *Le droit de la famille en Afrique noire et à Madagascar*, Maisonneuve et Larose, 1968.

N. Rouland, *Anthropologie juridique*, PUF, 1988.

É. Le Roy, *Le jeu des lois. Une anthropologie « dynamique » du droit*, LGDJ, 1999.

J. Vanderlinden, *Les systèmes juridiques africains*, PUF, coll. « Que sais-je ? », 1983.

Usages et commerce international

Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (Vienne, 11 avril 1980).

Chambre de commerce internationale, *Incoterms®*, dernière version.

Sources officielles

Loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 modifiée ; décret n° 2019-266 du 27 mars 2019 ; loi n° 2014-428 du 14 juillet 2014 ; Constitution (art. 175-176) ; AUDCG ; Statut de la Cour internationale de justice (art. 38).

CHAPITRE 10

La jurisprudence et la doctrine

« Un code, quelque complet qu'il puisse paraître, n'est pas plutôt achevé, que mille questions inattendues viennent s'offrir au magistrat. »

— Portalis, Discours préliminaire du premier projet de Code civil (1801)

1. Introduction et problématique

La loi est générale ; les litiges sont particuliers. Entre la règle abstraite et le cas concret s'interpose nécessairement le **juge**, qui interprète la règle, en précise le sens, en comble les lacunes et l'adapte à des situations que le législateur n'avait pas prévues. L'ensemble des solutions ainsi dégagées par les juridictions forme la **jurisprudence**. À côté des juges, les **auteurs** — professeurs, chercheurs, praticiens qui écrivent sur le droit — analysent les textes et les décisions, les systématisent, les critiquent et proposent des solutions : leurs travaux forment la **doctrine**.

Dans les pays de tradition civiliste, ni la jurisprudence ni la doctrine ne sont, en principe, des sources formelles du droit : le juge est tenu d'appliquer la loi et il lui est interdit de statuer par voie de disposition générale (C. civ., art. 5) ; l'opinion d'un auteur, si éminent soit-il, n'oblige personne. Et pourtant, des pans entiers du droit — la responsabilité du fait des choses, l'abus de droit, l'enrichissement sans cause, la quasi-totalité du droit administratif — sont l'œuvre des juges, éclairés par la doctrine.

En Côte d'Ivoire, la question présente des traits particuliers : réorganisation récente des juridictions suprêmes (Cour de cassation et Conseil d'État institués par la Constitution de 2016), rôle d'une juridiction supranationale — la CCJA — dans l'unification du droit des affaires, difficultés d'accès à la jurisprudence publiée, poids de la doctrine française et émergence d'une doctrine africaine, notamment en droit OHADA.

Problématique. *La jurisprudence et la doctrine sont-elles de véritables sources du droit, ou seulement des autorités qui en orientent l'interprétation ?* Le chapitre montrera que la jurisprudence est une source **réelle** du droit, dont la force procède de l'organisation hiérarchique des juridictions et de l'autorité des cours suprêmes, mais une source **encadrée**, soumise à la loi et

dépourvue de force obligatoire générale ; la doctrine, quant à elle, est une **autorité** dont l'influence, considérable, s'exerce par la persuasion.

2. Fondements historiques et théoriques

A. Le rôle des juristes à Rome

À Rome, le droit s'est développé par l'activité des **jurisconsultes**, qui donnaient des consultations (*responsa*) aux particuliers et aux magistrats. Certains d'entre eux reçurent de l'empereur le droit de répondre avec son autorité (*jus respondendi*). La « loi des citations » de 426 conféra une autorité particulière aux écrits de cinq jurisconsultes (Papinien, Paul, Ulpien, Gaius et Modestin), dont l'opinion majoritaire s'imposait au juge. La doctrine fut ainsi, à Rome, une véritable source formelle du droit.

B. La méfiance révolutionnaire envers les juges

Sous l'Ancien Régime, les **parlements** — cours souveraines de justice — rendaient des **arrêts de règlement**, décisions de portée générale qui s'imposaient pour l'avenir dans leur ressort. Ils s'opposèrent souvent au pouvoir royal, d'où la méfiance des révolutionnaires à leur égard. La Révolution interdit aux juges de faire des règlements, organisa un temps le **référé législatif** — obligation pour les juges de s'adresser au corps législatif lorsqu'ils estimaient nécessaire d'interpréter une loi — et créa en 1790 le Tribunal de cassation, chargé de censurer les violations de la loi. Le Code civil consacra cette conception : le juge doit juger, même dans le silence ou l'obscurité de la loi, sous peine de déni de justice (art. 4), mais il lui est défendu de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire (art. 5).

C. L'essor de la jurisprudence

Au cours du XIXe et du XXe siècle, l'écart entre un Code immobile et une société en transformation rapide a conduit les juges, sous l'impulsion de la Cour de cassation, à développer des solutions nouvelles à partir des textes anciens. La révolution industrielle a multiplié les accidents causés par les machines : la Cour de cassation a découvert dans l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil un principe général de responsabilité du fait des choses (arrêts *Teffaine*, 1896, et *Jand'heur*, 1930). Elle a consacré l'action fondée sur l'enrichissement sans cause (*Boudier*, 1892) et la théorie de l'abus de droit (*Clément-Bayard*, 1915). En droit administratif, le Conseil d'État a construit l'essentiel de la discipline. Édouard Lambert, observant le rôle de la Cour suprême américaine, a dénoncé le risque d'un « gouvernement des juges »[1].

1. É. Lambert, *Le gouvernement des juges et la lutte contre la législation sociale aux États-Unis*, Giard, 1921.

D. La doctrine, de l'Université médiévale à l'Afrique contemporaine

La doctrine européenne naît avec la redécouverte du droit romain dans les universités médiévales. Les **glossateurs** de Bologne (Irnerius, Accurse) annotent les textes ; les **commentateurs** (Bartole) en tirent des principes applicables ; les **humanistes** du XVIe siècle (Cujas) en restituent le sens historique. En France, Jean Domat, avec *Les Lois civiles dans leur ordre naturel* (1689-1694), et Robert-Joseph Pothier, avec ses traités, notamment le *Traité des obligations* (1761), préparent directement le Code civil, dont de nombreux articles reprennent leurs formules. Au XIXe siècle, l'École de l'exégèse commente le Code article par article ; à la fin du siècle, l'École scientifique (Gény, Saleilles) renouvelle les méthodes.

En Afrique francophone, la doctrine s'est d'abord développée dans le prolongement de la doctrine française. Depuis les indépendances, les facultés de droit africaines ont formé une doctrine nationale et régionale, particulièrement active en droit constitutionnel, en droit de la famille, en droit foncier et en droit OHADA, dont les travaux sont diffusés par des revues spécialisées et par des bases de données comme Ohadata.

3. Explication approfondie des concepts

A. La jurisprudence

> **DÉFINITION — JURISPRUDENCE**
>
> Au sens large, ensemble des décisions rendues par les juridictions. Au sens strict, ensemble des solutions de principe dégagées par les juridictions, en particulier par les juridictions supérieures, et suivies de manière constante, qui précisent le sens des règles de droit ou en comblent les lacunes.

Plusieurs distinctions permettent d'apprécier la portée d'une décision :

- l'**arrêt de principe**, qui énonce une règle formulée en termes généraux, destinée à guider les solutions futures, et l'**arrêt d'espèce**, dont la solution est étroitement liée aux circonstances de la cause ;
- la **jurisprudence constante**, résultant d'une série concordante de décisions, et la **décision isolée** ;
- le **revirement de jurisprudence**, par lequel une juridiction abandonne une solution qu'elle retenait jusque-là ;
- l'**avis**, rendu par une juridiction en dehors de tout litige, à la demande d'une autorité habilitée ou d'une juridiction : ainsi des avis consultatifs de la CCJA.

B. L'autorité de la chose jugée

> **DÉFINITION — AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE**
>
> Force attachée à une décision de justice, qui interdit de remettre en discussion, entre les mêmes parties, ce qui a été tranché, lorsque la nouvelle demande porte sur la même chose, est fondée sur la même cause et oppose les mêmes parties agissant en la même qualité (C. civ., art. 1351).

L'autorité de la chose jugée est **relative** : elle ne vaut qu'entre les parties au litige. Un jugement ne lie pas les tiers ni, en principe, les autres juges. C'est ce qui distingue la décision de justice de la loi, et ce qui explique que la jurisprudence n'ait pas, en droit, de force obligatoire générale.

C. La doctrine

> **DÉFINITION — DOCTRINE**
>
> Ensemble des opinions émises sur le droit par ceux qui l'étudient et l'enseignent, sous forme d'ouvrages, d'articles, de notes de jurisprudence, de thèses ou de commentaires ; par extension, ensemble des auteurs eux-mêmes.

La doctrine s'exprime sous des formes variées : traités et manuels, qui systématisent une matière ; notes et commentaires de décisions, qui en dégagent la portée ; articles et chroniques ; thèses de doctorat ; encyclopédies et répertoires. Il faut en rapprocher, sans les confondre avec elle, les **conclusions** des rapporteurs publics ou des avocats généraux et les **rapports** des conseillers rapporteurs, qui éclairent les décisions des juridictions supérieures.

D. Les principes généraux du droit et les adages

Les juges dégagent parfois des **principes généraux du droit**, qui ne figurent dans aucun texte mais qu'ils estiment inhérents à l'ordre juridique : en droit administratif français, le Conseil d'État a ainsi consacré les droits de la défense (CE, sect., 5 mai 1944, *Dame veuve Trompier-Gravier*), le droit à un recours pour excès de pouvoir contre toute décision administrative (CE, ass., 17 février 1950, *Dame Lamotte*), ou l'égalité devant le service public. Les **adages** (*nemo auditur propriam turpitudinem allegans*, *fraus omnia corrumpit*, *specialia generalibus derogant*) condensent des principes que les juges appliquent, sans texte, ou pour interpréter les textes.

4. Analyse des principes et mécanismes juridiques

A. L'organisation juridictionnelle et l'unification de la jurisprudence

La jurisprudence n'est une source du droit que parce que les juridictions sont organisées **hiérarchiquement**. Les juridictions du fond — tribunaux de première instance, cours d'appel — appliquent le droit aux faits; les juridictions suprêmes ne rejugent pas les faits, mais contrôlent la bonne application du droit par les juges du fond et assurent ainsi l'**unité de l'interprétation** sur tout le territoire.

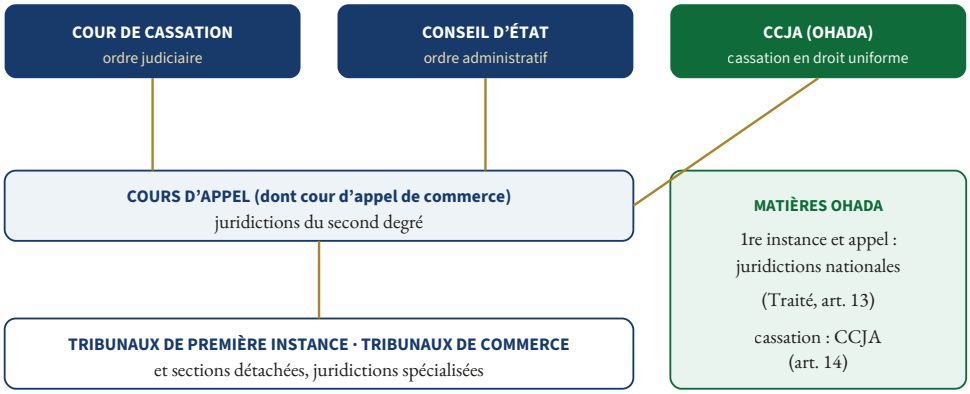


Schéma simplifié ; la répartition précise des compétences est étudiée au Tome 8

Schéma 1 — L'organisation juridictionnelle et l'unification de la jurisprudence

La Constitution du 8 novembre 2016 a institué une **Cour de cassation**, juridiction suprême de l'ordre judiciaire, et un **Conseil d'État**, juridiction suprême de l'ordre administratif, qui se sont substitués à la Cour suprême; leurs attributions, leur composition et leur fonctionnement ont été fixés par des lois organiques de 2020 (n° 2020-967 et n° 2020-968).

Dans les matières régies par les actes uniformes, l'unification de la jurisprudence relève de la **CCJA**. Le contentieux relatif à l'application des actes uniformes est réglé en première instance et en appel par les juridictions nationales (Traité OHADA, art. 13); la CCJA se prononce sur les décisions d'appel et sur les décisions non susceptibles d'appel dans ces affaires, à l'exception des décisions appliquant des sanctions pénales, et, en cas de cassation, évoque et statue sur le fond (art. 14). La saisine de la CCJA suspend toute procédure de cassation engagée devant une juridiction nationale contre la même décision (art. 16). Si une juridiction nationale de cassation statue alors qu'elle était incompétente, la partie qui avait soulevé cette incompétence peut saisir la CCJA, qui, si elle estime que la juridiction nationale s'est déclarée compétente à tort, déclare sa décision nulle et non avenue (art. 18). Les arrêts de la CCJA ont

l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire dans chacun des États parties (art. 20). La CCJA rend en outre des **avis consultatifs** sur l'interprétation et l'application du Traité et des actes uniformes, à la demande des États, du Conseil des ministres ou des juridictions nationales (art. 14).

B. Comment la jurisprudence crée du droit

La jurisprudence contribue à la formation du droit par plusieurs voies :

1. **l'interprétation** : en fixant le sens d'un texte obscur ou ambigu, la juridiction suprême détermine le contenu effectif de la règle ;
2. **le comblement des lacunes** : obligé de juger même dans le silence de la loi (C. civ., art. 4), le juge doit dégager une solution, en recourant à l'analogie, aux principes généraux ou à l'équité ;
3. **l'adaptation** : par une interprétation évolutive, le juge adapte des textes anciens à des réalités nouvelles (machines, véhicules, communications électroniques) ;
4. **la concrétisation des standards** : en précisant le contenu des notions-cadres (faute, bonne foi, ordre public, délai raisonnable), le juge en fait des règles opératoires.

La force de la jurisprudence ne procède pas d'une obligation juridique pour les juges inférieurs de suivre les précédents — il n'existe pas de règle du précédent obligatoire (*stare decisis*) dans la tradition civiliste —, mais de la **probabilité** que la juridiction suprême censure une décision contraire à sa jurisprudence. C'est en ce sens que l'on parle d'une autorité de fait, qui confine à une autorité de droit lorsque la jurisprudence est constante.

C. Les limites du pouvoir normatif du juge

Le pouvoir normatif du juge est limité :

- **par la loi** : le juge ne peut écarter une loi claire (sauf contrariété à une norme supérieure, dans les conditions étudiées au chapitre 7) ;
- **par l'interdiction des arrêts de règlement** (C. civ., art. 5) : le juge statue sur le litige qui lui est soumis et ne peut édicter de règle générale pour l'avenir ;
- **par la relativité de la chose jugée** (C. civ., art. 1351) ;
- **par l'intervention du législateur**, qui peut toujours modifier la règle jurisprudentielle : ainsi, en France, la loi du 4 mars 2002 a mis fin à la jurisprudence *Perruche* en posant que nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance.

D. Les revirements de jurisprudence et le temps

La jurisprudence est **rétroactive** par nature : la règle dégagée par le juge s'applique au litige qui lui est soumis, c'est-à-dire à des faits antérieurs à la décision ; un revirement s'applique

donc à des situations nées sous l'empire de la jurisprudence ancienne. Cette rétroactivité peut porter atteinte à la sécurité juridique, notamment lorsqu'une partie a agi en se fiant à la jurisprudence établie.

Les juridictions françaises ont admis, dans certains cas, de **moduler dans le temps** les effets de leurs décisions. Le Conseil d'État s'est reconnu le pouvoir de moduler les effets dans le temps de l'annulation d'un acte administratif (CE, ass., 11 mai 2004, *Association AC!*) et a réservé l'application d'une voie de recours nouvelle aux contrats conclus après sa décision (CE, ass., 16 juillet 2007, *Société Tropic Travaux Signalisation*). La Cour de cassation a refusé d'appliquer immédiatement une règle nouvelle de prescription lorsque cette application aurait privé la victime d'un procès équitable (Cass. ass. plén., 21 décembre 2006, n° 00-20.493). Un rapport remis au premier président de la Cour de cassation en 2004 avait étudié les conditions d'une modulation des revirements[2].

E. L'influence de la doctrine

La doctrine n'a pas de force obligatoire, mais son influence s'exerce à plusieurs niveaux :

- **sur le législateur**, qu'elle inspire par ses critiques et ses propositions, et à qui elle prête souvent ses rédacteurs (commissions de réforme, experts chargés de l'élaboration des actes uniformes) ;
- **sur le juge**, qui s'appuie sur ses analyses, même lorsqu'il ne la cite pas, et sur les conclusions et rapports qui en reprennent les arguments ;
- **sur la formation des juristes**, puisque ce sont les auteurs qui enseignent et transmettent les catégories du droit ;
- **sur la cohérence du droit**, que la doctrine construit en systématisant des solutions éparses.

L'autorité d'une opinion doctrinale tient à la qualité de son raisonnement, à la réputation de son auteur, et au consensus qui se forme éventuellement autour d'elle (*communis opinio doctorum*).

5. Étude des textes applicables

Tableau 1 — Textes relatifs à la jurisprudence

2. N. Molfessis (dir.), *Les revirements de jurisprudence. Rapport remis à Monsieur le Premier Président Guy Canivet*, Litec, 2005.

Texte	Disposition	Portée
C. civ., art. 4	Déni de justice en cas de refus de juger	Obligation de juger ; fondement du pouvoir d'interprétation et de comblement des lacunes
C. civ., art. 5	Interdiction des arrêts de règlement	Limite du pouvoir normatif du juge
C. civ., art. 1351	Autorité relative de la chose jugée	Absence de force obligatoire générale des jugements
Constitution de 2016	Cour de cassation, Conseil d'État	Juridictions suprêmes nationales
Lois organiques n° 2020-967 et n° 2020-968	Attributions et fonctionnement de la Cour de cassation et du Conseil d'État	Unification de la jurisprudence nationale
Traité OHADA, art. 13 à 20	Compétences de la CCJA	Unification supranationale de la jurisprudence en droit des affaires

ÉTAT DU DROIT — POINT DE VIGILANCE

La jurisprudence ivoirienne demeure d'un accès inégal. Les décisions de la CCJA sont publiées dans un recueil officiel et dans des bases de données (Ohadata, CIVLII) ; les décisions du Conseil constitutionnel sont publiées sur son site ; la Cour de cassation ivoirienne a entrepris la publication de recueils de ses arrêts. Une large partie des décisions des juridictions du fond n'est pas publiée. Toute citation d'une décision ivoirienne suppose l'identification précise de la juridiction, de la date et du numéro, et la consultation du texte intégral.

6. Analyse de jurisprudences vérifiables

Jurisprudence — Cass. civ. (France), 16 juin 1896, Teffaine ; Cass. ch. réunies, 13 février 1930, Jand'heur

Faits. Dans l'affaire *Teffaine*, un ouvrier avait été tué par l'explosion de la chaudière d'un remorqueur, due à un vice de construction ; dans l'affaire *Jand'heur*, une enfant avait été renversée par un camion.

Solutions. La Cour de cassation découvre dans l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil — qui se bornait, dans l'esprit de ses rédacteurs, à annoncer les cas particuliers de responsabilité des articles suivants — un principe général de responsabilité du fait des choses que l'on a sous sa garde. En 1930, les chambres réunies précisent que cette présomption de responsabilité ne peut être détruite que par la preuve d'un cas fortuit ou de force majeure ou d'une cause étrangère non imputable au gardien, et qu'il n'est pas nécessaire que la chose ait un vice inhérent à sa nature.

Portée. Ces arrêts constituent l'exemple le plus célèbre de création jurisprudentielle à partir d'un texte ancien. Rendus sur l'article 1384, alinéa 1er, dans sa rédaction commune aux droits français et ivoirien, ils font partie du patrimoine jurisprudentiel auquel se réfèrent les juridictions ivoiriennes en matière de responsabilité civile, sous réserve des règles spéciales du Code CIMA en matière d'accidents de la circulation.

Jurisprudence — Cass. req. (France), 15 juin 1892, Patureau-Miran c. Boudier

Solution. La Cour de cassation admet l'action d'un fournisseur d'engrais contre le propriétaire d'un fonds qui avait profité de la récolte fertilisée, sans être tenu par un contrat envers lui, en se fondant sur le principe d'équité qui défend de s'enrichir au détriment d'autrui.

Portée. L'arrêt consacre, sans texte, l'action *de in rem verso* fondée sur l'enrichissement sans cause, dont la jurisprudence a ensuite précisé les conditions. Il illustre la création d'une institution par la jurisprudence à partir d'un principe général.

Jurisprudence — Cass. ass. plén. (France), 17 novembre 2000, Perruche ; loi n° 2002-303 du 4 mars 2002

Solution. L'Assemblée plénière admet qu'un enfant né handicapé puisse demander réparation du préjudice résultant de son handicap, causé par la rubéole de sa mère pendant la grossesse, lorsque les fautes commises par un médecin et un laboratoire dans l'exécution des contrats formés avec la mère avaient empêché celle-ci d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse.

Suite législative. La décision suscita un vif débat. Le législateur intervint par la loi du 4 mars 2002, dont l'article 1er pose que nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance.

Portée. L'épisode illustre le dialogue — parfois conflictuel — entre le juge et le législateur : le premier crée une solution, le second, détenteur du pouvoir normatif général, la renverse. Il montre que le pouvoir normatif du juge s'exerce sous le contrôle ultime du législateur.

Jurisprudence — Cass. ass. plén. (France), 21 décembre 2006, n° 00-20.493

Question. Une règle jurisprudentielle nouvelle, relative à l'interruption de la prescription en matière de presse, devait-elle s'appliquer à une instance engagée avant le revirement ?

Solution. L'Assemblée plénière juge que l'application immédiate de la règle nouvelle dans l'instance en cours aboutirait à priver la victime d'un procès équitable, au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en lui interdisant l'accès au juge.

Portée. La Cour de cassation admet ainsi, exceptionnellement, de différer l'application d'un revirement, lorsque sa rétroactivité porterait une atteinte excessive au droit d'accès au juge.

La solution transpose à la jurisprudence les exigences de sécurité juridique applicables à la loi (chapitre 8).

Jurisprudence — CE (France), ass., 11 mai 2004, Association AC ! et autres

Solution. Le Conseil d'État juge que, si l'annulation d'un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n'être jamais intervenu, il peut, à titre exceptionnel, lorsque l'effet rétroactif de l'annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits que de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets, moduler dans le temps les effets de sa décision.

Portée. L'arrêt reconnaît au juge un pouvoir de régulation des effets de ses propres décisions, qui manifeste la dimension normative de la jurisprudence et le souci de la sécurité juridique. La question de l'existence d'un tel pouvoir au profit du juge administratif ivoirien relève du Tome 4.

7. Présentation des débats doctrinaux

A. La jurisprudence est-elle une source du droit ?

DÉBAT DOCTRINAL — SOURCE OU AUTORITÉ ?

La thèse négative. Dans la conception légaliste héritée de la Révolution, la jurisprudence n'est pas une source du droit : le juge applique la loi, il ne la fait pas ; l'article 5 du Code civil lui interdit de statuer par voie générale ; l'autorité de ses décisions est relative ; il peut à tout moment revenir sur sa jurisprudence, ce qui montre qu'elle ne l'oblige pas DOC.

La thèse positive. Pour une large partie de la doctrine contemporaine, la jurisprudence est une source du droit, au moins lorsqu'elle émane d'une juridiction suprême et qu'elle est constante. Ses défenseurs invoquent l'observation des faits (des pans entiers du droit sont jurisprudentiels), la logique de l'organisation judiciaire (la Cour suprême a pour mission d'unifier l'interprétation), et la pratique des juristes, qui traitent la jurisprudence établie comme du droit positif DOC.

Les positions intermédiaires. D'autres auteurs distinguent la **source** (ce qui produit des normes obligatoires) et l'**autorité** (ce qui influence, de manière plus ou moins contraignante, l'interprétation des normes) : la jurisprudence serait une autorité, dont la force est considérable mais de fait. La théorie réaliste de l'interprétation (chapitre 4) dissout la question : si le sens des textes est fixé par leurs interprètes authentiques, la jurisprudence des cours suprêmes est non seulement une source, mais la source principale du droit effectivement appliqué.

Appréciation. La jurisprudence doit être regardée comme une source **réelle** du droit, dont la force procède de l'organisation hiérarchique des juridictions, mais une source **subordonnée** à la loi, qui peut toujours la renverser, et **instable**, puisque le juge peut revenir sur ses solutions.

B. Le précédent : *common law* et droit civil

La comparaison avec la *common law* éclaire le débat. En droit anglais, la règle du précédent obligatoire (*stare decisis*) impose aux juridictions de suivre les décisions des juridictions supérieures, et le droit se construit par induction à partir des précédents ; la Chambre des lords s'est néanmoins reconnu, par une déclaration de 1966 (*Practice Statement*), le pouvoir de s'écarter de ses propres précédents. En droit civil, il n'existe pas de règle du précédent obligatoire, mais les juridictions suivent en pratique la jurisprudence des cours suprêmes. Les deux traditions convergent : la *common law* fait une place croissante à la loi, et le droit civil à la jurisprudence.

C. Le gouvernement des juges

Le développement du pouvoir normatif des juges — juges constitutionnels, juges européens et africains des droits de l'homme, juges supranationaux comme la CCJA — nourrit la crainte d'un « gouvernement des juges », dans lequel des magistrats non élus imposeraient leurs choix aux représentants du peuple. Les défenseurs de la justice constitutionnelle répondent que le juge ne fait que garantir le respect de normes adoptées par le peuple lui-même (Constitution) ou par l'État (traités), et que le dernier mot appartient au constituant, qui peut réviser la Constitution.

D. La doctrine africaine et la doctrine française

La doctrine ivoirienne et africaine a longtemps été tributaire de la doctrine française, dont les manuels demeurent largement utilisés dans les facultés. Le risque est double : d'une part, transposer des analyses conçues pour un droit français qui a évolué différemment depuis 1960 ; d'autre part, négliger les spécificités africaines (pluralisme, OHADA, contexte économique et social). Le développement d'une doctrine OHADA dynamique, nourrie de la jurisprudence de la CCJA, montre qu'une doctrine régionale autonome est possible.

PROPOSITION DE L'AUTEUR — UN ACCÈS OUVERT À LA JURISPRUDENCE IVOIRIENNE

La jurisprudence ne peut jouer son rôle de source du droit que si elle est **connue**. Il serait souhaitable que les juridictions ivoiriennes, à commencer par la Cour de cassation et le Conseil d'État, publient de manière systématique et gratuite leurs décisions, avec un résumé

des principes dégagés, dans une base de données en ligne accessible à tous, sous réserve de la protection des données personnelles des parties. Cette publication favoriserait l'unité de la jurisprudence, la prévisibilité du droit, la formation des juristes et le développement d'une doctrine nationale fondée sur l'analyse des décisions ivoiriennes PP.

8. Illustrations pratiques

La recherche de la jurisprudence de la CCJA. Un avocat chargé d'un litige relatif à une saisie-attribution doit connaître la jurisprudence de la CCJA sur l'interprétation de l'AUPSRVE. Il consultera le recueil de jurisprudence de la CCJA et les bases de données spécialisées, en vérifiant la date des décisions (une solution ancienne a pu être abandonnée) et leur caractère de principe ou d'espèce.

Les décisions contradictoires des juges du fond. Deux cours d'appel retiennent des interprétations opposées d'une même disposition. Le justiciable débouté devant l'une peut, par un pourvoi, permettre à la juridiction suprême de trancher la divergence ; la décision rendue unifiera l'interprétation pour l'avenir.

La citation de la jurisprudence française. Un plaideur ivoirien cite, à l'appui de son argumentation en matière de responsabilité contractuelle, un arrêt de la Cour de cassation française rendu en 2020. Si l'arrêt interprète une disposition issue de la réforme française de 2016, il est sans pertinence en droit ivoirien ; s'il interprète un principe commun aux deux droits, il peut avoir une valeur de persuasion, que le juge ivoirien apprécie librement.

La doctrine dans le procès. Une partie produit une consultation d'un professeur de droit à l'appui de ses prétentions. Cette consultation n'a pas de force obligatoire ; elle vaut par la qualité de son raisonnement, que le juge peut reprendre dans sa motivation.

9. Cas pratiques corrigés

Cas pratique n° 1 — Le pourvoi égaré

Énoncé. Dans un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale par voie d'injonction de payer (procédure régie par l'AUPSRVE), la société A, déboutée en appel, forme un pourvoi devant la Cour de cassation ivoirienne. La société B soulève l'incompétence de la Cour de cassation au profit de la CCJA ; la Cour de cassation rejette l'exception et statue au fond. Quelle voie s'offre à la société B ?

CORRIGÉ

Problème de droit. Quelle juridiction est compétente pour connaître du pourvoi formé contre une décision d'appel rendue en application d'un acte uniforme, et quel recours est ouvert lorsqu'une juridiction nationale de cassation retient à tort sa compétence ?

Règles applicables. La CCJA se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d'appel des États parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l'application des actes uniformes (Traité OHADA, art. 14). Toute partie qui, après avoir soulevé l'incompétence d'une juridiction nationale statuant en cassation, estime que cette juridiction a, dans un litige la concernant, méconnu la compétence de la CCJA peut saisir cette dernière dans un délai déterminé ; si la CCJA décide que la juridiction nationale s'est déclarée compétente à tort, la décision rendue par celle-ci est réputée nulle et non avenue (art. 18).

Application. Le litige porte sur une procédure d'injonction de payer régie par l'AUPSRVE : il soulève des questions relatives à l'application d'un acte uniforme et relève, en cassation, de la CCJA. La société B a soulevé l'incompétence devant la Cour de cassation ivoirienne, condition de recevabilité du recours de l'article 18. Elle peut donc saisir la CCJA dans le délai prévu par le Traité.

Conclusion. La société B doit saisir la CCJA sans délai sur le fondement de l'article 18 ; si la CCJA retient sa propre compétence, l'arrêt de la Cour de cassation sera réputé nul et non avenu. Le cas souligne l'importance, pour les praticiens, d'identifier dès l'origine le droit applicable au litige.

Cas pratique n° 2 — Le revirement en cours d'instance

Énoncé. M. Diomandé a introduit une action en justice en 2023, dans un délai jugé suffisant par la jurisprudence constante de la juridiction suprême compétente. En 2025, cette juridiction opère un revirement et adopte une interprétation plus stricte du délai, en vertu de laquelle l'action de M. Diomandé serait tardive. Peut-il échapper à l'application du revirement ?

CORRIGÉ

Problème de droit. Un revirement de jurisprudence peut-il être appliqué à une instance engagée conformément à la jurisprudence antérieure, lorsque son application priverait le justiciable de l'accès au juge ?

Règles et références. La jurisprudence est en principe rétroactive. Toutefois, le droit au procès équitable, garanti par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (art. 7) et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (art. 14), protège le droit d'accès au juge. En droit comparé, la Cour de cassation française a refusé d'appli-

quer immédiatement une règle nouvelle de prescription qui aurait privé la victime d'un procès équitable (Cass. ass. plén., 21 décembre 2006).

Application. M. Diomandé a agi en se conformant à la jurisprudence constante de la juridiction suprême ; l'application rétroactive du revirement le priverait de tout accès au juge, sans qu'aucune négligence puisse lui être reprochée. Il peut demander au juge de ne pas lui appliquer le revirement, en invoquant le droit au procès équitable et le principe de sécurité juridique, et en s'appuyant, à titre de droit comparé, sur la jurisprudence française.

Conclusion. L'argument est sérieux ; son succès dépend de l'accueil réservé par les juridictions ivoiriennes à la technique de la modulation des revirements, qui n'est consacrée par aucun texte ivoirien et relèverait d'une création jurisprudentielle.

10. Synthèse et connaissances essentielles

SYNTHÈSE — CONNAISSANCES ESSENTIELLES

- La **jurisprudence** est l'ensemble des solutions dégagées par les juridictions, en particulier par les juridictions suprêmes ; on distingue arrêt de principe et arrêt d'espèce, jurisprudence constante et décision isolée, revirement, avis.
- Le juge doit juger même dans le silence de la loi (C. civ., **art. 4**), mais ne peut rendre d'arrêts de règlement (**art. 5**) ; l'autorité de la chose jugée est **relative** (**art. 1351**).
- La jurisprudence crée du droit par l'**interprétation**, le **comblement des lacunes**, l'**adaptation** et la **concrétisation des standards** (*Teffaine*, *Jand'heur*, *Boudier*).
- Sa force tient à l'**organisation hiérarchique** des juridictions : en Côte d'Ivoire, Cour de cassation et Conseil d'État (Constitution de 2016, lois organiques de 2020) ; en droit OHADA, **CCJA** (Traité, art. 13 à 20 : cassation avec évocation, avis, nullité des décisions nationales rendues en méconnaissance de sa compétence).
- Les **revirements** sont rétroactifs, mais leur application peut être différée pour garantir l'accès au juge (Cass. ass. plén., 21 décembre 2006) ; le juge administratif français module les effets de ses annulations (*AC !*, 2004).
- La **doctrine** est une **autorité** sans force obligatoire, dont l'influence s'exerce sur le législateur, le juge et la formation des juristes.

11. Questions d'évaluation

QUESTIONS D'ÉVALUATION

Questions de cours

1. Que prévoient les articles 4 et 5 du Code civil ? Comment se concilient-ils ?
2. Qu'est-ce que l'autorité relative de la chose jugée ?
3. Distinguez arrêt de principe et arrêt d'espèce.
4. Quelles sont les compétences de la CCJA ?
5. Qu'est-ce qu'un revirement de jurisprudence ? Pourquoi pose-t-il un problème de sécurité juridique ?

Questions de réflexion

1. La jurisprudence de la CCJA est-elle une source du droit ivoirien ?
2. La doctrine ivoirienne doit-elle s'affranchir de la doctrine française ?

Sujets de dissertation

1. « La jurisprudence, source du droit ? »
2. « Le juge et le législateur. »
3. « Les revirements de jurisprudence. »

Commentaire

1. Commentez l'arrêt de la Cour de cassation (ch. réunies) du 13 février 1930, *Jand'heur*.

12. Références bibliographiques

Ouvrages généraux

F. Terré, *Introduction générale au droit*, Dalloz, coll. « Précis », dernière éd.

P. Jestaz, *Les sources du droit*, Dalloz, coll. « Connaissance du droit », dernière éd.

P. Deumier, *Introduction générale au droit*, LGDJ, coll. « Manuel », dernière éd.

Ouvrages spéciaux

N. Molfessis (dir.), *Les revirements de jurisprudence*, Litec, 2005.

É. Lambert, *Le gouvernement des juges et la lutte contre la législation sociale aux États-Unis*, Giard, 1921.

H. Capitant, F. Terré, Y. Lequette et F. Chénedé, *Les grands arrêts de la jurisprudence civile*, Dalloz, dernière éd.

M. Long, P. Weil, G. Braibant, P. Delvolvé et B. Genevois, *Les grands arrêts de la jurisprudence administrative*, Dalloz, dernière éd.

Droit OHADA

OHADA. Traité et actes uniformes commentés et annotés, Juriscope, dernière éd.

P.-G. Pougoué (dir.), *Encyclopédie du droit OHADA*, Lamy, 2011.

Sources officielles et bases de données

Constitution du 8 novembre 2016 ; lois organiques n° 2020-967 et n° 2020-968 ; Traité OHADA (art. 13 à 20) ; Recueil de jurisprudence de la CCJA ; base Ohadata ; CIVLII ; site du Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire.

TROISIÈME PARTIE

Les droits subjectifs et leur réalisation

CHAPITRE 11

Les droits subjectifs et leurs titulaires

1. Introduction et problématique

Les chapitres précédents ont envisagé le droit comme un ensemble de règles — le **droit objectif**. Mais le droit se présente aussi, du point de vue des personnes, comme un ensemble de **prérogatives** : le propriétaire a le droit de jouir de sa maison, le créancier a le droit d'exiger le paiement, l'auteur a le droit d'exploiter son œuvre, chacun a droit au respect de sa vie privée. Ce sont les **droits subjectifs**. Ils sont la traduction, à l'échelle de chaque personne, de ce que le droit objectif permet, protège ou garantit.

L'étude des droits subjectifs soulève trois séries de questions. Qu'est-ce qu'un droit subjectif, et cette notion est-elle même fondée ? Comment classer la masse des droits subjectifs, et quelles conséquences attacher à ces classifications ? Qui peut être titulaire de droits, c'est-à-dire quels sont les **sujets de droit** ? Ces questions ont, en Côte d'Ivoire, des prolongements concrets : la distinction des droits réels et personnels commande le régime des sûretés de l'Acte uniforme OHADA ; la théorie du patrimoine explique que l'entrepreneur individuel engage tous ses biens ; la personnalité morale conditionne la vie des sociétés, des associations, des coopératives agricoles ; la protection des droits de la personnalité prend une acuité nouvelle avec le numérique.

Problématique. *Qu'est-ce qu'un droit subjectif, comment les droits subjectifs s'ordonnent-ils, et qui peut en être titulaire ?* Le chapitre montrera que le droit subjectif, malgré les critiques dont il a fait l'objet, demeure la catégorie centrale par laquelle le droit organise la protection des intérêts des personnes ; que ses classifications commandent des régimes précis ; et que la notion de sujet de droit, centrée sur la personne humaine, s'est étendue aux groupements par la technique de la personnalité morale, et fait aujourd'hui l'objet de propositions d'extension plus audacieuses.

2. Fondements historiques et théoriques

A. La formation de la notion de droit subjectif

Le droit romain classique ne raisonnait pas en termes de droits subjectifs, mais d'**actions** : la question était de savoir si une personne disposait d'une action en justice pour obtenir telle chose. Michel Villey a soutenu que la notion moderne de droit subjectif — pouvoir appartenant à l'individu — est née au XIVe siècle, dans la philosophie nominaliste de Guillaume d'Ockham, avant d'être systématisée par l'École du droit naturel moderne (Grotius définit le droit comme une « qualité morale » de la personne, une faculté). La Déclaration de 1789 et le Code civil de 1804 ont consacré une conception individualiste, dans laquelle le droit subjectif — au premier rang duquel la propriété — est la traduction juridique de la liberté de l'individu.

B. Volonté ou intérêt ?

Au XIXe siècle, deux définitions s'opposent. Pour Bernhard Windscheid, le droit subjectif est un **pouvoir de volonté** (*Willensmacht*) conféré par l'ordre juridique. Pour Rudolf von Jhering, c'est un **intérêt juridiquement protégé** : le droit protège non la volonté, mais l'utilité que le titulaire retire de la chose ou de la prestation ; la preuve en est que les enfants et les personnes privées de discernement ont des droits, sans avoir de volonté juridiquement efficace. Des théories mixtes ont combiné les deux éléments.

C. Les négations du droit subjectif

Au début du XXe siècle, Léon Duguit nie l'existence des droits subjectifs, qu'il tient pour des notions métaphysiques : il n'existe que des **situations juridiques** objectives, résultant de l'application de la règle de droit, et des fonctions sociales ; la propriété elle-même n'est pas un droit, mais une fonction sociale. Hans Kelsen réduit le droit subjectif à un **reflet** des obligations imposées par le droit objectif, ou à la **compétence** reconnue à une personne de déclencher l'application d'une sanction par l'exercice d'une action en justice. Michel Villey, de son côté, critique la notion au nom du droit naturel classique, pour lequel le droit est une juste part et non un pouvoir.

D. La synthèse de Dabin

Jean Dabin a proposé une définition qui a largement inspiré la doctrine francophone : le droit subjectif est une prérogative, reconnue et protégée par le droit objectif, qui se caractérise par une relation d'**appartenance** (une chose, une valeur ou une prestation appartient au titulaire) et de **maîtrise** (le titulaire en dispose)[1]. La notion de droit subjectif est ainsi rattachée à l'idée de propriété au sens large, sans y être réduite.

3. Explication approfondie des concepts

A. La notion de droit subjectif

> **DÉFINITION — DROIT SUBJECTIF**
>
> Prérogative individuelle reconnue et sanctionnée par le droit objectif, qui permet à son titulaire de faire, d'exiger ou d'interdire quelque chose dans son propre intérêt, et dont il peut se prévaloir en justice.

Le droit subjectif se distingue de notions voisines :

- les **libertés** (aller et venir, s'exprimer, entreprendre) sont des facultés générales, reconnues à tous, qui ne portent pas sur un objet déterminé et ne s'exercent pas contre un débiteur particulier ;
- les **pouvoirs** ou **droits-fonctions** sont des prérogatives conférées à une personne dans l'intérêt d'autrui : l'autorité parentale, exercée dans l'intérêt de l'enfant, ou le pouvoir du dirigeant de société, exercé dans l'intérêt social ;
- les **simples intérêts**, non protégés par le droit, ne donnent pas lieu à action en justice.

B. Les classifications des droits subjectifs

1° Droits patrimoniaux et droits extrapatrimoniaux

Tableau 1 — Droits patrimoniaux et droits extrapatrimoniaux

Critère	Droits patrimoniaux	Droits extrapatrimoniaux
Valeur pécuniaire	Évaluables en argent	Non évaluables en argent (même si leur violation peut donner lieu à réparation pécuniaire)
Transmissibilité à cause de mort	Transmissibles aux héritiers	En principe intransmissibles

1. J. Dabin, *Le droit subjectif*, Dalloz, 1952.

Critère	Droits patrimoniaux	Droits extrapatrimoniaux
Cessibilité entre vifs	Cessibles	Incessibles
Saisissabilité	Saisissables par les créanciers	Insaisissables
Prescription	Susceptibles de s'éteindre par prescription ou de s'acquérir par usucapion	Imprescriptibles
Exemples	Propriété, créances, droits d'exploitation d'une œuvre	Droit au respect de la vie privée, à l'image, au nom ; droits familiaux ; droits politiques

La frontière n'est pas étanche : le droit à l'image peut faire l'objet de contrats d'exploitation à titre onéreux ; le droit moral de l'auteur, extrapatrimonial, coexiste avec ses droits patrimoniaux ; l'atteinte à un droit extrapatrimonial ouvre droit à des dommages-intérêts.

2° Les droits patrimoniaux : réels, personnels, intellectuels

DÉFINITION — DROIT RÉEL

Droit qui confère à son titulaire un pouvoir direct et immédiat sur une chose, sans l'intermédiaire d'une autre personne (*jus in re*). Il est opposable à tous.

DÉFINITION — DROIT PERSONNEL (OU DROIT DE CRÉANCE)

Droit qui permet à une personne, le créancier, d'exiger d'une autre, le débiteur, l'exécution d'une prestation : donner, faire ou ne pas faire (*jus ad personam*).

Les **droits réels principaux** sont la propriété et ses démembrements (usufruit, usage, habitation, servitudes, emphytéose) ; les **droits réels accessoires** sont les sûretés réelles (hypothèque, gage, nantissement, privilèges), qui garantissent une créance et qui, dans l'espace OHADA, sont régies par l'Acte uniforme portant organisation des sûretés. Les **droits intellectuels** portent sur des créations de l'esprit (œuvres, inventions, marques, dessins et modèles) ; ils sont régis dans l'espace francophone d'Afrique de l'Ouest et du Centre par l'Accord de Bangui instituant l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI), signé le 2 mars 1977 et révisé à plusieurs reprises.

Tableau 2 — Droit réel et droit personnel

Caractère	Droit réel	Droit personnel
Objet	Une chose	Une prestation d'une personne

Caractère	Droit réel	Droit personnel
Sujet passif	Aucun débiteur déterminé (obligation passive universelle de respect)	Un débiteur déterminé
Opposabilité	À tous	En principe aux seules parties (mais la créance est un bien opposable aux tiers)
Droit de suite	Oui : le titulaire suit la chose entre les mains de tout détenteur	Non
Droit de préférence	Oui (sûretés réelles) : le créancier titulaire est payé par priorité	Non : le créancier chirographaire concourt avec les autres
Nombre	Limité, en principe, par la loi	Illimité (liberté contractuelle)

3° Les droits extrapatrimoniaux

Ils comprennent :

– les **droits de la personnalité**, qui protègent les attributs de la personne : droit à la vie et à l'intégrité physique, droit au respect de la vie privée, droit à l'image, droit à l'honneur, droit au nom, droit à la protection des données personnelles ;
– les **droits familiaux** (droits et devoirs des époux, autorité parentale, droits liés à la filiation), souvent mêlés d'obligations et finalisés ;
– les **droits civiques et politiques** (droit de vote, d'éligibilité).

C. Le patrimoine

> **DÉFINITION — PATRIMOINE**
>
> Ensemble des biens et des obligations d'une personne, envisagé comme une universalité de droit, c'est-à-dire comme un tout dans lequel l'actif répond du passif.

La théorie classique du patrimoine, élaborée au XIXe siècle par Charles Aubry et Charles-Frédéric Rau, voit dans le patrimoine une **émanation de la personnalité** et en tire quatre propositions : seules les personnes ont un patrimoine ; toute personne a nécessairement un patrimoine, même vide ; une personne n'a qu'un patrimoine (unité et indivisibilité) ; le patrimoine est inséparable de la personne et ne peut être cédé entre vifs dans son ensemble.

La conséquence principale de cette théorie est le **droit de gage général** des créanciers : quiconque s'est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir, et les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers (C. civ., art. 2092 et 2093).

À cette conception s'oppose la théorie du **patrimoine d'affectation**, développée par la doctrine allemande : un patrimoine peut exister sans titulaire personnel, dès lors qu'une masse de biens est affectée à un but déterminé. Le droit contemporain a admis des formes d'affectation par plusieurs techniques : la société unipersonnelle (une personne crée une personne morale à laquelle elle affecte une partie de ses biens), la fiducie, et, en droit français, le patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel.

D. Les sujets de droit

> **DÉFINITION — PERSONNALITÉ JURIDIQUE**
>
> Aptitude à être titulaire de droits et assujetti à des obligations. Elle appartient à toutes les personnes physiques, et aux groupements et masses de biens auxquels le droit reconnaît la qualité de personne morale.

On distingue la **capacité de jouissance** — aptitude à être titulaire de droits — et la **capacité d'exercice** — aptitude à exercer seul ses droits. Toute personne a, en principe, la capacité de jouissance, sous réserve d'incapacités spéciales ; la capacité d'exercice peut faire défaut aux mineurs et à certains majeurs, qui sont alors représentés ou assistés.

4. Analyse des principes et mécanismes juridiques

A. Les personnes physiques

1° Le début et la fin de la personnalité

La personnalité juridique commence à la **naissance**, à condition que l'enfant naisse **vivant et viable**. Par exception, l'enfant simplement conçu est considéré comme né chaque fois qu'il y va de son intérêt (*infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis ejus agitur*) : il peut ainsi hériter de son père décédé avant sa naissance, s'il naît ensuite vivant et viable. Cette règle, d'origine romaine, a une portée générale.

La personnalité prend fin avec la **mort**. Le droit organise en outre les situations d'incertitude : l'**absence** (on ignore si la personne, qui a cessé de paraître, est vivante) et la **disparition** (la personne a disparu dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger), qui peuvent aboutir à un jugement déclaratif de décès.

2° L'identification des personnes physiques

L'identification d'une personne repose sur plusieurs éléments : son **nom**, son **domicile** — défini comme le lieu de son principal établissement (C. civ., art. 102) —, sa **nationalité**

(Tome 10) et son **état civil**, constaté par les actes de l'état civil (naissance, mariage, décès). L'état civil est régi en Côte d'Ivoire par la loi n° 2018-862 du 19 novembre 2018 relative à l'état civil, dont les modalités d'application ont été précisées par le décret n° 2019-805 du 2 octobre 2019, et complétée par une loi du même jour instituant une procédure spéciale de déclaration de naissance (loi n° 2018-863).

3° La capacité

Le **mineur** n'a pas la capacité d'exercice : il est représenté par ses parents ou son tuteur. L'âge de la majorité civile, longtemps fixé à vingt et un ans en Côte d'Ivoire, a été abaissé à **dix-huit ans** par la réforme de 2019 relative à la minorité V. Certains **majeurs** dont les facultés sont altérées peuvent être placés sous un régime de protection. Les incapacités de jouissance, toujours spéciales, sont fondées sur des considérations de protection ou de moralité (interdiction pour certaines personnes de recevoir des libéralités, par exemple).

B. Les personnes morales

1° La diversité des personnes morales

Tableau 3 — Les principales personnes morales

Catégorie	Exemples en Côte d'Ivoire	Textes
Personnes morales de droit public	État, collectivités territoriales (régions, communes), établissements publics	Constitution ; lois sur l'organisation territoriale
Sociétés commerciales	SARL, SA, SAS, SNC, SCS	AUSCGIE (30 janvier 2014)
Groupements d'intérêt économique	GIE	AUSCGIE
Sociétés coopératives	Coopératives agricoles	Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives (15 décembre 2010)
Associations	Associations déclarées, ONG	Loi n° 60-315 du 21 septembre 1960 relative aux associations
Syndicats professionnels	Syndicats de salariés et d'employeurs	Code du travail

2° Les théories de la personnalité morale

La théorie de la fiction, associée à Savigny, enseigne que seul l'être humain est naturellement sujet de droit ; la personnalité morale est une fiction créée par le législateur, qui peut l'accorder ou la refuser à son gré.

Les théories de la réalité voient dans les groupements des réalités sociales. Dans sa version organiciste (Otto von Gierke), le groupement est un être vivant doté d'une volonté propre ; dans sa version technique (Léon Michoud, Raymond Saleilles), la personnalité morale est une technique juridique adaptée à une réalité : l'existence d'un intérêt collectif distinct des intérêts individuels et d'une organisation capable de l'exprimer[2].

Les théories négatrices (Planiol, Duguit) voient dans la personne morale un simple procédé de gestion collective de biens, une forme de propriété collective.

3° L'acquisition et les attributs de la personnalité morale

L'acquisition de la personnalité morale obéit à des règles propres à chaque catégorie. Les **sociétés commerciales** jouissent de la personnalité juridique à compter de leur immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier (AUSCGIE, art. 98) ; avant l'immatriculation, la société est « en formation », et les actes accomplis pour son compte obéissent à un régime particulier (AUSCGIE, art. 106 et s. V). Les **associations** acquièrent la capacité juridique selon les conditions de la loi de 1960, inspirée de la loi française de 1901, qui subordonne leur capacité à une déclaration V.

La personne morale possède des **attributs** comparables à ceux des personnes physiques : un nom (dénomination sociale), un domicile (siège social), une nationalité, un patrimoine propre, une capacité juridique. Sa capacité est limitée par le **principe de spécialité** pour les personnes morales de droit public et les associations, qui ne peuvent agir que dans les limites de leur objet. Elle peut engager sa responsabilité civile et, dans les conditions prévues par la loi pénale, sa responsabilité pénale.

5. Étude des textes applicables

Tableau 4 — Textes relatifs aux droits subjectifs et aux personnes

Texte	Contenu	Observation
C. civ., art. 102	Domicile : lieu du principal établissement	Rédaction applicable en Côte d'Ivoire
C. civ., art. 516 et s.	Distinction des biens meubles et immeubles	Classification des biens, objets des droits réels
C. civ., art. 544	Définition de la propriété	Droit réel principal
C. civ., art. 2092 et 2093	Droit de gage général des créanciers	Conséquence de l'unité du patrimoine ; renumérotés en France en 2006

2. L. Michoud, *La théorie de la personnalité morale et son application au droit français*, LGDJ, 2 vol., 1906-1909.

Texte	Contenu	Observation
Loi n° 2018-862 du 19 novembre 2018	État civil	Décret d'application n° 2019-805 du 2 octobre 2019
Lois de 2019 sur la famille et la minorité	Mariage, filiation, minorité, successions	Majorité à 18 ans V
Loi n° 60-315 du 21 septembre 1960	Associations	Version en vigueur à vérifier
AUSCGIE, art. 1er et 98	Champ d'application ; personnalité juridique à compter de l'immatriculation	Droit uniforme OHADA
AUDCG (2010)	Statut de l'entreprenant	Pas de séparation des patrimoines
AUS (2010)	Sûretés personnelles et réelles	Droits réels accessoires
Accord de Bangui (OAPI)	Propriété intellectuelle	Droits intellectuels
Loi de 2013 relative à la protection des données à caractère personnel	Droits des personnes sur leurs données	Droits de la personnalité à l'ère numérique V

DROIT COMPARÉ —

En droit français, l'unité du patrimoine a été progressivement aménagée : création de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (1985), de la fiducie (loi n° 2007-211 du 19 février 2007), de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (loi n° 2010-658 du 15 juin 2010), puis, par la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, séparation de plein droit du patrimoine professionnel et du patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel. Le droit OHADA admet les sociétés unipersonnelles (SARL, SA, SAS), mais le statut de l'entreprenant n'emporte pas de séparation des patrimoines.

6. Analyse de jurisprudences vérifiables

Jurisprudence — Cass. civ. 2e (France), 28 janvier 1954, Comité d'établissement de Saint-Chamond

Question. Un groupement auquel aucun texte n'attribue expressément la personnalité juridique peut-il en être doté ?

Solution. La Cour de cassation juge que la personnalité civile n'est pas une création de la loi ; qu'elle appartient, en principe, à tout groupement pourvu d'une possibilité d'expression collective pour la défense d'intérêts licites, dignes, par suite, d'être juridiquement reconnus et protégés ; et que, si le législateur a le pouvoir de la refuser, il n'en a pas fait usage en l'espèce.

Portée. L'arrêt consacre la **théorie de la réalité technique** : la personnalité morale est reconnue, et non créée, par le droit, dès lors que le groupement présente les caractères requis. Il est fondé sur des principes de droit commun et éclaire la question de la personnalité des groupements dont le statut n'est pas fixé par un texte.

Jurisprudence — Cass. 1re civ. (France), 10 décembre 1985, Bull. civ. I, n° 339

Question. Un enfant conçu au moment du décès de son père peut-il bénéficier d'un capital d'assurance réservé aux enfants « à charge » de l'assuré ?

Solution. La Cour de cassation applique la règle selon laquelle l'enfant conçu est réputé né chaque fois qu'il y va de son intérêt, et la qualifie de **principe général du droit**.

Portée. L'arrêt confirme la portée générale de l'adage *infans conceptus*, au-delà des matières où un texte l'applique expressément (successions, libéralités).

Jurisprudence — Cass. ass. plén. (France), 29 juin 2001, n° 99-85.973 ; CEDH, gr. ch., 8 juillet 2004, Vo c. France

Question. L'atteinte involontaire à la vie d'un enfant à naître constitue-t-elle un homicide involontaire ?

Solutions. L'Assemblée plénière juge que le principe de la légalité des délits et des peines, qui impose une interprétation stricte de la loi pénale, s'oppose à ce que l'incrimination d'homicide involontaire soit étendue au cas de l'enfant à naître, dont le régime juridique relève de textes particuliers. La Cour européenne, saisie de la question, estime que le point de départ du droit à la vie relève de la marge d'appréciation des États.

Portée. Ces décisions montrent que le début de la personnalité juridique — et donc de la qualité de « personne » protégée par certaines incriminations — est une question de droit positif, sur laquelle les solutions des États peuvent diverger.

Jurisprudence — Cour constitutionnelle de Colombie, arrêt T-622/16 du 10 novembre 2016 (fleuve Atrato)

Solution. La Cour constitutionnelle colombienne reconnaît le fleuve Atrato comme **sujet de droits**, titulaire de droits à la protection, à la conservation et à la restauration, et organise sa représentation par des gardiens désignés.

Portée. La décision s'inscrit dans un mouvement de reconnaissance des « droits de la nature », dont témoignent aussi la Constitution de l'Équateur de 2008 et la loi néo-zélandaise de 2017 relative au fleuve Whanganui (Te Awa Tupua). Elle interroge les limites de la notion de sujet de droit (rubrique 7).

7. Présentation des débats doctrinaux

A. Le droit subjectif existe-t-il ?

DÉBAT DOCTRINAL — DROIT SUBJECTIF OU SITUATION JURIDIQUE ?

Les négations. Duguit voit dans le droit subjectif une notion métaphysique, qui exprime une conception individualiste de la société ; Kelsen n'y voit qu'un reflet des obligations imposées par le droit objectif ou une compétence pour agir en justice ; Villey y voit une déformation moderne de l'idée de droit DOC.

Les défenses. Dabin et la majorité de la doctrine maintiennent la notion, qui exprime une réalité juridique incontestable : le droit positif reconnaît à des personnes des prérogatives dont elles ont la maîtrise, qu'elles peuvent exercer, céder ou abandonner, et dont elles peuvent obtenir la protection en justice DOC.

Appréciation. La notion de droit subjectif demeure indispensable à l'exposé du droit positif et à la protection des personnes ; les critiques ont toutefois eu le mérite de montrer que les droits ne sont pas absolus, qu'ils sont reconnus en vue de fins sociales et que leur exercice peut être abusif (chapitre 12).

B. L'unité du patrimoine en question

La théorie d'Aubry et Rau a été critiquée pour sa rigidité : en imposant à chaque personne un patrimoine unique, elle expose l'entrepreneur individuel à perdre l'ensemble de ses biens personnels en cas d'échec, ce qui décourage l'initiative économique. Le droit contemporain y a répondu par des techniques d'affectation. Dans l'espace OHADA, la réponse principale est la **société unipersonnelle**, qui permet de limiter la responsabilité au prix de la création d'une personne morale. Pour l'entreprenant, le droit uniforme a privilégié la simplicité des formalités plutôt que la séparation des patrimoines.

PROPOSITION DE L'AUTEUR — UN PATRIMOINE PROFESSIONNEL POUR L'ENTREPRENANT

Le statut de l'entreprenant vise à attirer vers le droit formel les acteurs de l'économie informelle. Son attractivité pourrait être renforcée par une **séparation légale du patrimoine professionnel et du patrimoine personnel**, sur le modèle — adapté — de la réforme française de 2022, afin de protéger la résidence familiale et les biens personnels de l'entrepreneur contre les créanciers professionnels. Une telle réforme relèverait du législateur OHADA ; elle devrait être assortie de garanties pour les créanciers (publicité, responsabilité en cas de confusion des patrimoines) PP.

C. Faut-il étendre la personnalité juridique ?

Le débat contemporain porte sur l'extension de la personnalité juridique à de nouveaux êtres ou entités. Pour les **animaux**, le droit français a choisi une voie intermédiaire : depuis la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, le Code civil français reconnaît que les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité, tout en les soumettant, sous réserve des lois qui les protègent, au régime des biens. Pour la **nature**, plusieurs systèmes ont reconnu des droits à des fleuves ou à des écosystèmes. Pour les **systèmes d'intelligence artificielle**, le Parlement européen a évoqué, dans une résolution du 16 février 2017 relative à des règles de droit civil sur la robotique, la création à terme d'une « personnalité électronique », proposition largement critiquée. Ces débats montrent que la personnalité juridique est une **technique**, dont l'extension dépend de choix de politique juridique : protéger des intérêts, organiser une représentation, imputer des responsabilités.

Dans le contexte africain, la question rejoint celle des **groupes coutumiers** — lignages, communautés villageoises — qui exercent des droits collectifs sur la terre sans être, en principe, dotés de la personnalité juridique : la reconnaissance de leurs droits suppose de déterminer qui peut les représenter et agir en leur nom.

8. Illustrations pratiques

L'entreprenant et sa maison. Une couturière d'Abobo, déclarée comme entreprenante, contracte des dettes professionnelles auprès de fournisseurs. En cas d'impayés, ses créanciers peuvent, en vertu du droit de gage général, saisir tous ses biens, y compris son logement, sous réserve des règles d'insaisissabilité. La création d'une SARL unipersonnelle lui aurait permis de limiter sa responsabilité à ses apports, sous réserve des garanties personnelles exigées par les banques.

La coopérative agricole. Des planteurs de cacao constituent une société coopérative régie par l'Acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés coopératives. Une fois immatriculée, la coopérative est une personne morale distincte de ses membres : elle peut contracter, emprunter, ester en justice et posséder des biens en son nom.

La photographie publiée sans autorisation. La photographie d'une jeune femme, prise dans un lieu privé, est publiée sur un réseau social à des fins publicitaires. L'atteinte à son droit à l'image et au respect de sa vie privée peut fonder une action en responsabilité et des mesures de retrait, ainsi que, le cas échéant, des poursuites pénales sur le fondement de la législation relative à la cybercriminalité et à la protection des données personnelles.

Le bien du lignage. Un terrain coutumier est revendiqué par les membres d'un lignage. Le lignage n'étant pas une personne morale, la question se pose de savoir qui peut agir en jus-

tice en son nom ; la certification foncière oblige à identifier un ou plusieurs titulaires, personnes physiques ou morales.

9. Cas pratiques corrigés

Cas pratique n° 1 — Le contrat de la société en formation

Énoncé. M. Bamba et Mme Koffi décident de créer une SARL. Avant l'immatriculation, M. Bamba signe, « au nom de la société en formation », le bail du local commercial. La société est immatriculée deux mois plus tard. Le bailleur demande le paiement des loyers à la société ; celle-ci soutient qu'elle n'était pas partie au bail. Qui est tenu des loyers ?

CORRIGÉ

Problème de droit. Une société peut-elle être tenue d'un contrat conclu pour son compte avant son immatriculation ?

Règles applicables. La société jouit de la personnalité juridique à compter de son immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier (AUSCGIE, art. 98). Avant l'immatriculation, elle n'a pas la personnalité juridique ; les personnes qui ont agi au nom de la société en formation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, sauf si la société, après sa constitution et son immatriculation, reprend les engagements souscrits, ces engagements étant alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société (AUSCGIE, art. 106 et s. V). L'Acte uniforme organise les modalités de cette reprise.

Application. Le bail a été conclu avant l'immatriculation, au nom de la société en formation. Si la société a repris le bail dans les formes prévues par l'Acte uniforme (mention dans les statuts, décision des associés, etc.), elle est tenue des loyers depuis l'origine. À défaut de reprise, M. Bamba demeure personnellement tenu.

Conclusion. Le bailleur doit vérifier si le bail a été repris par la société ; à défaut, il doit agir contre M. Bamba. Le cas illustre le lien entre l'acquisition de la personnalité morale et l'imputation des droits et obligations.

Cas pratique n° 2 — L'enfant posthume

Énoncé. M. N'Guessan est décédé dans un accident ; son épouse, avec laquelle il était marié civilement, était alors enceinte de trois mois. L'enfant naît vivant et viable six mois plus tard. Les frères du défunt soutiennent que l'enfant, qui n'était pas né au jour du décès, ne peut pas hériter. Qu'en pensez-vous ?

CORRIGÉ

Problème de droit. Un enfant conçu mais non encore né au jour de l'ouverture de la succession peut-il hériter ?

Règles applicables. La personnalité juridique commence à la naissance d'un enfant vivant et viable ; toutefois, selon l'adage *infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis ejus agitur*, l'enfant conçu est réputé né chaque fois qu'il y va de son intérêt. Les législations successorales de tradition civiliste font application de cette règle en exigeant, pour succéder, d'exister — c'est-à-dire d'être au moins conçu — au jour de l'ouverture de la succession, et de naître vivant et viable ; les dispositions précises de la loi ivoirienne relative aux successions doivent être vérifiées sur ce point V. La jurisprudence française regarde la règle comme un principe général du droit (Cass. 1re civ., 10 décembre 1985).

Application. L'enfant était conçu au jour du décès ; il est né vivant et viable. Il y va de son intérêt d'être considéré comme né à la date du décès pour recueillir la succession. Il a donc vocation à hériter de son père, en qualité d'enfant. Sa filiation paternelle, établie dans le cadre du mariage, n'est pas en cause.

Conclusion. Les frères du défunt ont tort : l'enfant est héritier. Ses droits seront exercés par sa mère, en qualité de représentante légale.

10. Synthèse et connaissances essentielles

SYNTHÈSE — CONNAISSANCES ESSENTIELLES

- Le **droit subjectif** est une prérogative reconnue et sanctionnée par le droit objectif au profit de son titulaire ; il se distingue des libertés, des droits-fonctions et des simples intérêts. Défini comme pouvoir de volonté (Windscheid) ou intérêt protégé (Jhering), il a été nié par Duguit et Kelsen et refondé par Dabin (**appartenance-maîtrise**).
- Classifications : droits **patrimoniaux** (réels, personnels, intellectuels) et **extrapatrimoniaux** (droits de la personnalité, droits familiaux, droits politiques).
- Le **droit réel** confère un pouvoir direct sur une chose, opposable à tous, avec droit de suite et, pour les sûretés, droit de préférence ; le **droit personnel** permet d'exiger une prestation d'un débiteur.
- Le **patrimoine** est une universalité ; selon Aubry et Rau, il est une émanation de la personnalité, unique et indivisible ; d'où le **droit de gage général** (C. civ., art. 2092-2093). L'affectation se réalise en droit OHADA par la **société unipersonnelle**.
- La **personnalité juridique** appartient aux personnes physiques (de la naissance, ou de la conception selon *infans conceptus*, jusqu'à la mort) et aux **personnes morales** (théories de la fiction, de la réalité, réalité technique : *Saint-Chamond*, 1954).
- Les sociétés commerciales acquièrent la personnalité à leur **immatriculation au RCCM** (AUSCGIE, art. 98).

– La majorité civile est fixée à **18 ans** depuis la réforme de 2019 V ; l'état civil est régi par la loi n° 2018-862.

11. Questions d'évaluation

QUESTIONS D'ÉVALUATION

Questions de cours

1. Définissez le droit subjectif et distinguez-le de la liberté et du droit-fonction.
2. Comparez droit réel et droit personnel.
3. Exposez la théorie classique du patrimoine et ses conséquences.
4. Qu'est-ce que l'adage *infans conceptus* ? Quelle en est la portée ?
5. Présentez les théories de la personnalité morale.
6. À quel moment une société commerciale acquiert-elle la personnalité juridique dans l'espace OHADA ?

Questions de réflexion

1. La théorie de l'unité du patrimoine est-elle adaptée à l'économie ivoirienne ?
2. Faut-il reconnaître la personnalité juridique aux communautés coutumières ?

Sujets de dissertation

1. « Le droit subjectif. »
2. « La personnalité morale, réalité ou fiction ? »
3. « L'extension de la personnalité juridique. »

Commentaire

1. Commentez l'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 28 janvier 1954, *Comité d'établissement de Saint-Chamond*.

12. Références bibliographiques

Ouvrages généraux

J. Carbonnier, *Droit civil. Introduction. Les personnes. La famille, l'enfant, le couple*, PUF, coll. « Quadrige ».

F. Terré, *Introduction générale au droit*, Dalloz, coll. « Précis », dernière éd.

J.-L. Aubert et É. Savaux, *Introduction au droit et thèmes fondamentaux du droit civil*, Sirey, dernière éd.

Ouvrages spéciaux

J. Dabin, *Le droit subjectif*, Dalloz, 1952.

L. Michoud, *La théorie de la personnalité morale et son application au droit français*, LGDJ, 1906-1909.

M. Villey, *Le droit et les droits de l'homme*, PUF, 1983.

L. Duguit, *Traité de droit constitutionnel*, de Boccard, 3e éd.

Droit OHADA

J. Issa-Sayegh et J. Lohoues-Oble, *OHADA. Harmonisation du droit des affaires*, Bruylant, 2002.

OHADA. Traité et actes uniformes commentés et annotés, Juriscope, dernière éd.

Sources officielles

Code civil ; loi n° 2018-862 du 19 novembre 2018 relative à l'état civil ; lois du 26 juin 2019 ; loi n° 60-315 du 21 septembre 1960 ; AUSCGIE (30 janvier 2014) ; AUDCG (15 décembre 2010) ; Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives (15 décembre 2010) ; Accord de Bangui (OAPI).

CHAPITRE 12

La preuve et la sanction des droits

Idem est non esse et non probari.

— Adage : ne pas être et ne pas être prouvé, c'est tout un.

1. Introduction et problématique

Avoir un droit ne suffit pas : encore faut-il pouvoir le **prouver**, le **faire reconnaître** et le **faire exécuter**. Le créancier qui ne peut établir l'existence de sa créance est, en pratique, dans la même situation que celui qui n'en a pas ; le propriétaire dont le titre est contesté doit en convaincre le juge ; le titulaire d'un jugement doit encore en obtenir l'exécution, au besoin par la contrainte. L'adage *idem est non esse et non probari* exprime cette vérité : un droit non prouvé est, devant le juge, un droit inexistant.

La réalisation des droits est en outre encadrée. Le titulaire d'un droit ne peut se faire justice à lui-même : il doit, en principe, passer par le juge ou par les autres modes de règlement des différends que le droit organise. Et il ne peut exercer son droit de n'importe quelle manière : l'exercice d'un droit dans le seul but de nuire, ou de manière détournée de sa finalité, constitue un **abus de droit** sanctionné. Le temps, enfin, éteint les droits négligés : c'est la **prescription**.

En Côte d'Ivoire, ces questions présentent des aspects spécifiques : coexistence des règles de preuve du Code civil hérité et des règles plus souples du droit commercial OHADA ; essor de la preuve électronique, reconnue par la loi de 2013 sur les transactions électroniques ; conditions d'exercice de l'action en justice fixées par le Code de procédure civile, commerciale et administrative ; procédures d'exécution unifiées par l'Acte uniforme OHADA ; place croissante de la médiation et de l'arbitrage.

Problématique. *Comment un droit subjectif devient-il effectif — par quels moyens se prouve-t-il, par quelles voies se réalise-t-il — et dans quelles limites peut-il être exercé ?* Le chapitre montrera que le droit organise la réalisation des droits selon un équilibre entre l'efficacité, qui commande de faciliter la preuve et l'exécution, et la protection des personnes, qui

commande d'encadrer les moyens de preuve, de garantir le procès équitable et de sanctionner l'exercice abusif des droits.

2. Fondements historiques et théoriques

A. L'histoire de la preuve

Les systèmes juridiques anciens recouraient souvent à des modes de preuve irrationnels, fondés sur l'intervention supposée de la divinité : ordalies, combats judiciaires, serments purgatoires. Le droit canonique médiéval a développé un système de **preuves légales**, dans lequel la loi fixe à l'avance la force de chaque moyen de preuve. En France, l'ordonnance de Moulins de 1566 a posé la règle de la **prééminence de l'écrit** sur le témoignage pour les conventions dépassant une certaine valeur, résumée par l'adage « lettres passent témoins ». Le Code civil de 1804 a repris ce système (art. 1341), tout en le combinant avec des modes de preuve plus libres pour les faits juridiques.

En matière pénale, la Révolution a substitué au système des preuves légales celui de l'**intime conviction** du juge, qui apprécie librement la valeur des preuves. En matière commerciale, la rapidité et la confiance réciproque des échanges ont conduit à admettre la **liberté de la preuve** entre commerçants.

B. De l'action au droit d'agir

Le droit romain était un droit d'actions : chaque prétention devait entrer dans une formule procédurale déterminée. Le droit moderne a progressivement séparé le **droit substantiel** et l'**action en justice**, définie comme le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée — définition proposée par Henri Motulsky et consacrée par l'article 30 du Code de procédure civile français. Le droit d'accès au juge est aujourd'hui garanti comme un droit fondamental, notamment par l'article 7 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples.

C. L'interdiction de se faire justice à soi-même

La formation de l'État moderne s'est accompagnée de l'interdiction de la justice privée et de la vengeance : le titulaire d'un droit méconnu doit s'adresser au juge, et l'exécution forcée est réservée aux agents habilités, avec le concours de la force publique. Ce principe connaît des tempéraments limités : légitime défense, exception d'inexécution dans les contrats synallagmatiques, droit de rétention.

D. La relativité des droits et l'abus de droit

Le droit romain connaissait déjà des maximes limitant l'exercice malveillant des droits, et Cicéron rappelait que l'application extrême du droit peut conduire à l'extrême injustice (*summum jus, summa injuria*). Au XIXe siècle, la conception absolutiste des droits subjectifs, consacrée par le Code civil, a été tempérée par la jurisprudence, qui a sanctionné l'exercice des droits dans l'intention de nuire. Louis Josserand a systématisé la théorie de l'**abus de droit** en soutenant que les droits sont relatifs, reconnus en vue d'une finalité sociale, et que leur exercice détourné de cette finalité est abusif[1]. Marcel Planiol lui a objecté que la notion est contradictoire : le droit cesse où l'abus commence, et un même acte ne peut être à la fois conforme et contraire au droit. Le Code civil allemand (BGB, § 226) interdit l'exercice d'un droit qui ne peut avoir d'autre but que de causer un dommage à autrui ; le Code civil suisse dispose que l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (art. 2, al. 2).

3. Explication approfondie des concepts

A. Faits juridiques et actes juridiques

DÉFINITION — ACTE JURIDIQUE

Manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit : contrat, testament, reconnaissance d'enfant, décision d'une assemblée d'associés. Les effets de droit sont produits parce qu'ils ont été voulus.

DÉFINITION — FAIT JURIDIQUE

Événement, volontaire ou non, auquel le droit attache des effets qui n'ont pas été recherchés par leur auteur : naissance, décès, accident, faute délictuelle, enrichissement sans cause.

La distinction, que le Code civil applicable en Côte d'Ivoire ne formule pas expressément (le Code civil français ne la définit que depuis la réforme de 2016, art. 1100-1 et 1100-2), est essentielle en matière de preuve : les actes juridiques, que les parties peuvent préconstituer, sont soumis à des exigences de preuve par écrit ; les faits juridiques, qu'on ne peut prévoir, se prouvent par tous moyens.

B. La preuve : objet, charge et modes

L'objet de la preuve. Ce sont les **faits** pertinents et contestés qui doivent être prouvés. Le **droit**, en principe, n'a pas à l'être : le juge est censé le connaître (*jura novit curia*) ; il en va dif-

féremment de la loi étrangère et, dans une certaine mesure, des coutumes et usages (chapitre 9).

La charge de la preuve. Selon l'article 1315 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Ce texte exprime l'adage *actori incumbit probatio* (la preuve incombe au demandeur), complété par l'adage *reus in excipiendo fit actor* (le défendeur qui invoque une exception devient demandeur quant à celle-ci). La charge de la preuve détermine le **risque de la preuve** : si le doute subsiste, celui qui avait la charge de prouver perd le procès.

Les modes de preuve.

Tableau 1 — Les modes de preuve en droit civil

Mode	Définition	Force probante	Observations
Acte authentique	Écrit reçu par un officier public compétent (notaire, officier de l'état civil) dans les formes requises	Fait foi jusqu'à inscription de faux pour ce que l'officier a constaté	Force exécutoire pour les actes notariés revêtus de la formule exécutoire
Acte sous seing privé	Écrit signé par les parties	Fait foi jusqu'à preuve contraire, si la signature n'est pas désavouée	Formalités : pluralité d'originaux pour les contrats synallagmatiques (art. 1325) ; mention manuscrite pour certains engagements unilatéraux (art. 1326)
Écrit électronique	Écrit sous forme électronique	Admis comme l'écrit sur support papier, sous condition d'identification de l'auteur et d'intégrité	Loi n° 2013-546 du 30 juillet 2013 (art. 23)
Témoignage	Déclaration d'une personne sur des faits qu'elle a personnellement constatés	Librement apprécié par le juge	Recevabilité limitée pour les actes juridiques en matière civile
Présomptions	Conséquences que la loi ou le juge tire d'un fait connu à un fait inconnu	Légales : simples, mixtes ou irréfragables ; du fait de l'homme : « graves, précises et concordantes » (art. 1353)	Les présomptions légales simples renversent la charge de la preuve

1. L. Josserand, *De l'esprit des droits et de leur relativité. Théorie dite de l'abus des droits*, Dalloz, 2e éd., 1939.

Mode	Définition	Force probante	Observations
Aveu	Reconnaissance par une partie d'un fait qui lui est défavorable	Judiciaire : fait pleine foi, indivisible, irrévocable sauf erreur de fait ; extra-judiciaire : librement apprécié	
Serment	Affirmation solennelle d'une partie	Décisoire (déféré par une partie, il tranche le litige) ; supplétoire (déféré par le juge)	Mode de preuve devenu rare

C. Les systèmes de preuve

En **matière civile**, la preuve des actes juridiques obéit à un système de **preuve légale** : au-delà d'un montant fixé par les textes, la preuve doit être faite par écrit, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes (C. civ., art. 1341) V. Cette exigence connaît des exceptions : le **commencement de preuve par écrit**, émanant de celui contre lequel la demande est formée et rendant vraisemblable le fait allégué, peut être complété par témoignages ou présomptions (art. 1347) ; l'**impossibilité**, matérielle ou morale, de se procurer un écrit, notamment entre proches, dispense de la preuve écrite (art. 1348) ; la perte de l'écrit par cas fortuit est également admise.

En **matière commerciale**, la preuve est **libre** : selon l'AUDCG, les actes de commerce se prouvent par tous moyens, même par voie électronique, à l'égard des commerçants (AUDCG, art. 5). La jurisprudence relative à l'application de l'Acte uniforme en a déduit que la règle de la preuve écrite du Code civil ne s'applique pas à la preuve des actes de commerce entre commerçants[2].

En **matière pénale**, la preuve est libre et le juge statue selon son **intime conviction**, dans le respect de la présomption d'innocence et de la loyauté de la preuve (Tome 7).

D. L'action en justice

> **DÉFINITION — ACTION EN JUSTICE**
>
> Droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée ; pour l'adversaire, droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.

En droit ivoirien, l'article 3 du Code de procédure civile, commerciale et administrative subordonne la recevabilité de l'action à trois conditions cumulatives : le demandeur doit justi-

fier d'un **intérêt** légitime, juridiquement protégé, direct et personnel; il doit avoir **qualité** pour agir en justice; il doit posséder la **capacité** d'agir en justice. L'absence de l'une de ces conditions entraîne l'irrecevabilité de l'action, sans examen du fond.

E. Les titres exécutoires et l'exécution forcée

L'exécution forcée suppose un **titre exécutoire** : décision de justice revêtue de la formule exécutoire, acte notarié revêtu de la formule exécutoire, sentence arbitrale ayant reçu l'exequatur, et les autres titres énumérés par l'AUPSRVE. Tout créancier peut, quelle que soit la nature de sa créance, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard, dans les conditions prévues par l'Acte uniforme; l'État est tenu de prêter son concours à l'exécution des décisions et des autres titres exécutoires; l'exécution forcée n'est cependant pas applicable aux personnes qui bénéficient d'une immunité d'exécution (AUPSRVE de 1998, art. 28 à 30; chapitre 6). Cet acte uniforme a été remplacé par un acte révisé, adopté le 17 octobre 2023 et entré en vigueur le 16 février 2024, dont la numérotation et la rédaction doivent être vérifiées MOD V.

F. L'abus de droit

> **DÉFINITION — ABUS DE DROIT**
>
> Faute commise dans l'exercice d'un droit, soit que son titulaire l'exerce dans l'intention de nuire à autrui, soit qu'il l'exerce sans intérêt légitime ou en le détournant de sa finalité, et qui engage sa responsabilité ou prive l'acte de ses effets.

G. La prescription

> **DÉFINITION — PRESCRIPTION**
>
> Moyen d'acquérir un droit (prescription acquisitive ou usucapion) ou de se libérer d'une obligation (prescription extinctive) par l'écoulement d'un certain laps de temps, dans les conditions déterminées par la loi (C. civ., art. 2219).

4. Analyse des principes et mécanismes juridiques

A. La charge et le risque de la preuve

La répartition de la charge de la preuve est souvent décisive. Le demandeur en paiement doit prouver l'existence de la créance; le débiteur qui se prétend libéré doit prouver le paiement.

Les **présomptions légales** modifient cette répartition : ainsi, en matière de responsabilité du fait des choses, la victime n'a pas à prouver la faute du gardien, présumé responsable (chapitre 10). Les parties peuvent également aménager conventionnellement la preuve, dans certaines limites.

B. La loyauté et la licéité de la preuve

La preuve doit être obtenue de manière loyale et licite. Cette exigence protège la vie privée, le secret des correspondances et l'équité de la procédure. Elle entre cependant en tension avec le **droit à la preuve**, composante du droit au procès équitable : interdire à une partie de produire le seul élément de preuve dont elle dispose peut la priver de toute chance de faire valoir son droit. La jurisprudence française a connu sur ce point une évolution significative (rubrique 6), qui intéresse directement la pratique ivoirienne, où les enregistrements téléphoniques, les captures de messages et les publications sur les réseaux sociaux sont de plus en plus produits en justice.

C. La recevabilité de l'action

Le juge examine d'abord la recevabilité de l'action, avant d'en apprécier le bien-fondé. Les **fins de non-recevoir** (défaut d'intérêt, de qualité, de capacité, prescription, autorité de la chose jugée) peuvent être soulevées en tout état de cause et entraînent le rejet de la demande sans examen au fond. La **qualité** pose des difficultés particulières lorsque l'action est exercée au nom d'une personne morale : le signataire de l'acte introductif doit justifier de son pouvoir de représentation, faute de quoi l'action est irrecevable.

D. Les modes alternatifs de règlement des différends

Le procès n'est pas la seule voie de réalisation des droits. Le droit ivoirien et le droit OHADA organisent plusieurs **modes alternatifs** :

- la **négociation** et la **transaction**, contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître, qui a autorité de la chose jugée entre elles ;
- la **conciliation**, menée par un tiers ou par le juge lui-même ;
- la **médiation**, processus dans lequel un tiers impartial aide les parties à trouver une solution, régie dans l'espace OHADA par l'Acte uniforme relatif à la médiation du 23 novembre 2017 ;
- l'**arbitrage**, mode juridictionnel privé, régi par l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage du 23 novembre 2017, et pratiqué notamment sous l'égide de la CCJA et de centres d'arbitrage nationaux comme la Cour d'arbitrage de Côte d'Ivoire.

2. V. la décision recensée dans la base Ohadata sous la référence J-06-35 V.

E. Les critères et les sanctions de l'abus de droit

La jurisprudence et la doctrine ont dégagé plusieurs critères de l'abus :

1. l'**intention de nuire** : critère le plus strict, retenu par les premières décisions (rubrique 6) ;
2. l'**absence d'intérêt légitime** : le titulaire exerce son droit sans en retirer d'utilité sérieuse, au détriment d'autrui ;
3. le **détournement de la finalité** du droit (Josserand) : le droit est exercé dans un but étranger à celui pour lequel il a été reconnu ;
4. la **disproportion** entre l'avantage retiré par le titulaire et le préjudice causé à autrui.

L'abus est sanctionné par l'octroi de **dommages-intérêts** sur le fondement de la responsabilité civile (C. civ., art. 1382), et, le cas échéant, par la **suppression de l'acte abusif** (démolition d'un ouvrage, levée d'une mesure) ou par son **inopposabilité**.

Le droit OHADA consacre plusieurs applications de la théorie. L'AUSCGIE définit l'**abus de majorité** comme la résolution adoptée par les associés majoritaires dans leur seul intérêt, contrairement aux intérêts des associés minoritaires, et sans que cette résolution puisse être justifiée par l'intérêt de la société (art. 130) ; il sanctionne symétriquement l'**abus de minorité** (art. 131).

F. La prescription

La prescription extinctive répond à plusieurs justifications : sécurité juridique et paix sociale, présomption de paiement ou de renonciation, sanction de la négligence du créancier, difficulté croissante de la preuve avec le temps. Ses règles essentielles sont les suivantes :

– le **délai de droit commun**, en matière civile, est de trente ans dans le Code civil applicable en Côte d'Ivoire (art. 2262), sous réserve des nombreux délais spéciaux ;
– en matière commerciale, les obligations nées à l'occasion du commerce entre commerçants, ou entre commerçants et non-commerçants, se prescrivent par **cinq ans** si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes (AUDCG, art. 16 V) ;
– la prescription peut être **interrompue** (un nouveau délai court alors), notamment par une demande en justice ou une reconnaissance du débiteur, ou **suspendue** (le délai cesse temporairement de courir) ;
– la **prescription acquisitive** permet d'acquérir la propriété d'un immeuble par une possession utile prolongée : trente ans en principe, dix à vingt ans en cas de juste titre et de bonne foi (C. civ., art. 2262 et 2265), sous réserve des règles propres aux immeubles immatriculés, que le régime de l'immatriculation foncière soustrait en principe à la prescription V.

DROIT COMPARÉ —

En France, la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile a ramené le délai de droit commun des actions personnelles ou mobilières à cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer (C. civ., art. 2224 nouveau), et a renuméroté les dispositions. Cette réforme n'est pas applicable en Côte d'Ivoire, où le délai de trente ans de l'ancien article 2262 demeure le délai de droit commun, sous réserve des textes spéciaux et du droit uniforme.

5. Étude des textes applicables

Tableau 2 — Textes relatifs à la preuve et à la sanction des droits

Texte	Objet	Observation
C. civ., art. 1315	Charge de la preuve	Rédaction ancienne, applicable en Côte d'Ivoire
C. civ., art. 1317 et s.	Acte authentique, acte sous seing privé	Rédaction ancienne
C. civ., art. 1341, 1347, 1348	Exigence d'un écrit ; commencement de preuve par écrit ; impossibilité	Montant au-delà duquel l'écrit est exigé à vérifier V
C. civ., art. 1349 à 1369	Présomptions, aveu, serment	
Loi n° 2013-546 du 30 juillet 2013	Transactions électroniques ; écrit électronique	Art. 23 relatif à l'écrit électronique ; modification ultérieure de l'art. 50 à vérifier
CPCCA, art. 3	Conditions de recevabilité de l'action	Appliqué par la Cour d'appel de commerce d'Abidjan
AUDCG, art. 5 et 16	Liberté de la preuve commerciale ; prescription quinquennale	V pour l'art. 16
AUPSRVE (1998), art. 28 à 30 MOD	Droit à l'exécution ; concours de l'État ; immunité d'exécution	Texte remplacé par l'acte révisé du 17 octobre 2023 ; numérotation à vérifier V
AUSCGIE, art. 130 et 131	Abus de majorité et de minorité	
AUA et Acte uniforme relatif à la médiation (23 novembre 2017)	Arbitrage et médiation	
C. civ., art. 2219, 2262, 2265	Prescription	Rédaction ancienne, applicable en Côte d'Ivoire
Charte africaine, art. 7	Droit à ce que sa cause soit entendue	Fondement du droit d'accès au juge

6. Analyse de jurisprudences vérifiables

Jurisprudence — Cour d'appel de Colmar (France), 2 mai 1855, Doerr (affaire de la « fausse cheminée »)

Faits. Un propriétaire avait fait édifier sur son toit une fausse cheminée, dépourvue de toute utilité, dans le seul but d'obscurcir la fenêtre de son voisin.

Solution. La cour juge que, si le droit de propriété est un droit en quelque sorte absolu, l'exercice de ce droit doit avoir pour limite la satisfaction d'un intérêt sérieux et légitime, et ordonne la démolition de l'ouvrage.

Portée. L'arrêt est l'une des premières applications de la théorie de l'abus du droit de propriété, fondée sur l'**intention de nuire** et l'**absence d'intérêt légitime**.

Jurisprudence — Cass. req. (France), 3 août 1915, Coquerel c. Clément-Bayard

Faits. Un propriétaire avait dressé sur son terrain, en bordure de celui de son voisin, constructeur de dirigeables, des carcasses de bois surmontées de tiges de fer pointues, sans utilité pour lui, afin de gêner les manœuvres des dirigeables ; l'un d'eux fut endommagé.

Solution. La Cour de cassation approuve les juges du fond d'avoir retenu l'abus du droit de propriété et condamné le propriétaire à réparer le dommage et à supprimer les tiges.

Portée. L'arrêt consacre, au niveau de la Cour de cassation, la théorie de l'abus de droit, fondée sur l'intention malveillante révélée par l'absence d'utilité de l'ouvrage pour son auteur.

Jurisprudence — Cass. 2e civ. (France), 19 novembre 1986

Solution. La Cour de cassation énonce que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.

Portée. La théorie des **troubles anormaux de voisinage** prolonge celle de l'abus de droit, mais s'en affranchit : la responsabilité est engagée dès lors que le trouble excède les inconvénients normaux du voisinage, même en l'absence de faute ou d'intention de nuire. La solution est d'un grand intérêt dans les villes ivoiriennes en forte densification (bruit, constructions, activités artisanales).

Jurisprudence — Cass. ass. plén. (France), 7 janvier 2011, n° 09-14.316 et 09-14.667 ; Cass. ass. plén., 22 décembre 2023, n° 20-20.648

Première décision (2011). L'Assemblée plénière juge que l'enregistrement d'une communication téléphonique réalisé à l'insu de l'auteur des propos tenus constitue un procédé déloyal rendant irrecevable sa production à titre de preuve.

Seconde décision (2023). Revenant sur cette jurisprudence, l'Assemblée plénière juge que, dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats : le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le **droit à la preuve** et les droits antinomiques en présence; le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.

Portée. L'évolution illustre le passage d'une règle d'exclusion à une logique de **proportionnalité**, sous l'influence de la jurisprudence européenne sur le procès équitable. Elle offre une grille d'analyse aux juridictions ivoiriennes confrontées aux preuves numériques obtenues à l'insu des intéressés.

Jurisprudence — Cour d'appel de commerce d'Abidjan, arrêts de 2020 et 2021 (publiés sur CIVLII)

Apport. Dans plusieurs arrêts publiés, la Cour d'appel de commerce d'Abidjan a fait application de l'article 3 du Code de procédure civile, commerciale et administrative pour déclarer irrecevables des actions ou des recours, notamment pour défaut de qualité à agir ou à défendre, ou faute pour le signataire d'un acte de justifier de sa qualité pour représenter une personne morale V.

Portée. Ces décisions illustrent la rigueur avec laquelle les juridictions ivoiriennes contrôlent les conditions de recevabilité de l'action, et l'importance pratique, pour les avocats, de vérifier les pouvoirs des représentants des personnes morales avant l'introduction de l'instance. Les références précises des arrêts doivent être consultées sur la base CIVLII.

7. Présentation des débats doctrinaux

A. L'abus de droit : logomachie ou nécessité ?

DÉBAT DOCTRINAL — JOSSERAND CONTRE PLANIOL

Planiol. La notion d'abus de droit est une **logomachie** : si j'use de mon droit, mon acte est licite; s'il est illicite, c'est que je dépasse mon droit et que j'agis sans droit. Le droit cesse où l'abus commence. Les solutions jurisprudentielles s'expliquent par la responsabilité pour faute, sans qu'il soit besoin d'une théorie spéciale DOC.

Josserand. Les droits ne sont pas des pouvoirs absolus : ils sont **relatifs**, reconnus en vue de fins sociales. L'acte peut être conforme à la lettre du droit et contraire à son esprit; c'est cet

usage détourné que sanctionne la théorie de l'abus. Le critère de l'abus n'est pas seulement l'intention de nuire, mais le **détournement de la fonction sociale** du droit DOC.

Synthèse. La théorie de l'abus de droit s'est imposée en droit positif, à travers une jurisprudence abondante et des consécrations législatives (abus de majorité en droit OHADA des sociétés). Le débat porte aujourd'hui sur ses critères : l'intention de nuire, trop étroite, laisse place à l'absence d'intérêt légitime et au contrôle de proportionnalité, au risque d'un pouvoir d'appréciation étendu du juge.

B. Droit à la preuve et protection de la vie privée

La production en justice de preuves obtenues à l'insu des personnes concernées oppose deux exigences : le droit à la preuve, sans lequel le droit d'agir est vain, et le respect de la vie privée, du secret des correspondances et de la loyauté procédurale. L'évolution française vers une logique de proportionnalité est discutée : ses partisans y voient un progrès vers l'effectivité des droits ; ses critiques redoutent un encouragement à la surveillance et à la déloyauté. En Côte d'Ivoire, la question doit être articulée avec la législation de 2013 relative à la protection des données personnelles et à la cybercriminalité.

C. Justice étatique et justice alternative

Le développement de la médiation et de l'arbitrage est encouragé par les pouvoirs publics et par l'OHADA, pour désengorger les juridictions, réduire les délais et favoriser des solutions acceptées. Il suscite aussi des interrogations : risque d'une justice à deux vitesses, accès inégal à l'arbitrage, déséquilibre entre parties de puissance inégale, perte de la fonction normative de la jurisprudence lorsque les litiges sont réglés confidentiellement. Dans le contexte ivoirien, la place des autorités traditionnelles dans la conciliation des litiges (chapitre 9) ajoute une dimension spécifique au débat.

PROPOSITION DE L'AUTEUR — CONSACRER LE DROIT À LA PREUVE ET LA PROPORTIONNALITÉ

Le droit ivoirien de la preuve repose encore sur les dispositions du Code civil de 1804, conçues pour un monde de documents papier. Une réforme du droit de la preuve pourrait consacrer expressément le **droit à la preuve** et la règle de **proportionnalité** dans l'appréciation des preuves obtenues de manière illicite ou déloyale, préciser le régime des preuves numériques (messages, enregistrements, données de géolocalisation) en cohérence avec la loi de 2013 sur les transactions électroniques, et actualiser le seuil au-delà duquel l'écrit est exigé en matière civile PP.

8. Illustrations pratiques

Le prêt familial. Un frère prête une somme importante à sa sœur pour l'achat d'un terrain, sans écrit. En cas de litige, la preuve du prêt se heurte à l'exigence de l'écrit en matière civile ; l'impossibilité morale de se procurer un écrit, admise entre proches, et les commencements de preuve par écrit (messages, reçus) pourront être invoqués.

Les messages électroniques entre commerçants. Deux commerçants ont négocié une commande par messagerie instantanée. La preuve étant libre en matière commerciale, et l'écrit électronique étant admis dans les conditions de la loi de 2013, ces messages peuvent être produits, à condition que leur auteur puisse être identifié et que leur intégrité soit garantie (constat d'huissier, expertise).

L'assemblée générale abusive. Les actionnaires majoritaires d'une société anonyme décident, année après année, de mettre en réserve la totalité des bénéfices, tout en s'attribuant des rémunérations élevées en qualité de dirigeants. Les minoritaires peuvent invoquer l'abus de majorité (AUSCGIE, art. 130).

Le mur de la discorde. À Cocody, un propriétaire édifie, à la limite de sa parcelle, un mur très élevé qui prive la maison voisine de lumière, sans utilité apparente pour lui. Le voisin peut agir sur le fondement de l'abus de droit et, en droit comparé, des troubles anormaux de voisinage, sous réserve du respect des règles d'urbanisme applicables.

9. Cas pratiques corrigés

Cas pratique n° 1 — Le prêt sans écrit

Énoncé. M. Konan a prêté à son cousin, M. Assi, une somme importante pour financer l'achat d'un véhicule. Aucun écrit n'a été établi, mais M. Assi a envoyé, quelques jours après la remise des fonds, un message téléphonique ainsi rédigé : « Merci cousin pour l'argent, je te rembourse dès que le taxi tourne. » M. Assi refuse aujourd'hui de rembourser, en soutenant qu'il s'agissait d'un don. Comment M. Konan peut-il prouver le prêt ?

CORRIGÉ

Problème de droit. Comment prouver un contrat de prêt civil d'un montant élevé, en l'absence d'écrit signé ?

Règles applicables. Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver (C. civ., art. 1315). En matière civile, la preuve d'un acte juridique d'un montant supérieur au seuil fixé par les textes doit être faite par écrit (art. 1341) V, sauf commencement de preuve par écrit complété par d'autres éléments (art. 1347) ou impossibilité morale de se procurer un écrit (art. 1348). L'écrit électronique est admis comme l'écrit sur papier

sous condition d'identification de son auteur et d'intégrité (loi n° 2013-546 du 30 juillet 2013).

Application. Le prêt, acte juridique civil entre deux non-commerçants, est soumis à l'exigence de la preuve écrite. Deux voies s'offrent à M. Konan. (1) Le message de M. Assi émane de celui contre lequel la demande est formée ; il rend vraisemblable l'existence d'une obligation de remboursement (« je te rembourse ») : il peut constituer un commencement de preuve par écrit, voire, si son authenticité et son intégrité sont établies, un écrit électronique ; il devra être complété par d'autres éléments (relevés bancaires, témoignages). (2) Les liens familiaux entre les parties peuvent caractériser une impossibilité morale d'exiger un écrit, ce qui ouvrirait la preuve par tous moyens.

Conclusion. M. Konan a de bonnes chances de prouver le prêt. Il est conseillé de faire constater le message par un commissaire de justice ou un expert, afin d'en garantir l'origine et l'intégrité.

Cas pratique n° 2 — L'abus de majorité

Énoncé. La société anonyme S. réalise depuis cinq ans d'importants bénéfices. Les actionnaires majoritaires, qui sont aussi administrateurs et perçoivent à ce titre des rémunérations élevées, décident chaque année d'affecter la totalité des bénéfices aux réserves, sans projet d'investissement précis. Les actionnaires minoritaires, privés de dividendes, vous consultent.

CORRIGÉ

Problème de droit. La mise en réserve systématique des bénéfices, décidée par les majoritaires, constitue-t-elle un abus de majorité ?

Règles applicables. Selon l'article 130 de l'AUSCGIE, constitue un abus de majorité la résolution adoptée par les associés majoritaires dans leur seul intérêt, contrairement aux intérêts des associés minoritaires, et sans que cette résolution puisse être justifiée par l'intérêt de la société. L'Acte uniforme attache à l'abus des sanctions (nullité de la délibération, responsabilité des auteurs de l'abus), dont les modalités doivent être vérifiées dans le texte.

Application. Trois éléments doivent être établis. (1) Une décision contraire à l'intérêt des minoritaires : la privation durable de dividendes. (2) Une décision prise dans l'intérêt exclusif des majoritaires : ceux-ci perçoivent par ailleurs des rémunérations élevées, ce qui leur permet de capter la richesse sociale à leur seul profit. (3) L'absence de justification par l'intérêt social : aucun projet d'investissement ne justifie la mise en réserve. Si la société démontre un besoin réel de financement, l'abus ne sera pas caractérisé.

Conclusion. Sous réserve de la preuve de l'absence d'intérêt social, les minoritaires peuvent agir en nullité des délibérations et en responsabilité contre les majoritaires.

Cas pratique n° 3 — L'action irrecevable

Énoncé. La société Y assigne un client en paiement devant le tribunal de commerce d'Abidjan. L'assignation est délivrée à la requête de « la société Y, représentée par M. Z, directeur commercial ». Le défendeur soulève l'irrecevabilité de l'action. Sur quel fondement ? Avec quelles chances ?

CORRIGÉ

Problème de droit. L'action engagée au nom d'une personne morale par une personne qui n'en est pas le représentant légal est-elle recevable ?

Règles applicables. Selon l'article 3 du CPCCA, l'action n'est recevable que si le demandeur justifie d'un intérêt, a qualité pour agir et possède la capacité d'agir en justice. La personne morale agit par ses représentants légaux ou par des mandataires régulièrement habilités ; les pouvoirs des organes de direction des sociétés commerciales sont fixés par l'AUSCGIE et par les statuts.

Application. Le directeur commercial n'est pas, en principe, le représentant légal de la société (gérant, directeur général, président selon la forme sociale). Faute de justifier d'une délégation de pouvoir régulière l'habilitant à agir en justice au nom de la société, l'acte est entaché d'un défaut de qualité. Les juridictions commerciales d'Abidjan appliquent cette exigence avec rigueur.

Conclusion. L'exception d'irrecevabilité a de sérieuses chances de prospérer. La société Y devrait régulariser la procédure, si cela est encore possible, ou réintroduire l'instance à la requête de son représentant légal, en veillant à ce que la prescription ne soit pas acquise entre-temps.

10. Synthèse et connaissances essentielles

SYNTHÈSE — CONNAISSANCES ESSENTIELLES

- *Idem est non esse et non probari* : un droit non prouvé est inefficace devant le juge.
- **Acte juridique** (effets voulus) et **fait juridique** (effets non recherchés) : les premiers se prouvent en principe par écrit en matière civile, les seconds par tous moyens.
- **Charge de la preuve** : sur le demandeur (C. civ., art. 1315) ; les présomptions légales la renversent ; le doute profite à celui qui ne supporte pas la charge.
- **Modes de preuve** : acte authentique, acte sous seing privé, écrit électronique (loi n° 2013-546), témoignage, présomptions, aveu, serment.
- **Systèmes** : preuve légale pour les actes juridiques civils (art. 1341, avec exceptions : commencement de preuve par écrit, impossibilité) ; **liberté de la preuve** en matière commerciale (AUDCG, art. 5) et pénale (intime conviction).

- **Action en justice** : intérêt, qualité, capacité (CPCCA, art. 3); interdiction de se faire justice à soi-même; exécution forcée sur titre exécutoire (AUPSRVE, art. 28 à 30 de l'acte de 1998, révisé en 2023).
- **Modes alternatifs** : transaction, conciliation, médiation (AU du 23 novembre 2017), arbitrage (AUA du 23 novembre 2017).
- **Abus de droit** : intention de nuire (*Colmar*, 1855; *Clément-Bayard*, 1915), absence d'intérêt légitime, détournement de finalité (Josserand); consécrations OHADA : **abus de majorité et de minorité** (AUSCGIE, art. 130-131).
- **Prescription** : trente ans en droit civil ivoirien (art. 2262); cinq ans en matière commerciale (AUDCG) V.

11. Questions d'évaluation

QUESTIONS D'ÉVALUATION

Questions de cours

1. Distinguez acte juridique et fait juridique et précisez l'intérêt de la distinction en matière de preuve.
2. Sur qui pèse la charge de la preuve ? Qu'est-ce que le risque de la preuve ?
3. Présentez les exceptions à l'exigence de la preuve écrite en matière civile.
4. Quelles sont les conditions de recevabilité de l'action en justice en droit ivoirien ?
5. Quels sont les critères de l'abus de droit ?
6. Comment l'AUSCGIE définit-il l'abus de majorité ?

Questions de réflexion

1. La liberté de la preuve en matière commerciale est-elle justifiée ?
2. Le droit à la preuve doit-il l'emporter sur le respect de la vie privée ?

Sujets de dissertation

1. « L'abus de droit. »
2. « La preuve, condition de l'effectivité des droits. »
3. « Justice étatique et modes alternatifs de règlement des différends en Côte d'Ivoire. »

Commentaire

1. Commentez l'arrêt de la chambre des requêtes du 3 août 1915, *Clément-Bayard*.

12. Références bibliographiques

Ouvrages généraux

F. Terré, *Introduction générale au droit*, Dalloz, coll. « Précis », dernière éd.

J. Ghestin et G. Goubeaux, *Traité de droit civil. Introduction générale*, LGDJ, dernière éd.

J.-L. Aubert et É. Savaux, *Introduction au droit et thèmes fondamentaux du droit civil*, Sirey, dernière éd.

Ouvrages spéciaux

L. Josserand, *De l'esprit des droits et de leur relativité. Théorie dite de l'abus des droits*, Dalloz, 2e éd., 1939.

H. Motulsky, *Principes d'une réalisation méthodique du droit privé. La théorie des éléments générateurs des droits subjectifs*, Sirey, 1948 (rééd. Dalloz).

H. Capitant, F. Terré, Y. Lequette et F. Chénedé, *Les grands arrêts de la jurisprudence civile*, Dalloz, dernière éd.

Droit OHADA

J. Issa-Sayegh et J. Lohoues-Oble, *OHADA. Harmonisation du droit des affaires*, Bruylant, 2002.

P. Meyer, *OHADA. Droit de l'arbitrage*, Bruylant, 2002.

OHADA. Traité et actes uniformes commentés et annotés, Juriscope, dernière éd.

Sources officielles

Code civil (art. 1315 et s., 2219 et s.) ; loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 (CPCCA) ; loi n° 2013-546 du 30 juillet 2013 relative aux transactions électroniques ; AUDCG ; AUPSRVE (1998) et acte révisé du 17 octobre 2023 ; AUSCGIE ; AUA et Acte uniforme relatif à la médiation (23 novembre 2017) ; Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (art. 7).

Bibliographie générale et spécialisée

La présente bibliographie rassemble les principaux ouvrages et articles cités dans le tome, complétés par des références de base utiles à l'approfondissement. Les éditions ne sont précisées que lorsqu'elles ont été établies avec certitude ; à défaut, la mention « dernière éd. » invite le lecteur à consulter l'édition la plus récente.

I. Dictionnaires et instruments de travail

G. Cornu (dir.), *Vocabulaire juridique*, Association Henri Capitant, PUF, coll. « Quadrige », dernière éd.

S. Guinchard et Th. Debard (dir.), *Lexique des termes juridiques*, Dalloz, dernière éd.

H. Roland et L. Boyer, *Adages du droit français*, Litec, dernière éd.

H. Capitant, F. Terré, Y. Lequette et F. Chénedé, *Les grands arrêts de la jurisprudence civile*, Dalloz, dernière éd.

M. Long, P. Weil, G. Braibant, P. Delvolvé et B. Genevois, *Les grands arrêts de la jurisprudence administrative*, Dalloz, dernière éd.

II. Introduction au droit et théorie générale

J.-L. Aubert et É. Savaux, *Introduction au droit et thèmes fondamentaux du droit civil*, Sirey, coll. « Université », dernière éd.

J.-L. Bergel, *Théorie générale du droit*, Dalloz, coll. « Méthodes du droit », dernière éd.

J. Carbonnier, *Droit civil. Introduction*, PUF, coll. « Thémis », dernière éd.

G. Cornu, *Droit civil. Introduction au droit*, Montchrestien, coll. « Domat droit privé », dernière éd.

J. Dabin, *Le droit subjectif*, Dalloz, 1952.

P. Deumier, *Introduction générale au droit*, LGDJ, coll. « Manuel », dernière éd.

J. Ghestin et G. Goubeaux, *Traité de droit civil. Introduction générale*, LGDJ, dernière éd.

P. Jestaz, *Le droit*, Dalloz, coll. « Connaissance du droit », dernière éd.

P. Jestaz, *Les sources du droit*, Dalloz, coll. « Connaissance du droit », dernière éd.

L. Josserand, *De l'esprit des droits et de leur relativité. Théorie dite de l'abus des droits*, Dalloz, 2e éd., 1939.

Ph. Malaurie et P. Morvan, *Introduction au droit*, LGDJ, dernière éd.

L. Michoud, *La théorie de la personnalité morale et son application au droit français*, LGDJ, 1906-1909.

H. Motulsky, *Principes d'une réalisation méthodique du droit privé*, Sirey, 1948.

G. Ripert, *La règle morale dans les obligations civiles*, LGDJ, 4e éd., 1949.

P. Roubier, *Le droit transitoire (Conflits des lois dans le temps)*, Dalloz et Sirey, 2e éd., 1960.

R. Savatier, *Du droit civil au droit public*, LGDJ, 1945.

F. Terré, *Introduction générale au droit*, Dalloz, coll. « Précis », dernière éd.

III. Philosophie et théorie du droit

Aristote, *Éthique à Nicomaque*.

N. Bobbio, *Essais de théorie du droit*, trad. M. Guéret et Ch. Agostini, Bruylant-LGDJ, 1998.

R. Carré de Malberg, *Contribution à la théorie générale de l'État*, Sirey, 1920-1922.

R. Dworkin, *Prendre les droits au sérieux*, PUF, coll. « Léviathan », 1995.

L. L. Fuller, *The Morality of Law*, Yale University Press, 1964.

F. Gény, *Méthode d'interprétation et sources en droit privé positif*, LGDJ, 2e éd., 1919.

H. L. A. Hart, *Le concept de droit*, trad. M. van de Kerchove, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 1976.

H. L. A. Hart, *Law, Liberty and Morality*, Oxford University Press, 1963.

P. Devlin, *The Enforcement of Morals*, Oxford University Press, 1965.

H. Kelsen, *Théorie pure du droit*, trad. Ch. Eisenmann, Dalloz, 1962.

F. Ost, *Le temps du droit*, Odile Jacob, 1999.

F. Ost et M. van de Kerchove, *De la pyramide au réseau ? Pour une théorie dialectique du droit*, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 2002.

M. Troper, *La philosophie du droit*, PUF, coll. « Que sais-je ? ».

M. Troper, *Pour une théorie juridique de l'État*, PUF, coll. « Léviathan », 1994.

G. Vedel, « Souveraineté et supraconstitutionnalité », *Pouvoirs*, n° 67, 1993.

M. Villey, *Le droit et les droits de l'homme*, PUF, 1983.

M. Villey, *Philosophie du droit*, Dalloz.

IV. Sociologie et anthropologie juridiques

M. Alliot, *Le droit et le service public au miroir de l'anthropologie. Textes choisis*, éd. C. Kuyu, Karthala, 2003.

P. Bourdieu, « La force du droit. Éléments pour une sociologie du champ juridique », *Actes de la recherche en sciences sociales*, n° 64, 1986.

J. Carbonnier, *Flexible droit. Pour une sociologie du droit sans rigueur*, LGDJ, dernière éd.

J. Carbonnier, *Sociologie juridique*, PUF, coll. « Quadrige ».

É. Durkheim, *De la division du travail social*, Alcan, 1893.

M. Gluckman, *The Judicial Process among the Barotse of Northern Rhodesia*, Manchester University Press, 1955.

J. Griffiths, « What is Legal Pluralism? », *Journal of Legal Pluralism*, n° 24, 1986.

G. Gurvitch, *L'idée du droit social*, Sirey, 1932.

O. W. Holmes, « The Path of the Law », *Harvard Law Review*, vol. 10, 1897.

É. Le Roy, *Le jeu des lois. Une anthropologie « dynamique » du droit*, LGDJ, coll. « Droit et société », 1999.

H. Lévy-Bruhl, *Sociologie du droit*, PUF, coll. « Que sais-je ? », 1961.

B. Malinowski, *Crime and Custom in Savage Society*, Londres, Kegan Paul, 1926.

S. F. Moore, « Law and Social Change: The Semi-Autonomous Social Field as an Appropriate Subject of Study », *Law & Society Review*, vol. 7, 1973.

R. Pound, « Law in Books and Law in Action », *American Law Review*, vol. 44, 1910.

S. Romano, *L'ordre juridique*, trad. L. François et P. Gothot, Dalloz, 1975.

N. Rouland, *Anthropologie juridique*, PUF, coll. « Droit fondamental », 1988.

B. Z. Tamanaha, « The Folly of the "Social Scientific" Concept of Legal Pluralism », *Journal of Law and Society*, vol. 20, 1993.

K. von Benda-Beckmann, « Forum Shopping and Shopping Forums », *Journal of Legal Pluralism*, n° 19, 1981.

M. Weber, *Économie et société*, trad. fr., Plon, 1971.

V. Droit comparé, droits africains et droit colonial

Coutumiers juridiques de l'Afrique occidentale française, Larose, 1939.

G. Conac (dir.), *Les Cours suprêmes en Afrique*, Economica.

R. David et C. Jauffret-Spinosi, *Les grands systèmes de droit contemporains*, Dalloz, coll. « Précis », dernière éd.

J. du Bois de Gaudusson, « Le mimétisme postcolonial, et après ? », *Pouvoirs*, n° 129, 2009.

É. Lambert, *Le gouvernement des juges et la lutte contre la législation sociale aux États-Unis*, Giard, 1921.

P. Legrand, « The Impossibility of "Legal Transplants" », *Maastricht Journal of European and Comparative Law*, vol. 4, 1997.

U. Mattei, « Three Patterns of Law: Taxonomy and Change in the World's Legal Systems », *American Journal of Comparative Law*, vol. 45, 1997.

K. Mbaye, *Les droits de l'homme en Afrique*, Pedone, 2e éd., 2002.

K. Mbaye (dir.), *Le droit de la famille en Afrique noire et à Madagascar*, Maisonneuve et Larose, 1968.

Y. Mény (dir.), *Les politiques du mimétisme institutionnel. La greffe et le rejet*, L'Harmattan, 1993.

J. Vanderlinden, *Les systèmes juridiques africains*, PUF, coll. « Que sais-je ? », 1983.

A. Watson, *Legal Transplants. An Approach to Comparative Law*, Scottish Academic Press, 1974.

F. Wodié, *Institutions politiques et droit constitutionnel en Côte d'Ivoire*, Presses universitaires de Côte d'Ivoire, 1996.

K. Zweigert et H. Kötz, *Introduction to Comparative Law*, trad. T. Weir, Oxford, Clarendon Press, 3e éd., 1998.

VI. Droit OHADA et droit communautaire

J. Issa-Sayegh et J. Lohoues-Oble, *OHADA. Harmonisation du droit des affaires*, Bruylant, coll. « Droit uniforme africain », 2002.

P. Meyer, *OHADA. Droit de l'arbitrage*, Bruylant, 2002.

OHADA. Traité et actes uniformes commentés et annotés, Juriscope, dernière éd.

P.-G. Pougoué (dir.), *Encyclopédie du droit OHADA*, Lamy, 2011.

VII. Rapports et études

Conseil d'État, *Rapport public 1991. De la sécurité juridique*, La Documentation française, 1991.

Conseil d'État, *Rapport public 2006. Sécurité juridique et complexité du droit*, La Documentation française, 2006.

Conseil d'État, *Le droit souple*, Étude annuelle 2013, La Documentation française, 2013.

N. Molfessis (dir.), *Les revirements de jurisprudence*, Litec, 2005.

VIII. Revues

Penant. Revue de droit des pays d'Afrique ; *Revue de l'ERSUMA* ; *Afrilex* (revue en ligne) ; *Revue trimestrielle de droit civil* ; *Revue du droit public* ; *Pouvoirs* ; *Journal of Legal Pluralism*.

IX. Sources officielles et bases de données

Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire ; Journal officiel de l'OHADA ; site du Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire ; CIVLII (Côte d'Ivoire Legal Information Institute, Laws.Africa) ; Ohadata ; Recueil de jurisprudence de la CCJA ; site de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples ; site de la Cour de justice de la CEDEAO ; Légifrance ; HUDOC (Cour européenne des droits de l'homme) ; site de la Cour internationale de justice ; FAOLEX.

Annexe — Fiche de vérification des références

Conformément à la charte de fiabilité de la collection, la présente fiche recense les textes et décisions ivoiriens et régionaux cités dans le tome et indique le degré de vérification atteint à la date de rédaction (4 novembre 2026). Les références de droit français, de droit européen et de droit international public, largement documentées dans les recueils et manuels de référence, ne sont reprises que lorsqu'un point particulier le justifie.

À RETENIR — LÉGENDE

- **Vérifié** : référence confrontée au texte officiel ou à sa reproduction par l'institution concernée, ou à une décision de juridiction qui en cite la lettre.
- **Recoupé** : référence établie par au moins deux sources fiables et concordantes (décisions de justice, publications institutionnelles, bases de données juridiques, travaux universitaires), sans confrontation directe au texte officiel.
- **À confirmer** : référence plausible, signalée V dans le texte, qui ne sert pas de fondement décisif au raisonnement.

ÉTAT DU DROIT — POINT DE VIGILANCE

L'accès direct aux bases officielles en ligne (Journal officiel, CIVLII, site du Conseil constitutionnel) n'a pas été possible depuis l'environnement de rédaction. Les vérifications ont été conduites par recoupement de sources publiées. Une vérification complémentaire sur le JORCI est recommandée pour toutes les références classées « recoupé » ou « à confirmer » avant usage contentieux.

A. Constitution et textes constitutionnels

Tableau A — Statut des références constitutionnelles

Référence	Objet	Statut	Chapitres
Loi n° 2016-886 du 8 novembre 2016 portant Constitution	Constitution de la IIIe République	Vérifié	passim
Loi constitutionnelle n° 2020-348 du 19 mars 2020	Révision de la Constitution	Vérifié	Intr., 7

Référence	Objet	Statut	Chapitres
Const., art. 3	Droit à la vie ; abolition de la peine de mort	Vérifié	1, 3
Const., art. 7	Légalité des délits et des peines	Recoupé	3, 8
Const., art. 101	Domaine de la loi	Vérifié	1, 7, 8
Const., art. 103	Domaine du règlement	À confirmer	1, 7
Const., art. 113	Saisine du Conseil constitutionnel avant promulgation	Recoupé (lettre à confirmer)	8
Const., art. 122	Engagement international comportant une clause contraire à la Constitution	Recoupé	7
Const., art. 123	Autorité des traités, sous réserve de réciprocité	Recoupé (numérotation à confirmer ; ancien art. 87 de la Constitution de 2000)	3, 7
Const., art. 135	Exception d'inconstitutionnalité	Vérifié	3, 7
Const., art. 137, al. 4, et 138	Autorité des décisions du Conseil constitutionnel	Vérifié	7
Const., art. 175 et 176	Chambre nationale des Rois et Chefs traditionnels	Recoupé	4, 9
Const., art. 178	Limites de la révision (forme républicaine, laïcité, intégrité du territoire)	Vérifié	2, 3, 7
Dispositions relatives aux ordonnances, à la ratification des traités et aux accords d'unité africaine	—	À confirmer (numérotation)	7
Disposition transitoire de continuité de la législation	—	À confirmer	5
Révision constitutionnelle du 16 août 1994	Mise en place du Conseil constitutionnel	Recoupé	7

B. Lois, ordonnances et décrets ivoiriens

Tableau B — Statut des références législatives et réglementaires

Référence	Objet	Statut	Chapitres
Loi organique n° 2001-303 du 5 juin 2001	Conseil constitutionnel	Recoupé (version en vigueur à vérifier)	7

Référence	Objet	Statut	Chapitres
Lois organiques n° 2020-967 et n° 2020-968	Cour de cassation ; Conseil d'État	Recoupé	6, 10
Loi n° 2014-335 du 18 juin 2014	Commission électorale indépendante	Recoupé	1
Loi n° 2019-708 du 5 août 2019	Recomposition de la CEI	Recoupé	1
Lois du 7 octobre 1964 (n° 64-373 à 64-381)	Personnes et famille	Recoupé pour les n° 64-375 et 64-381 ; série à confirmer	Intr., 5, 9
Loi n° 64-375 du 7 octobre 1964, modifiée par les lois n° 83-800 du 2 août 1983 et n° 2013-33 du 25 janvier 2013	Mariage (abrogée en 2019)	Recoupé	2, 9
Loi n° 2019-570 du 26 juin 2019	Mariage	Vérifié	1, 2, 9
Abrogation par la loi n° 2019-570 des dispositions prohibant la dot (loi n° 64-381, art. 20 à 22)	Dot	Recoupé (désignation exacte des dispositions abrogées à confirmer)	1, 2, 9
Loi n° 2019-571 du 26 juin 2019	Filiation	Vérifié	5
Loi n° 2019-573 du 26 juin 2019	Successions	Recoupé	8, 11
Loi de 2019 relative à la minorité (majorité civile à 18 ans)	Minorité	Recoupé (numéro et article à confirmer)	11
Loi n° 2018-862 du 19 novembre 2018 ; décret n° 2019-805 du 2 octobre 2019 ; loi n° 2018-863	État civil	Recoupé	11
Loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 (art. 564)	Code pénal ; abrogation du Code de 1981	Recoupé	8
Loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018	Code de procédure pénale	Recoupé	5
Loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 (art. 3)	Code de procédure civile, commerciale et administrative	Recoupé	6, 12
Loi n° 98-750 du 23 décembre 1998, modifiée par les lois n° 2004-412, n° 2013-655 et n° 2019-868	Domaine foncier rural	Vérifié	4, 5, 9
Loi n° 98-750, art. 3, art. 4 (rédaction 2019), art. 17 bis	Domaine coutumier ; certificat foncier ; cessions	Recoupé	4, 9
Décret n° 2019-266 du 27 mars 2019	Domaine foncier rural coutumier	Recoupé	4, 9

Référence	Objet	Statut	Chapitres
Loi n° 2014-428 du 14 juillet 2014	Statut des Rois et Chefs traditionnels	Recoupé (certaines sources indiquent le 11 juillet 2014)	4, 9
Loi n° 2013-546 du 30 juillet 2013 (art. 23)	Transactions électroniques ; écrit électronique	Recoupé	12
Loi n° 2013-451 du 19 juin 2013	Cybercriminalité	Recoupé	11, 12
Loi de 2013 relative à la protection des données à caractère personnel	Données personnelles	À confirmer (numéro)	11, 12
Loi n° 60-315 du 21 septembre 1960	Associations	À confirmer (régime de capacité ; version en vigueur)	11
Montant au-delà duquel la preuve écrite est exigée (C. civ., art. 1341)	Preuve	À confirmer	12

C. Décisions des juridictions ivoiriennes

Tableau C — Statut des décisions ivoiriennes citées

Référence	Objet	Statut	Chapitres
Cons. const., décision n° CI-2011-EP-036/04-05/CC/SG du 4 mai 2011	Proclamation du Président de la République après la crise post-électorale	Recoupé	3
Cons. const., décision du 19 mars 2020 (n° CI-2020-002)	Révision constitutionnelle ; art. 178	Recoupé	7
Cons. const., décision n° 2023-001 du 11 mai 2023	Exception d'inconstitutionnalité ; application de la loi pénale dans le temps	Recoupé (solution à consulter)	8
Cons. const., décisions de 2020 sur la qualité de « plaideur »	Exception d'inconstitutionnalité	Recoupé	7
Cour d'appel de commerce d'Abidjan, arrêts de 2020 et 2021 (CIVLII)	Application de l'art. 3 du CPCCA	Recoupé (références précises à consulter)	12

D. Droit OHADA, communautaire et régional

Tableau D — Statut des références régionales et communautaires

Référence	Objet	Statut	Chapitres
Traité OHADA (Port-Louis, 1993 ; Québec, 2008), art. 1er, 5, 9, 10, 13 à 20, 42	Objet ; sanctions pénales ; entrée en vigueur ; supranationalité ; CCJA ; langues	Recoupé	1, 5, 6, 7, 8, 10
CCJA, avis n° 001/2001/EP du 30 avril 2001	Portée de l'article 10 du Traité	Recoupé	5, 7
CCJA, arrêt n° 043/2005 du 7 juillet 2005	Immunité d'exécution (sous l'acte de 1998)	Recoupé	6
AUDCG (15 décembre 2010 ; JO OHADA 15 février 2011 ; en vigueur le 15 mai 2011), art. 5 et 234	Preuve commerciale ; vente commerciale	Recoupé	6, 8, 12
AUDCG, art. 16 ; art. 30 et s. ; dispositions relatives aux usages	Prescription ; entrepreneur ; usages	À confirmer	4, 9, 11, 12
AUSCGIE (30 janvier 2014), art. 1er, 2, 98, 130, 131	Champ d'application ; ordre public ; personnalité ; abus	Recoupé	1, 6, 11, 12
AUSCGIE, art. 106 et s.	Société en formation	À confirmer	11
AUPSRVE (10 avril 1998), art. 28 à 30	Exécution forcée ; immunité	Recoupé ; texte remplacé en 2023 (ligne suivante)	1, 6, 12
AUPSRVE révisé (adopté le 17 octobre 2023 ; JO OHADA du 15 novembre 2023 ; en vigueur le 16 février 2024), art. 30 et 30-1	Immunité d'exécution ; inscription d'office	Recoupé (lettre à confirmer) — ajouté en version 1.1	1, 6, 12
AUA et Acte uniforme relatif à la médiation (23 novembre 2017)	Arbitrage ; médiation	Recoupé	2, 9, 12
Décision recensée dans Ohadata sous la référence J-06-35	Preuve des actes de commerce	À confirmer (identification de la décision)	12
Traité de l'UEMOA (Dakar, 10 janvier 1994 ; modifié le 29 janvier 2003), art. 6 et 43	Primauté ; règlements et directives	Recoupé	6, 7
Traité révisé de la CEDEAO (Cotonou, 24 juillet 1993)	Intégration régionale	Recoupé	Intr., 5

Référence	Objet	Statut	Chapitres
CJ CEDEAO, 27 octobre 2008, *Hadijatou Mani Koraou c. Niger*	Esclavage coutumier ; responsabilité de l'État	Recoupé	4, 9
Cour ADHP, 18 novembre 2016, *APDH c. Côte d'Ivoire*, req. n° 001/2014	Indépendance de l'organe électoral	Recoupé	1
Cour ADHP, 26 mai 2017, *Commission africaine c. Kenya (Ogiek)*, req. n° 006/2012	Droits fonciers communautaires	Recoupé	4
Cour ADHP, 11 mai 2018, *APDF et IHRDA c. Mali*, req. n° 046/2016	Code de la famille ; égalité	Recoupé	2, 9
Commission ADHP, comm. n° 155/96, *SERAC c. Nigeria* (2001)	Droits des peuples ; environnement	Recoupé	4
Conseil constitutionnel du Sénégal, décision n° 3/C/93 du 16 décembre 1993	Conformité du Traité OHADA	Recoupé (numéro à confirmer)	7
Cour constitutionnelle du Bénin, DCC 06-074 du 8 juillet 2006	Consensus national ; limites de la révision	Recoupé	7
TIDM, Chambre spéciale, 23 septembre 2017, *Ghana / Côte d'Ivoire*	Délimitation maritime	Recoupé	5

Table des matières

Avant-propos **12**

Introduction générale **14**

1. Le droit, objet de connaissance. 14
   A. Les sens du mot « droit » 14
   B. Théorie générale, philosophie et sociologie du droit 14
2. L'ordre juridique ivoirien : un ordre pluriel en construction 15
   A. Une histoire en strates 15
   B. Trois défis pour la théorie du droit 16
3. Méthode et plan du tome 17

PREMIÈRE PARTIE — LE DROIT : NOTION ET FONDEMENTS **19**

CHAPITRE 1 La règle de droit : définition, caractères et fonctions **20**

1. Introduction et problématique 20
2. Fondements historiques et théoriques 21
   A. Jus et directum : la double origine du mot et de l'idée 21
   B. La règle de droit, commandement de l'État 21
   C. Les conceptions africaines de la norme 22
3. Explication approfondie des concepts 23
   A. Droit objectif et droits subjectifs 23
   B. La définition de la règle de droit 23
   C. Les classifications des règles de droit 26
4. Analyse des principes et mécanismes juridiques 27
   A. La structure logique de la règle : présupposé et effet juridique 27
   B. La force obligatoire et la connaissance de la règle 27
   C. Validité, effectivité et efficacité 28
   D. Les fonctions de la règle de droit 29
5. Étude des textes applicables 29
   A. Les dispositions préliminaires du Code civil 29
   B. Les dispositions constitutionnelles 30
   C. Le droit uniforme OHADA 31
6. Analyse de jurisprudences vérifiables 31
7. Présentation des débats doctrinaux 33
   A. La sanction est-elle le critère de la règle de droit ? 33
   B. Le « droit souple » est-il du droit ? 33
8. Illustrations pratiques 34
9. Cas pratiques corrigés 35
10. Synthèse et connaissances essentielles 37
11. Questions d'évaluation 38
12. Références bibliographiques 38

CHAPITRE 2 Le droit et les autres systèmes normatifs 40
1. Introduction et problématique 40
2. Fondements historiques et théoriques 40
A. De la confusion à la distinction 40
B. La sécularisation du droit 41
C. Le droit, ordre normatif institutionnalisé 41
3. Explication approfondie des concepts 42
A. Le droit et la morale 42
B. Le droit et la religion 43
C. Le droit et les mœurs, usages et règles de bienséance 43
D. Le droit et l'équité 44
E. Le droit et les autres normativités contemporaines 44
4. Analyse des principes et mécanismes juridiques 45
A. La réception par les notions-cadres 45
B. L'obligation naturelle, passerelle entre devoir moral et obligation juridique 45
C. L'ordre public et les bonnes mœurs, limites de la liberté contractuelle 46
D. La neutralité de l'État et ses conséquences 46
5. Étude des textes applicables 47
A. Les textes ivoiriens 47
B. Les textes régionaux et africains 47
6. Analyse de jurisprudences vérifiables 48
7. Présentation des débats doctrinaux 50
A. Le droit doit-il imposer la morale ? 50
B. La laïcité : séparation ou reconnaissance ? 50
8. Illustrations pratiques 51
9. Cas pratiques corrigés 51
10. Synthèse et connaissances essentielles 54
11. Questions d'évaluation 54
12. Références bibliographiques 55

CHAPITRE 3 Les fondements du droit (I) : droit naturel et positivisme juridique 56
1. Introduction et problématique 56
2. Fondements historiques et théoriques 57
A. Le jusnaturalisme classique 57
B. L'École moderne du droit naturel 58
C. Le positivisme juridique 58
D. Le renouveau du droit naturel après 1945 59
3. Explication approfondie des concepts 60
A. Le droit naturel 60
B. Le positivisme juridique 60
C. Validité, légitimité et justice 61
4. Analyse des principes et mécanismes juridiques 61
A. Le mécanisme positiviste d'identification du droit valide 61
B. La « positivation » des exigences du droit naturel 62

C. Le droit de résistance à l'oppression 63
5. Étude des textes applicables 63
6. Analyse de jurisprudences vérifiables 64
7. Présentation des débats doctrinaux 66
A. Le débat Hart–Fuller 66
B. Le positivisme et ses critiques contemporaines 67
C. L'universalité des droits de l'homme en question 67
8. Illustrations pratiques 68
9. Cas pratiques corrigés 68
10. Synthèse et connaissances essentielles 70
11. Questions d'évaluation 71
12. Références bibliographiques 71

CHAPITRE 4 Les fondements du droit (II) : approches sociologiques, réalistes et anthropologiques ; le pluralisme juridique 73

1. Introduction et problématique 73
2. Fondements historiques et théoriques 74
A. L'École historique allemande 74
B. De la jurisprudence des concepts à la jurisprudence des intérêts 74
C. Les fondateurs de la sociologie 74
D. Les juristes sociologues français 75
E. Les réalismes juridiques 75
F. L'anthropologie juridique 76
3. Explication approfondie des concepts 77
A. Les notions de la sociologie du droit 77
B. L'acculturation juridique 77
C. Le pluralisme juridique 78
D. Tableau comparatif des approches 78
4. Analyse des principes et mécanismes juridiques 79
A. Mesurer l'effectivité du droit 79
B. Les mécanismes de l'internormativité 79
C. Le « choix du forum » 80
D. Le pluralisme organisé par le droit étatique ivoirien 80
5. Étude des textes applicables 81
A. La loi relative au domaine foncier rural 81
B. Le statut des autorités traditionnelles 82
C. Le statut de l'entreprenant 82
D. La Charte africaine 82
6. Analyse de jurisprudences vérifiables 82
7. Présentation des débats doctrinaux 84
A. La controverse Kelsen–Ehrlich 84
B. Le pluralisme juridique : concept éclairant ou confusion ? 84
C. Codifier contre la coutume ? Le débat africain 84
8. Illustrations pratiques 85

9. Cas pratiques corrigés 86
10. Synthèse et connaissances essentielles 88
11. Questions d'évaluation 88
12. Références bibliographiques 89

DEUXIÈME PARTIE — L'ORDRE JURIDIQUE : SYSTÈMES, DIVISIONS ET SOURCES . 91

CHAPITRE 5 Les systèmes juridiques et la formation du droit ivoirien 92

1. Introduction et problématique 92
2. Fondements historiques et théoriques 93
   A. La naissance du droit comparé et la notion de famille de droits 93
   B. Les grandes traditions juridiques 93
   C. La formation historique du droit ivoirien 94
3. Explication approfondie des concepts 95
4. Analyse des principes et mécanismes juridiques 97
   A. Les modes de réception du droit 97
   B. La continuité du droit et ses conséquences 97
   C. La mixité du système ivoirien 98
5. Étude des textes applicables 99
6. Analyse de jurisprudences vérifiables 100
7. Présentation des débats doctrinaux 101
   A. La classification en familles est-elle encore pertinente ? 101
   B. Mimétisme juridique et greffes institutionnelles 101
   C. L'OHADA : greffe ou appropriation ? 101
8. Illustrations pratiques 102
9. Cas pratiques corrigés 102
10. Synthèse et connaissances essentielles 104
11. Questions d'évaluation 104
12. Références bibliographiques 105

CHAPITRE 6 Les divisions du droit 107

1. Introduction et problématique 107
2. Fondements historiques et théoriques 108
   A. L'origine romaine de la distinction 108
   B. La construction moderne : séparation de l'État et de la société civile 108
   C. Les contestations doctrinales 108
   D. La réception en Côte d'Ivoire 109
3. Explication approfondie des concepts 109
   A. Les critères de la distinction du droit public et du droit privé 109
   B. Les branches du droit 111
   C. Les autres divisions du droit 111
4. Analyse des principes et mécanismes juridiques 112
   A. Les conséquences de la qualification 112
   B. La méthode de qualification 113

C. L'articulation du droit commun et du droit spécial 113
D. L'interpénétration du droit public et du droit privé 113
5. Étude des textes applicables 114
6. Analyse de jurisprudences vérifiables 115
7. Présentation des débats doctrinaux 116
A. La summa divisio est-elle dépassée ? 116
B. Droit uniforme et droit communautaire : une distinction utile 117
8. Illustrations pratiques 117
9. Cas pratiques corrigés 118
10. Synthèse et connaissances essentielles 120
11. Questions d'évaluation 120
12. Références bibliographiques 121

CHAPITRE 7 La hiérarchie des normes : Constitution, normes internationales, communautaires et uniformes 122
1. Introduction et problématique 122
2. Fondements historiques et théoriques 123
A. La théorie de la pyramide des normes 123
B. L'État de droit 123
C. L'essor de la justice constitutionnelle 123
D. L'internationalisation de la hiérarchie des normes 124
3. Explication approfondie des concepts 124
4. Analyse des principes et mécanismes juridiques 126
A. La suprématie de la Constitution et son contrôle 126
B. Les engagements internationaux 127
C. Le droit communautaire de l'UEMOA 127
D. Le droit uniforme de l'OHADA 128
E. La loi, l'ordonnance et le règlement 128
5. Étude des textes applicables 129
6. Analyse de jurisprudences vérifiables 130
7. Présentation des débats doctrinaux 132
A. Pyramide ou réseau ? 132
B. La supraconstitutionnalité 133
C. Le droit OHADA peut-il primer la Constitution ? 133
D. Qui contrôle la conventionnalité des lois en Côte d'Ivoire ? 134
8. Illustrations pratiques 134
9. Cas pratiques corrigés 135
10. Synthèse et connaissances essentielles 137
11. Questions d'évaluation 138
12. Références bibliographiques 138

CHAPITRE 8 La loi : élaboration, entrée en vigueur, application dans le temps et dans l'espace 140
1. Introduction et problématique 140

2. Fondements historiques et théoriques 141
A. La loi, expression de la volonté générale 141
B. Le déclin du légicentrisme 141
C. La question du temps : de Portalis à Roubier 141
D. La question de l'espace : territorialité et personnalité 141
3. Explication approfondie des concepts 142
A. Les sens du mot « loi » 142
B. Les actes du cycle de vie de la loi 143
C. Les notions du droit transitoire 143
4. Analyse des principes et mécanismes juridiques 144
A. L'élaboration de la loi 144
B. L'entrée en vigueur 144
C. La disparition de la loi 145
D. L'application de la loi dans le temps 145
E. L'application de la loi dans l'espace 147
5. Étude des textes applicables 148
6. Analyse de jurisprudences vérifiables 149
7. Présentation des débats doctrinaux 151
A. Droits acquis ou théorie de Roubier ? 151
B. L'inflation législative et la qualité de la loi 151
8. Illustrations pratiques 152
9. Cas pratiques corrigés 152
10. Synthèse et connaissances essentielles 154
11. Questions d'évaluation 155
12. Références bibliographiques 156

CHAPITRE 9 La coutume et les usages 157

1. Introduction et problématique 157
2. Fondements historiques et théoriques 158
A. La coutume dans l'histoire du droit 158
B. L'École historique et la valorisation de la coutume 158
C. La coutume en Afrique : de la reconnaissance coloniale à la reconnaissance encadrée 158
3. Explication approfondie des concepts 159
A. La notion de coutume 159
B. Coutume et usages 159
C. Les rapports de la coutume et de la loi 160
D. La coutume en droit international 160
4. Analyse des principes et mécanismes juridiques 160
A. La preuve de la coutume 160
B. La reconnaissance de la coutume par la loi foncière ivoirienne 161
C. Les usages dans le droit des affaires 161
D. Les limites de la coutume 162
5. Étude des textes applicables 162
6. Analyse de jurisprudences vérifiables 163

7. Présentation des débats doctrinaux. . . . 164
A. Le fondement de la force obligatoire de la coutume. . . . 164
B. Faut-il rédiger ou codifier les coutumes ? . . . 165
C. La conversion des droits coutumiers : sécurisation ou dépossession ? . . . 165
8. Illustrations pratiques . . . 165
9. Cas pratiques corrigés . . . 166
10. Synthèse et connaissances essentielles . . . 167
11. Questions d'évaluation. . . . 168
12. Références bibliographiques . . . 169

CHAPITRE 10 La jurisprudence et la doctrine . . . 170

1. Introduction et problématique . . . 170
2. Fondements historiques et théoriques . . . 171
A. Le rôle des juristes à Rome . . . 171
B. La méfiance révolutionnaire envers les juges . . . 171
C. L'essor de la jurisprudence . . . 171
D. La doctrine, de l'Université médiévale à l'Afrique contemporaine . . . 172
3. Explication approfondie des concepts . . . 172
A. La jurisprudence . . . 172
B. L'autorité de la chose jugée . . . 173
C. La doctrine . . . 173
D. Les principes généraux du droit et les adages . . . 173
4. Analyse des principes et mécanismes juridiques . . . 174
A. L'organisation juridictionnelle et l'unification de la jurisprudence . . . 174
B. Comment la jurisprudence crée du droit . . . 175
C. Les limites du pouvoir normatif du juge . . . 175
D. Les revirements de jurisprudence et le temps . . . 175
E. L'influence de la doctrine . . . 176
5. Étude des textes applicables . . . 176
6. Analyse de jurisprudences vérifiables . . . 177
7. Présentation des débats doctrinaux. . . . 179
A. La jurisprudence est-elle une source du droit ? . . . 179
B. Le précédent : common law et droit civil . . . 180
C. Le gouvernement des juges. . . . 180
D. La doctrine africaine et la doctrine française . . . 180
8. Illustrations pratiques . . . 181
9. Cas pratiques corrigés . . . 181
10. Synthèse et connaissances essentielles . . . 183
11. Questions d'évaluation. . . . 183
12. Références bibliographiques . . . 184

TROISIÈME PARTIE — LES DROITS SUBJECTIFS ET LEUR RÉALISATION. 187

CHAPITRE 11 Les droits subjectifs et leurs titulaires . . . 188

1. Introduction et problématique 188
2. Fondements historiques et théoriques 189
A. La formation de la notion de droit subjectif 189
B. Volonté ou intérêt ? 189
C. Les négations du droit subjectif 189
D. La synthèse de Dabin 190
3. Explication approfondie des concepts 190
A. La notion de droit subjectif 190
B. Les classifications des droits subjectifs 190
C. Le patrimoine 192
D. Les sujets de droit 193
4. Analyse des principes et mécanismes juridiques 193
A. Les personnes physiques 193
B. Les personnes morales 194
5. Étude des textes applicables 195
6. Analyse de jurisprudences vérifiables 196
7. Présentation des débats doctrinaux 198
A. Le droit subjectif existe-t-il ? 198
B. L'unité du patrimoine en question 198
C. Faut-il étendre la personnalité juridique ? 199
8. Illustrations pratiques 199
9. Cas pratiques corrigés 200
10. Synthèse et connaissances essentielles 201
11. Questions d'évaluation 202
12. Références bibliographiques 202

CHAPITRE 12 La preuve et la sanction des droits 204

1. Introduction et problématique 204
2. Fondements historiques et théoriques 205
A. L'histoire de la preuve 205
B. De l'action au droit d'agir 205
C. L'interdiction de se faire justice à soi-même 205
D. La relativité des droits et l'abus de droit 206
3. Explication approfondie des concepts 206
A. Faits juridiques et actes juridiques 206
B. La preuve : objet, charge et modes 206
C. Les systèmes de preuve 208
D. L'action en justice 208
E. Les titres exécutoires et l'exécution forcée 209
F. L'abus de droit 209
G. La prescription 209
4. Analyse des principes et mécanismes juridiques 209
A. La charge et le risque de la preuve 209
B. La loyauté et la licéité de la preuve 210

C. La recevabilité de l'action 210
D. Les modes alternatifs de règlement des différends 210
E. Les critères et les sanctions de l'abus de droit 211
F. La prescription 211
5. Étude des textes applicables 212
6. Analyse de jurisprudences vérifiables 213
7. Présentation des débats doctrinaux 214
A. L'abus de droit : logomachie ou nécessité ? 214
B. Droit à la preuve et protection de la vie privée 215
C. Justice étatique et justice alternative 215
8. Illustrations pratiques 216
9. Cas pratiques corrigés 216
10. Synthèse et connaissances essentielles 218
11. Questions d'évaluation 219
12. Références bibliographiques 219

Bibliographie générale et spécialisée 221

I. Dictionnaires et instruments de travail 221
II. Introduction au droit et théorie générale 221
III. Philosophie et théorie du droit 222
IV. Sociologie et anthropologie juridiques 223
V. Droit comparé, droits africains et droit colonial 223
VI. Droit OHADA et droit communautaire 224
VII. Rapports et études 224
VIII. Revues 225
IX. Sources officielles et bases de données 225

Annexe — Fiche de vérification des références 226

A. Constitution et textes constitutionnels 226
B. Lois, ordonnances et décrets ivoiriens 227
C. Décisions des juridictions ivoiriennes 229
D. Droit OHADA, communautaire et régional 229

LE TOME

Qu'est-ce qu'une règle de droit ? D'où le droit tire-t-il sa force obligatoire ? Comment s'ordonnent, en Côte d'Ivoire, la Constitution, les traités, le droit communautaire de l'UEMOA, les actes uniformes de l'OHADA, la loi, le règlement et la coutume ? Que signifie avoir un droit, et comment le faire valoir ?

Ce premier tome expose la théorie générale et les fondements du droit à partir de l'ordre juridique ivoirien, en mobilisant le droit OHADA, le droit communautaire ouest-africain et le droit comparé. Ses douze chapitres traitent de la règle de droit et des autres systèmes normatifs, du droit naturel et du positivisme, des approches sociologiques et du pluralisme juridique, des systèmes juridiques et de la formation du droit ivoirien, des divisions du droit, de la hiérarchie des normes, de la loi, de la coutume, de la jurisprudence et de la doctrine, des droits subjectifs et de leurs titulaires, de la preuve et de la sanction des droits.

LA MÉTHODE

Chaque chapitre suit douze rubriques : problématique, fondements, concepts, mécanismes, textes, jurisprudence, débats doctrinaux, illustrations pratiques, cas pratiques corrigés, synthèse, questions d'évaluation et bibliographie. Une fiche de vérification indique le degré de certitude de chaque référence ivoirienne et régionale.

LA COLLECTION

Douze tomes autonomes, de la théorie générale aux matières de spécialisation, pour former des juristes capables de comprendre, d'analyser, d'interpréter, d'appliquer, d'enseigner et de critiquer le droit.